

스터디파이터 2차 보상법규 개별법

제1판 2024.12.24

01
CHAPTER

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률

01
PART

공용수용

제1장 공용수용

제1절 공용수용 10

제2절 공공적 수용수용 (사적 공용수용, 수용수용) 15

제2장 공익사업, 당사자(2조), 목적물(3조)

제1절 수용적격사업으로서 공익사업 18

제2절 당사자 20

제3절 목적물 24

제3장 공익사업의 준비 (9~13조)

제1절 의의와 법적 성격 35

제2절 타인 점유토지에의 출입 35

제3절 장애물의 제거 등 38

제4절 권리구제 39

제4장 약식절차 (38,39조)

제1절 공용수용(공용사용)의 보통절차 42

제2절 수용과 사용의 구분 42

제3절 약식수용절차 42

제5장 사업인정 전 협의취득 (14~17조)

제1절	토지조서 및 물건조서의 작성	46
제2절	보상계획의 공고 및 열람	47
제3절	보상액의 산정	48
제4절	협의를 계약체결	49

제6장 사업인정 (20조)

제1절	사업인정	54
제2절	개별법에 의한 사업인정 의제제도	60
제3절	사업인정의 효력상실과 완료	61

제7장 사업인정 후 협의 (26조) 및 협의성립확인 (29조)

제1절	토지조서 및 물건조서의 작성	64
제2절	협의	67
제3절	협의성립확인	72

제8장 재결

제1절	재결신청의 청구	76
제2절	재결신청	80
제3절	수용재결	81
제4절	재결의 실효	85
제5절	화해	87

제9장 공용수용의 효과 (대집행, 환매권 포함)

제1절	공용수용의 일반적 효과	90
제2절	보상금 지급 또는 공탁	92
제3절	수용목적물의 인도·이전 의무 및 그 의무이행 확보수단	97
제4절	위험부담의 이전	100
제5절	담보물권자의 물상대위	102
제6절	반환 및 원상회복의 의무	102
제7절	환매권	103

제10장 권리구제 (83~88조)

제1절	개설	114
제2절	이의신청	116
제3절	행정소송	119

제11장 토지수용위원회와 보상협의회

제1절	토지수용위원회	130
제2절	보상협의회	132

02

PART

손실보상

제1장 손실보상제도

제1절	손실보상 일반론	134
제2절	손실보상의 원인	136
제3절	헌법 제23조 제3항의 해석	139
제4절	손실보상의 요건	143
제5절	행정상 손실보상의 기준	149
제6절	개발이익 배제와 정당보상	152
제7절	공시지가 기준보상과 정당보상	155
제8절	그 밖의 요인 보정과 정당보상	156
제9절	생활보상	158

제2장 행정상 손실보상

제1절	손실보상의 원칙	164
제2절	채권보상	167
제3절	대토보상	169

제3장 토지보상법상 손실보상

제1절	보상평가의 의의 및 평가	172
제2절	토지의 일반적 보상평가 기준	173
제3절	공시지가 기준보상의 구체적 기준	176

제4장 손실보상각론 (이주대책, 간접손실보상)

제1절	공법상 제한받는 토지 평가	180
제2절	무허가건축물 등의 부지와 불법형질변경된 토지의 평가	183
제3절	미지급용지의 평가	186
제4절	도로부지의 평가	189
제5절	구거부지 및 도수로부지의 평가	192
제6절	개간비의 보상과 평가	193
제7절	토지에 대한 소유권 외의 권리에 대한 보상	194
제8절	사용하는 토지에 대한 보상평가	195
제9절	잔여지에 대한 보상평가	197
제10절	토지에 대한 특별한 가치의 보상평가	199
제11절	건축물 등 물건에 대한 보상평가	200
제12절	건축물에 관한 소유권 외의 권리 등의 평가	203
제13절	건축물의 잔여부분에 대한 보상평가	204
제14절	권리에 대한 보상액 산정과 평가	205
제15절	영업손실보상	208
제16절	농업손실보상	213
제17절	이주대책	215
제18절	간접손실보상	221
제19절	공작물 등의 보상평가	230
제20절	농작물의 보상평가	231
제21절	휴직 또는 실직보상	232
제22절	주거이전비	233
제23절	사업폐지 등에 대한 보상	236

02
CHAPTER

부동산 가격공시에 관한 법률

제1장	표준지공시지가	238
제2장	개별공시지가	244
제3장	토지가격비준표	254
제4장	부동산가격공시위원회	256
제5장	타인토지출입 및 공시제도	257

03
CHAPTER

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률

제1장 감정평가사의 법적지위 및 자격등록

제1절	감정평가사의 법적 지위	265
제2절	감정평가사의 자격등록 및 갱신등록 (감정평가법 제17조)	268

제2장 감정평가법인 등

제1절	사무소 개설 등	270
제2절	감정평가법인등의 법적 지위	271
제3절	감정평가법인 설립행위와 감정평가법인 설립인가의 관계	272
제4절	고용인 신고 등	273

제3장	감정평가법인등의 손해배상책임(감정평가법 제28조)	276
제4장	징계 및 징계위원회	280
제5장	감정평가	286
제6장	기타 (과징금, 과태료, 한국감정평가협회)	290

PART 01

공용수용

Chapter 01 공용수용

Chapter 02 공익사업, 당사자(2조), 목적물(3조)

Chapter 03 공익사업의 준비(9~13조)

Chapter 04 약식절차(38,39조)

Chapter 05 사업인정 전 협의취득(14~17조)

Chapter 06 사업인정(20조)

Chapter 07 사업인정 후 협의(26) 및 협의성립확인(29)

Chapter 08 재결

Chapter 09 공용수용의 효과(대집행, 환매권 포함)

Chapter 10 권리구제(83~88)

Chapter 11 토지수용위원회와 보상협의회

제1절

공용수용

01 공용수용과 공용수용제도

공용수용(公用收用)이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 사인의 재산권은 사유재산제 아래서 존중되어야 하나, 사업의 원활한 실시를 확보하고, 공공이익의 증진을 도모하기 위해 사인의 토지소유권 등 권리를 강제적으로 취득하게 하는 법적 수단이 필요하다. 공용수용제도는 공익사업을 위해 권리자의 의사에 관계없이 토지소유권 등을 강제적으로 취득하는 길을 열어두기 위해 마련된 제도이다.

02 근거

1) 이론적 근거

- ① 〈사유재산불가침 원칙에 대한 특례〉 현대국가의 사유재산제도 아래에서 소유권은 절대권이라 하더라도 소유권 행사는 사회의 안녕질서를 위해 필연적으로 사회적 제약을 받게 된다.
- ② 〈공공복리를 위한 국가권력의 발동〉 현대복지국가는 단순한 경찰 목적의 임무 외에 공공복리 증진을 중요한 임무로 하고 있다.

2) 헌법적 근거

공용수용은 재산권에 대한 중대한 침해이므로 헌법에 근거를 두고 있다. 헌법은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다(헌법 제23조 제3항).”고 규정함으로써, 재산권의 수용을 인정하고 있다.

3) 실정법적 근거

- ① 공용수용의 일반법은 헌법을 구체화한 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 명칭 사용에는 “토지보상법”으로 하고, 관련 법규정은 조항으로만 표기함)이다. 토지보상법은 공용수용의 목적물을 비롯하여 공익사업, 공용수용의 절차와 효과 등에 관한 일반규정, 손실보상의 기준과 보상액 산정에 관한 구체적 규정을 두고 있다.
- ② 많은 개별 법률은 공익사업의 시행을 위하여 토지보상법에서 정하는 토지·물건 또는 권리를 수용 또는 사용할 수 있다고 규정하고, 수용 또는 사용에 관하여는 개별 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지보상법을 준용하도록 하고 있다.
- ③ 개별 법률은 사업인정에 관한 특례, 재결신청기간에 관한 특례, 관할 토지수용위원회에 관한 특례, 환매에 관한 특례, 사적 공용수용에 관한 특례 등을 두고 있다.

03 특징

1) 목적의 특징

공용수용의 목적은 특정 공익사업을 원활하게 수행하여 공익 증진을 도모하는 데 있다. 수용에 의해 재산을 취득할 때 해당 재산은 직접 공공이익의 증진에 이바지하여야 한다.

2) 수단의 특징

공용수용의 법적 수단은 강제적 취득이다. 공익사업에 제공하기 위해 민사계약에 의해 임의로 재산권을 조달하는 경우 등은 공용수용과 구별된다.

3) 목적물의 특징

공용수용의 목적물은 특정한 재산권이다. 공용수용 대상 가운데 가장 일반적인 것은 토지소유권이며, 그 밖에 토지에 관한 소유권 이외의 권리, 토지와 함께 공익사업을 위하여 필요한 입목(立木), 건물, 그 밖에 토지에 정착된 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권·어업권 또는 물의 사용에 관한 권리, 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리가 있다(제3조).

4) 효과의 특징

공용수용의 효과는 재산권을 취득·소멸시키는 물건변동이다. 일반적으로 공용수용에 의한 토지 등의 취득은 국가 권력에 의한 권리의 원시취득이다. 원시취득으로 해석하는 실질적 논거는 수용이 공익사업을 시행하는 자에게 완전히 토지 기타 물건을 취득시켜 아무런 장애 없이 사업을 실시할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있음에서 찾을 수 있다. 임의매수가 승계취득이라는 점에서 공용수용과 구별된다.

5) 손실보상의 전제

공용수용은 손실보상을 전제한다. 수용으로 인해 권리를 상실하는 자에 대하여 부담의 공평을 위해 정당한 보상이 지불되어야 한다(헌법 제23조 제3항).

04 요건

1) 공용수용의 당사자

공용수용의 당사자는 공용수용 법률관계의 당사자로서, 수용권 주체인 수용권자와 수용목적물에 대한 권리를 가진 피수용자이다.

2) 공용수용의 내용상 요건

헌법 제23조 제3항에 따라 공용수용의 요건을 살펴볼 수 있다. 즉 공공필요가 있을 것, 재산권에 대한 공권적 침해 일 것, 재산권 침해의 법적 근거가 있을 것, 특별한 희생이 발생할 것, 보상규정이 존재할 것이 그 요건이 된다.

3) 공용수용의 절차상 요건

공용수용에 따른 토지의 취득 및 보상에 관한 일반법적 지위에 있는 토지보상법은 사업인정 전 협의(제16조), 사업인정(제20조), 토지조서 및 물건조서의 작성(제14조), 협의(제26조), 수용재결(제34조)로 이어지는 일련의 공용수용의 절차를 규정하고 있다.

05 공용수용의 유형

본래수용이란 공익사업을 위해 목적물을 직접 수용하는 일반수용을 말한다. 간주수용이란 본래수용 이외의 것으로서 매수청구의 의미를 가지며 본래수용의 연장선상에서 존재하는 것을 말한다. 실정법상 잔여지 등의 매수 및 수용청구(제74조), 사용에 갈음하는 수용(제72조), 이전수용(제75조 제1항)과 같은 확장수용 제도를 말한다. 확장수용은 공익사업의 필요에 의한 것이라기보다 피수용자에 대한 권리구제의 보충적 필요에 의해 인정되는 제도라는 점에서 본래수용과 차이가 있다.

06 공용수용과 공공필요 [★]

1) 공공필요의 의미

공공필요란 대표적 불확정개념으로, 확실적인 개념정립이 불가능하나, 공익을 위해 공익사업을 실현시키거나, 국가안전보장·질서유지 등의 공익 목적을 달성하기 위해 재산권의 수용·사용·제한이 불가피한 경우를 말한다. 공익과 사익의 개념은 고정적인 것으로 볼 것은 아니며, 공익은 역사적으로 가변적인 것이므로 그 내용도 시대에 따라 달라지는 것으로 볼 수 있다.

심화

공공필요

헌법 제23조 제3항에서 규정하고 있는 ‘공공필요’는 “국민의 재산권을 그 의사에 반하여 강제적으로라도 취득해야 할 공익적 필요성”으로서, ‘공공필요’의 개념은 ‘공익성’과 ‘필요성’이라는 요소로 구성되어 있는바, ‘공익성’의 정도를 판단함에 있어서는 공용수용을 허용하고 있는 개별법의 입법목적, 사업내용, 사업이 입법목적에 이바지 하는 정도는 물론, 특히 그 사업이 대중을 상대로 하는 영업인 경우에는 그 사업 시설에 대한 대중의 이용·접근가능성도 아울러 고려하여야 한다. 그리고 ‘필요성’이 인정되기 위해서는 공용수용을 통하여 달성하려는 공익과 그로 인하여 재산권을 침해당하는 사인의 이익 사이의 형량에서 사인의 재산권침해를 정당화할 정도의 공익의 우월성이 인정되어야 하며, 사업시행자가 사인인 경우에는 그 사업 시행으로 획득할 수 있는 공익이 현저히 해태되지 않도록 보장하는 제도적 규율도 갖추어져 있어야 한다(헌법재판소 2014. 10. 30. 선고 2011헌바129,172).

2) 수용과 공공필요의 관계

(1) 헌법 제23조 제3항의 공공필요

헌법 제23조 제3항은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.”라고 규정한다. 재산권에 대한 공권적 침해는 공공필요가 있을 때만 행해질 수 있으므로, 공공필요는 공용침해의 실질적 허용요건이자 본질적 제약요소이다.

(2) 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업

토지보상법은 공공필요가 있는 사업을 수용적격사업으로 규정하고 있다(제4조 및 별표, 제4조의2). 사업의 공공성을 확보하기 위해 사업인정 발령 시 실질적 공공필요가 있는지 판단한다. 개별법률은 공공필요를 확보하기 위해 수용적격사업과 사업인정 의제에 관하여 규정하고 있는 것이 일반적이다.

(3) 공공필요의 판단기준

공공필요는 공용침해를 통하여 얻어지는 공익과 재산권자의 재산권 보유이익 간에 이익형량을 통해서 그 여부가 결정되고, 재산권 침해가 정당화할 만한 공익의 존재가 비교형량의 결과로 입증되어야 하며 그 입증책임은 사업시행자에게 있다(대법 2005. 11. 10. 선고 2003두7507). 공공필요는 재산권에 대한 공권적 침해의 구체적 사안에 따라 결정될 성질의 것이며, 공공필요는 사업인정 시에 비례의 원칙을 적용하여 판단한다.

(4) 수용에 있어 공공필요의 확대 경향

최근 민간의 이윤, 동기까지 포함하는 시설의 설치 등을 목적으로 하는 사업에 대하여도 점차 공공필요를 인정하기에 이르고 있어 '공공의 이익'이란 개념은 확대현상을 보이고 있다. 토지보상법은 제4조 제5호에서 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업을 규정하고 있다.

07 최근 공용수용제도의 동향

1) 공익사업의 확대와 공익성 검증 강화

토지보상법 제4조와 제4조 제8호 해당 사업인 별표 규정을 살펴보면, 다른 법률에 따라 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 수많은 사업이 포함된다. 이는 개별법률 역시 다양한 사업에 대하여 수용권을 부여하는 경향을 보이고 있는 것으로서, 공공필요를 널리 인정하여 공익사업의 범위를 확대하는 현상을 반영하고 있는 것이다.

아울러, 토지보상법은 입법단계 시 공익성에 관한 중앙토지수용위원회의 심의제도를 도입하고(제4조의3), 사업인정 시 중앙토지수용위원회의 협의 절차를 강화하는 등 공익성 검증을 강화하였다.

2) 공적 사용수용의 확대

공공적 사용수용이란 공공필요를 위해, 사적 주체가 손실보상을 전제로, 사인의 특정한 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 공공목적의 토지취득은 종래 공적 주체에게 한정되는 것으로 이해되어 왔으나, 공공적 사용수용은 공익상 필요, 공익사업의 증대, 민간 활력의 도입, 공행정의 민간화 등에 의해 그 필요성이 인정되고 있으며, 최근 민자유치사업 등에서 확대 현상을 보이고 있다. 토지보상법은 사업주체를 구분하지 않고 공익사업을 시행하는 자에게 수용권을 부여하여 공공적 사용수용을 인정하고 있다. 한편 개별법률은 택지개발촉진법, 도시개발법, 기업도시개발특별법 등에서 공공적 사용수용을 인정하고 있다.

3) 보상금에서 개발이익의 배제

공용수용은 재산권의 본질적 내용의 침해에 해당되기 때문에 당연히 정당한보상이 수반되어야 한다. 그렇지만 정당한보상이 결코 해당 공익사업으로 인한 지가상승분인 개발이익까지 포함된 것으로 볼 수는 없다. 개발이익은 불로소득으로 사회에 환수되어야 하므로 공용수용에 따른 보상에서 개발이익을 배제하는 제도적 장치가 일반화되고 있다.

4) 정당보상과 생활보상의 확대

(1) 정당보상의 확대

손실보상은 공용침해로 인해 특정한 재산권자가 입은 특별한 희생을 전보하는 제도로서, 공익과 사익을 조정하고 피해자를 구제하기 위한 제도이다. 헌법 제23조 제3항은 정당한 보상을 하여야 함을 규정하고, 그에 따른 토지보상법은 부대적 손실보상과 생활보상 등의 규정을 두고 있다. 보상제도의 선진화를 위해 여러 차례 제도개선을 위한 법령 개정이 있었고, 2002년에는 「토지수용법」과 「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법」을 통합하여 제도를 개편하였다.

(2) 생활보상의 확대

손실보상은 종래 대물보상을 중심으로 인정되어 왔으나, 오늘날 대물보상의 문제를 해결하고 피수용자 보호를 위해 생활보상이 확대되고 있다. 보상목적은 수용이 없었던 것과 같은 재산 상태를 만드는 것만으로는 불충분하고, 수용이 없었던 것과 마찬가지로의 생활상태를 회복시키는 데 있다. 이주대책과 간접손실보상은 생활보상을 대표하는 제도로써 널리 활용되고 있다. 최근 피수용자의 생활회복을 위해 생활보상이 확대되고, 그 유형도 다양화되어 가는 현상을 보이고 있다.

01 제도의 배경

공공목적의 토지취득은 공적 주체에게 한정되는 것으로 이해되어 왔으나, 날로 공익사업이 증대함에 따라 공적 주체만으로는 이를 감당할 수 없게 되었다. 도시화의 진전과 산업의 발전에 따라 사회기반시설의 설치를 비롯하여 택지 등의 개발에 민간 활력의 도입이 절실히 요구되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 사적 주체에게도 공적 주체와 마찬가지로 수용권이 적극적으로 부여할 필요가 있다. 토지보상법은 이 한계를 극복하기 위해 사적 주체에게도 수용권을 인정하고 있다.

02 의의·취지 및 요건

공공적 사용수용(사적 공용수용, 사용수용)이란 특정한 공익사업을 위하여 사적 주체가 타인의 특정 재산권을 법률의 힘에 의해 보상을 조건으로 강제적으로 취득하는 것이다. 민간활력의 도입, 사업의 확대 등에 취지가 있다. 공공적 사용수용은 다음과 같은 개념 요소를 내용으로 한다.

- ① 공공적 사용수용은 공익사업의 목적에만 인정된다.
- ② 사적 주체로서 국가권력에 의해 수용권을 부여받는다.
- ③ 대상은 특정한 재산권이다.
- ④ 법률에 근거하여 타인의 재산권을 강제적으로 취득한다. 강제적 취득이란 권리자의 의사에 상관없이 일방적으로 재산권을 취득하는 것을 말한다.
- ⑤ 공공적 사용수용은 공용수용과 마찬가지로 재산권자에게 특별한 희생을 발생시키므로, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

03 인정여부

독일에서는 일반 사기업도 공익을 위해 수용이 허용된다고 보는 것이 일반적이다. 독일법상의 사기업의 유형으로는 생존배려형 사기업과 경제적 사기업이 있다. 생존배려형 사기업은 공공재화 등의 공익사업을 수행하는 경우의 국민의 생존을 배려하는 급부행정작용을 수행하는 사기업이고, 경제적 사기업은 공공성보다는 이윤추구를 우선적 목적으로 하는 사기업이다. 생존배려형 사기업의 공익사업은 국가적 과제이므로 사기업에게 수용권한을 부여하는 것은 당연하다. 그러나 경제적 사기업에 대해서는 엄격한 요건 아래에서 허용해야 한다는 주장이 있으나, 오늘날 경제적 사기업은 경제구조 개선·고용 증진·지역 발전 등이라는 공익이 합리적으로 요구될 때 공익사업을 수행하므로, 경제적 사기업의 재산권 침해는 공익적 요청에 의한 것이라면 정당화될 수 있다고 봄이 일반적 입장이다. <대법원>은 어떤 사업이 공익사업인가의 여부는 그 사업자체의 성질에 의하여 정할 것이고, 사업주체의 여하에 의하여 정할 것이 아니라고 판시한 바 있다[대법 70누81]. <헌법재판소>도 관공진흥법 위헌소원사건에서 재산권의 수용의 주체를 한정하지 않고 있는바 합헌 판결을 하였다[헌재 2011헌바250].

04 사용수용과 공공필요

1) 대상사업과 공공필요

수용권이 부여하려면 공공필요를 근거로 사업인정을 받아야 한다. 일반적으로는 기업의 법형식이나 사업시행자의 동기가 문제되지 않고, 객관적으로 공익사업을 시행하여 공익이 실현될 수 있는지 여부에 따라 공공필요는 인정된다. 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2는 공익사업을 규정하고 있으며, 개별법률은 사업인정 의제조항을 두고 있다. 헌법재판소는 민간기업에게 산업단지에 필요한 토지 등을 수용할 수 있도록 한 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 조항이 위헌이 아니라고 하였고, 토지 등 소유자가 도시환경정비사업을 시행할 수 있는 토지수용 규정인 「도시 및 주거환경정비법」 규정도 피수용자의 재산권을 과도하게 침해하지 않는다고 하였다.

2) 공공필요의 판단기준인 비례의 원칙

공공적 사용수용의 공익사업이 모두 공공성을 바탕으로 한다고 보기 어려운 경우도 있다. 어떠한 공익사업이 공공필요가 있는지 여부는 판단하기 쉽지 않기 때문에, 비례의 원칙에 의하여 엄격한 이익형량이 필요하다.

05 계속적 공익실현의 보장책

1) 보장책 마련의 필요성 및 법적근거

공공적 사용수용의 사적 주체는 이윤추구의 목적도 함께 가지고 있으므로 언제든지 사업을 중도에 포기할 가능성이 있어 보장책이 필요하다. 계속적 공익실현을 위한 법적·제도적 장치에 대한 요청은 헌법 제23조 제3항에 근거하고 있다. 우리 헌법은 “법률로써 하되”라고 규정하여 보장책 없는 공용침해의 법률은 위헌이 된다.

2) 보장의 수단

(1) 토지보상법상 환매권 및 사업인정의 실효

- ① 환매권(제91조)은 토지보상법상 공익사업의 계속성을 담보하기 위한 가장 일반적인 수단이다. 그러나 환매권은 공행정주체의 개입 없이 환매권자에 의해서만 행사된다는 점에서 공익성 계속적 보장책으로서 미흡하다는 지적이 있다.
- ② 사업인정의 실효(제23조와 제24조) 제도는 수용법관계의 조속한 확정을 바라는 피수용자를 보호하고 간접적으로 공익사업의 계속을 보장한다.

(2) 입법적 통제 및 사법적 통제

① <입법적 통제>

「사회기반시설에 대한 민간투자법」에서는 사업시행자에 대한 감독명령과 처분, 위반시 벌칙 등을 규정하고 있다. 그러나 민간자본유치 촉진에 역점을 둔 까닭에 공익사업의 계속성 담보에 대한 배려가 미흡하다. 구체적 보장책 수단으로 입법론이 요구된다.

② <사법적 통제>

공익사업의 계속성 보장책이 헌법 제23조 제3항의 공공필요의 요건을 충족하지 못할 경우에는 위헌·위법한 재산권의 침해라 할 것이어서 행정쟁송의 제기, 위헌법률심판, 헌법소원 등의 방법으로 사법적 통제가 가능하다.

3) 문제점

개별법에는 공익의 계속적 실현을 위한 여러 보장수단이 규정되어 있으나 추상적이고 제한적이어서 실효성 확보수단으로는 미흡하므로 법규명령, 자치법규 등 개괄적인 규정의 마련이 검토되어야 할 것이다.

제1절 수용적격사업으로서 공익사업

01 의미

수용적격사업이란 수용주체가 수용할 수 있는 적격을 갖는 공익사업을 말한다. 입법자는 해당 사업이 객관적으로 보아 충분히 공공필요를 지녔다고 판단될 때 수용적격을 승인하여 이에 관한 입법을 하고, 사업인정의 처분청은 이를 근거로 해당 공익사업이 과연 수용적격사업에 해당하는가를 다시 판단하여 사업인정을 하게 된다.

02 토지보상법 제4조, 별표, 제4조의2의 설정방법

입법시 수용적격방법을 정하는 방법에는 개별입법주의, 제한열거주의, 포괄주의로 구분할 수 있다.

- ① <개별입법주의>는 개개 사업이 토지를 수용할 만한 공공성을 지니는가를 입법자가 개별적으로 심사하여 입법하는 것이다.
- ② <제한열거주의>는 법률상 수용대상사업의 범위를 한정하고, 그 범위 내에서 사업의 수용적격성 유무를 행정청에게 판단하게 하는 것이다.
- ③ <포괄주의>는 수용 대상사업의 범위를 법률로 한정하지 않고 포괄적으로 행정청에게 맡겨 구체적 사업에 대해 수용여부를 판단하게 하는 것이다.
- ④ <검토> 토지보상법은 공익사업의 종류를 규정하고(제4조 및 별표), 토지 등을 사용하거나 수용할 수 있는 사업은 제4조 또는 별표에 규정된 법률에 따르지 않고는 정할 수 없으며, 별표는 이 법 외의 다른 법률로 개정할 수 없다고 하여(제4조의2) 제한열거주의를 채택하고 있다.

03 내용

토지보상법에 따라 토지 등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업은 다음 어느 하나에 해당하는 사업이어야 한다(제4조 및 별표). 공익사업이란 토지보상법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다(제2조 제2호).

- ① 국방·군사에 관한 사업
- ② 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 철도·도로·공항·항만·주차장·공영차고지·화물터미널·궤도(軌道)·하천·제방·댐·운하·수도·하수도·하수종말처리·폐수처리·사방(砂防)·방풍(防風)·방화(防火)·방조(防潮)·방수(防水)·저수지·용수로·배수로·석유비축·송유·폐기물처리·전기·전기통신·방송·가스 및 기상 관측에 관한 사업
- ③ 국가나 지방자치단체가 설치하는 청사·공장·연구소·시험소·보건시설·문화시설·공원·수목원·광장·운동장·시장·묘지·화장장·도축장 또는 그 밖의 공공용 시설에 관한 사업

- ④ 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 학교·도서관·박물관 및 미술관 건립에 관한 사업
- ⑤ 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업
- ⑥ 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 통로, 교량, 전선로, 재료 적치장 또는 그 밖의 부속시설에 관한 사업
- ⑦ 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 주택, 공장 등의 이주단지 조성에 관한 사업
- ⑧ 그 밖에 별표에 규정된 법률에 따라 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업

04 공익사업 신설 등에 대한 개선요구 등

1) 토지보상법 제4조의2

수용(또는 사용)할 수 있는 사업은 제4조 또는 별표에 규정된 법률에 따르지 않고는 정할 수 없고(제1항), 별표는 토지보상법 외의 다른 법률로 개정할 수 없다(제2항). 국토교통부장관은 사업인정이 의제되는 공익사업의 공공성, 수용의 필요성 등을 5년마다 재검토하여 폐지, 변경 또는 유지 등을 위한 조치를 하여야 한다(제3항).

2) 토지보상법 제4조의3

중앙토지수용위원회는 사업인정이 의제되는 공익사업의 신설, 변경 및 폐지 등에 관하여 개선요구 등을 할 수 있고, 중앙토지수용위원회의 개선요구 등을 받은 관계 행정기관은 정당한 사유가 없으면 이를 반영하여야 한다. 또한, 중앙토지수용위원회는 개선요구 등을 위하여 관계 기관 소속 직원 또는 관계 전문가 등에게 의견진술이나 자료제출을 요구할 수 있다. 이는 공익사업의 공공성을 높이는 데 그 취지가 있고, 위 개정은 중앙토지수용위원회의 권한이 확대되고 적극적인 지위를 명시한 것으로 평가할 수 있다.

01 의미

당사자란 공익사업을 위해 토지 등을 취득하는 사업시행자와 토지 등을 양도하는 토지소유자 및 관계인을 말한다. 토지수용의 당사자는 수용권의 주체인 수용자와 수용목적물인 재산권의 주체인 피수용자가 된다.

02 사업시행자와 수용권의 주체

1) 사업시행자의 의미

사업시행자란 공익사업을 수행하는 자를 말한다(제2조 제3호). 사업시행자는 국가·지방자치단체·법인 또는 사인에 관계없이 특정한 공익사업의 시행자를 말한다. 여기에서 공익사업이란 토지보상법 제4조 각 호 규정에 따른 사업을 말한다. 따라서 사업시행자는 수용적격사업에 관한 법률상 권한을 갖는 자이다.

2) 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의

(1) 문제점

국가가 사업시행자인 경우는 논란이 없으나, 국가 이외의 공공단체나 사인(공무수탁사인)이 사업시행자인 경우 수용권의 주체가 누구인지 견해가 대립한다.

(2) 학설

- ① <국가수용권설> 수용권이란 수용의 효과를 야기할 수 있는 능력이므로 수용권자는 국가라고 한다. 사업시행자는 수용권의 발동을 국가에게 청구하는 권리를 갖는데 지나지 않는다고 한다.
- ② <사업시행자수용권설> 수용의 본질이 특정한 재산권을 취득하는 데 있으므로, 수용권이란 수용의 효과를 누리는 능력이라고 한다. 따라서 수용권자는 사업시행자라고 한다. 이 설이 우리나라 다수설로 되어 있다.
- ③ <국가위탁권설> 수용권은 국가에 귀속되는 국가적 공권이고, 국가는 사업인정(수용권 설정)을 통하여 이를 사업시행자에게 위탁한다고 한다.

(3) 판례

대법원은 사업인정을 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정해 주는 설권적 형성처분이라 판시하여 사업시행자수용권설의 입장이다.

(4) 검토

국가공권력의 개입이 수용의 효과를 야기한다 하더라도, 현행 공용수용제도는 공공단체는 물론 기업이나 사인에게도 수용권을 부여하고 있을 뿐 아니라, 수용에 관한 소송도 사업시행자를 당사자로 할 수 있기 때문에 타당한 논거가 되지 못한다. 비록 국가가 수용의 효과를 야기한다 하더라도 수용권은 수용의 효과를 누릴 수 있는 능력이라 볼 수 있으므로, 사업시행자수용권설을 취하는 것이 타당하다.

03 사업시행자의 법적 지위

1) 권리

사업시행자의 권리에는

- ① 사업준비를 위한 타인 토지에의 출입권(제9조),
- ② 장애물 제거권(제12조),
- ③ 사업인정 신청권(제20조),
- ④ 토지 및 물건에 관한 조사권(제27조),
- ⑤ 재결신청권(제28조),
- ⑥ 협의성립확인 신청권(제29조),
- ⑦ 토지나 물건을 원시취득할 권리(제45조),
- ⑧ 토지나 물건의 인도 또는 이전이 없는 경우 대항신청권(제44조),
- ⑨ 재결에 불복하는 경우 행정쟁송권(제83조 및 제85조),
- ⑩ 의무 불이행 등에 대한 대집행신청권(제89조) 등이 있다.

2) 의무

사업시행자의 의무에는

- ① 타인 토지에의 출입 등에 의한 측량·조사, 장애물 제거 등으로 인한 손실보상 의무(제9조 제4항, 제12조 제4항),
- ② 협의 불성립시 피수용자의 재결신청청구에 응할 의무(제30조 제2항),
- ③ 피수용자의 고의·과실 없이 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 손실부담의 이전(제46조),
- ④ 재결로 인한 토지 등 취득시 손실보상 의무(제61조) 등이 있다.

3) 권리·의무의 승계

권리·의무의 승계는 사업의 승계와 절차의 승계로 구분된다. 사업승계란 사업이 이전되면 사업시행자의 권리·의무는 그 사업을 승계한 자에게 이전되는 것을 말한다(제5조 제1항). 절차승계란 이 법에 따라 이행한 절차와 그 밖의 행위는 사업시행자·토지소유자 및 관계인의 승계인에게도 효력이 미치게 되는 것을 말한다(제5조 제2항).

사업승계는 사업시행자에 대한 것인 반면, 절차승계는 사업시행자·토지소유자 및 관계인에 대한 것이다.

승계에 대하여는 사업인정 처분청의 승인을 요하지 아니한다. 승계를 인정하는 것은 수용절차의 중복을 피하고, 사업집행의 촉진을 도모함과 동시에 피수용자를 보호하기 위해서이다.

04 피수용자

1) 의의

피수용자란 수용의 목적물인 재산권의 주체 및 수용에 의해 영향을 받는 기타 관계 권리자를 말한다. 토지보상법상 수용권의 객체가 되는 토지소유자와 관계인이 피수용자가 된다(토지보상법 제2조 제4호 및 동조 제5호).

2) 토지소유자와 관계인

(1) 토지소유자

토지소유자란 공익사업에 필요한 토지의 소유자를 말한다(제2조 제4호). 진실한 소유자를 확정할 수 없는 경우 토지보상법은 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때 보상금을 공탁할 수 있도록 함으로써 사업시행자의 토지취득을 원활하게 하도록 하고 있다. (제40조 제2항 제2호).

(2) 관계인

관계인이란

- ① 사업시행자가 취득하거나 사용할 토지에 관하여 지상권·지역권·전세권·저당권·사용대차 또는 임대차에 따른 권리 또는 그 밖에 토지에 관한 소유권 외의 권리를 가진 자나
- ② 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자를 말한다.

다만, 사업인정의 고시(제22조)가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호).

관계인에 관한 규정에서 열거하고 있는 권리는 하나의 예시에 불과하고, 토지소유권 외의 권리자 모두를 포함하는 것으로 해석된다. 또한, 관계인으로서의 지위가 인정되려면 사업인정고시를 할 때 이들 권리가 존재하고 있어야 한다. 이는 수용의 절차를 간소화하기 위해서이다. 관계인은 부동산물권의 경우를 제외하고는 반드시 등기된 권리자임을 요하지 아니하는 것으로 보고 있다.

대법원 2019.4.11. 선고 2018다277419

토지보상법상 보상 대상이 되는 '기타 토지에 정착한 물건에 대한 소유권 그 밖의 권리를 가진 관계인'에는 정착물에 대한 소유권 등을 가진 자뿐 아니라 토지와 별도로 취득 또는 사용의 대상이 되는 정착물에 대한 소유권이나 수거·철거권 등 실질적 처분권을 가진 자도 포함된다.

3) 피수용자의 법적 지위

피수용자의 법적 지위란 토지소유자 및 관계인으로서의 권리·의무 관계를 말한다.

(1) 권리

피수용자의 권리에는

- ① 사업인정시 의견을 제시할 수 있는 권리(제21조),
- ② 재결신청에 따른 열람시 의견을 제시할 수 있는 권리(제31조 제2항),
- ③ 협의 불성립시 재결신청청구권(제30조 제1항),
- ④ 사용하는 토지의 매수청구권(제72조),
- ⑤ 잔여지 등의 매수 및 수용청구권(제74조 제1항),
- ⑥ 비용보상에 대한 협의 불성립시 재결신청권(제80조 제2항),
- ⑦ 환매권(제91조 제1항),
- ⑧ 재결에 불복시 행정쟁송권(제83조 제1항, 제85조 제1항) 등이 있다.

(2) 의무

피수용자의 의무에는

- ① 사업시행자의 토지출입에 따른 행위의 인용의무(제11조, 제27조 제1항),
- ② 토지 등의 보전의무(제25조 제1항), ③ 토지 또는 물건의 인도와 이전의무(제43조 제1항) 등이 있다.

(3) 권리·의무의 승계

피수용자에게는 단지 절차승계만이 인정될 수 있을 따름이다. 사업인정고시가 있을 후 새로운 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계하기 때문이다.

01 의미

공익사업의 목적물이란 공익사업을 위해 독립하여 취득의 대상으로 다루어질 수 있는 토지, 물건 등에 관한 소유권 및 기타 권리이다. 공익사업의 목적물은 사업을 위해 필요한 범위, 정도에 따라 취득하는 것이 원칙이다. 따라서 목적물은 사업의 원활한 시행의 필요성과 공익사업에 제공되는 토지 등 재산권자의 권리 보호의 관점에서 제한적으로만 적용되어야 하며, 목적물은 수용의 경우 사업인정의 절차에 의해 구체적으로 특정된다.

대법원 2005. 11. 10. 선고 2003두7507

공용수용은 공익사업을 위한 필요가 있어야 하고 필요가 있는지에 대하여는 쌍방의 이익의 비교형량의 결과로 입증되어야 하며 입증책임은 사업시행자에게 있다. 수용할 목적물의 범위는 원칙적으로 사업을 위하여 필요한 최소한도에 그쳐야한다.

02 종류

1) 토지보상법 제3조 적용대상

토지보상법은 사업시행자가 다음에 해당하는 토지·물건 및 권리를 취득하거나 사용하는 경우에는 이 법을 적용한다고 규정한다(제3조).

- ① 토지 및 이에 관한 소유권 외의 권리,
- ② 토지와 함께 공익사업을 위하여 필요한 입목(立木), 건물, 그 밖에 토지에 정착된 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리,
- ③ 광업권·어업권·양식업권 또는 물의 사용에 관한 권리,
- ④ 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리

2) 토지소유권과 토지소유권 외의 권리

(1) 토지소유권

공익사업을 위한 수용의 목적물 가운데 가장 중요한 것은 토지이다. 토지는 단순히 지표만을 의미하지 않고, 일정 면적의 지면에 정당한 이익이 미치는 범위 내에서 그 수직의 상하, 즉 공중과 지하를 포함하고 있다(민법 제212조). 토지보상법에서는 사업시행자는 공익사업의 수행을 위하여 필요하면 이 법이 정하는 바에 따라 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있다고 규정한다(제19조 제1항).

(2) 토지에 관한 소유권 외의 권리

토지에 관한 소유권 외의 권리란 물권인 지상권·지역권·전세권·저당권·채권인 임차권 및 기타 공법상의 사용권 등을 말한다. 토지 수용 시 이러한 권리들이 그대로 존속하게 되면 사업을 지연시키는 결과가 된다. 이들 권리는 강제적으로 소멸시켜 사업을 원활하게 하기 위해 수용의 대상으로 하고 있다.

3) 토지에 정착한 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리

(1) 토지에 정착한 물건의 소유권

토지에 정착한 물건이란 건물이나 교량 또는 수목 등과 같이 토지에 고정적으로 부착되어 용이하게 이동할 수 없는 물건으로서 토지와는 독립한 것을 말한다. 토지보상법은 건축물·임목·공작물과 그 밖에 토지에 정착한 물건(“건축물 등”이라 함, 제75조)에 대해서는 이전에 필요한 비용(“이전비”라 함)으로 보상하고 이전하게 하는 것을 원칙으로 하고 있다.

(2) 토지에 정착한 물건의 소유권 외의 권리

토지에 정착한 물건의 소유권 외의 권리란 소유권 외의 물건, 채권 기타 공법상의 권리 등을 말한다. 이와 같은 권리를 취득의 대상으로 하는 것은 타인이 소유권 외의 권리를 지니고 있어 사업의 시행을 방해하는 것을 방지하고자 함이다.

4) 광업권·어업권·양식업권 및 물의 사용에 관한 권리

- ① 「광업법」은 미채굴의 광물을 토지소유권과 분리하여 독립적인 소유권의 대상으로 하고 있다. 광업권이란 탐사권과 채굴권을 말한다(광업법 제2조 제3호). 따라서 토지수용만으로는 광업권을 소멸시킬 수 없으므로 별도로 광업권을 소멸수용의 대상으로 하고 있다.
- ② 어업권이란 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다(수산업법 제2조 제8호). 어업권은 광업권과 마찬가지로 독립적인 권리이므로 별도로 소멸수용의 대상으로 하고 있다.
- ③ 양식이란 수산동식물을 인공적인 방법으로 길러서 거두어들이는 행위와 이를 목적으로 어선·어구를 사용하거나 양식시설물을 설치·운영하는 행위를 말하고(양식산업발전법 제2조제1호), 양식업이란 「양식산업발전법」 제2조제2호에 따라 수산동식물을 양식하는 사업을 말한다(수산업법 제2조제2의2호). 양식업권이란 양식산업발전법 제10조에 따라 면허를 받아 양식업을 경영할 수 있는 권리를 말하며, 동법의 제정에 따라 재산권의 일종으로 명시되었다.
- ④ 유수·해수의 사용권 등도 그 자체로서 권리의 소멸수용의 목적물이 될 수 있다. 공익사업의 목적물이 되는 물의 사용에 관한 권리는 독립하는 권리로서 존재하기 때문이다.

심화

판례는, 하천법상 하천수 사용권은 물의 사용에 관한 권리로서 손실보상 대상이 되지만, 항로권은 독립하여 손실보상 대상이 될 수 없다고 보았다.

5) 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리

흙·돌·모래 또는 자갈은 토지의 구성부분이기 때문에 토지가 취득될 때 당연히 취득된다. 그러나 공익사업에 토지는 필요 없으나, 그에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈만이 필요한 경우 토지와는 독립하여 목적물로 할 수 있다. 대법원은 흙·돌·모래 또는 자갈이 당해 토지와 별도로 취득 등의 대상이 되기 위해서는, 수용대상 토지에 관하여 토지의 형질변경 또는 채석·채취를 적법하게 할 수 있는 행정적 조치가 있거나 그것이 가능하고 구체적으로 토지의 가격에 영향을 미치고 있음이 객관적으로 인정되어 토지와는 별도의 경제적 가치가 있다고 평가되는 경우여야 한다고 보았다(대법원 2014. 4. 24. 선고 2012두16534 판결).

03 목적물의 제한 [★]

1) 수용제도 본질상 제한

수용의 목적물이 되려면 해당 목적물이 **비대체적인 목적물**이어야 할 뿐만 아니라, 그 목적물을 해당 사업에 이용하는 것이 **객관적으로 보아 가장 합리적이고 타당하다고 인정되는 경우**라야 한다. 또한 수용은 비록 공익사업을 위해 불가결하다 하더라도 수용할 목적물의 범위는 원칙적으로 사업을 위하여 필요한 최소한도에 그쳐야 한다(대판 2005. 11. 10. 2003두7507).

대판 1994.1.11. 93누8108

수용할 목적물의 범위는 원칙적으로 사업을 위하여 필요한 최소한도에 그쳐야 하므로 그 한도를 넘는 부분은 수용대상이 아니므로 그 부분에 대한 수용은 위법하고, 초과 수용된 부분이 적법한 수용대상과 불가분적 관계에 있는 경우에는 그에 대한 재결 전부를 취소할 수밖에 없다.

2) 토지세목에 따른 제한

사업인정고시는 사업시행지 및 수용 또는 사용할 토지세목을 내용으로 하므로, 이에 포함된 토지 등에 한하여 수용이 가능하게 된다. 따라서 토지세목에 기재되지 아니한 토지 등은 수용의 목적물이 될 수 없다. 그러나 잔여지를 수용하는 경우 잔여지는 사업인정 및 사업인정고시가 있는 것으로 보므로(제73조 제3항, 제74조 제3항), 그 예외가 인정된다.

3) 목적물의 성질에 따른 제한

(1) 사업시행자 소유의 토지

자기 소유의 토지를 수용한다는 것은 관념상 모순되므로, 사업시행자는 스스로 자기 소유의 토지를 수용하지 못하는 것으로 해석된다.

(2) 공익사업에 이용되고 있는 토지

① 수용권의 충돌

공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다(제19조 제2항). 이는 수용권 충돌 문제를 해결하기 위한 제도이며, 수용적격사업 간에 경합함으로써 충돌하는 공익의 조정을 목적으로 한다. 현재 공익사업에 제공되는 토지라 하더라도 현재의 사업보다 한층 공익성이 큰 사업에 해당 토지를 제공할 필요가 있고, 그렇게 하는 것이 토지의 적정하고 합리적인 이용에 기여하는 경우에는 예외적으로 해당 토지를 수용의 목적물로 하는 길을 열어두는 것이 바람직하다.

② 판단기준

새로운 사업을 위해 '특별한 필요'가 인정된다면 수용의 목적물이 될 수 있는 것으로 해석된다. 이 경우 특별한 필요는 현재 토지를 이용하고 있는 공익사업과 새로 수용하고자 하는 공익사업의 토지이용의 공공성 정도나 효율성 정도를 구체적으로 비교형량하여 판단한다.

(3) 외국대사관 등의 부지·건물

외국의 대사관·공사관 등으로 사용하는 부지·건물은 치외법권이 존재하여 국가의 공권력이 미치지 못하므로 수용의 목적물이 되지 못한다(외교관계에 관한 비엔나조약 제22조 제3항).

(4) 국·공유재산에 대한 재산

국·공유재산 중 일반재산은 그 성질상 당연히 수용의 목적물이 될 수 있으나, 행정재산이 수용의 목적물이 될 수 있는가에 대하여는 한마디로 말하기 어렵다. 이에 대해서 일반적으로 공물을 중심으로 논의되고 있으며, 공물이 공적 목적에 제공되고 있는 한 공용수용의 대상이 되지 않는 것으로 보고 있다.

그러나 토지보상법의 “공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위해 수용하거나 사용할 수 없다(제19조 제2항).”는 규정의 해석에 대하여 견해가 나누어지고 있다.

(5) 공물의 수용가능성 논의 [★★]

① 문제점

토지보상법 제19조 제2항은 “공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다”고 규정하고 있어 공물의 수용시 별도의 공용폐지가 요구되는가와 특별한 필요의 해석이 문제된다.

② 학설

① <긍정설>

토지보상법 제19조 제2항은 현재의 용도보다 한층 공익상 중요한 용도를 위한 특별한 필요가 있는 때에 공용폐지 없이 예외적으로 수용을 허용하는 것으로 본다.

② <부정설>

공물의 수용은 공물의 목적에 반하므로 원칙적으로 허용되지 않지만, 더 큰 공익을 위해 수용이 필요한 경우 공용폐지를 선행해야 한다고 한다.

③ 판례의 태도

대법원은 구 문화재보호법에 의하여 지방문화재로 지정된 토지가 수용대상이 된다고 하여 공적 보존물이 수용의 대상이 될 수 있다고 판시하였으나(대판 1996. 4. 26. 95누13241 판결),

요존국유림, 불요존국유림과 관련하여서는, 구 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률에서 정하는 절차와 방법에 따라 소유권이나 사용권을 취득하려는 조치를 우선적으로 취하지 아니한 채, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 재결을 통해 불요존국유림의 소유권이나 사용권을 취득할 수 없다고 판단하였다(대판 2018. 11. 29. 2018두51904 판결).

헌법재판소는 토지보상법 제19조 제2항에 대하여 공익 또는 수용권의 충돌문제를 해결하기 위한 것으로, 특별한 필요가 있는 경우에는 예외적으로 수용의 목적물이 될 수 있다고 판시하였다(헌재 2000헌바32).

④ 검토

공물은 현재 공익 목적에 제공되고 있지만, 보다 큰 공익 목적을 위해 다른 용도로 전환될 수 있어야 한다. 따라서 공용폐지 없이도 토지보상법 제19조 제2항의 특별히 필요한 경우가 있을 때 수용목적물이 될 수 있는 것으로 보아야 한다. 특별한 필요는 비례의 원칙에 따라 종래의 공익과 새로운 공익을 비교형량하여 판단한다.

04 목적물의 확장 [★★]

1) 확장수용의 의미 및 취지, 종류

확장수용은 특정한 공익사업을 위하여 목적물의 필요한 범위를 넘어서 수용하는 것이다. 확장수용은 원칙상 인정되지 않는다. 그러나 예외적으로 수용권자와 피수용자간 이해관계를 합리적으로 조정하고, 피수용자에 대한 권리구제에 이바지하며, 사업의 원활한 실시를 위해 법률규정이 있는 경우 인정된다. 토지보상법상 규정된 확장수용에는 완전수용(제72조), 잔여지수용(제74조), 이전수용(제75조)이 있다.

2) 확장수용의 성질

(1) 문제점

확장수용이 일반적으로 피수용자의 청구에 의해 이뤄진다는 점에서 그 성질에 대하여 견해가 나뉜다. 적용법규 및 쟁송형태의 차이에 논의의 실익이 있다.

(2) 학설

① <사법상 매매설>

사업시행자의 재산권 취득은 피수용자와의 합의를 바탕으로 하므로 사법상 매매의 성질을 띤다고 한다.

② <공법상 특별행위설>

확장수용이 해당 공익사업의 시행상 필요 최소한도를 넘긴 하나, 피수용자의 청구에 의해 이뤄진다는 점에서 공법상 특별행위라고 한다.

③ <공용수용설>

확장수용은 피수용자의 청구를 요건으로 하는 사업시행자의 일방적 권리취득 행위로서, 그 본질은 일반적 수용과 다른 것이 없다고 한다. 이 견해가 다수설이다.

(3) 판례의 태도

대법원은 잔여지 수용청구권이 그 요건을 갖춘 때에는 토지수용위원회의 특별한 조치를 기다릴 것 없이 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하므로, 이는 형성권적 성질을 가진다고 판시하여 공용수용설 입장이라고 할 수 있다.

대법원 2015. 4. 9. 선고 2014두46669 [토지수용재결신청거부처분취소]

토지보상법 제72조의 문언, 연혁 및 취지 등에 비추어 보면, 위 규정이 정한 수용청구권은 토지보상법 제74조 제1항이 정한 잔여지 수용청구권과 같이 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 청구에 의하여 수용 효과가 생기는 형성권의 성질을 지니므로, 토지소유자의 토지수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 '보상금의 증감에 관한 소송'에 해당하고, 피고는 토지수용위원회가 아니라 사업시행자로 하여야 한다.

심화

72조 수용청구권, 74조 잔여지수용청구권의 법적성질 : 형성권

소송방법 : 보상금증액청구소송 ○, 수용재결취소소송 ×

수용재결취소송 제기하면 부적법 각하판결

(4) 검토

확장수용은 피수용자에 대한 권리구제의 보충적 필요에 의의가 있으므로, 본래의 수용개념과는 구별된다. 그러나 확장수용은 피수용자의 청구를 요건으로 한 사업시행자의 권리취득 행위로서 공용수용의 효과가 발생하므로, 공용수용설이 타당하다.

3) 완전수용

(1) 의의

완전수용이란 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 현저한 장해에 갈음하여 수용보상을 가능하게 해주는 제도이다. 완전수용은 '사용에 갈음하는 수용'이라고도 한다(제72조).

(2) 요건

사업인정고시 후

- ① 토지사용기간이 3년 이상인 경우,
- ② 토지사용으로 인하여 토지형질이 변경되는 경우,
- ③ 사용하려는 토지에 그 토지소유자의 건축물이 있는 경우

해당 토지소유자는 사업시행자에게 토지매수를 청구하거나 관할 토지수용위원회에 토지수용을 청구할 수 있다.

여기에서 '토지사용'이란 토지보상법이 정하는 절차에 따라 적법하게 사용하는 것을 말한다.

대법 1996. 9. 10. 선고 96누5896판결

무단사용에 대한 차별대우가 평등권을 침해한다거나 재산권 보장 및 정당한 보상의 원칙에 위배되는 것은 아니다.

(3) 완전수용청구권 및 관계인의 권리 존속 청구

완전수용청구권은 토지소유자만 갖는다. 이 경우 관계인은 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 대하여 그 권리의 존속을 청구할 수 있다(제72조 제2문). 그 청구가 이유 있는 것으로 받아들여지면 수용재결이 있더라도 그 권리는 소멸하지 않고 존속한다.

4) 잔여지수용

(1) 의의

잔여지수용이란 동일한 토지소유자에게 속하는 수용 목적물인 일단의 토지 일부가 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때 토지소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 토지의 전부를 매수하거나 수용하는 것을 말한다.

(2) 잔여지의 판단

① 잔여지의 요건

동일한 토지소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때이다(제74조 제1항).

② 종래 목적 및 사용이 현저히 곤란할 때의 의미

‘종래의 목적’이라 함은 수용재결 당시에 해당 잔여지가 현실적으로 사용되고 있는 구체적 용도를 의미하고, ‘사용하는 것이 현저히 곤란한 때’라 함은 물리적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우는 물론 사회적·경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우, 즉 절대적으로 이용 불가능한 경우뿐만 아니라, 이용은 가능하나 많은 비용이 소요되는 경우를 포함한다(대판 2005. 1. 28. 2002두4679). ‘현저히 곤란할 때’라 함은 개별적·구체적으로 판단하여 결정할 성질의 것이다.

③ 구체적 요건 (시행령 제39조 제1항)

잔여지가

- ① 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우,
- ② 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우,
- ③ 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우,
- ④ 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우의 어느 하나에 해당하는 경우 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지의 매수를 청구하거나, 관할 토지수용위원회에 수용하여 줄 것을 청구할 수 있다.

상기 ①에서 ‘대지로서 면적이 너무 작은 경우’는 대지가 해당 시·군 건축조례에 의한 대지분할 제한면적(건축법 제57조 제1항) 이하인 토지로 해석할 수 있다. 또한 잔여지의 범위는 보상협의회의 협의사항이다(제82조 제1항 제2호 참조).

잔여지를 판단할 때에는 ① 잔여지의 위치·형상·이용상황 및 용도지역, ② 공익사업 편입토지 면적 및 잔여지 면적을 종합적으로 고려하여야 한다(령 제39조 제2항).

(3) 매수·수용의 절차

동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, 사업완료일까지 하여야 한다(제74조 제1항). 사업인정 이전에는 매수청구를 하고, 이후에는 수용청구가 가능하다. 잔여지에 대한 수용청구는 매수협의를 필수적 절차로 하고 있는 점에 특징이 있다.

(4) 매수·수용의 효과

① 관계인의 권리 존속 청구

매수 또는 수용청구가 있는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 관하여 권리를 가진 자는 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 그 권리의 존속을 청구할 수 있다(제74조 제2항). 청구가 이유 있는 것으로 받아들여지면 수용재결이 있더라도 그 권리는 소멸하지 않고 존속한다. 이는 관계인의 권리보호를 위함이다.

② 사업인정 및 사업인정고시의 의제

잔여지의 매수·수용청구 규정에 따라 토지를 취득하는 경우는 그 잔여지에 대하여 사업인정(제20조) 및 사업인정고시(제22조)가 된 것으로 본다(제74조 제3항).

(5) 관련 문제 (잔여지 손실 및 공사비 보상 관련, 제73조)

토지소유자가 재결절차를 거치지 않고 사업시행자를 상대로 잔여지 가격감소 등으로 인한 손실보상을 청구할 수 있는지가 문제된다. <대법원>은 잔여지 가격감소 등으로 인한 손실보상을 받기 위해서는 토지보상법에 규정된 재결절차를 거친 다음 권리구제를 받을 수 있을 뿐이라고 한다. 따라서 이러한 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다는 입장을 취하고 있다(대판 2008. 7. 10. 2006두19495).

5) 이전수용

(1) 의의

토지상의 지장물은 이전에 필요한 비용(이하 “이전비”라 함)을 보상하고 이전하는 것이 원칙이다. 이전수용이란 물건 등의 이전을 강행하는 것이 소유자나 사업시행자에게 과중한 손실을 가져올 우려가 있는 예외적인 경우 수용할 수 있도록 하는 제도이다.

여기에서 지장물이란 공익사업시행지구 내의 토지에 정착한 건축물·공작물·시설·입목·죽목 및 농작물 그 밖의 물건 중에서 당해 공익사업 수행을 위하여 직접 필요하지 아니한 물건을 말한다(칙 제2조 제3호).

(2) 이전비보상의 원칙과 예외

① 원칙

건축물 등은 이전비로 보상하여야 한다(제75조 제1항 본문). 이전비란 대상물건의 유용성을 동일하게 유지하면서 이를 당해 공익사업시행지구 밖의 지역으로 이전·이설 또는 이식하는 데 소요되는 비용(물건의 해체비, 건축허가에 일반적으로 소요되는 경비를 포함한 건축비와 적정거리까지의 운반비를 포함하며, 「건축법」등 관계 법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용을 제외)을 말한다(칙 제2조 제4호).

② 예외

a. 물건가격 보상

- ① 건축물 등을 이전하기 어렵거나, 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적으로 사용할 수 없게 된 경우,
- ② 건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우,
- ③ 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우의 어느 하나에 해당하는 경우는 해당 물건의 가격으로 보상하여야 한다(제75조 제1항 단서).

b. “이전 곤란”의 의미

‘이전이 어렵다는 것’은 이전에 관한 물리적인 곤란뿐만 아니라 이전을 위하여 부당하게 많은 비용을 요하는 등 사회적·경제적 곤란도 포함되는 것으로 해석된다. 그러나 이전수용의 요건인 이전 곤란성과 사용 가능성은 개별적·구체적으로 판단할 성질의 것이다. 이전보상을 위해서는 이전 가능성과 함께 이전비용이 취득가격을 초과하는지 여부 등을 검토하여야 한다.

(3) 절차 및 효과

사업시행자는 사업예정지에 있는 건축물 등이 물건가격으로 보상해야 할 경우에 해당(제75조 제1항 제1호 또는 제2호)하는 경우 관할 토지수용위원회에 그 물건의 수용재결을 신청할 수 있다. 이는 사업시행자에게 수용 청구권을 인정하여 사업시행자의 경제적 부담을 적게 함으로써 공익사업을 원활하게 시행하게 함을 목적으로 한다.

6) 확장수용재결에 대한 불복

(1) 문제점

확장수용은 공용수용의 성질을 갖고, 확장수용청구권의 법적성질은 공권으로서, 토지보상법 체계상 확장수용은 토지수용위원회의 재결에 의하여 이루어진다. 따라서 확장수용 거부 시 이에 대한 불복은 토지보상법 제83조 및 제85조의 규정에 따르면 된다. 이 때 항고소송을 제기하지 않고 보상금증감청구소송을 제기할 수 있는지, 민사소송의 제기는 가능한지 문제된다.

(2) 이의신청

토지보상법 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 토지보상법 제83조에 따라 재결서正本 송달일로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다. 토지보상법은 이의신청을 임의적 절차로 규정하여 행정심판법의 행정심판 임의주의의 입법취지와 균형을 맞추어 신속한 권리구제를 도모하고 있다. 토지보상법상 특례를 따르고 토지보상법에서 정하지 아니한 사항은 행정심판법을 따른다(행정심판법 제4조 제2항).

(3) 확장수용 거부(수용재결 중 기각재결)에 대한 보상금증감청구소송 가능성

① 문제점

분쟁의 일회적 해결을 위하여 보상금증감청구소송 하나로 잔여지의 목적물까지 심리 범위에 포함하여 심리할 수 있는지 논란이 있다.

② 학설

① <부정설>

확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로, 취소소송이나 무효등확인소송을 제기해야 한다고 한다. 보상금증감청구소송은 보상금액을 다투는 소송이라 한다.

② <긍정설>

보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있고, 확장수용의 실질을 형평의 원칙에 입각한 피수용자의 불이익 구제의 손실보상으로 보는 한 보상금증감청구소송에서 심리할 수 있다고 한다.

③ 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 수용의 효과가 발생하는 형성권적 성질을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 “보상금의 증감에 관한 소송”에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다고 판시하였다(대판 2010. 8. 19. 2008두822).

④ 검토

보상금증감청구소송의 제도 취지가 분쟁의 일회적 해결로서 피수용자의 권리구제를 위한 것이므로, 보상금증감청구소송에서 목적물 범위까지 심리하여 다툴 수 있도록 함이 타당하다.

(4) 민사소송의 가능성

잔여지 수용청구에 대한 불복방법으로 민사소송이 제기가능한가와 관련하여 잔여지수용청구권을 공권으로 볼 때 민사소송의 제기는 불가능하다. <대법원>도 수용재결 및 이의재결에 불복이 있으면 재결청과 기업자를 공동피고로 하여 그 이의재결의 취소 및 보상금의 증액을 구하는 행정소송을 제기하여야 하며 곧바로 기업자를 상대로 하여 민사소송으로 잔여지에 대한 보상금의 지급을 구할 수 없다고 하여 이를 부정하였다.

공익사업 절차 및 관련 규정

구분	절차(토지보상법 조문)	
공익사업 준비절차	타인토지출입(9), 방해물 제거(12) 등	토지보상법 9조~13조
	토지 및 물건조서 작성(14)	
	보상계획공고 및 열람(15)	
사업인정 전 협의절차	협의(16) 계약체결(17)	- 협의는 수용재결 전 반드시 거쳐야 함 - 사업인정 전 협의(임의), 후 협의(필수) - 협의 손실보상금을 위한 감정평가 진행 (3인의 감정평가법인등, 토지소유자 추천제도 적용)
	사업인정(20), 협의 및 의견청취 등(21)	- 주체 : 국토부장관 - 절차 : 중앙행정기관 장, 시도지사, 중토위(공공성판단)와 협의 - 이해관계자 의견청취 - 비교: 22조 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생/ 25조 사업인정고시가 된 후 누구든지 토지보전의무 발생
강제수용 취득절차	사업인정후 협의(26): 사업인정 전 절차(14~16) 준용	26조 필수조항
	수용재결(34)	- 주체 : 관할 토지수용위원회 - 절차 : 사업시행자의 재결신청(28) (피수용자의 재결신청청구(30) 가능) - 화해(33), 협의성립확인(29) 가능 - 소유권 원시취득(45)과 가격시점(67①) - 수용재결 손실보상금을 위한 감정평가 진행 (2인의 감정평가법인등 복수평가(68))
	이의재결(84)	- 주체 : 중앙토지수용위원회 - 절차 : 수용재결에 이의있는 자의 이의신청(83) 〈특별법상 행정심판〉 - 이의재결 손실보상금을 위한 감정평가 진행 (2인의 감정평가법인등(68))
	행정소송(85)	- 취소소송(1항), 무효등확인소송(판례) - 보증소(2항), 보증소 손실보상금을 위한 감정평가 진행 (1인의 감정평가법인등)

의의와 법적 성격

01 의의

공익사업 준비란 공익사업을 위해 조사·측량 및 장해물의 제거 등을 하는 일련의 준비행위이다. 사업시행자가 사업계획을 작성하고, 수용 또는 사용하려는 토지의 구역을 확정하기 위하여 사업지역에 출입하여 조사·측량 또는 장해물 제거 등의 행위를 할 필요가 있다.

02 법적 성격

공익사업의 준비에 대하여는 공용제한으로 이해하는 견해와 공용사용으로 이해하는 견해가 있다. 생각건대 공익사업의 준비는 일시적 사용을 전제하므로, 공용사용으로 봄이 타당하다. 공익사업 준비과정은 수용이나 사용에 비하여 재산권에 대한 침해 정도가 경미하고 일시적이므로, 토지수용절차를 거치지 않고 단지 허가에 의하도록 하는 특징을 지닌다.

제2절

타인 점유토지에의 출입 [★]

심화

		9조 사업인정 전 타토출	27조 사업인정 후 타토출
차 이 점	목적	공익사업적합성판단	분쟁예방(사업준비, 조서작성, 감정평가), 심리와 재결의 신속
	절차	사업인정 전 (허가 필요)	사업인정 후 (허가 불요)
	출입근거	시군구장 허가	사업인정 효과
	내용	장해물 제거 및 시굴권 등 동의 얻어 가능	준용규정 없어 장해물 제거 및 시굴권 등 불가능
	권리구제	허가를 대상으로 쟁송 가능 (사업인정에 대한 쟁송불가)	사업인정을 대상으로 쟁송 가능
공 통 점	법적근거	① 토지보상법 근거 ② 10, 13조 준용(절차상 공통점), 11조(수인의무)	
	법적성격	① 사용제한 중 일시적 사용 ② 행정조사	
	손실보상	§9④~⑦준용	
관련문제		직접적인 실행행사 불가	

구분		토지보상법(9)상 타토출	부동산공시법(13)상 타토출
공통점		특허 & 타인토지출입행위의 법적성질(권력적 사실행위·행정조사) & 출입제한 및 증표 휴대	
차 이 점	목적	공익사업 준비 & 조서작성	표준지 가격 조사·평가 & 개별공시지가 산정
	수인의무	수인의무 있음 & 벌칙규정 있음	수인의무 있음 & 벌칙규정 없음
	장해물 제거 및 출입의 통지기간	장해물 제거 규정 있음 & 5일전	장해물 제거 규정 없음 & 3일전
	손실보상	손실보상 규정 있음	손실보상 규정 없음

01 출입의 허가과 통지

1) 의의 및 근거

사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제9조 제1항). 사업시행자 측량·조사를 하려면 사업의 종류와 출입할 토지의 구역 및 기간을 정하여 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다.

2) 출입허가의 법적성질 및 권리구제

출입의 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 출입허가를 강학상 허가, 강학상 특허 또는 예외적 승인이라고 보는 견해가 대립하나, 타인의 토지에 출입할 수 있는 권리를 부여한다는 점에서 강학상 특허로 보아야 할 것이다. 사업인정 이전의 경우는 공공성을 판단하기 이전이므로, 허가의 성질을 고려할 때 공익 관련성이 크다는 점에서 재량행위로 봄이 타당하다. 허가는 행정쟁송법상 처분인 바, 행정쟁송으로 다툴 수 있다.

02 출입 측량·조사 행위

1) 의의 및 취지, 근거

타인토지에 출입하여 측량·조사하는 행위는 그 지역이 해당 공익사업에 적합한 지역인지 판단하는 행정조사행위이다(제9조).

2) 법적 성질

출입 측량·조사 행위 자체는 비권력적 사실행위이나, 토지보상법상 토지점유자의 인용의무(제11조)가 부과되므로, 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서 권력적 사실행위에 해당하고, 처분성이 인정된다.

3) 요건 및 절차

사업시행자는 타인토지에 출입, 측량·조사하려면 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다(제9조 제2항). 다만, 사업시행자가 국가일 때에는 그 사업을 시행할 관계 중앙행정기관의 장이 특별자치도지사 등에게 통지하여야 한다. 특별자치도지사 등은 위 허가 또는 통지를 받은 때 사업시행자, 사업의 종류와 출입할 토지의 구역 및 기간을 공고하고 이를 토지점유자에게 통지하여야 한다(제9조 제3항).

타인 토지에 출입하려는 사업시행자는 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사 등에게 통지하여야 하고(제10조 제1항), 통지를 받은 특별자치도지사 등은 통지를 받은 때 또는 직접 출입하려는 경우에는 지체 없이 이를 공고하고 그 토지점유자에게 통지하여야 한다(제10조 제2항). 사업시행자는 해가 뜨기 전이나 해가 진 후에는 토지점유자의 승낙 없이 그 주거(住居)나 경계표·담 등으로 둘러싸인 토지에 출입할 수 없다(제10조 제3항). 출입하려는 사람은 그 신분을 표시하는 증표와 허가증을 지녀야 하고(제13조 제1항), 증표 및 허가증은 토지 또는 장애물의 소유자 및 점유자 그 밖의 이해관계인에게 이를 보여 주어야 한다(제13조 제3항).

4) 효과

사업시행자가 타인토지출입의 공용사용권을 취득하면 토지점유자의 인용의무(제11조) 발생, 손실보상청구권(제9조 제4항), 장애물 제거·시굴허가 신청권(제12조 제1항), 사용기간 만료시 반환 및 원상회복의무(제48조), 행정쟁송권 등이 발생한다. 실효성 확보수단으로서, 제9조 제2항을 위반하여 허가를 받지 않고 타인 점유 토지에 출입하거나 출입하게 한 사업시행자는 200만 원 이하의 벌금에 처한다(제97조 제1호). 제11조의 인용의무를 위반하여 사업시행자 또는 감정평가법인등의 행위를 방해한 토지점유자는 200만 원 이하의 벌금에 처한다(제97조 제2호).

5) 실력 행사의 가부

(1) 문제점

타인토지출입 측량조사와 같은 권력적 행정조사 중, 상대방이 조사를 거부하는 경우 벌칙규정은 존재하지만, 실력행사에 관한 명문 규정이 없는 경우 직접 실력행사를 통해 필요한 출입 측량·조사를 할 수 있는지 문제된다.

(2) 학설

① <긍정설>

제재규정을 둔 것은 피조사자의 수인의무 위반을 위법으로 보아 비례의 원칙 안에서 실력을 가할 수 있는 규정으로 볼 수 있다고 한다.

② <부정설>

토지보상법상 벌칙 규정만을 둔 취지는 조사의 실효성을 간접적으로 확보하려는 것으로서 실력행사는 허용되지 않는다고 한다.

(3) 검토

국민의 신체나 재산에 대한 실력행사는 명문의 근거가 있어야 하므로 부정설이 타당하다.

6) 위법한 측량·조사와 그에 따른 사업인정의 효력

(1) 문제점

측량·조사의 내용에 흠이 있어 그 정보에 기초하여 내려진 사업인정은 내용상 위법하다.
그러나 내용상으로는 정확하나 측량·조사가 절차를 위반한 경우, 즉 상기와 같은 실력행사를 하여 측량·조사를 마쳤거나 하는 등과 같은 절차 위반 시, 그 측량·조사에 의해 수립된 정보에 기초하여 내려진 사업인정이 위법한 것으로 되는지 문제된다.

(2) 학설

① <적극설>

절차의 적법성 보장 원칙에 비추어 행정조사가 위법한 경우 당해 조사를 기초로 한 행정행위는 위법하다.

② <소극설>

행정조사는 법령에서 특히 행정행위의 전제조건으로 규정되어 있는 경우를 제외하고는 일응 별개의 제도로 볼 수 있어 조사의 위법이 바로 행정행위를 위법하게 하지는 않는다.

③ <절충설>

행정조사와 행정처분은 하나의 과정을 구성하므로 적정절차 관점에서 행정조사에 중대한 위법사유가 있으면 그에 기초한 행정행위도 위법한 것으로 볼 수 있다.

(3) 판례

판례는 위법한 세무조사에 기초한 부가가치세 부과처분은 위법하다고 하여 적극설을 취하고 있다.
다만, 행정조사 절차하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본다.

(4) 검토

사업인정에 필요한 정보를 수집하기 위해 행해진 측량·조사가 위법한 경우 당해 행정행위의 절차하자가 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 경우 사업인정의 효력은 절차 하자의 문제가 될 것이다.

01 장해물 제거 등을 위한 허가

1) 의의 및 근거

측량·조사시 장해물 제거 등을 해야 할 부득이한 사유가 있는 경우 소유자 및 점유자의 동의를 얻어야 하고, 동의를 얻지 못한 때에는 허가를 받아 장해물 제거를 할 수 있다(제12조 제1항).

2) 법적성질 및 권리구제

장해물 제거 등을 위한 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 허가에 대하여 강학상 허가, 강학상 특허, 예외적 승인 등의 견해가 대립하나, 장해물 등을 제거할 수 있는 권리를 부여하는 강학상 특허로 봄이 타당하다. 사업인정 이전의 경우는 공공성을 판단하기 이전이므로, 허가의 성질을 고려할 때 공익 관련성이 크다는 점에서 재량행위로 봄이 타당하다. 허가는 행정쟁송법상 처분인 바, 행정쟁송으로 다룰 수 있다.

02 장해물 제거 등 행위

1) 의의 및 취지, 근거

장해물 제거란 측량·조사시 부득이하게 장해물을 제거하고 토지의 시굴·시추를 해야 하는 경우를 말한다(제12조 제1항). 허가를 받는 것은 사업시행자의 측량·조사 등을 원활하게 하고, 토지소유자 또는 점유자의 권리가 부당하게 침해되지 않도록 하기 위함이다.

2) 법적 성질

장해물 제거행위 자체는 비권력적 사실행위이다. 토지보상법은 타인토지 출입시 토지점유자의 인용의무를 규정하나, 장해물 제거행위에는 인용의무를 규정하지 않고 있다. 장해물 제거행위는 측량·조사의 원활함을 위한 것이므로, 정당하게 허가받고 제거하는 행위에 대하여는 명문 규정이 없다 하더라도, 타인토지 출입 시 인용의무를 준용함이 타당하다. 따라서 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서, 권력적 사실행위에 해당하고, 이는 처분성이 인정된다.

3) 요건 및 절차

사업시행자는 소유자 및 점유자의 동의를 얻어야 하고, 동의를 받지 못할 경우에는 사업시행자는 허가를 받아 장해물 제거 등을 할 수 있다(제12조 제1항). 특별자치도지사 등이 허가를 하거나 장해물 제거 등을 하려면 미리 그 소유자 및 점유자의 의견을 들어야 한다(제12조 제2항). 장해물 제거 등을 하려는 자는 장해물 제거 등을 하려는 날의 3일 전까지 그 소유자 및 점유자에게 통지하여야 한다(제12조 제3항). 장해물 제거 등을 하려는 자는 그 신분을 표시하는 증표와 허가증을 지녀야 하고(제13조 제1항), 이를 장해물의 소유자 및 점유자, 그 밖의 이해관계인에게 보여주어야 한다(제13조 제3항).

4) 효과

장해물 제거권(제12조 제1항), 토지점유자의 인용의무(제11조 준용), 손실보상청구권(제12조 제4항), 사용기간 만료시 반환 및 원상회복의무(제48조), 행정쟁송권이 발생한다. 실효성 확보수단으로서, 제12조 제1항을 위반하여 장해물 제거 등을 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다(제95조의2 제1호).

01 사업시행자의 권리구제

1) 허가신청 거부에 대한 권리구제

허가는 행정쟁송법상 처분으로서 특별자치도지사 등의 공권력의 행사이고, 허가 거부로 인하여 사업시행자의 측량·조사 또는 장애물 제거의 공익사업 준비과정과 그 이후 공익사업 진행과 관련된 실체상 권리행사에 중대한 지장을 미칠 수 있다. 신청권 요구에 대하여 견해대립이 있으나, 토지보상법 제9조 및 제12조에 의해 사업시행자에게 신청권이 있는 것으로 해석된다. 따라서 허가거부는 처분으로서 대상적격이 있다. 기타 소송요건이 충족된다면, 허가거부처분의 위법성의 정도에 따라 항고소송을 제기할 수 있다. 위법·부당의 경우 항고심판 가능하다.

춘천지법 강릉지원 2015.5.21. 선고 2015구합1541 판결 : 확정

甲 시장이 원자력발전소 전원개발사업을 시행하는 乙 주식회사에 사업 예정구역에 대한 지적현황 측량 및 지장물 실태조사를 위한 출입허가를 하였다가, 민간기구 주관으로 실시한 원전 유치 찬반 주민투표 결과 원전 유치 반대의견이 압도적으로 높아 원전 건설사업이 더 이상 진행되기 어려운 상황이라는 등의 이유로 출입허가를 취소하는 처분을 한 사안에서, 공익사업의 시행에 관한 결정이 당연 무효에 해당하지 않고 취소 또는 철회되지 않아 효력을 유지하고 있다면 결정의 하자나 지역 주민 대다수가 사업의 추진을 반대하고 있다는 등의 사정을 들어 이미 확정된 공익사업의 준비를 위한 출입허가를 취소할 수 없으므로 위 처분은 정당한 처분사유를 갖추지 못하였고, 행정절차법 제21조에 따른 청문절차를 거치지 않아 절차상으로도 중대한 하자가 있어 위법하다고 한 사례.

2) 허가신청 부작위에 대한 권리구제

사업시행자에게 토지보상법 제9조 및 제12조에 의해 신청권이 있는 것으로 해석되고, 특별자치도지사 등에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있다. 만약 상당한 기간 내에 특별자치도지사 등이 아무런 처분도 하지 않고 있다면 부작위가 성립한다. 사업시행자는 의무이행심판과 부작위위법확인소송을 제기할 수 있다.

02 토지소유자의 권리구제

1) 사전적 권리구제

출입 측량·조사 시 통지, 장애물 제거 시 통지, 장애물 제거 허가 시 소유자 및 점유자의 의견청취 등이 토지보상법에 규정되어 있다. 측량·조사와 장애물 제거 행위는 권력적 사실행위로서, 처분성이 인정되고, 토지소유자 및 점유자에게는 침익적 행위인 바, 예방적 금지소송과 가처분이 권리구제방법으로 논의될 수 있으나, 현행법상 인정되지 않고 있다.

2) 사후적 권리구제

(1) 손실보상 (제9조 제4항, 제12조 제4항)

사업시행자는 타인 토지에 출입하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다(제9조 제4항). 사업시행자는 장애물 제거 등을 함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다(제12조 제4항). 손실의 보상은 손실이 있음을 안 날부터 1년이 지났거나 손실이 발생한 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제9조 제5항). 손실의 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정한다(제9조 제6항). 협의 불성립 시 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다(제9조 제7항).

(2) 손실보상의 재결에 대한 불복

토지보상법 제9조 제7항에 의한 재결은 보상금만에 대한 재결이나, 제34조의 수용재결과 동일한 절차, 심리 과정을 거쳐 결정되므로, 양자의 불복수단을 일관성 있게 봄이 타당하다. 따라서 토지보상법상 이의신청(제83조), 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 권리구제가 가능하다. 다만, 보상재결의 처분성을 부정할 경우 이 손실보상청구권의 법적 성질에 따라 민사소송 또는 공법상 당사자소송으로 다룰 수 있다.

(3) 수용재결절차 없이 사업시행자를 상대로 손실보상청구 가능한지

① 견해 대립

보상재결은 단순한 보상견적액 제시에 불과하므로 민사 또는 당사자소송으로 다뤄야 한다는 견해, 재결절차를 반드시 거쳐야 한다는 견해가 있다.

② 판례

판례는 재결절차를 거친 후 재결 불복 시 비로소 토지보상법 규정으로 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 재결절차를 거치지 않고 곧바로 사업시행자에게 손실보상을 청구할 수 없다고 하였다.

③ 검토

생각건대, 판례와 같이, 보상재결은 수용재결과 주체, 형식, 절차 등이 동일하고 손실보상에 관한 권리, 의무를 규율하는 수용재결과 같은 처분으로 봄이 타당하다. 따라서 토지보상법상 권리구제수단을 인정함이 권리구제에 실효적이라는 견해가 타당하다. 참고로 토지보상법 제9조 제6, 7항을 준용하거나, 제80조에 따른 수용재결에서는 위 논의를 그대로 적용할 수 있다.

(4) 측량·조사 및 장애물 제거에 대한 행정쟁송

출입 측량·조사행위, 장애물 제거행위는 권력적 사실행위로서 처분성이 인정되므로, 항고쟁송으로 다룰 수 있다. 다만 조사기간이 짧아 단기에 종료될 수 있으므로 협의 소익이 없어 각하될 가능성이 높다.

(5) 기타 (위법한 조사와 사업인정, 손해배상 및 결과제거 청구권 등)

- ① 위법한 행정조사에 기한 후속조치로 처분이 행해진 경우 적법절차 관점에서 행정조사의 위법을 이유로 후행처분의 취소를 구할 수 있다.
- ② 위법한 행정조사는 국가배상법에 의해 손해배상청구가 가능하며 위법한 행정조사 결과로 위법한 상태가 계속되는 경우 결과제거청구권 행사가 가능하다.

제1절

공용수용(공용사용)의 보통절차

보통절차란 토지 등의 수용을 위해 단계적으로 밟아야 하는 일련의 절차이다.

공용수용은 특정한 사유재산권의 강제적 취득을 바탕으로 하므로, 엄격한 절차에 의해 진행되어야 한다.

보통절차는 ① 사업인정 → ② 토지조서 및 물건조서의 작성 → ③ 협의 → ④ 수용재결로 구성된다.

제2절

수용과 사용의 구분

01 수용과 사용의 의미

수용(收用)이란 공익사업을 위해 특정한 자가 소유하고 있는 토지 등에 관한 권리를 사업시행자가 강제적으로 취득하고 권리를 소멸시키는 것을 말한다. 사용(使用)이란 공익사업을 위해 특정인의 토지 등에 관한 권리를 사업시행자가 일시적 또는 영속적으로 점유(占有)하여 지배하고, 그 목적에 따라 이용하는 것을 말한다. 공용수용은 수용이라는 용어를 사용하고 있으나, 실정법상 사용을 포괄하고 있다. 토지보상법은 수용과 사용을 따로 구별하지 않고, 양자의 구분 기준에 대하여도 규정하지 않는다.

02 수용과 사용의 구분

수용과 사용의 구분은 일반 사회의 통념에 따라 판단할 수 있다. 시간적 측면에서 사업을 위한 사용에 영속성이 인정되는 경우는 수용을, 일정기간으로 짧은 것이라 인정되는 경우는 사용으로 하고 있다. 공간적 측면에서는 사업을 위한 사용이 토지의 이용 가능한 범위 전부에 대하여 또는 지표면을 필요로 하는 경우에는 수용을, 지표면을 제외한 토지의 상하 공간 일부인 경우에는 사용으로 하고 있다.

제3절

약식수용절차

01 의미

약식절차란 토지의 수용 또는 사용에 관한 보통절차 가운데 그 일부를 생략하고 행하는 절차를 말한다. 토지의 수용 또는 사용 절차는 모든 단계를 거쳐야 함이 원칙이나, 특별한 사유가 있는 경우는 절차 중 일부를 생략할 필요가 있다. 공익상 긴급할 경우 간소한 절차를 통해 수용 또는 사용을 인정할 필요가 있으나, 이는 재산권보장원칙에 대한 중대한 예외이므로, 반드시 법률에 근거를 둔 경우에만 인정될 수 있다.

구분		법38조 천재지변 시 토지 사용	법39조 시급한 토지 사용
공 통 점	취지	보통절차를 거칠 여유가 없는 경우 원활한 사업진행을 도모	
	요건	관련 행정청의 허가 & 토지소유자 및 점유자에 대한 통지&공용사용의 경우만 허용	
	사용기간 및 효과	6개월 이내, 반환 및 원상회복 의무	
	보상의 특징	사후보상 (사전보상의 예외)	
차 이 점	허가권자	시·군·구청장	재결신청전제&관할토지수용위원회
	담보물 제공 여부	제공 X	제공 O
	보상금 지급 절차	협의절차 있음 (9조5항~7항준용)	협의절차 없음
	손실보상액에 대한 불복	별도규정 없음 (9조)	별도규정 있음 (41조)

02 천재지변 시의 토지의 사용

1) 의의

천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때 특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가로서 타인의 토지 등을 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(제38조).

2) 요건

- ① 천재지변 그 밖의 사변 시에 한정된다.
- ② 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있어야 한다.
- ③ 토지보상법 제4조 각 호의 하나에 해당하는 공익사업이어야 한다.
- ④ 사업시행자의 신청을 전제한다.
- ⑤ 사용기간은 6개월을 넘지 못한다(제38조 제3항). 이 기간을 초과하여 사용하려면 공용수용이 보통절차를 거쳐야 한다.

3) 절차

사업시행자는 허가를 받아 즉시 사용할 수 있고, 사업시행자가 국가 또는 특별시·광역시 또는 도일 때에는 통지하고 사용할 수 있다(제38조 제1항). 허가를 하거나 통지를 받은 경우 또는 직접 사용하려는 경우 즉시 토지소유자 및 토지점유자에게 통지하여야 한다(동조 제2항).

4) 효과

사업시행자는 사용권을 취득하고, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조)를 지며, 대행(제44조)·대집행(제89조) 신청권을 갖는다. 토지소유자는 토지인도의무와 손실보상청구권을 갖는다.

5) 권리구제

(1) 위법한 허가에 대한 행정쟁송 및 손해배상

위법한 허가에 대하여 행정쟁송으로 다룰 수 있고, 손해배상 요건 충족 시 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 적법한 허가에 대한 손실보상

사업시행자는 타인의 토지를 사용함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다(제38조 제4항). 손실보상에 관하여는 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다. 이 손실보상은 사후보상으로서 사전보상원칙의 예외에 해당한다. 토지보상법 제9조 제7항에 의한 재결은 보상금만에 대한 재결이나, 제34조의 수용재결과 동일한 절차, 심리과정을 거쳐 결정되므로, 양자의 불복수단을 일관성 있게 봄이 타당하다. 따라서 토지보상법상 이의신청(제83조), 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 권리구제가 가능하다. 다만, 보상재결의 처분성을 부정할 경우 이 손실보상청구권의 법적 성질에 따라 민사소송 또는 공법상 당사자소송으로 다룰 수 있다.

(3) 원상회복에 대한 공법상 결과제거청구권

사업시행자가 사용기간이 만료되었음에도 원상회복 및 반환하지 않을 때에는 공법상 결과제거청구권 행사가 가능하다.

03 시급한 토지사용에 대한 허가

1) 의의

공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우 재결신청을 받은 토지수용위원회의 허가로서 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(제39조).

2) 요건

- ① 보통절차에 의해 재결신청 중에 있는 공익사업이어야 한다.
- ② 토지수용위원회의 재결이 지연되고 있는 경우여야 한다.
- ③ 재결이 지연됨으로 인하여 재해를 방지하기 곤란하거나, 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되어야 한다.
- ④ 사업시행자의 신청을 전제한다.
- ⑤ 사업시행자가 국가나 지방자치단체인 경우를 제외하고 담보를 제공하여야 한다.
- ⑥ 사용기간은 6개월을 넘지 못한다(제39조 제2항). 이 기간을 초과하여 사용하려면 공용수용이 보통절차를 거쳐야 한다.

3) 절차

토지수용위원회가 허가한 때에는 토지소유자 및 점유자에게 통지하여야 한다. 담보의 제공은 토지수용위원회가 상당하다고 인정하는 금전 또는 유가증권을 공탁함으로써 행한다(령 제19조 제1항).

4) 효과

사업시행자는 사용권을 취득하고, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조)를 지며, 대행(제44조)·대집행(제89조) 신청권을 갖는다. 토지소유자는 토지인도의무와 손실보상청구권을 갖는다. 토지소유자나 관계인은 사업시행자가 재결의 보상금의 지급시기까지 보상금을 지급하지 아니하면 제공된 담보의 전부 또는 일부를 취득한다(제41조 제2항).

5) 권리구제

(1) 위법한 허가에 대한 행정쟁송 및 손해배상

위법한 허가에 대하여 행정쟁송으로 다룰 수 있고, 손해배상 요건 충족 시 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 적법한 허가에 대한 손실보상

토지수용위원회의 재결이 있기 전에 토지소유자나 관계인이 청구할 때에는 사업시행자는 자기가 산정한 보상금을 토지소유자나 관계인에게 지급하여야 한다(제41조 제1항). 이 손실보상은 사후보상으로서 사전보상원칙의 예외에 해당한다.

(3) 원상회복에 대한 공법상 결과제거청구권

사업시행자가 사용기간이 만료되었음에도 원상회복 및 반환하지 않을 때에는 공법상 결과제거청구권 행사가 가능하다.

협약에 의한 취득의 절차는 토지·물건조서의 작성(제14조), 보상계획의 공고·열람 등(제15조), 보상액의 산정(제68조), 협의(제16조), 보상계약의 체결(제17조) 단계로 이루어져 있다.

제1절 토지조서 및 물건조서의 작성

01 조사·조서작성의 의의 및 취지

토지조서 및 물건조서란 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지와 그 토지상의 물건내용을 사업시행자가 일정한 절차를 거쳐 작성하는 문서이다. 조사·작성은 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지 및 물건내용을 확정하고 문서로 작성하는 행위이다. 취득 또는 사용절차 개시 전 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 토지나 물건에 대하여 필요한 사항을 확인하게 하여 당사자 간 분쟁 소지를 미리 예방하고, 공익사업을 신속하게 진행하고, 수용의 경우 수용위원회의 원활한 심리와 신속한 재결을 도모하기 위함에 취지가 있다.

02 협의취득을 위한 조서의 작성

1) 조서의 작성 절차

(1) 서명 또는 날인하는 경우

사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하여 서명 또는 날인을 하고 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다(제14조 제1항). 토지조서 및 물건조서의 작성 시기에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않으나, 조서가 토지 등의 취득 또는 사용의 기초가 된다는 점을 고려할 때 협의하기 전까지 작성하여야 할 것이다.

(2) 서명 또는 날인을 거부하는 경우 등

- ① 토지소유자 및 관계인이 정당한 사유 없이 서명 또는 날인을 거부하는 경우 또는
- ② 토지소유자 및 관계인을 알 수 없거나 그 주소·거소를 알 수 없는 등의 사유로 서명 또는 날인을 받을 수 없는 경우에는 사업시행자는 해당 토지조서와 물건조서에 그 사유를 적어야 한다(제14조 제1항 단서). 이와 같이 서명의 거부 또는 불가능시 그 사유를 해당 조서에 기재하도록 함으로써 최종적으로 수용재결에서 다룰 수 있도록 하고 있다.

2) 조서의 작성 방법 및 내용

사업시행자는 공익사업의 계획이 확정된 때에는 지적도 또는 임야도에 대상물건인 토지를 표시한 용지도를 작성하여야 하고(령 제7조 제1항), 작성된 용지도를 기본으로 하여 토지조서 및 물건조서를 작성하여야 한다(령 제7조 제2항). 토지조서 및 물건조서에 포함될 내용은 시행령 제7조 제3항 및 제4항의 내용과 같다. 조서의 내용은 취득 또는 사용의 근거가 될 뿐만 아니라 토지수용위원회의 심리에 필요하기 때문에 구체적으로 규정하고 있다.

01 보상계획의 공고

사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 공익사업의 개요, 토지조서 및 물건조서의 내용과 보상의 시기·방법 및 절차 등이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 각각 통지하여야 하며, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 통지하여야 한다. 다만, 토지소유자와 관계인이 20인 이하인 경우에는 공고를 생략할 수 있다(제15조 제1항).

02 보상계획의 열람

사업시행자는 공고나 통지를 하였을 때에는 그 내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 사업지역이 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있거나 사업시행자가 행정청이 아닌 경우에는 해당 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 그 사본을 송부하여 열람을 의뢰하여야 한다(제15조 제2항).

03 보상계획에 대한 이의신청

공고·통지된 토지조서 및 물건조서의 내용에 대하여 이의가 있는 토지소유자 또는 관계인은 열람기간 이내에 사업시행자에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다. 다만, 사업시행자가 고의 또는 과실로 토지소유자 또는 관계인에게 보상계획을 통지하지 아니한 경우 해당 토지소유자 또는 관계인은 제16조에 따른 협의가 완료되기 전까지 서면으로 이의를 제기할 수 있다(제15조 제3항). 사업시행자는 해당 토지조서 및 물건조서에 제기된 이의를 부기하고 그 이의가 이유 있다고 인정할 때에는 적절한 조치를 하여야 한다(제15조 제4항).

01 감정평가법인등의 선정

사업시행자는 보상액을 산정하려는 경우 감정평가법인등 3인(시·도지사 및 토지소유자가 모두 감정평가법인등을 추천하지 아니하거나 시·도지사 또는 토지소유자 어느 한쪽이 감정평가법인등을 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. 다만, 사업시행자가 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 직접 보상액을 산정할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다(제68조 제1항). 사업시행자가 감정평가법인등을 선정할 때 해당 토지를 관할하는 시·도지사 및 토지소유자는 감정평가법인등을 각 1인씩 추천할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 추천된 감정평가법인등을 포함하여 선정하여야 한다(제68조 제2항).

02 보상평가의 의뢰 및 평가 등

사업시행자는 평가를 의뢰하고자 하는 때에는 보상평가의뢰서에 대상물건의 표시, 대상물건의 가격시점, 평가서 제출기한, 대상물건의 취득 또는 사용의 구분, 건축물등 물건에 대하여는 그 이전 또는 취득의 구분, 영업손실을 보상하는 경우에는 그 폐지 또는 휴업의 구분, 보상액 평가를 위한 사전 의견수렴에 관한 사항, 그 밖의 평가조건 및 참고사항을 기재하여 감정평가법인등에게 평가를 의뢰하여야 한다(칙 제16조).

03 재평가의 의뢰

1) 당해 감정평가법인등에게 재의뢰

사업시행자는 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 관계법령에 위반하여 평가되었거나 합리적 근거 없이 비교 대상이 되는 표준지의 공시지와 현저하게 차이가 나는 등 부당하게 평가되었다고 인정하는 경우에는 당해 감정평가법인등에게 그 사유를 명시하여 다시 평가할 것을 요구하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 필요하면 국토교통부장관이 보상평가에 관한 전문성이 있는 것으로 인정하여 고시하는 기관에 해당 평가가 위법 또는 부당하게 이루어졌는지에 대한 검토를 의뢰할 수 있다(칙 제17조 제1항).

2) 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 의뢰

- ① 사업시행자는 보상평가가 관계 법령에 위반 또는 부당하게 평가되었다고 인정될 때 당해 감정평가법인등에게 평가를 요구할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우,
- ② 대상물건의 평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 110퍼센트를 초과하는 경우(대상물건이 지장물인 경우 최고평가액과 최저평가액의 비교는 소유자별로 지장물 전체 평가액의 합계액을 기준으로 한다),
- ③ 평가를 한 후 1년이 경과할 때까지 보상계약이 체결되지 아니한 경우 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 평가를 재의뢰하여야 한다(칙 제17조 제2항).

01 협의

1) 의의 및 취지

협이란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다(제16조). 협의에 의한 토지 등의 사용이라 함은 공익사업에 필요한 토지 등을 협의에 의하여 사용 또는 제한하는 것을 말한다. 협의는 수용에 의한 강제적 취득 전에 최소침해 원칙을 실현하는 제도적 취지가 있다.

2) 법적 성질

(1) 논의의 배경 및 논의의 실익

- ① <논의의 배경> 종래 「공특법」상 협의취득은 사경제 주체로서 행하는 사법상 매매행위에 지나지 않기 때문에 그 법적 성질이 사법상 계약이라는 것에 의문의 여지가 없었다. 「공특법」과 「토지수용법」을 통합하여 「토지보상법」을 제정하면서 협의절차를 이원화함에 따라 협의의 법적 성질이 문제된다.

공익사업용지 취득과 보상에 관한 기본법인 토지보상법에 협의취득을 규정하고, 토지보상법이 사업인정 전에 사업시행자가 토지 등에 대한 보상에 관하여 토지소유자 및 관계인과 성실하게 협의하여야 한다는 규정을 두고 있는 점 등에 비추어 사업인정 전 협의를 사법상 계약으로 보는 데에 의문이 제기될 수 있다.

- ② <논의의 실익> 적용 법규, 쟁송형태 등에 논의의 실익이 있다.

(2) 학설

- ① <사법상 계약설> 사업인정 전 협의는 사경제 주체로서의 쌍방 합의에 의한 사법상 매매행위라고 한다.
 ② <공법상 계약설> 사업인정 후 협의와 실질적 기능면에서 동일한 제도이므로 공법상 계약으로 본다.

(3) 판례

대법원은 구「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법」에 의한 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로서, 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상의 요건을 완화하는 약정을 할 수 있고, 그와 같은 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상 기준에 의하지 아니한 매매대금을 정할 수 있다고 판시하였다(대판 2000. 9. 8. 99다26924).

(4) 검토

입법의 형식이나 법문(法文)에 비추어 보면 사업인정 전 협의가 공법상 계약의 성질을 갖는 것으로 해석할 여지도 있다. 그러나 협의가 토지소유자의 의사에 의해 좌우되고, 협력을 바탕으로 하기 때문에 그 실질에 있어서 사법상 계약에 불과하다. 또한 토지보상법이 비록 성신탁의를 규정하고 있다 하더라도 이는 공익사업의 원활화를 위해 사업시행자에게 의무를 부여한 것에 불과하다.

3) 내용, 절차 및 방법 등

(1) 내용

토지 등의 구체적 대상, 범위, 보상의 시기·방법·절차 및 금액 등이 협의의 내용이 되고(령 제8조 제1항 참조), 계약의 내용에는 계약의 해지 또는 변경에 관한 사항과 이에 따르는 보상액의 환수 및 원상복구 등에 관한 사항이 포함되어야 한다(령 제8조 제4항).

(2) 절차 및 방법

사업시행자는 보상협의요청서를 토지소유자 및 관계인에게 통지하여야 하고, 통지할 수 없을 때에는 공고로 갈음할 수 있다. 협의의 기간은 특별한 사유가 없으면 30일 이상으로 하여야 한다.

부산지법 2008.11.13. 2007가단145338

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률이 사업시행자로 하여금 관계인과 협의하거나 그 협의를 위한 통지를 하도록 규정한 취지는 비자발적으로 담보권을 상실하게 될 저당권자 등의 관계인으로 하여금 당해 협의절차에 참여하여 자신의 권리를 스스로 행사할 수 있는 기회를 부여함으로써 그와 같은 토지수용으로 인하여 불측의 손해를 입지 아니하도록 예방할 뿐만 아니라, 협이가 성립하지 아니하여 수용재결로 나아가는 경우 물상대위권을 행사할 수 있는 기회를 제공함으로써 법률상 당연히 인정되는 물상대위권 행사의 실효성을 보장하기 위한 것이다.

4) 효과

(1) 협의 성립 시 효과

협의를 내용에 따른 **사법상 계약의 효과**가 발생한다. 사업시행자는 공익사업에 제공될 토지 등의 권리를 취득하며, 이 때 권리 취득은 **승계취득**이 된다. 사업시행자는 보상금을 지급하였을 때 소유권의 이전등기를 하게 된다. 토지소유자 및 관계인 **손실보상청구권**을 취득한다. 보상액은 토지보상법이 정하는 바에 따라 산정한 보상금이다. 토지소유자는 **환매권 행사요건 충족 시 환매권**을 행사할 수 있다. 공익사업 변환은 제91조 제6항의 문언 상 사업인정 이후 협의취득하거나 수용한 경우에 인정될 수 있으므로, 적용되기 어렵다고 본다.

(2) 협의 불성립 시 효과

협의 불성립 시 사업시행자는 협의경위서를 작성하여 토지소유자 및 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다. 정당한 사유 없이 서명 또는 날인을 거부하거나, 서명 또는 날인을 받을 수 없는 경우에는 받지 아니하되, 그 사유를 기재하여야 한다. 사업시행자는 공익사업의 진행을 위해 국토교통부장관에게 사업인정을 신청할 수 있다.

5) 사업인정 후 협의와의 차이점

(1) 임의적 절차인지 필수적 절차인지 여부

사업인정 전 협의는 **임의적 절차**이나, 사업인정 후 협의는 **필수적 절차**이다. 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성실협의를무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다. 단지 절차의 중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있을 따름이다.

(2) 사업인정을 기준으로 한 전·후의 절차

사업인정 전 협의는 아직 공익사업이 공적으로 승인되기 전에 임의적 협력을 바탕으로 이루어지는 반면, 사업인정 후 협의는 사업의 공공성이 인정되고 재결에 의한 강제절차에 들어가기 전에 상대방의 협력을 구하기 위한 제도이다. 사업인정 전 협의에서는 관할 토지수용위원회로부터 **협의성립 확인**을 받을 수 없으나, 사업인정 후 협의에서는 받을 수 있다.

(3) 법적 성질의 차이

사업인정 전 협의는 사법상 계약이나, 사업인정 후 협의는 공법상 계약에 해당한다는 점(견해대립에 관하여 '사업인정 후 협의' 부분에서 후술함)에서 서로 다르다. 사업인정 후 협의는 사업인정고시 후 행해지는 절차의 하나이고, 공익이라는 공법적 효과의 발생을 목적으로 하기 때문에 공법상 계약으로 보는 것이 타당하다.

6) 협의 관련 판례 정리

대법원 93누18594

토지소유자의 등기부상 주소와 실제 주소가 다른 사실을 알지 못하여 등기부상 주소로 보상협약에 관한 통지하여 보상협의절차를 거치지 못하였다 하더라도 그러한 사유만으로는 수용재결이 당연무효이거나 부존재하는 것으로 볼 수 없다.

대법원 91누3871

도시계획사업의 시행자가 그 사업에 필요한 토지를 협의취득 하는 행위는 사경제주체로서 행하는 사법상의 법률행위에 지나지 않으며 공권력의 주체로서 우월한 지위에서 행하는 공법상의 행정처분이 아니므로 행정소송의 대상이 되지 않는다.

대법원 96다3319

사업인정 전/후 협의를 모두 사법상 계약으로 봄

대법원 2016두64241

판례는 수용재결 이후라도, 협의를 할 수 있다고 봄

대법원 96다3319

손실보상 요건을 완화하는 계약 가능함

대법원 2009다35842

기업자가 수용할 토지의 저당권자에게 협의나 통지를 하지 아니하였다면 위법하다. 저당권자로 하여금 적법한 물상대위권을 행사할 수 있는 기회를 상실하게 하였다면 수용재결의 무효원인사실을 알리지 않은 일련의 행위와 저당권자의 물상대위권 행사 기회의 상실 사이에는 상당인과관계가 있어 기업자의 불법행위책임이 성립할 수 있다.

대법원 2012다3517

- 토지보상법 기준에 의하지 않은 손실보상금 정할 수 있음
- 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 보상협약은 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로서, 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상의 기준에 의하지 아니한 손실보상금을 정할 수 있으며, 이와 같이 같은 법이 정하는 기준에 따르지 아니하고 손실보상액에 관한 합의를 하였다고 하더라도 그 합의가 착오 등을 이유로 적법하게 취소되지 않는 한 유효하다. 따라서 공익사업법에 의한

보상을 하면서 손실보상금에 관한 당사자 간의 합의가 성립하면 그 합의 내용대로 구속력이 있고, 손실보상금에 관한 합의 내용이 공익사업법에서 정하는 손실보상 기준에 맞지 않는다고 하더라도 합의가 적법하게 취소되는 등의 특별한 사정이 없는 한 추가로 공익사업법상 기준에 따른 손실보상금 청구를 할 수는 없다.

대법원2010다91206

- 협의시 매매대금 과부족금 지급의무 약정할 수 있고, 계약해석 시 공익적 특성을 고려해야 함
- 공익사업법은 공익사업의 효율적인 수행을 통하여 공공복리의 증진과 재산권의 적절한 보호를 도모하는 것을 목적으로 하고 협의취득의 배후에는 수용에 의한 강제취득 방법이 남아 있어 토지 등의 소유자로서는 합의에 불응하면 바로 수용을 당하게 된다는 심리적 강박감이 자리 잡을 수밖에 없으며 협의취득 과정에는 여러 가지 공법적 규제가 있는 등 공익적 특성을 고려하여야 한다.
- 개발제한구역 해제된 것으로 보고 감정평가해야 하는데, 해제되지 않은 상태를 기준한 감정평가를 하였고, 이 금액으로 협의하였음. 이후 토지소유자가 과부족금을 청구하였는데, 법원은 협의감정평가가 고의, 과실 착오평가라 하여 과부족금 지급의무 인정
- 위 판례는 “토지보상법 기준에 의하지 않은 손실보상금을 정할 수 없다”는 뜻이 아님

2011다104253 판결

- 나지상정평가를 하여야 하는데, 철탑 및 고압송전선의 제한을 받는 상태로 평가를 하였고, 이 금액으로 협의하였음, 이후 토지소유자가 과부족금을 청구하였는데, 법원은 협의감정평가가 고의, 과실 착오평가라 하여 과부족금 지급의무 인정
- 위 판례는 “토지보상법 기준에 의하지 않은 손실보상금을 정할 수 없다”는 뜻이 아님.

02 계약체결

사업시행자는 합의가 성립된 때에는 토지소유자 및 관계인과 **계약을 체결하여야 한다**(제17조).

제1절

사업인정 [★★]

01 의미 및 취지, 근거

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다(제2조 제7호).

사업인정은 당해 사업이 토지보상법 제4조에 해당함을 인정하고, 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 행위이다(제20조).

사업인정은 당해 사업이 공공성이 있는가를 개별·구체적으로 판단하여 피수용자의 권리를 보호하고, 이에 의해 수용 가능여부가 결정되는 수용절차의 제1단계로서, 수용행정의 적정화, 사전적 권리구제장치로서의 역할을 한다.

02 법적성질

1) 강학상 행정행위 및 행정쟁송법상 처분

사업인정은 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 외부에 대하여 직접적 법적 효과를 발생시키는 권력적 행위인 공법행위이다(대판 1995. 12. 5. 95누4889, 대판 1994. 11. 11. 93누19375). 사업인정이 있으면 수용할 목적물의 범위가 확정되고, 사업시행자는 수용권을 부여 받아 당해 사업에 필요한 토지·물건 등을 소유자의 의사에 불구하고 취득하는 등 사업시행자와 토지소유자 등에게 일정한 구체적 법적 효과가 발생하므로, 강학상 행정행위이자, 행정쟁송법상 처분이다.

2) 설권적 형성행위 여부

(1) 학설

수용권의 주체에 관한 학설의 입장에 따라 사업인정의 법적 성질을 달리 본다

- ① <설권적 형성행위설>은 사업시행자수용권설에 의거하여, 사업인정은 당해 사업의 공익성, 사업 신청자의 사업시행자로서의 적정성 및 당해 토지의 공공 필요성 등을 종합적으로 판단하여 사업시행자에게 토지를 수용할 수 있는 공익사업자의 법적 지위를 설정하여 주는 행위라 한다.
- ② <확인행위설>은 수용을 행하는 것은 국가이므로 수용권의 설정은 생각할 필요가 없다는 국가수용권설의 입장에 의거하여, 사업인정이란 특정한 사업이 토지를 수용할 수 있는 사업에 해당하는 것을 확인하고 선언하는 행위라고 한다.

(2) 판례

- ① 토지수용을 위한 사업인정은 단순한 확인행위가 아니라 형성행위이고 당해 사업이 비록 토지를 수용할 수 있는 사업에 해당된다 하더라도 행정청으로서는 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 것이므로 사업인정의 여부는 행정청의 재량에 속한다(대판 1992. 11. 13. 92누596).

- ② 사업인정처분이라 함은 공익사업을 토지 등을 수용 또는 사용할 사업으로 결정하는 것으로서, 단순한 확인행위가 아니라 형성행위이므로, 당해 사업이 외형상 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업에 해당된다 하더라도 행정주체로서는 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부와 공익성이 있는 경우에도 그 사업의 내용과 방법에 대하여 사업인정처분에 관련된 자들의 이익을 공익과 사익 간에서는 물론, 공익 상호간 및 사익 상호간에도 정당하게 비교·교량하여야 하고, 그 비교·교량은 비례의 원칙에 적합하도록 하여야 한다(대판 2005. 4. 29. 2004두14670).

(3) 소결

사업인정권자는 특정 사업이 토지보상법 제4조에 열거하고 있는 공익사업이라 하더라도 당해 사업이 토지를 수용 또는 사용할 수 있는 공공성을 갖는가, 그 토지가 적정하고 합리적인 이용에 기여하는가 등을 판단한 다음 구체적으로 사업시행자·사업시행지 및 사업계획을 확정하고 사업시행자에게 토지를 수용할 권리를 부여하기 위한 결정을 하게 된다. 이와 같이 사업인정은 사업시행자에게 수용권을 설정해 주는 행정행위이기 때문에 설권적 형성행위로 보는 것이 타당하다.

3) 재량행위 여부

- ① <설권적 형성행위설>은 사업인정이 사업시행자에게 일정한 내용의 수용권을 부여하는 행위이므로 재량행위라고 한다. 한편 <확인행위설>은 사업인정이 단순히 특정 사업이 법률에서 정하는 일정한 요건을 갖추고 있는지 여부를 판단하는 기속행위에 불과한 것으로 보고 있다.
- ② <대법원> 역시 사업인정은 단순한 확인행위가 아니라 형성행위이고, 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 것이므로 사업인정의 여부는 행정청의 재량에 속한다고 하였다(대판 1992. 11. 13. 92누596).
- ③ 1차적으로 법문언에 따를 때, 토지보상법 제20조는 “사업시행자는 ~ 사업인정을 받아야 한다.”라고 되어 있어 판단이 애매하나, 토지보상법의 입법 목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때, 재량행위로 봄이 타당하다.

4) 제3자효 행정행위

사업시행자에게는 수익적 처분으로서 수익적 처분과 관련된 논의를 함에 논의의 실익이 있고, 피수용자는 제3자로서 제3자의 원고적격과 관련하여 논의의 실익이 있다.

사업인정은 사업시행자에게 수용권을 설정하는 수익적 효과를 지니고, 피수용자에게는 재산권을 침해하는 침익적 효과를 발생시킨다. 수익적 효과와 침익적 효과를 각기 다른 이에게 귀속시키는 제3자효적 행정행위이다.

1) 성립요건

(1) 주체

사업시행자는 토지 등을 수용하거나 사용하려면 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다(제20조 제1항). 개별 법률상 사업인정을 의제하는 경우에는 주무부장관이나 시·도지사 등이 사업인정의 권한을 갖는다.

(2) 내용

- ① 공익사업이 토지보상법 제4조의 각 호 중 하나에 해당하여야 한다.
- ② 해당 사업이 공용수용을 할 만한 공공성 내지 공공필요가 존재하여야 하고, 이는 당해 사업으로 얻어지는 공익과 이로 인해 침해되는 사익을 비례의 원칙에 따라 비교·교량해서 판단해야 한다.
- ③ 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다.

대법원 2011. 1. 27. 선고 2009두1051 판결 [토지수용재결처분취소]

- [1] 사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용 또는 사용할 사업으로 결정하는 것으로서 공익사업의 시행자에게 그 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 일정한 내용의 수용권을 설정하여 주는 형성행위이므로, 해당 사업이 외형상 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업에 해당한다고 하더라도 사업인정기관으로서 그 사업이 공용수용을 할 만한 공공성이 있는지의 여부와 공공성이 있는 경우에도 그 사업의 내용과 방법에 관하여 사업인정에 관련된 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론, 공익 상호간 및 사익 상호간에도 정당하게 비교·교량하여야 하고, 그 비교·교량은 비례의 원칙에 적합하도록 하여야 한다. 그뿐만 아니라 해당 공익사업을 수행하여 공익을 실현할 의사나 능력이 없는 자에게 타인의 재산권을 공권력적·강제적으로 박탈할 수 있는 수용권을 설정하여 줄 수는 없으므로, 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다는 것도 사업인정의 한 요건이라고 보아야 한다.
- [2] 공용수용은 헌법상의 재산권 보장의 요청상 불가피한 최소한에 그쳐야 한다는 헌법 제23조의 근본취지에 비추어 볼 때, 사업시행자가 사업인정을 받은 후 그 사업이 공용수용을 할 만한 공공성을 상실하거나 사업인정에 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 사업시행자가 해당 공익사업을 수행할 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 공익 목적에 반하는 수용권의 남용에 해당하여 허용되지 않는다.

(3) 절차

a. 국토부장관의 사업인정 (제21조 제1항)

사업인정을 받으려는 자는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 사업인정신청서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 국토교통부장관이 사업인정을 하려면 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 및 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 미리 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다. 중앙토지수용위원회는 협의를 요청받은 경우 사업인정에 이해관계가 있는 자에 대한 의견 수렴 절차 이행 여부, 허가·인가·승인대상 사업의 공공성, 수용의 필요성 등을 검토하여 협의를 요청받은 날부터 30일 이내에 의견을 제출하여야 하고, 같은 기간 이내에 의견제출을 아니하는 경우 협의가 완료된 것으로 본다. 사업인정에서 협의 및 의견청취 절차는 사전적 권리구제와 공공성 확보 기능을 한다. 그 밖의 절차는 행정절차법을 따른다.

b. 사업인정 의제 (제21조 제2항)

별표에 규정된 법률에 따라 사업인정이 있는 것으로 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등은 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하려는 경우 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다. 중앙토지수용위원회의 협의 내용은 위와 동일하다. 사업인정에서 협의 및 의견청취 절차는 사전적 권리구제와 공공성 확보 기능을 한다. 그 밖의 절차는 행정절차법을 따른다.

심화

중앙토지수용위원회의 역할

1. 개요

토지수용 공익성 검증을 강화하는 시대적 요구에 따라 토지보상법은 입법단계와 사업시행단계에서 중앙토지수용위원회(이하 '중토위')의 역할을 규정하였다.

2. 입법단계에서의 역할 (심의제도)

토지보상법 제4조의 3에 따라 토지수용사업 신설 등에 관한 입법을 할 때, 중토위의 심의를 거쳐야 하고 중토위는 관계부처에 개선요구 및 의견을 제시할 수 있으며, 관계부처는 개선요구사항을 반영하여야 하며, 중토위는 개선요구사항을 반영했는지를 조회할 수 있다(시행령 2조).

3. 사업시행단계에서의 역할

국토부장관 또는 사업의 인허가권자 등은 사업인정을 하기 위해서 중토위와의 협의를 거쳐야 한다. 사업시행자가 수용재결신청시 중토위 협의결과 및 의견서를 첨부하여야 한다(시행령 제12조 제1항).

4. 중토위의 공익성 검토 기준 및 보완요청

중토위는 해당 공익사업의 공공성, 수용의 필요성, 입법목적의 부합성, 사업시행자의 사업능력 등을 기준하여 공익성을 검토하며(21조 시행령 11조의2), 보완할 필요가 있는 경우 보완을 요청할 수 있다.

(4) 형식

토지보상법상 특별한 규정이 없으므로, 사업인정처분은 행정절차법 제24조에 따라 문서로 하여야 한다.

2) 효력발생요건

(1) 사업인정의 고시

사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구에게나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다. 국토교통부장관은 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다(제22조 제1항). 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사를 제외함)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다(제22조 제2항). 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생한다(제22조 제3항). 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

(2) 토지세목고시 누락이 사업인정처분의 절차하자인지

토지세목(土地細目)의 고시는 사업인정에 의해 지정된 범위 내에서 구체적으로 수용할 수 있는 목적물을 임시로 결정하는 행위이며, 이로써 목적물에 대한 막연한 효력밖에 없었던 사업인정이 현실화되고 구체화된다.

토지세목고시를 누락한 것은 절차상 위법으로서 사업인정의 취소사유가 된다(대판 1988. 12. 27. 87누1141).

04 효과 (사업인정고시의 효과)

1) 토지수용권의 발생

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2) 수용목적물의 확정

사업인정이 고시되면 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다. 사업시행자는 수용 또는 사용할 토지의 위치와 예정 면적의 범위가 정해지면 그 범위 내에서 공익사업의 시행에 따른 권리를 행사할 수 있고 현재 또는 장래의 권리자에게 대항할 수 있다(대판 1987. 9. 8. 87누395).

3) 관계인의 범위 제한

사업인정 고시가 있는 후 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호). 사업인정고시가 있는 후 새로이 권리를 취득한 자는 관계인으로 인정되지 않기 때문에 보상금을 받을 수 없다. 관계인의 범위를 한정하는 것은 수용절차에 참여하는 자를 제한함으로써 절차를 간소하게 하는 데 이바지한다.

4) 토지 등의 보전 의무

사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 제3조에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다(제25조 제1항). 사업인정고시가 된 후에 고시된 토지에 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가(附加)·증치(增置)를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행자의 의견을 들어야 한다(제25조 제2항). 이 규정을 위반하여 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가·증치를 한 토지소유자 또는 관계인은 해당 건축물·공작물 또는 물건을 원상으로 회복하여야 하며 이에 관한 손실의 보상을 청구할 수 없다(제25조 제3항).

5) 토지·물건조사권의 발생

사업인정고시 후 사업시행자 또는 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 조서작성이나 감정평가를 위하여 필요한 경우 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다. 이 경우 출입의 통지(제10조), 토지점유자의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대 규정(제13조) 규정을 준용한다(제27조 제1항).

05 권리구제

1) 개설

사업인정은 재산권자에게는 침익적 행정행위인 바, 국민의 권리구제가 문제된다.

권리구제는 사전적 권리구제와 사후적 권리구제로 나눌 수 있다.

사후적 권리구제로서 행정쟁송에 관하여 토지보상법은 아무런 규정을 두지 않은 바,

행정심판법 제3조 제1항 및 행정소송법 제8조 제1항에 따라 행정심판법 및 행정소송법이 정하는 바에 의한다.

2) 사전적 권리구제

사전적 권리구제 제도로서, 협의 및 의견청취절차(제21조) 규정이 있다.

재산권의 침해 받는 국민은 예방적 금지소송과 가처분을 권리구제수단으로 취할 수 있으나,

현행법상 인정되기 어려울 것이다.

3) 사후적 권리구제로서 행정쟁송

① <항고심판> 위법·부당한 사업인정에 대하여 청구인 적격이 있는 자(행정심판법 제13조)는,

피청구인 적격이 있는(행정심판법 제17조) 국토교통부장관을 상대로, 청구기간 내에(행정심판법 제27조),

기타 심판청구의 요건을 갖추어 항고심판을 제기하여 권리구제를 받을 수 있다.

② <항고소송> 위법한 사업인정에 대하여 원고적격(행정소송법 제12조)이 있는 자는,

피고적격이 있는(행정소송법 제13조) 국토교통부장관을 상대로, 제소기간 내에(행정소송법 제20조),

기타 소송요건(재판관할, 협의 소의, 행정심판 임의주의 등)을 갖추어 항고소송을 제기하여 권리구제를 받을 수 있다.

01 개설

공익사업에 대하여 원칙적으로 사업인정절차가 요구되지만, 개별 법률상 공익사업은 사업지구 지정 또는 실시계획 인가를 사업인정에 갈음하도록 규정하고 있다. 사업인정 의제제도는 재산권 침해가능성 등 문제가 있으므로, 이하 사업인정 의제제도의 문제점과 개선방안을 논한다.

02 의의 및 근거, 유용성

사업인정 의제제도는 개별 법률상의 실시계획인가 등을 토지보상법상 사업인정으로 갈음하는 제도로써, 개별 법률에 근거가 있는 경우에만 인정된다. 절차 간소화 및 행정경제 기여에 유용성이 있다.

03 사업인정 의제제도의 문제점

1) 사업인정주체의 정당성 문제

사업인정권이 없는 행정청이 사업인정을 함으로써, 수용권 남발 및 수용권 주체 정당성 문제가 제기된다.

2) 재결신청기간 장기화

많은 사업인정 의제의 경우, 개별 법률에서 재결신청기간 특례규정이 있어, 재결신청기간 장기화로 피수용자의 재산권행사에 큰 제한을 받게 되는 문제점이 있다.

3) 정당보상의 문제

개별 법률에 따라 사업시행자가 자의적으로 재결신청을 늦출 경우, 몇 년 전 사업인정을 기준으로 공시지가 선정 및 보상액 평가가 되어, 정당보상 문제가 발생할 수 있다.

04 사업인정 의제제도의 개선방안

1) 단기적 개선방안 (사전적 권리구제 강화)

공익사업의 홍보를 통한 지역주민의 참가와 이로 인한 사전적 권리구제의 가능성을 높일 필요가 있다.

2) 장기적 개선방안 (사업인정의제 제도 최소화)

사업인정의제 제도를 최소한으로 제한할 필요가 있으며, 나아가 토지보상법 규정에 의한 사업인정 내지 표준적인 절차로 일원화, 재결신청기간의 제한, 사업인정 의제시 통지의무를 부과하는 방법 등의 입법적 개선이 필요하다.

05 결론

사업인정 의제제도는 절차 간소화, 행정경제 기여 등의 유용성이 있으나, 사업인정주체의 정당성 문제, 사업기간의 장기화 등의 문제가 있으므로, 향후 이러한 문제를 해결하기 위해서는 사업의 계획과정에 지역 주민의 참여가 적극적으로 이루어져 사전적 권리구제가 이뤄질 수 있도록 하여야 할 것이고, 점차적으로 문제점을 해결하기 위한 입법적 보완이 필요하다.

01 사업인정의 효력상실

1) 개설

사업인정 고시 후 협의가 성립하거나 수용재결이 발령되거나, 화해가 있는 등 사업시행자가 사업에 필요한 토지 등을 취득하게 되면 사업인정의 효력은 당연히 소멸한다. 다만, 토지보상법상 다음과 같은 사유로 사업인정의 효력은 상실된다.

심화

구분	재결신청기간 경과 실효	사업의 폐지, 변경 실효
근거	23조	24조
절차	사업인정고시일부터 1년 되는 날 다음 날 실효	사업시행자의 신고, 통지 → 시도지사의 고시, 국토교통부장관에게 보고
법적성질	조건 성취로 인한 실효	강학상 철회와 유사 (단, 시도지사가 실효 고시)
공통점	◎ 취지 : 공공성 계속적 담보 및 피수용자 보호 ◎ 손실 발생시 손실보상청구 가능 (9조 5~7항, 24조 6,7항)	

2) 재결신청기간의 경과로 인한 실효

(1) 의의 및 취지

실효란 객관적 사실발생에 의하여 행정행위의 효력이 상실하는 것을 의미한다. 사업인정의 실효제도는 공공성의 계속적 담보를 통해 피수용자의 보호 및 법적안정성을 위한 제도이다.

(2) 실효의 사유 및 실효 시기

사업시행자가 사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 재결신청(제28조)을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다(제23조 제1항).

(3) 실효의 효과

사업시행자는 사업인정이 실효됨으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다(제23조 제2항). 이 규정에 따른 손실보상에 관하여는 손실보상의 청구(제9조 제5항), 협의결정(제9조 제6항), 재결신청(제9조 제7항) 규정을 준용한다(제27조 제4항).

재결신청 기간 경과로 인한 피수용자의 금전적 손해는 사업시행자의 토지보상법 위반에 따른 위법한 행정작용에 기인한 것이다. 그러나 피수용자의 입장에서 국가배상 청구요건을 입증하여야 하는 어려움에 대한 현실적인 문제를 손실보상규정을 마련함으로써 입법적으로 해결한 것으로, 이 손실보상규정은 손해배상의 성격을 지닌다.

(4) 관련 문제

개별법은 재결신청기간을 토지보상법과 달리 당해 사업시행기간 내로 하는 특례를 규정하고 있어 재결신청의 해태로 인한 사업인정 실효 규정이 적용될 여지가 없어 제도 취지를 무의미하게 할 우려가 있다.

3) 사업의 폐지 및 변경으로 인한 실효

(1) 의의 및 취지

사업인정고시 후 공익사업의 폐지 또는 변경 등으로 인하여 토지를 수용하거나 사용할 필요가 없게 된 경우, 시·도지사가 사업시행자의 신고 또는 직권으로 이를 고시하여 사업인정을 실효시키는 제도이다(제24조).

(2) 내용

사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지 등의 전부 또는 일부를 수용하거나 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 사업시행자는 지체 없이 사업지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하고, 토지소유자 및 관계인에게 이를 통지하여야 한다(제24조 제1항). 시·도지사는 이 규정에 따른 신고를 받으면 사업의 전부 또는 일부가 폐지되거나 변경된 내용을 관보에 고시하여야 한다(제24조 제2항). 시·도지사는 신고가 없는 경우에도 사업시행자가 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지를 수용하거나 사용할 필요가 없게 된 것을 알았을 때에는 미리 사업시행자의 의견을 듣고 고시를 하여야 한다(제24조 제3항).

(3) 실효 시기 및 고시의 법적성질

사업의 전부 또는 일부의 폐지나 변경의 고시가 된 날부터 그 고시된 내용에 따라 사업의 전부 또는 일부는 그 효력을 상실한다(제24조 제6항). 사업인정의 폐지 변경에 관한 고시는 행정행위의 효력을 상실시키기 위한 새로운 행정행위로서 강학상 철회의 성격을 가지며, 이 경우 소급효(遡及效)는 인정되지 않는다.

(4) 실효의 효과

- ① 사업시행자는 사업의 전부 또는 일부를 폐지 변경함으로 인하여 토지소유자 또는 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다(제24조 제7항). 사업의 폐지 변경의 경우 피수용자가 입은 손실을 보상하게 하는 것은 공익사업에 대한 신뢰보호 및 피해구제를 위한 것이다. 이 규정에 따른 손실보상에 관하여는 손실보상의 청구(제9조 제5항), 협의결정(제9조 제6항), 재결신청(제9조 제7항) 규정을 준용한다(제24조 제7항).
- ② 고시로 인한 사업인정의 실효가 공용수용절차에 미치는 영향으로서, 재결신청이 토지수용위원회에 계속되고 있을 때에는 사업시행자는 그 신청을 취하하여야 하고, 취하지 않으면 재결은 각하되어야 할 것이다. 만약 재결이 있고, 수용 또는 사용의 개시일 이전에 사업인정 취소의 고시가 있으면 재결의 취소를 요하지 않고 그 고시에 따라 재결은 실효가 되는 것으로 해석된다.

심화

토지보상법상 실효제도

1. 사업인정의 실효

- ① 사업인정의 의의 및 효과 (법20)
- ② 재결신청 해태로 인한 실효 (법23)
- ③ 사업의 폐지·변경으로 인한 실효 (법24)

2. 재결의 실효

- ① 재결 (법34)
- ② 재결의 실효 사유 (법42)

3. 실효의 효과

- ① 사업인정과 재결의 효력 상실
- ② 사업인정 실효로 인한 손실보상 (법23②, 법24⑦) → 법9조5항~7항 준용
- ③ 재결 실효로 인한 손실보상 (법42②) → 법9조5항~7항 준용

02 공익사업의 완료 (제24조의2)

1) 공익사업의 완료에 따른 고시

사업이 완료된 경우 사업시행자는 지체 없이 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역, 사업인정고시일 및 취득한 토지의 세목을 사업지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 한다.

신고를 받은 시·도지사는 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 사업인정고시일을 관보에 고시하여야 하며, 위 신고가 없는 경우에도 사업이 완료된 것을 알았을 때에는 미리 사업시행자의 의견을 듣고 고시를 하여야 한다.

2) 사업인정의 의제되는 공익사업의 경우

사업인정이 의제되는 공익사업의 경우 해당 법률에서 정하는 바에 따라 해당 사업의 준공·완료·사용개시 등이 고시·공고된 경우에는 고시가 있는 것으로 본다.

3) 환매권 제도와의 관계

헌법재판소는 환매권 요건을 정한 91조 1항에 대해 헌법불합치결정을 하였고(헌재 2020. 11. 26.자 2019헌바 131), 이후 위 규정이 개정되었다. 공익사업의 완료 규정은 91조 1항의 환매권 행사 기산일과 관련 있으며, 위 개정과 함께 도입되었다.

제1절

토지조서 및 물건조서의 작성

01 조서의 의의 및 성질

1) 의의 및 취지

토지조서·물건조서란 공익사업을 위해 필요로 하는 토지 및 토지상의 물건 내용을 사업시행자가 작성하는 문서이다. 토지조서·물건조서의 작성은 공용수용의 2단계 절차로서, 수용 또는 사용할 토지 및 물건 내용을 확정하는 절차이다. 조서는 재결신청 준비절차의 일종으로서 수용 또는 사용의 목적이 된 토지 및 물건에 관한 당사자의 분쟁을 예방하고, 토지수용위원회의 심리 및 재결을 용이하게 하고, 신속·원활함을 기하는데 취지가 있다.

2) 법적성질

타인토지출입 측량·조사행위는 권력적 사실행위에 해당하고, 조서작성행위 자체는 비권력적 사실행위로 보는 것이 일반적이다.

02 조서의 작성절차

1) 토지 및 물건에 관한 조사권

- ① <의의> 사업인정고시가 된 후에는 사업시행자 또는 제68조에 따라 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 사업준비 또는 감정평가를 위해 필요한 경우 허가 또는 통지 없이 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제27조 제1항). 이 경우 출입의 통지(제10조), 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대(제13조)를 준용한다.
- ② <법적성질> 조사권은 사업인정고시의 효과로서 발생하는 권리이다. 사업인정에 의해 당해 사업의 공익성이 확인되어 있고, 토지범위가 확정되어 있는 점 등을 고려할 때, 조사권은 사업준비를 위한 타인토지출입에 비해 간단한 절차로 규정되어 있다. 공용사용의 일종으로 해석할 수 있다.

2) 작성절차 및 작성의 특례

- ① 조서의 작성은 협의에 의한 취득 또는 사용을 위한 조서작성의 규정(제14조)의 규정을 준용한다(제26조 제1항).
- ② <작성의 특례> 토지보상법은 절차 간소화를 위해 사업인정 이전에 토지조서 및 물건조서의 작성(제14조), 보상계획의 열람 등(제15조), 협의(제16조) 및 보상액의 산정(제68조)에 따른 절차를 거쳤으나 협의가 성립되지 아니하고 사업인정(제20조)을 받은 사업으로서, 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 토지조서 및 물건조서의 작성(제14조), 보상계획의 열람 등(제15조), 협의(제16조)의 절차를 거치지 아니할 수 있다(제26조 제2항 본문).

3) 손실보상의무

사업시행자는 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실(감정평가법인등이 감정평가를 위하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실도 포함)을 보상하여야 한다. 이 경우 손실보상에 관하여는 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

4) 장애물 제거 관련 논의

조서작성을 위한 장애물 제거에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 조서작성을 위해 장애물을 제거할 필요가 있을 수 있고, 이로 인해 발생하는 손실에 대해 보상이 행해지는 것을 전제로 한다면 이 경우에도 장애물을 제거하는 것이 가능한 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 사업 준비를 위한 장애물 제거 등에 관한 규정(제12조)은 조서작성을 위해서도 적용할 여지가 있다.

03 조서의 효력

1) 진실의 추정력

사업시행자가 작성하고 토지소유자와 관계인이 서명 또는 날인한 토지조서 및 물건조서는 이의가 부기(附記)되지 아니한 경우에는 진정한 것으로 추정되어 그 효력은 토지 등의 소유자 및 관계인에게까지 미치며, 이의가 부기된 것은 수용재결에 따르게 된다. 토지조서와 물건조서는 토지소유자 및 관계인이 관여하여 그 진실 여부를 확인하여 서명 또는 날인하게 됨으로써, 물건의 현황을 증명하고, 토지수용위원회의 재결이나 당사자 사이의 분쟁시 증거 방법이기 때문에 조서상의 내용은 별도의 입증을 기다릴 것이 없이 진실한 것으로 추정되는 효력을 지닌다.

토지수용위원회는 토지조서와 물건조서에 부여되어 있는 추정력(推定力)을 전제하여 심리하고, 수용 또는 사용의 재결을 하게 된다. 그러나 기재 사항이 사실과 다른 것을 알 수 있는 경우에는 단지 하나의 증거 방법에 지나지 않는 조서의 내용에 토지수용위원회가 구속되지 않는다.

2) 하자 있는 조서의 효력

(1) 하자의 유형

조서의 내용상 하자로는 물적상태 및 권리관계에 대한 오기, 오산 등이 있을 수 있고, 절차상 하자로는 서명·날인 누락이나 누락사유 기재의 누락 등의 하자가 있을 수 있다.

(2) 내용상 하자있는 조서의 효력

내용상 하자는 조서 자체의 효력에는 영향을 미치지 않고, 열람기간 내 이의를 제기하거나 열람기간이 지나더라도 조서내용이 진실과 다르다는 것을 입증할 때에는 조서의 추정력을 차단하여 이의를 제기할 수 있다. 이 때는 이의를 부기하여 재결 단계에서 효력부인이 가능하다. 단 입증책임은 하자를 주장하는 피수용자에게 있다.

(3) 절차상 하자있는 조서의 효력

사업시행자가 피수용자의 입회를 요구하지 않고 작성한 조서 등 절차상 하자 있는 조서는 적법하게 작성된 조서가 아니므로 효력을 발생하지 않는다. 절차상 하자에 의해 작성된 조서는 진실성의 효력이 원칙적으로 인정될 수 없다.

(4) 절차하자 있는 조서가 재결에 미치는 효력

- ① 일설은 조서의 작성에 하자가 있더라도 그것이 바로 재결의 효력에 영향을 미치는 것이 아니므로, 재결이 위법 또는 무효로 되지 않는다고 한다. 일설은 적법하게 작성되지 아니한 무효인 조서를 근거로 재결을 한다면 그 재결은 위법하다는 것이다. 이 주장은 토지수용위원회가 무효의 조서에 의해 토지·물건을 결정하고, 그 조서의 기재가 진실에 반한다는 토지소유자의 의견이 있음에도 불구하고 사실의 심사를 하지 않았기 때문임을 논거로 한다.
- ② 대법원 역시 절차의 하자만으로 재결이 위법하다 하여 취소 사유가 되지 않는다는 입장을 취하고 있다 (대판 1993. 9. 10. 93누5543, 대판 1993. 8. 13. 93누2148).
- ③ <검토> 조서의 효력은 수용위원회의 심리를 위해 중요한 증거 방법이지만 유일한 증거 방법이 아니고, 그 기재 내용에 토지수용위원회의 사실 인정을 구속하는 법률상의 힘이 부여되어 있는 것도 아니다.
생각건대, 조서작성이 적법하지 않고 조서의 기재 내용이 사실에 반하는 경우라 하더라도, 토지수용위원회가 토지소유자 등의 주장을 청취하거나 직접 조사한 결과를 근거로 재결을 할 수 있으므로, 조서의 부적법을 가지고 바로 재결이 위법이라거나 무효로 해석할 수는 없는 것으로 보아야 할 것이다.

04 권리구제방안

1) 이의 부기

토지조서 및 물건조서 내용에 이의가 있는 토지소유자 또는 관계인은 열람기간 이내에 사업시행자에게 이의를 제기할 수 있고, 사업시행자는 제기된 이의를 부기하고 이의 부기된 내용은 수용재결에 의하여 판단하게 된다.

2) 행정쟁송

조서작성행위는 비권력적 사실행위이므로 행정쟁송으로 다룰 수 없다.

조서작성을 위한 타인토지출입 측량·조사행위는 권력적 행정조서로서 권력적 사실행위이므로 처분성이 인정되어 항고쟁송으로 다룰 수 있으나, 짧은 시간 안에 완성되는 것이므로 협의 소익이 없어 각하될 가능성이 높다.

다만, 장기간을 요하는 측량·조사행위는 협의 소익이 인정될 수 있고, 집행정지 신청이 필요하다.

3) 손실보상

사업시행자는 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다 (제27조 제3항). 손실보상에 관하여는 손실보상의 청구(제9조 제5항), 협의결정(제9조 제6항), 재결신청(제9조 제7항) 규정을 준용한다(제27조 제4항).

01 의의 및 목적, 취지

- ① <의의> 협의란 사업인정고시 후 사업시행자가 공익사업에 제공될 토지 등에 대한 권리를 취득하거나 소멸시키기 위해 피수용자와 합의하는 것을 말한다(제26조 제1항). 협의가 성립되면 수용절차는 종결된다.
- ② <목적> 협의제도는 공익사업에 제공될 토지 등을 간편하게 취득하여 사업을 원활하게 수행하는 것을 목적으로 한다.
- ③ <취지> 토지보상법이 사업인정 이전과 이후에 협의절차를 중복적으로 두고 있는 것은 강제적으로 재산권을 취득하기보다 상대방의 협력을 구하여 사업의 원활을 기하기 위해서이다. 협의절차의 입법 취지는 피수용자에 대하여 수용의 취지·절차 및 그에 따른 손실보상제도를 설명하고 이해시키며, 가능한 한 공권력 발동에 의하지 않고 원만하게 토지 취득의 목적을 달성하려는 데 있다.

02 필수절차인지

토지보상법 제26조는 제16조를 준용하여, 사업시행자가 피수용자와 성실하게 협의하여야 한다고 규정하면서(제26조 제1항), 사업인정 이전에 협의절차를 거쳤으나, 협의가 성립되지 아니하여 사업인정을 받은 사업으로서 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 협의절차를 거치지 아니할 수 있다(제26조 제2항)라고 하여, 원칙상 필수절차이나, 예외적으로 생략할 수 있도록 하였다. 그러나 생략 가능한 경우라 하더라도 사업시행자나 토지소유자 및 관계인이 협의를 요구할 때에는 협의를 거쳐야 한다(제26조 제2항 단서).

03 법적성질

1) 논의의 실익

적용법규, 쟁송형태에 논의의 실익이 있다. 협의성립 확인을 받으면 재결로 간주되므로, 논의의 대상은 협의성립 확인을 받지 않은 협의를 말한다.

2) 학설

- ① <사법상 계약설> 수용권의 주체를 국가로 보는 국가수용권설의 입장에서는 협의는 수용자와 피수용자 사이에 대등한 지위에서 행하는 임의적 합의로서, 수용권의 행사가 아닌 사법상 매매계약과 동일한 성질을 갖는 사법상 계약이라고 한다.
- ② <공법상 계약설> 수용권의 주체를 사업시행자로 보는 사업시행자수용권설에서는 협의는 사업시행자가 수용권의 주체로서 토지소유자 및 관계인에 대하여 수용권을 실행하는 방법의 하나일 뿐이며, 협의가 성립되지 아니하면 재결에 의하게 된다는 점에서도 공법상 계약으로 이해하고 있다. 우리나라의 다수설로 되어 있다.

3) 판례

대법원은 토지수용에 있어서 협의 그 자체는 사법상의 법률행위라 하나(대판 1979. 7. 24. 79다655), 최근의 판시에서도 협의의 법적성질을 사법상 계약으로 보면서, 다만 협의취득 과정에는 여러 공법적 규제가 있는 등 공익적 특성을 고려해야 한다고 판시하였다(대판 2012. 2. 23. 2010다91206).

4) 검토

협이는 사업시행자가 수용권의 주체로서 수용권을 실행하는 하나의 방법으로서, 협의가 성립하면 확인의 절차를 거쳐 수용의 효과가 발생하게 되므로 공법상 계약으로 보는 것이 타당하다. 그러나 실무상으로는 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의를 구별하지 않고 그 법적 성질을 사법상 계약으로 보는 경향이 있다.

04 협의의 성립

1) 협의의 당사자

협이는 토지소유자 및 관계인 등 피수용자 전원을 상대방으로 하여 행하여야 한다.
협이는 진정한 권리자와 하여야 한다.

2) 협의기간

- ① 사업인정 후 협의는 사업인정 전 협의절차가 준용되므로(제26조 제1항), 사업인정 전 협의의 기간이 특별한 사유가 없는 한 30일 이상으로 하도록 하는 동법 시행령 제8조 제3항의 기간과 같다고 할 수 있다.
- ② 그러나 협의는 수용절차와의 관계에 비추어 재결이 있기 전까지를 시한(時限)으로 한다.
따라서 사업인정 후 협의는 사업인정고시가 된 날로부터 1년 이내에 하여야 한다.
- ③ 다만, 최근 판례는 수용재결 후 보상금 공탁 전에도 가능하다고 본 판례가 있다.
(대법원 2017. 4. 13. 선고 2016두64241)

대법원 2017. 4. 13. 선고 2016두64241

공익사업의 효율적인 수행을 통하여 공공복리를 증진시키고, 재산권을 적정하게 보호하려는 토지보상법의 입법목적에 비추어 보면 수용재결이 있는 후라고 하더라도 임의로 계약을 체결할 수 있다.

3) 협의의 범위 및 내용

- ① 〈범위〉 협의는 토지조서 및 물건조서의 범위 내에서 행하여야 한다. 토지조서와 물건조서는 일정한 절차를 거쳐 작성되어 진실성의 추정을 받으므로 그 범위를 넘어 협의할 수 없는 것으로 새겨진다.
- ② 〈내용〉 취득할 토지 등의 구체적 대상과 범위, 보상액과 보상의 시기 및 방법이 내용 된다.
따라서 협의사항은 수용목적물의 범위 손실보상, 수용시기 등을 정하는 재결사항(제50조)과 내용적으로 거의 같다고 할 수 있다.

4) 협의의 방법

사업시행자는 피수용자에 대하여 개별적으로 성실하게 협의하여야 한다. 성실한 협의란 사업의 목적 및 계획, 보상 방법 등에 관하여 성의 있고 진실하게 설명하여 이를 소유자 또는 관계인이 이해할 수 있도록 하는 것을 말한다.

5) 협의의 절차

사업시행자는 사업인정고시가 있은 후 협의하고자 할 때 토지소유자 및 관계인에게

① 협의기간·협의장소 및 협의방법,

② 보상의 시기·방법·절차 및 금액,

③ 계약체결에 필요한 구비서류

를 통지하여야 한다.

다만, 토지소유자 및 관계인을 알 수 없거나 그 주소·거소 또는 그 밖에 통지할 장소를 알 수 없을 때에는 공고로써 갈음할 수 있다(령 제8조 제1항).

6) 협의경위서 작성

사업시행자는 협의기간에 협의가 성립하지 아니한 경우에는 협의경위서에 협의와 관련된 사항을 적어 토지소유자 및 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다(령 제8조 제5항).

05 협의 성립 및 불성립의 효과

1) 협의 성립의 효과

협약이 성립되면 **공용수용의 절차는 종결되고** 협의의 내용에 따라 취득의 효과가 발생한다.

사업시행자는 목적물에 대한 권리를 취득하고, 피수용자는 그 권리를 상실하게 된다. 사업시행자는 보상금을 지급 또는 공탁하고(제40조), 피수용자는 협의에서 정한 날까지 토지·물건을 사업시행자에게 인도 또는 이전하여야 한다(제43조). 협의취득 당시의 토지소유자 또는 포괄승계인은 환매권을 갖는다(제91조). 사업시행자가 협의에 의해 목적물을 취득하는 경우에는 승계취득으로 보고 있다(대판 1978.11.14.78다1528).

2) 협의 불성립의 효과

사업시행자는 사업인정고시일로부터 1년 이내에 관한 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다(제28조 제1항). 피수용자는 사업시행자에게 **재결신청할 것을 청구할 수 있다**(제30조 제1항). 사업시행자는 재결신청청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다(제30조 제2항).

06 관련 문제

1) 협의절차하자와 재결의 관계

토지보상법은 협의전치주의를 취하여 사업시행자가 재결신청 전에 협의불능의 경우를 제외하고 반드시 협의를 거치도록 하고 있다. 사업시행자가 협의절차를 거치지 않고 재결을 신청하였다면 위법한 것이 되는 것은 말할 나위 없다. 이 경우 협의절차를 거치지 않은 재결의 효력이 문제되는데, 이에 대하여는 대개의 경우 절차의 위법과 재결의 효력을 명백히 구분하지 않고, 단지 위법이며 원칙적으로 무효라는 주장을 하고 있다.

이와 관련하여 대법원은 상대방의 주소를 알지 못하여 협의절차를 거치지 않은 사유만으로 재결이 당연무효로 되는 것은 아니라는 입장을 취하고 있다(대판 1994. 4. 15. 93누18594).

실무에서는 사업인정 전과 후의 협의를 구별 없이 사용하고 있는 것이 우리의 현실이며, 협의를 거치지 않은 재결의 신청은 협의불능의 경우를 제외하고 사실상 존재하지 않는 실정이다. 따라서 협의절차를 거치지 않은 재결의 신청과 그 재결의 효력에 대하여 이론적으로 논하는 것 자체가 아무런 실익이 없다 해도 과언이 아니다.

2) 위험부담의 문제

민법상 위험부담은 채무자가 지게 되어 있다. 그러나 토지보상법 제46조는 재결이 있은 후 피수용자의 고의나 과실 없이 목적물이 멸실되거나 훼손된 경우 위험부담을 사업시행자에게 지우고 있어, 협의 후 목적물 멸실 등 경우에도 적용할 수 있는지 문제된다. **대법원은** **담건설로 인한 수몰지역 내 토지를 매수하고 지상입목에 대하여 적절한 보상을 하기로 특약하였다면 보상금이 지급되기 전에 그 입목이 홍수로 멸실되었다 하더라도 매수 또는 보상하기로 한 자는 이행불능을 이유로 위 보상약정을 해제할 수 없다**(대판 1977. 12. 27. 76다1472)라고 판시하였다. 위험부담이전 규정 취지는 피수용자 권리보호를 위한 것이므로, **협의 후 귀책사유 없이 목적물이 멸실된 경우에도 적용될 수 있다고** 보아야 할 것이다.

3) 사업시행자의 손실보상 의무 불이행시 재결실효규정 적용여부

토지보상법상 재결실효규정(제42조)을 유추 적용하여 협의의 실효를 주장할 수 있는지가 문제되나, 협의 성립 시 이를 재결과 달리 취급할 이유가 없으므로 재결실효규정 적용을 긍정하는 견해가 있다. 그러나 토지보상법 명문 규정상 협의의 실효에 관한 규정이 없으므로 적용하기 어렵다고 봄이 타당하다. 판례에 의하면 민사소송으로, 다수설에 의하면 공법상 당사자소송으로 해결이 가능할 것이다.

심화

사업인정 전·후 협의 비교

구분	사업인정 전 협의	사업인정 후 협의
공통점	최소침해원칙, 협의내용 (법50조 후술 구.손.개.그)	
필수적 전치절차 여부	임의절차 & 성실협의의무만 있음	예외적 경우 제외하고 반드시 거쳐야 하는 필수절차
법적성질	사법상계약(판례) & 사법상계약(다수설)	사법상계약(판례) & 공법상계약 (다수설) → 어쨌든 승계취득
확인제도 유무	확인제도 없음	확인제도 있음
협의성립 시 효과	승계취득	협의성립확인 받기 전 승계취득, 확인 후 재결간주 원시취득
협의 불성립 시 효과	사업인정 신청	사업시행자 재결 신청 / 피수용자 재결신청청구
권리구제	민사소송	판례 민사소송 / 다수설 공법상 당사자소송
양자의 관계	절차상 선후관계 / 사업인정 전 협의 불성립하고 조서내용불변이며 당사자 협의 요구 없을 시 사업인정 후 협의 생략가능	

01 의의 및 취지

- ① <의의> 협의성립확인이란 사업인정 후 협의 성립 시 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용위원회에 협의성립확인을 받는 제도이다. 협의성립확인은 “신청할 수 있다”라고 되어 있어(제29조 제1항) 신청은 필요적 사항은 아니며, 확인절차를 거치지 않았다고 하여 협의성립 효력이 상실되는 것은 아니다.
- ② <취지> 협의성립확인은 당사자 간의 합의에 의해 수용재결과 같은 효력을 부여(원시취득)함으로써 수용재결절차에 의하지 아니하고 수용의 목적을 달성하고, 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행을 기함에 취지가 있다.

02 법적성질

- ① 협의성립 확인을 받으면 재결로 간주되어 처분성이 인정된다는 점에서 형성적 행정행위로 보아야 한다는 견해(형성적 행정행위설)와 법규정에 의해 특정한 사실 또는 법률관계의 존부 또는 정부에 관해 분쟁의 여지가 없도록 확인하는 준법률행위적 행정행위로서 확인행위라는 견해가 있다(준법률행위적 행정행위설).
- ② <검토> 법규정상 협의성립확인은 재결로 보며, 확인 시 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없다는 확정력이 부여되므로 재결과 같은 형성적 행정행위로 봄이 타당하다.

대법원 2018. 12. 13. 선고 2016두51719 판결 [협의성립확인신청수리처분취소]

1. 협의성립확인의 효과

토지보상법상 수용은 원시취득이다. 반면 토지보상법상 협의 취득은 승계취득이다.
협의성립확인 신청이 수리됨으로써 협의성립의 확인이 있었던 것으로 간주되면 재결이 있었던 것으로 재차 의제되고 원시취득하는 효과를 누리게 된다.

2. 협의성립확인의 법적 정당성 : 사업시행자와 토지소유자 등의 진정한 합의

협의성립의 확인의 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다.
토지보상법 29조 3항에 따른 토지소유자는 협의의 대상이 되는 토지의 진정한 소유자를 의미한다.

3. 진정한 소유자가 아닌 경우 : 협의성립의 확인의 위법성 인정됨

따라서 사업시행자가 단순히 등기부상 소유명의자의 동의만을 얻은 후 협의성립의 확인을 신청하였음에도 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면 소유자의 동의 요건을 갖추지 못한 것으로서 위법하다.
사업시행자의 과실이 있었는지 여부와 무관하게 그 동의의 흠결은 위법사유가 된다.
이에 따라 진정한 토지소유자는 수리 행위가 위법함을 주장하여 항고소송으로 취소를 구할 수 있다.

03 확인의 절차

1) 일반적 확인절차 (제29조 제1항; 재결절차 준용)

협약이 성립되었을 때 사업시행자는 재결의 신청기간 규정(제28조 제1항)에 따른 재결신청기간 이내에 해당 토지소유자 및 관계인의 동의를 받아 관할 토지수용위원회에 협의성립의 확인을 신청할 수 있다(제29조 제1항). 수수료의 납부(제28조 제2항), 공고 및 열람(제31조), 조사 및 심리(제32조), 재결(제34조), 재결기간(제35조), 회의개최와 의결(제52조 제7항), 지방토지수용위원회의 회의소집(제53조 제4항), 위원의 제척·기피·회피(제57조) 및 심리조사상의 권한(제58조)을 준용한다(제29조 제2항).

2) 공증에 의한 확인절차 (제29조 제3항; 수리로써 협의 성립확인)

공증에 의한 협의성립확인이란 공증에 의해 확인을 의제하는 것을 말한다. 사업시행자가 협약이 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 협의성립확인신청서의 기재사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 협의성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다(제29조 제3항, 령 제13조 제3항). 공증을 받아 제출된 확인신청에 대하여는 재결절차에 관한 사항의 준용 절차를 필요로 하지 아니한다. 이 절차는 특히 협의성립확인을 조속히 하고자 하는 경우에 필요하다. 여기에서 수리는 준법률행위적 행정행위로서의 수리에 해당한다.

04 확인의 효과

- ① <재결효> 확인은 이 법에 따른 재결로 보며, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용을 다툴 수 없다(제29조 제4항). 확인은 재결로 보므로 재결의 효과와 같은 효과가 발생한다.
- ② <차단효> 확인된 협의의 성립이나 내용을 다툴 수 없으므로, 협의에 대하여 불가변력, 즉 확정력이 발생한다(대판 1965. 4. 22. 63누141).
- ③ <확인효의 실효 여부> 확인은 재결로 간주되므로, 협의에서 정한 보상의 시기까지 보상을 하지 않으면 재결실효규정이 적용되어 확인의 효력은 상실된다고 볼 것이다. 이 때 협의의 효력도 상실되는지 논란이 있으나, 협의는 계약이므로 계약불이행의 문제가 발생되고, 곧바로 협의의 효력이 상실된다고 볼 수는 없다.

1) 확인에 대한 불복

확인 은 재결로 간주되므로, 처분에 해당하여 이에 불복하는 자는 중앙토지수용위원회에 이의신청(제83조)을 할 수 있고, 행정소송(제85조)으로 다룰 수 있다.

2) 협의 자체에 대한 불복

적법·유효한 확인이 있는 경우 협의에 불가변력이 인정되어 다룰 수 없다.

따라서 확인의 효력을 행정쟁송으로 없앤 후, 협의에 대하여 다룰 수 있다.

심화

사업인정 후 협의와 협의성립확인과의 비교

구분		사업인정 후 협의	협의성립확인
공동점		효과 동일(손실보상&환매권&위험부담의 이전&담보물권자의 물상대위)	
차 이 점	법적 성질에 따른 목적물 취득	승계취득	원시취득
	물권변동의 형태	법률행위에 의한 물권변동	법률규정에 의한 물권변동
	착오의 경우 권리구제	민법규정 유추적용	차단효 발생하여 못 다툼
양자의 관계		당사자 간의 계약을 공법상의 처분으로 전환시키는 관계	

제1절 재결신청의 청구 [★★]

01 의의, 취지 및 근거

재결신청청구란 사업인정고시 후 협의 불성립시 피수용자가 사업시행자에게 조속히 재결신청을 할 것을 청구하는 것이다. 토지소유자 및 관계인은 재결신청권을 갖지 않으므로, 수용을 둘러싼 법률관계의 조속한 확정을 바라는 토지소유자 및 관계인의 이익을 보호하고, 수용 당사자 간의 공평을 기하기 위함에 있다(대판 1997. 10. 24. 97다 31171). 토지보상법 제30조에 근거를 둔다.

심화

구분	재결신청의 청구	재결신청
근거	30조	28조
당사자	피수용자가 사업시행자에게	사업시행자가 관할 토지수용위원회에
의미	재결신청을 조속히 해 달라	재결 결정을 내려 달라
비고	자연가산금 발생 가능	사업인정 1년 내 하지 않으면 사업인정 실효

02 법적성질

재결신청청구권은, 재결 보상금에 부수하여 구 공익사업법상 인정되는 공법상 청구권의 성질을 지닌다. 판례도 같다(대법원 2010두9457).

03 요건

1) 당사자

재결신청 청구권자는 피수용자로서, 사업시행자에게 청구한다.

2) 청구기간

(1) 원칙

재결신청청구는 사업인정이 있는 후 협의가 성립되지 않을 경우 가능하다.
토지보상법상 사업인정 후 1년 이내 재결신청을 하지 않으면, 사업인정은 실효되므로,
협의기간 만료일 이후 사업인정고시일로부터 1년 이내에 청구하여야 한다.

(2) 협의성립 가능성 없음이 명백한 경우

판례는 협의기간이 정해져 있더라도 협의의 성립가능성 없음이 명백해졌을 때와 같은 경우에는 **굳이 협의기간이 종료될 때까지 기다리게 하여야 할 필요성도 없는 것이므로**, 협의기간 종료 전이라도 재결신청의 청구를 할 수 있는 것으로 보아야 하며, 다만 이 때 사업시행자의 **재결신청의 기산일은 협의기간 만료일로부터 기산하여야** 한다고 하였다(대판 1993. 7. 13. 93누2902).

(3) 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의에 대한 통지를 하지 않은 경우

사업시행자가 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의에 대한 통지를 토지 등의 소유자 등에게 하지 아니하였다면 토지 등의 소유자 등은 사업시행자에게 **조속한 재결신청의 청구**를 할 수 있다.

(「손실보상 및 수용업무처리규정」제44조 제2항)

(4) 협의가 성립하지 아니한 때의 의미에 대한 판례

토지보상법 제30조 제1항은 재결신청을 청구할 수 있는 경우를 ‘협의가 성립하지 아니한 때’로 정하고 있을 뿐 그 사유를 제한하고 있지 않은 점, 위 조항이 토지소유자 등에게 재결신청청구권을 부여한 취지는 손실보상에 관한 법률관계를 조속히 확정함으로써 공익사업을 효율적으로 수행하고 토지소유자 등의 재산권을 적정하게 보호하기 위한 것인데, 손실보상대상에 관한 이견으로 손실보상협의를 성립하지 아니한 경우에도 재결을 통해 손실보상에 관한 법률관계를 조속히 확정할 필요가 있는 점 등에 비추어 볼 때, ‘협의가 성립되지 아니한 때’에는 사업시행자가 토지소유자 등과 토지보상법 제26조에서 정한 협의절차를 거쳤으나 보상액 등에 관하여 협의가 성립하지 아니한 경우는 물론 토지소유자 등이 손실보상대상에 해당한다고 주장하며 보상을 요구하는데도 사업시행자가 손실보상대상에 해당하지 아니한다며 보상대상에서 이를 제외한 채 협의를 하지 않아 결국 협의가 성립하지 않은 경우도 포함된다고 보아야 한다.

3) 청구의 내용 및 형식

내용은 사업시행자에게 재결신청을 청구하는 것이다.

형식은 일정한 사항을 기재한 재결신청청구서를 사업시행자에게 제출하면 된다(령 제14조).

04 청구의 효과

1) 지연가산금의 지급

사업시행자는 청구를 받았을 때에는 청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다(제30조 제2항). 이 기간을 넘겨서 재결을 신청하였을 때에는 그 지연된 기간에 대하여 「소송촉진 등에 관한 특별법」제3조에 의한 **법정이율을 적용하여 산정한 금액을 재결한 보상금에 가산하여 지급하여야** 한다(제30조 제3항).

2) 지연가산금의 지급과 불복방법

판례는 지연가산금을 수용보상금에 대한 법정 지연손해금의 성격을 가진다고 하였고, 지연가산금은 수용재결에서 손실보상금과 함께 정하도록 규정하고 있으므로, 지연가산금에 대한 불복은 **보상금증액청구소송에** 의하여야 한다고 판시하였다. 보상금증액청구소송 이전에 **이의신청(83조)**도 불복방법으로 고려할 수 있다.

1) 사업시행자가 재결신청청구를 거부 또는 부작위하는 경우

(1) 민사소송 또는 공법상 당사자소송

판례는 가산금제도로 재결신청을 강제하고 있고, 사업인정의 효력 상실 규정제도 등을 이유로 민사소송 등의 방법으로는 그 이행을 청구할 수 없다고 하였다. 이러한 판례 태도에 비추어 공법상 당사자소송도 인정되기 어렵다.

(2) 항고소송 인정여부

a. 문제점

재결신청청구는 사인의 공법행위로서 사실행위이므로, 이에 대한 거부 또는 부작위가 항고소송의 대상적격이 있는가가 문제된다.

b. 재결신청청구 거부의 대상적격 인정여부

(가) 거부가 처분이 되기 위한 판례 요건

거부가 처분이 되려면, 법규상·조리상 신청권의 존재, 공권력행사의 거부일 것, 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미칠 것이 요구된다.

(나) 재결신청청구 거부가 공권력행사 거부인지

재결신청은 사업시행자의 공법행위로서 사실행위이나, 재결신청이 있어야 수용재결이 이루어지고, 수용재결이 토지수용위원회의 공권력행사이므로, 재결신청청구 거부 시 재결의 거부와 같은 결과를 가져올 수 있는 점, 사업인정이 실효되지 않는 한 피수용자에게 다른 구제방법이 없는 점 등을 고려하여 공권력행사로 봄이 타당하다.

(다) 판례의 태도

판례는 “토지소유자의 재결신청 청구에도 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자는 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 하고, 재결신청의 청구는 재결신청이 가능한 사업시행기간(토지보상법의 경우 사업인정고시일부터 1년, 개별법 규정 있을 시 그에 따름) 내에 하여야 한다고 판단하였다(대법원 2019. 8. 29. 선고 2018두 57865 판결).

(라) 검토

토지보상법 제30조에서는 토지소유자와 관계인에게 재결신청청구권을 규정하고 있다.

재결신청청구 거부 시 피수용자는 수용재결을 통한 권리의무에 직접 영향이 있다.

재결신청청구 거부는 상기 검토와 같이 공권력행사로 판단되는 바, 이 거부는 처분으로서 취소소송의 대상적격이 인정된다.

c. 소결

재결신청청구 거부가 항고소송의 대상적격이 인정되는 한, 기타 항고소송의 소송요건을 갖추고, 재결신청청구 거부가 위법한 경우 항고소송으로 권리구제를 받을 수 있다. 부작위의 경우 또한 같다.

2) 지연가산금에 대한 다툼

판례는, 지연가산금은 수용보상금에 대한 법정 지연손해금의 성격을 갖는 것이므로 이에 대한 불복은 수용보상금에 대한 불복절차에 의함이 상당할 뿐 아니라, 가산하여 지급할 금액은 관할 토지수용위원회가 재결서에 기재하여야 하며, 기업자는 수용 시기까지 보상금과 함께 이를 지급하여야 한다고 하여 지연가산금은 수용보상금과 함께 수용재결로 정하도록 규정하고 있으므로, 지연가산금에 대한 불복은 수용보상금의 증액에 관한 소에 의하여야 한다고 판시하였다. 토지보상법 제83조의 이의신청으로 지연가산금에 대한 다툼이 가능하다.

06 관련 문제

사업시행자가 재결신청청구를 받고도 재결신청을 하지 않을 경우 단지 지연된 기간에 대하여 가산금 규정만을 둔 것은, 조속히 수용관계를 해결하고자 하는 피수용자의 권리보호에 미흡한 제도라 할 것이다.

따라서 피수용자의 재결신청청구권의 효력이 직접 재결신청을 한 것과 같은 효력이 부여될 정도로 강화될 필요가 있다.

01 의미 및 근거

재결신청은 협의 불성립 시 사업시행자가 토지수용위원회에게 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차이다.
토지보상법 제28조에 근거를 둔다.

02 요건

- ① <재결신청권자> 재결신청권자는 오직 사업시행자 뿐이다.
- ② 재결은 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 하며, 토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다.
재결신청의무는 반드시 해야 하는 의무는 아니다. 재결신청기간이 경과하면 사업인정의 효력도 상실되므로 재결신청의 근거도 없어진다. 다른 개별법에서 재결신청기간이 특별히 규정되어 있다면 그 기간을 따르면 된다.
사업시행자의 재결신청을 기각하는 재결이 확정되었다 하더라도 재결신청기간의 제한규정에 저촉되지 않는 한 다시 재결신청을 할 수 있고, 토지수용위원회는 이에 근거하여 다시 수용재결을 할 수 있다.

03 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유와 타당성

- ① 토지보상법 구조상 피수용자에게 재결신청권을 인정할 수 없고,
- ② 피수용자에게 재결신청권 부여 시 공익사업 계획에 지장이 생길 우려가 있으며,
- ③ 목적물 취득권과 보상의무는 사업시행자에게 있는 점,
- ④ 형평차원에서 피수용자에게 재결신청청구권(토지보상법 제30조)이 인정되는 점 등을 고려할 때, 사업시행자에게만 재결신청권을 인정함이 타당하다.

01 의의 및 취지

수용재결은 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차이다(제34조, 제50조). 강제적 권력행사를 통해 공익을 실현하고, 엄격한 절차와 형식을 통해 공익과 사익을 조절하기 위한 제도로써 취지가 있다.

02 법적 성질

1) 형성적 행정행위 여부

(1) 문제점

수용권자를 누구로 보는지 견해에 따라 수용재결의 형성적 행정행위 여부가 달라진다.
어느 견해로 보더라도 강학상 행정행위이자 행정쟁송법상 처분으로서 항고쟁송의 대상이 된다.

(2) 학설

① 〈국가수용권설〉

수용권의 주체는 국가이므로, 수용재결은 국가가 수용권을 행사하여 피수용자의 권리를 박탈하여 사업시행자에게 이전해 주는 행위로 본다.

② 〈사업시행자수용권설〉

수용권의 주체는 사업시행자이므로, 수용재결은 사업시행자에게 부여된 수용권의 구체적 내용을 확정하고, 사업시행자와 피수용자간의 권리 취득 및 상실을 결정하는 형성적 행정행위라고 한다.
이 견해가 다수설이다.

(3) 판례

대법원은 수용재결은 일정한 법적 효과를 가져오는 처분으로서 행정행위의 성질을 갖는다고 하였다.
(대판 1993. 4. 27. 92누15789)

(4) 검토

생각건대 사업시행자수용권설의 입장이 타당한 바, 수용재결은 수용권의 구체적 내용을 결정하고 권리취득 및 상실을 결정하는 형성적 행정행위로 봄이 타당하다.

2) 기속행위·재량행위 여부

사업시행자가 재결신청을 하면 관할 토지수용위원회는 형식적 요건이 미비되지 않는 한 재결을 해야 한다.
토지수용절차의 이분화, 사업인정의 성격 등에 비추어 토지수용위원회는 사업인정 자체를 무의미하게 하는, 즉 사업의 시행이 불가능하게 되는 것과 같은 재결을 행할 수 없는 점에서 재결의 발령 자체는 기속행위로 볼 수 있다. 다만, 토지보상법 제50조 제2항 단서에 따르면 손실보상금에 관하여 증액재결을 할 수 있는바, 위 부분은 재량권이 인정된다.

3) 제3자효 행정행위

수용재결은 사업시행자에게는 재산권 취득의 수익적 효과를 피수용자에게는 재산권 박탈의 침익적 효과를 부여하므로, 제3자효 행정행위이다.

4) 기타의 법적성질

토지수용위원회가 독립적 판단작용을 하므로, 준사법작용과 유사한 당사자심판의 성격, 시심적 쟁송의 성질을 갖고, 수용권자와 피수용권자를 대신하여 수용재결의 사항을 판단하므로 공법상 대리의 성격도 갖고 있다.

03 재결의 성립

1) 재결의 주체

재결은 국민의 재산권을 강제적으로 수용하게 하는 결정을 내리게 되므로, 엄격한 형식과 절차가 요구되고, 이를 관장하는 재결기관의 독립성·중립성 및 전문성이 요구된다. 따라서 재결기관은 토지수용위원회로 하고 있다. 재결기관으로서 토지수용위원회는 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 지방토지수용위원회를 둔다(제49조). 토지수용위원회는 독립된 합의제 행정청이다.

2) 재결의 내용과 범위

토지수용위원회는

- ① 수용하거나 사용할 토지의 구역 및 사용방법,
- ② 손실보상,
- ③ 수용 또는 사용의 개시일과 기간,
- ④ 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항을 재결한다(제50조 제1항).

토지수용위원회는 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이 신청한 범위에서 재결하여야 한다.

다만 손실보상의 경우에는 증액재결을 할 수 있다(토지보상법 제50조 제2항).

불고불리(不告不理)의 원칙이 적용되어 신청 또는 주장이 없는 사항에 대하여 재결할 수 없다.

토지보상법은 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이 신청한 범위 내로 제한함으로써 처분권주의, 당사자주의를 취하면서, 손실보상에 관해서는 당사자가 신청한 액수 이상으로 재결할 수 있게 함으로써 직권주의를 취하고 있는 것으로 보고 있다. 또한 판례의 견해에 의할 때, 사업의 공익성, 사업시행자의 사업수행의 의사나 능력, 관련 이익 등의 형량내용 등을 판단하여 수용권을 행사하여야 한다(대판 2011. 1. 27. 2009두1051).

3) 재결 형식과 재결서의 송달

토지수용위원회의 재결은 서면으로 한다(제34조 제1항). 재결서에는 주문 및 그 이유와 재결일을 적고, 위원장 및 회의에 참석한 위원이 기명날인한 후 그 정본을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 송달하여야 한다(제34조 제2항). 수용재결서가 수용시기 이전에 피수용자에게 적법하게 송달되지 아니하였다고 하여 수용절차가 당연무효가 되는 것은 아니며, 그 수용재결서의 정본이 적법하게 송달된 날로부터 수용재결에 대한 이의신청기간이 진행된다(대판 1995. 6. 13. 선고 94누9085).

4) 재결의 절차

사업시행자는 재결신청서를 작성하여 관할 토지수용위원회에 제출하여야 한다(제28조, 령 제12조 제1항).

토지수용위원회는 재결신청서를 접수하였을 때에는 지체 없이 이를 공고하고, 공고한 날부터 14일 이상 관계 서류의 사본을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다(제31조 제1항).

토지수용위원회가 공고를 하였을 때에는 관계 서류의 열람기간 중에 토지소유자 또는 관계인은 의견을 제시할 수 있다(제31조 제2항). 이를 위해 시장·군수 또는 구청장은 공고를 한 경우에는 그 공고의 내용과 의견이 있으면 의견서를 제출할 수 있다는 뜻을 토지소유자 및 관계인에게 통지하여야 한다(령 제15조 제3항).

토지수용위원회는 열람기간이 지났을 때에는 지체 없이 해당 신청에 대한 조사 및 심리를 하여야 한다(제32조 제1항).

토지수용위원회는 심리를 할 때 필요하다고 인정하면 사업시행자, 토지소유자 및 관계인을 출석시켜 그 의견을 진술하게 할 수 있다(제32조 제2항). 토지수용위원회는 심리를 시작한 날부터 14일 이내에 재결을 하여야 한다. 심리는 서면주의, 비공개주의, 직권주의에 의하여 행한다.

다만, 특별한 사유가 있을 때에는 14일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다(제35조).

재결심리 기간을 규정한 것은 재결을 조속히 하여 법적안정성을 기함에 그 취지가 있다.

5) 재결의 결함

(1) 재결의 경정

재결은 확정력을 갖는 행정행위이므로, 행정쟁송에 의해 취소 또는 변경되지 않는 한 토지수용위원회도 임의로 당해 재결을 취소 또는 변경할 수 없다. 그러나 재결의 오류가 명백한 경우까지 행정쟁송에 의하도록 하는 것은 비합리적이므로, 간편하게 정정할 수 있는 방안이 필요하며, 토지보상법은 이를 경정재결로 제도와 하고 있다. 재결에 계산상 또는 기재상의 잘못이나 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있는 것이 명백할 때에는 토지수용위원회는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 경정재결을 할 수 있다(제36조 제1항).

경정재결은 원재결서의 원본과 정본에 부기하여야 한다.

다만, 정본에 부기할 수 없을 때에는 경정재결의 정본을 작성하여 당사자에게 송달하여야 한다(제36조 제2항).

(2) 재결의 유탈

토지수용위원회가 신청의 일부에 대한 재결을 빠뜨린 경우에 그 빠뜨린 부분의 신청은 계속하여 그 토지수용 위원회에 계속된다(제37조). 이 경우 토지수용위원회는 다시 그 유탈된 부분에 대하여 재결해야 한다.

이 재결을 추가재결이라고 하고, 먼저 행한 재결과 추가재결은 각각 별개의 재결이며, 이의신청기간도 개별적으로 진행된다.

6) 재결의 효과

(1) 행정행위의 일반적 효력

재결은 행정행위이므로, 행정행위의 일반적 효력이 발생한다.

(2) 재결 내용 및 토지보상법에 따른 효과

사업시행자의 권리취득(법 제45조) 및 피수용자의 환매권(법 제91조)은 수용의 개시일에, 손실보상청구권(법 제40조), 토지·물건의 인도·이전 의무(법 제43조), 위험부담의 이전(법 제46조) 등은 수용재결일을 기준으로 발생한다.

- ① <사업시행자>는 보상금의 지급 또는 공탁을 조건으로 수용시기에 토지 등에 관한 권리를 원시취득(제45조)하고, 사업시행자는 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다(손실보상 의무). 토지수용위원회의 재결이 있은 후 수용할 토지나 물건이 토지소유자 또는 관계인의 고의나 과실 없이 멸실 또는 훼손되었을 때 그로 인한 손실은 사업시행자의 부담으로 된다(위험부담 이전, 제46조). 피수용자가 의무를 이행하지 아니할 때 대행(제44조)·대집행 신청권(제89조)을 갖는다. 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조)를 진다.
- ② <피수용자>는 손실보상청구권을 갖는 대신 수용목적물의 인도·이전의무(제43조)를 부담한다. 수용목적물이 일정한 기간 경과하였는데도 필요 없게 된 때 원래의 토지소유자가 환매할 수 있는 권리(제91조)가 발생한다. 담보물권자의 물상대위가 인정된다. 담보물권의 목적물이 수용된 경우 당해 담보물권은 그 목적물의 수용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있게 된다(제47조).

7) 사업인정의 하자과 재결의 성립

공용수용의 절차에 있어서 재결의 전단계절차인 사업인정이 무효인 경우에는 어떻게 할 것인가 문제된다. 사업인정이 부존재의 의미에서 무효인 경우에는 토지수용위원회는 재결신청을 각하할 수 있지만, 사업인정은 행정쟁송에 의해 취소되지 아니한 이상 그 효력은 사실상 유효하기 때문에 토지수용위원회는 사업인정을 무효로 판정할 수 없다. 판례도 (구)토지수용법은 수용·사용의 일차 단계인 사업인정에 속하는 부분은 사업의 공익성 판단으로 사업인정기관에 일임하고 그 이후의 구체적인 수용·사용의 결정은 토지수용위원회에 맡기고 있는바, 이와 같은 토지수용절차의 2분화 및 사업인정의 성격과 토지수용위원회의 재결사항을 열거하고 있는 같은 법 제29조 제2항의 규정 내용에 비추어 볼 때, 토지수용위원회는 행정쟁송에 의하여 사업인정이 취소되지 않는 한 그 기능상 사업인정 자체를 무의미하게 하는, 즉 사업의 시행이 불가능하게 되는 것과 같은 재결을 행할 수는 없다고 판시하였다(대법원 2007. 1. 11. 선고 2004두8538 판결).

다만, 위 판례 법리는 “공익사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하거나 사업인정에 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 사업시행자가 해당 공익사업을 수행할 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 공익 목적에 반하는 수용권의 남용에 해당하여 허용되지 않는다(이 경우 수용재결은 취소사유에 위법이 있음).”는 판례 법리(대법원 2011. 1. 27. 선고 2009두1051 판결)와 구분하여 정리할 필요가 있다.

01 의의 및 취지

재결의 실효란 유효하게 성립한 재결효력이 객관적 사실의 발생에 따라 상실되는 것을 말한다(제42조).
재결실효제도는 사전보상원칙을 이행하기 위함이다.

02 사유

사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때에는 해당 토지수용위원회의 재결은 효력을 상실한다(제42조 제1항).

재결 이후 사용 또는 수용의 개시일 전에 사업인정이 취소 또는 변경되었을 경우 그 고시 결과에 따라 재결의 효력은 상실된다. 단, 이 경우에도 이미 보상금 지급·공탁 시 재결의 효력은 상실되지 않는다.

03 권리구제

① <손실보상>

사업시행자는 재결의 효력이 상실됨으로 인하여 토지소유자 또는 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다(제42조 제2항). 재결이 실효됨으로 인하여 발생한 손실을 사업시행자가 보상하는 것은 손해배상의 성격을 지닌다. 제척기간규정과 손실보상의 절차규정은 토지보상법 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

② <항고쟁송>

실효여부에 대한 다툼은 실효확인쟁송에 의할 수 있다.

04 관련 문제

1) 재결실효와 재결신청 효력의 관계

(1) 문제점

재결의 효력이 상실된 경우 재결신청의 효력이 어떻게 되느냐에 대하여 견해가 나뉘어져 있다.

(2) 견해 대립

재결신청의 효력이 유효하다는 견해는 보상금을 지급하거나 공탁하지 않으면 토지보상법 제42조 규정에서 재결의 효력만을 상실시킬 뿐 재결신청의 효력까지를 상실시키는 것은 아니므로 유효하다고 한다.

그러나 재결과 그 기초가 되는 재결신청은 운명을 같이 하여야 하므로, 보상금을 지급하거나 공탁하지 않아 재결의 효력이 상실되면 그 효력이 상실되어야 한다는 견해가 있다.

(3) 판례

토지수용의 내용이 공익사업을 위해서 기업자에게 타인의 재산권을 강제적으로 취득시키는 효과를 나타내는데 있다고 하더라도 이는 그 보상금의 지급을 조건으로 하고 있는 것인 만큼 토지수용법 제65조의 규정내용 역시 기업자가 그 재결된 보상금을 그 수용시기까지 지급 또는 공탁하지 않은 이상 위 수용위원회의 재결은 물론 재결의 전제가 되는 재결신청도 아울러 그 효력을 상실하는 것이라고 해석함이 상당하고, 재결의 효력이 상실되면 재결신청 역시 그 효력을 상실하게 되는 것이므로 그로 인하여 토지수용법 제17조 소정의 사업인정의 고시가 있는 날로부터 1년 이내에 재결신청을 하지 않는 것으로 되었다면 사업인정도 역시 효력을 상실하여 결국 그 수용절차 일체가 백지상태로 환원된다고 판시하였다(대판 1987. 3. 10. 84누158).

2) 이의재결 증액보상금 미지급 시 이의재결의 실효

사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때에는 해당 토지수용위원회의 재결은 효력을 상실한다. 이 경우 재결은 무효로 되어 수용의 목적물을 취득할 수 없게 된다(대판 1995. 9. 15. 93다48458). 그러나 이의재결에서 증액된 보상금을 지급·공탁하지 않았다 하여 이의재결이 당연히 실효되는 것은 아니라 한다(대판 1989. 6. 27. 88누3956).

01 의의 및 취지

토지보상법 제33조에서 정한 화해란 사업시행자의 재결신청 이후 재결이 있기 전에 토지수용위원회가 사업시행자와 토지소유자 및 관계인에게 권고하여 재결에 의하지 않고 분쟁을 해결하고자 하는 의사의 합치를 의미한다.

「민법」상 화해(和解)는 당사자가 서로 양보하여 당사자 사이의 분쟁을 종결할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이다(민법 제731조).

토지보상법은 ① 가급적 당사자 간 원만한 합의에 의해 토지를 취득하는 것이 바람직하고, ② 화해에 확정력을 부여하여 화해의 성립과 내용이 나중에 다투어짐으로써 공익사업의 시행에 지장을 줄 위험성을 미리 예방해 둘 필요에서 재결신청 후 화해를 제도화하고 있다.

토지보상법상 화해는 일정한 절차를 거친 후 화해조서의 작성이 있어야 비로소 토지보상법상 효과가 발생한다.

02 법적성질

① <화해>는 사업시행자수용권설에 따를 때, 공법상 계약으로 봄이 타당하다.

② <화해조서 작성행위>에 대하여는 재결로 본다는 규정이 없으나,

화해제도의 취지 및 협의성립확인제도와와의 균형을 맞추기 위해 재결과 같은 성질로 보아야 할 것이다.

03 협의와의 차이점

협의를 재결신청 전 수용 당사자 간에 공법상 계약에 의해 수용목적 달성을 하고자 하는 것이고,

화해는 재결신청 후 토지수용위원회의 중재에 의해 수용목적 달성을 하고자 하는 것이다.

협의를 협의전치주의를 취하고 있는 수용법제하에서는 필요적 절차로서, 그것을 결한 수용은 무효를 면할 수 없으나, 화해는 토지수용위원회의 재량에 따른 임의적 절차이므로, 그것을 결하였다고 하여 수용이 무효가 되는 것은 아니다.

04 절차

토지수용위원회는 그 재결이 있기 전에는 그 위원 3명으로 구성되는 소위원회로 하여금 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 화해를 권고하게 할 수 있다(제33조).

화해의 권고는 토지수용위원회에게 재량이 주어져 있는 임의적 절차이다(대판 1986. 6. 24. 84누554).

화해가 성립되었을 때에는 토지수용위원회는 화해조서를 작성하여 화해에 참여한 위원, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인이 서명 또는 날인하도록 하여야 한다(제33조 제2항).

토지수용위원회는 화해가 성립된 때에는 화해조서의 정본을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 송달하여야 한다(령 제17조).

05 화해의 효력

화해조서에 서명 또는 날인이 된 경우에는 당사자 간에 화해조서와 동일한 내용의 합의가 성립된 것으로 본다 (제33조 제3항). 화해의 효력은 명문상 규정은 없으나, 합의성립확인 또는 재결과 같은 효력이 있다고 보아야 할 것이며, 사업시행자는 조서에서 정한 시기까지 보상금을 지급하거나 공탁하여야 하고, 피수용자는 목적물을 인도·이전해야 하는 의무가 발생하게 된다.

06 화해조서 작성에 대한 다툼

화해조서의 작성은 토지수용위원회의 행정처분이므로, 그 작성절차의 위법을 이유로 하여 화해조서의 효력을 다툴 수 있다. 그러나 일단 유효하게 작성된 화해조서는 그 기초가 된 사법상의 행위가 없었다든가 그 기초가 된 사법상 합의가 유효하게 성립되지 않았다든가 또는 그 사법상의 합의내용이 사실과 다르다는 것을 이유로 당해 합의에 기한 법률관계를 소송대상으로 다툴 수는 없다.

제1절 공용수용의 일반적 효과

01 서

공용수용의 보통절차에 있어서 재결이 있게 되거나, 재결 단계에 이르기 전에 협의성립 및 협의성립의 확인 또는 화해조서작성은 재결로서 간주되므로, 이 경우에도 수용의 효과가 발생한다. 공용수용의 가장 기본이 되는 효과는 사업시행자가 공익사업에 필요한 목적물을 취득하고, 그 목적물에 대한 권리자인 토지소유자와 관계인은 그 권리를 상실하게 되는 권리변동이 생기는 것이다. 사업시행자가 목적물을 취득하는 것은 손실보상금을 수용의 개시일까지 권리자에게 지급하거나 공탁하는 것을 조건으로 그 효력이 발생한다. 즉 사업시행자가 목적물을 취득하는 권리는 토지소유자 또는 관계인의 의무이행을 기다릴 필요 없이 발생하게 되는 것이다.

02 권리변동의 시기

1) 공용수용 절차 종결 시기

공용수용의 절차는 협의의 성립, 재결, 협의성립확인, 화해조서작성으로 종결된다.

2) 공용수용 효과 발생 시기

권리의 취득·상실의 효과는 수용 또는 사용의 개시일에 발생하게 되며, 사업시행자가 그 개시일까지 피수용자에 대한 보상금의 지급 또는 공탁을 하는 것을 조건으로 한다.

이것은 사전보상원칙(제62조)을 보장하고, 수용의 개시일까지 수용목적물의 인도·이전의무(제43조)를 이행하게 하려는 것이며, 재결할 때에는 피수용자의 생활보호를 고려하여 수용의 개시일을 재결사항으로 결정하는 취지(제50조 제1항) 등 때문이다.

03 사업시행자에 대한 효과

1) 권리의 원시취득

사업시행자는 수용의 개시일에 토지나 물건의 소유권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 이와 동시에 소멸한다(제45조 제1항). 수용에 의한 사업시행자의 권리 취득은 권리의 승계취득이 아니라 법률에 의한 원시취득이며(대판 2001. 1. 16. 98다58511, 대판 2000. 7. 4. 98다62961), 그 효과는 대물적으로 모든 권리자에 대해 발생한다. 수용의 개시일이 도래함으로써 소유권 등 종래부터 그 토지상에 존재하던 권리(사법상 권리 또는 공법상 권리를 불문함)가 모두 소멸하고(이를 수용의 대물적 효과라 함), 그것에 대신하여 새로운 소유권이 사업시행자에게 발생한다. 그러나 토지수용위원회의 재결로 인정된 권리는 소멸되거나 그 행사가 정지되지 아니한다(제45조 제3항).

사업시행자는 등기하지 않더라도 수용한 날에 소유권을 취득한다.

그 이유는 수용에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다고 규정된 민법 제187조 본문에 따라 부동산 물권변동 시 취하고 있는 형식주의의 예외를 인정하고 있기 때문이다. 그러나 수용의 경우에도 취득한 소유권을 타인에게 처분하기 위해서는 등기하여야 한다(민법 제187조 단서).

2) 손실보상의무

사업시행자는 천재지변 시 토지사용 또는 시급한 토지사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다(제40조 제1항). 보상금의 지급은 피수용자에 대한 사업시행자의 의무이며, 수용의 정지조건이다. 수용은 보상금의 지급을 조건으로 그 효과가 발생한다.

3) 위험부담의 이전

토지수용위원회의 재결이 있은 후 수용하거나 사용할 토지나 물건이 토지소유자 또는 관계인의 고의나 과실 없이 멸실되거나 훼손된 경우 그로 인한 손실은 사업시행자가 부담한다(제46조).

4) 사용기간 만료 시 반환·원상회복의무

사업시행자는 토지나 물건의 사용기간이 끝났을 때나 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 지체 없이 그 토지나 물건을 그 토지나 물건의 소유자 또는 그 승계인에게 반환하여야 한다(제48조 제1항). 사업시행자는 토지소유자가 원상회복을 청구하면 미리 그 손실을 보상한 경우를 제외하고는 그 토지를 원상으로 회복하여 반환하여야 한다(제48조 제2항).

04 피수용자에 대한 효과

1) 손실보상청구권

토지보상법은 직접 명문의 규정을 두고 있지 않지만, 재결이 있게 되면 사업시행자에 대해 피수용자는 손실보상청구권이 발생하고, 수용의 시기에 사업시행자의 손실보상과 함께 피수용자의 목적물의 인도·이전이 이루어질 때 수용의 효과가 완성된다. 그러나 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다(대판 2008. 7. 10. 2006두19495).

2) 토지·물건의 인도·이전 의무

토지소유자 및 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다(제43조).

3) 담보물권자의 물상대위

담보물권의 목적물이 수용되거나 사용된 경우 그 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금이 채무자에게 지급되기 전에 압류하여야 한다(제47조).

01 사업시행자의 보상금 지급의무

사업시행자는 천재지변 시 토지사용 또는 시급한 토지사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다(제40조 제1항). 보상금의 지급은 피수용자에 대한 사업시행자의 의무이며, 수용의 정지조건이다. 수용은 보상금의 지급을 조건으로 그 효과가 발생한다.

02 보상금의 공탁

1) 의의 및 취지

보상금의 공탁이란 일정한 사유(제40조 제2항)가 있을 때, 사업시행자가 보상금을 공탁함으로써 보상금 지급에 갈음하는 제도이다. 이는 보상금이 미지급되면 재결이 실효되고, 그에 따라 공익사업의 원활한 시행이 불가능하게 되는 등을 고려하여 사전보상원칙을 실현하고, 피수용자의 권익을 보호함에 취지가 있다.

2) 요건

(1) 보상금 받을 자가 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때

사업시행자는 원칙적으로 보상금 채권자인 토지소유자 등의 현주소지에서 보상금을 현실적으로 제공하였음에도 토지소유자가 수령거부를 하였을 때에만 수령거부를 이유로 공탁을 할 수 있다고 할 것이다.

또한 보상금 받을 자가 보상금을 지급하여도 그것을 수령하지 않을 것이 명백하다고 인정되는 경우에는 바로 보상금을 공탁할 수 있다.

‘보상금을 수령할 수 없을 때’란 토지소유자 등의 부재, 주소불명 등 사실상의 수령불능인 경우뿐만 아니라 토지소유자 등이 무능력자로서 법정대리인이나 후견인이 없는 법률상의 불능인 경우도 포함된다.

(2) 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때

우리 공탁제도상 채권자가 누구인지 전혀 알 수 없는 절대적 불확지의 공탁은 허용되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 토지보상법은 절대적 불확지의 공탁을 허용함으로써, 사업시행자는 공탁에 의해 보상금 지급의무를 면하고, 토지에 대한 소유권을 취득하도록 하고 있는 바, 이는 공익을 위하여 신속한 수용이 불가피하기 때문에 사업시행자의 공탁으로 보상금 지급의무를 면하게 하는 것이다.

- ① 수용대상토지가 미등기이고, 토지대장상 소유자란이 공란으로 되어 있는 소유자를 확정할 수 없는 경우,
- ② 수용대상토지가 등기는 되어 있으나, 등기부상에 소유자의 주소표시가 없는 등 소유자를 특정할 수 없는 경우,
- ③ 수용재결 후 보상금 지급 전 토지소유자가 사망하여 그 상속인에게 보상금을 지급하고자 하나, 상속인의 범위 또는 상속지분을 구체적으로 알 수 없는 경우,
- ④ 등기부의 일부인 공동인명부와 토지대장상의 공유자 연명부가 멸실된 토지에 대하여 사업시행자가 토지소유자를 알 수 없어 협의를 할 수 없음을 이유로 재결을 신청하고 수용재결을 얻은 경우 등이 이에 해당한다.

(3) 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 사업시행자가 불복할 때

사업시행자가 재결한 보상금액에 대하여 불복할 때 보상금 받을 자에게 자기가 산정한 보상금을 지급하고 그 금액과 토지수용위원회가 재결한 보상금과의 차액을 공탁하여야 한다.

이 경우 보상금 받을 자는 그 불복절차가 종결될 때까지 공탁된 보상금을 수령할 수 없다(제40조 제4항).

이와 같은 '차액공탁제도'를 인정한 것은 쟁송에 의하여 보상금액이 변경(감액)되었을 때, 그 반환을 쉽게 하기 위한 제도이다.

(4) 압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때

토지소유자 등의 보상금지급청구권에 대하여 일반 채권에 근거한 압류 또는 가압류, 담보권자의 물상대위권 행사에 의한 압류, 처분금지가처분이 있는 경우 공탁이 가능하다. 압류 또는 가압류의 집행이 보상금청구권의 일부에 대하여만 된 경우에는 그 압류 또는 가압류된 부분만을 공탁하면 된다.

3) 공탁의 성질

(1) 문제점

토지보상법상의 공탁이 민법상 변제공탁과 그 성질이 같은 것인지 문제된다.

(2) 학설

- ① 사업시행자가 수용의 개시일까지 보상금을 지급할 수가 없어 수용의 효력이 상실되지 않도록 하기 위해 보상금 지급에 갈음하여 하는 공탁은 채무자가 채무를 변제한 것과 같은 효과를 발생시키기 위하여 변제의 대용으로 행하는 '변제공탁' 즉 민법상 변제공탁과 성질이 같다고 보는 견해가 있다.
- ② 민법상 변제공탁은 당사자 사이의 자유로운 계약에 의하나 토지보상법상 공탁은 국가 공권력에 의한 강제적인 것이고, 토지보상법상 공탁은 보상금 수령할 자가 누구지 알 수 없는 절대적 불확지도 포함한다는 점에서 민법상 변제공탁과 다르다고 하는 견해가 있다.
- ③ 사업시행자가 재결에 불복하여 공탁하는 경우는 일종의 담보공탁, 압류·가압류에 의한 공탁은 집행의 목적물 관리와 집행당사자간의 교부를 공탁절차에 따라 행하는 집행공탁이라 보는 견해가 있다.

(3) 판례

토지수용법 제61조 제2항 제1호에 따라서 토지수용위원회가 재결한 토지수용보상금을 공탁하는 경우, 그 공탁금은 기업자가 토지의 수용에 따라 토지소유자에 대하여 부담하게 되는 보상금의 지급의무를 이행하기 위한 것으로서, 민법 제487조에 의한 변제공탁과 다를 바 없다(대판 1990. 1. 25. 89누4109).
압류·가압류에 의한 공탁에 대하여는 변제공탁으로 보는 듯한 판례와 집행공탁으로 보는 듯한 판례가 있다.

(4) 검토

사업시행자가 보상금을 공탁하는 것은 보상금 지급의무를 면하고자 하는 채무 변제와 같은 효과를 위한 것이므로 변제공탁으로 볼 수 있을 것이다. 그러나 사업시행자가 재결에 불복하여 보상금액의 차액을 공탁한 경우 그 공탁의 성질은 변제공탁이 아니고 일종의 담보공탁이라고 할 수 있다.

4) 공탁의 구체적 내용

(1) 공탁의 당사자

공탁자는 사업시행자이며, 피공탁자는 수용대상토지의 소유자로서 재결서에 기재된 토지 등 소유자가 원칙적으로 피공탁자가 된다. 사업인정고시가 된 후 권리의 변동이 있을 때에는 그 권리를 승계한 자가 공탁금을 받는다(제40조 제3항).

(2) 관할 공탁소

보상금 공탁은 민법상 변제공탁과 그 성질이 같은 것이므로, 보상금을 수령할 토지소유자 또는 관계인이 거주하는 현주소지의 공탁소에 공탁하는 것이 원칙이다. 그러나 토지소유자 또는 관계인이 여러 지역에 산재하여 있는 경우 그 현 주소지를 찾는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 많은 인력과 시간이 소요되기 때문에 예외적으로 토지보상법은 토지 등의 소재지 공탁소에 공탁할 수 있도록 하고 있다(제40조 제2항).

(3) 공탁물

손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 하고(제63조 제1항 본문), 그 예외로서 채권보상을 인정하고 있으므로(제63조 제7항부터 제9항까지), 보상금을 공탁하는 경우에도 현금보상의 경우에는 현금을, 채권보상을 하는 경우에는 채권을 공탁의 목적물로 할 수 있다.

5) 공탁의 효과 및 공탁하지 아니한 경우 효과

(1) 공탁의 효과

토지보상법상 공탁은 변제공탁의 성질을 지니므로, 공탁에 의해 사업시행자는 손실보상의무를 이행한 것이 되고, 수용의 개시일에 토지 등을 취득하는 효과 등 공용수용의 효과가 발생한다.

(2) 공탁하지 아니한 경우 효과

보상금을 공탁하지 않으면 수용의 개시일까지 손실보상의무를 행하지 아니한 것으로 되어, 재결은 실효된다. 판례는 재결이 실효되면 재결신청도 효력을 상실한다고 한다. 보상금의 미지급·미공탁은 재결실효의 효과만을 발생시킬 뿐이며, 사업시행자에게 의무불이행으로 인한 어떤 제재나 의무이행이 강요되는 것은 아니다. 단지 재결실효에 따른 손실보상의무만을 질뿐이다. 이의재결에서 보상금이 증액된 경우, 사업시행자는 재결서 정본을 받은 날부터 30일 이내에 보상금을 지급하거나 공탁하여야 한다(제84조 제2항).

6) 하자 있는 공탁

(1) 하자 있는 공탁의 사유

공탁을 함으로써 보상금을 지급한 것과 같은 효력을 발생시키도록 한 것은 적법한 공탁에 대해서만 인정되는 것이다. 공탁의 하자는 보상금의 지급 또는 공탁을 하지 아니한 경우에 해당하여 재결의 효력이 상실된다. 특히 여기서 문제되는 것은 공탁의 요건에 해당하지 아니하는 공탁, 보상금 일부의 공탁과 수령에 조건을 붙인 공탁의 경우이다.

a. 공탁요건에 해당하지 아니하는 공탁

토지보상법 제40조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우에 한 공탁은 보상금 지급으로서의 효력을 발생하지 못한다.

b. 보상금 일부의 공탁

보상금 일부의 공탁은 공탁원인 자체가 성립하고 있지 않기 때문에 그 일부 공탁이 유효한 것이라고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 공탁은 무효가 되어 보상금을 지급한 것과 같은 효력이 없다.

c. 조건부 공탁

토지소유자 또는 관계인이 이행의무가 없는 반대급부의 제공을 조건으로 한 공탁은 토지소유자 또는 관계인이 그 조건을 수락하지 않는 한 그 조건 뿐만 아니라 공탁 자체까지도 전체가 무효로 된다.

(2) 공탁 하자의 치유

보상금 일부 공탁이나 조건부 공탁은 무효가 되지만, 그 공탁금을 토지소유자 또는 관계인 등 채권자가 수령하면, 채권자가 일부의 공탁이나 조건을 수락한 것이 되어 그 공탁은 공탁일에 소급하여 유효한 것으로 된다. 따라서 사업시행자가 조건을 붙여 공탁한 보상금이라도 이의 유보 없이 이를 수령하면 그 공탁은 유효하다(대판 1983. 6. 14. 81누254).

(3) 하자 있는 공탁금 수령의 효과

a. 이의를 유보하지 않고 수령한 경우

토지소유자 또는 관계인이 사업시행자에게 아무런 이의도 유보함 없이 사업시행자가 지급하는 보상금을 수령한 경우에는 관할 토지수용위원회가 행한 재결에 대하여 승복한 것으로 본다.

b. 이의신청 및 행정소송 제기 후 이의유보 없이 수령한 경우

(가) 견해 대립

- ① 이의신청 또는 행정소송의 제기는 관할 토지수용위원회의 재결에 대한 불복방법으로써, 그 자체를 이의유보로 보아 공탁금을 수령했다 하더라도 재결에 승복한 것이 아니라는 견해가 있다.
- ② 다른 견해는 이의신청이나 행정소송의 제기와 이의유보는 별개의 것으로서 이의신청 및 행정소송의 제기 후라도 이의유보 없이 공탁금을 수령하였다면, 그 토지소유자 또는 관계인은 그 재결에 승복한 것이라고 보아야 한다고 한다.

(나) 판례

기업자가 공탁한 토지수용위원회가 재결에 따른 토지수용보상금을 아무런 이의를 유보하지 아니하고 수령한 토지소유자는 비록 그 재결에 대한 이의를 신청하였다고 하더라도 그 재결에 승복하고 공탁의 취지에 따라 이를 수령한 것으로 보아야 한다(대판 1981. 2. 10. 80누492)고 판시하였다.

또한 토지소유자가 수용재결에서 정한 보상금을 수령할 당시 이의유보의 의사표시를 하였다 하여도 이의재결에서 증액된 보상금을 수령하면서 일부 수령이라는 등 유보의 의사표시를 하지 않은 경우에는 중앙토지수용위원회가 이의재결에서 정한 결과에 승복하여 그 공탁의 취지에 따라 수령한 것이라고 봄이 상당하며, 공탁금수령 당시 이의재결을 다투는 행정소송이 계속 중이라는 사실만으로 공탁금수령에 관한 이의유보의 의사표시가 있는 것과 같이 볼 수는 없다(대 1991.8.27. 90누7081)고 판시하였다.

(다) 검토

재결된 보상금의 공탁을 변제공탁으로 보는 한 공탁금의 수령을 재결에 대한 승복으로 보아야 할 것이다. 그러나 공탁에 하자가 있는 경우 토지소유자 등은 이의신청이나 행정소송의 제기 자체를 이의의 유보를 한 것으로 볼 수 있으므로, 피수용자의 권리보호를 위하여 공탁금 수령 시 불복여부에 관한 사항을 확인하는 절차를 마련하여 불이익을 방지할 필요가 있다.

c. 이의를 유보하고 수령한 경우

피공탁자가 하자 있는 공탁에 대하여 이의를 유보하고 그 공탁된 보상금을 수령한 경우에는 공탁의 취지에 따라 공탁금을 수령한 것으로 볼 수 없기 때문에 무효가 된 공탁의 하자가 치유될 수 없다(대판 1993. 8. 24. 92누9548). 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 불복한다는 의사를 유보하고 보상금을 수령한 경우에는 토지소유자 또는 관계인은 그 재결에 승복하지 아니한 것이 된다(대판 1987. 5. 12. 86누498). 이의유보의 의사표시는 사업시행자에게 하되, 공탁공무원에게 하여도 되며, 보상금 수령 전 그 의사를 표시하여야 하고, 의사표시의 형식은 정해져 있지 않으나 '재결에 불복' 또는 '보상금 중 일부의 수령' 등 관할 토지수용위원회에 재결에 승복하여 보상금을 수령하는 것이 아님을 분명히 표시함으로써 족하다(대판 1987. 2. 24. 86누759).

01 인도 및 이전의무

1) 의의

토지소유자나 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다(제43조).

수용·사용에 있어서 ‘인도’란 토지·물건 등의 점유, 즉 사실상 지배를 사업시행자에게 양도함을 말하며 권리는 물론 수용목적물 자체를 대상으로 한다. ‘이전’은 물건 등의 유용성을 유지하면서 사업시행지 이외의 지역으로 옮기는 것으로 수용목적물이 아닌 것을 대상으로 한다. 인도와 이전의무는 공익사업의 원활을 위한 것으로서 토지소유자와 관계인뿐만 아니라, 사업인정고시 후 새로이 권리를 취득한 자 또는 불법점거자와 같이 피수용자가 아닌 제3자에게도 부여된 것으로 새겨진다.

인도·이전의 권리자는 사업시행자이다. 다만, 사업시행자가 수용목적물의 권리를 취득하는 날은 수용의 개시일이므로, 수용목적물의 인도·이전에 관한 사업시행자의 권리는 소유권에 의거하는 것이 아니고, 재결의 효과로서 직접 법률에 의해 인정된 수용절차상의 권리이다.

2) 인도·이전 의무가 수용효과의 발생조건인가

피수용자가 인도의무를 이행하지 아니하는 경우에도 수용의 개시일이 도래하면 수용의 효과가 발생하기 때문에 인도의무는 수용효과의 발생조건이 아니라고 보는 것이 일반적이다.

3) 인도·이전의무와 손실보상이 동시이행의 관계인지 여부

- ① 긍정하는 견해는 수용의 시기가 재결에서 정한 날인 수용의 개시일이라 하더라도 그 효과는 사업시행자가 보상금을 지급하거나 공탁하고 피수용자가 목적물을 인도 또는 이전할 때 비로소 발생한다 할 것이므로 양자는 동시이행의 관계에 있다고 한다.
- ② 그러나 목적물의 인도·이전의무를 이행하는 것과 관계없이 사업시행자는 보상금을 지급 공탁함으로써 수용의 시기가 도래함으로써 목적물에 대한 권리를 취득하기 때문에 동시이행의 관계에 있지 않다고 봄이 타당하다. 즉 인도·이전의무의 이행과는 무관하게 사업시행자는 수용의 개시일에 수용목적물을 원시취득하게 된다.

02 토지보상법상 의무이행확보수단

1) 개설

피수용자 등의 수용목적물의 인도·이전의무의 불이행 등에 대하여 토지보상법에는 대행(제44조) 및 대집행(제89조)이 인정되어 제도적 목적의 실현을 공법적으로 보장하고 있다. 또한 토지보상법에는 인도·이전 의무 불이행시 벌칙규정(제95조의2 제2호)을 두어 간접적으로 실효성을 확보하고 있다.

2) 대행

(1) 의의 및 취지

토지·물건을 인도·이전해야 할 자가 고의나 과실 없이 의무를 이행할 수 없거나, 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도·이전할 자를 알 수 없을 때, 사업시행자의 청구에 의하여 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이 인도·이전의무를 대행하는 제도이다(제44조).

공익사업을 원활하게 추진하기 위한 의무이행의 실효성 확보수단이다.

(2) 법적성질

토지보상법 규정상 행정대집행의 일종으로 봄이 타당하고, 직접강제를 인정한 것으로 볼 수는 없다.

(3) 요건

특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은

① 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 자가 고의나 과실 없이 그 의무를 이행할 수 없을 때 또는

② 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 의무가 있는 자를 알 수 없을 때

사업시행자의 청구에 의하여 토지나 물건의 인도 또는 이전을 대행하여야 한다(제44조 제1항).

특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장이 대행하는 경우 그로 인한 비용은 그 의무자가 부담한다(제44조 제2항). 의무자가 그 비용을 내지 아니할 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다(제90조).

(4) 대행청구의 대상이 되는 토지·물건의 범위

인도·이전의무는 사업시행자의 소유권에 기한 의무는 아니므로, 대행청구의 대상범위도 수용목적물뿐만 아니라 사업시행에 방해가 되는 것이면 대행청구의 대상이 된다고 볼 것이다.

3) 대집행 [★★]

(1) 의의 및 취지

대체적 작위의무의 불이행에 대하여 당해 행정청이 스스로 또는 제3자로 하여금 의무를 이행하게 하고, 의무자에게 비용을 징수하는 제도이다. 공익사업을 원활하게 시행하기 위한 의무이행 확보수단이다.

토지보상법 제89조에 근거 규정이 있으며, 토지보상법에서 규정되지 않은 것은 행정대집행법을 따른다.

(2) 요건

a. 토지보상법상 요건

① 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가

② 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금

그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는 사업시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.

이 경우 신청을 받은 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다

(제89조 제1항). 사업시행자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라

직접 대집행을 할 수 있다(제89조 제2항). 사업시행자가 대집행을 신청하거나 직접 대집행을 하려는

경우에는 국가나 지방자치단체는 의무를 이행하여야 할 자를 보호하기 위하여 노력하여야 한다

(제89조 제3항).

b. 행정대집행법상 요건

- ① 법률(법률의 위임에 의한 명령, 지방자치단체의 조례를 포함한다. 이하 같다)에 의하여 직접 명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서
- ② 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우
- ③ 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한
- ④ 그 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는
- ⑤ 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

(3) 대집행 대상에 대한 검토 (인도·이전 의무가 토지보상법상 대집행 대상인지)

a. 문제점

물건의 이전은 의무자가 의무를 이행하지 않을 경우 그 의무가 대체적 작위의무이므로 대집행의 대상이 될 수 있다. 그러나 토지·물건의 인도의무는 대집행에 적합한 대체적 작위의무가 아니므로 대집행에 제한이 따른다. 이와 관련하여 토지보상법 제89조의 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무에 토지·물건의 인도의무까지 포함하여 대집행의 대상이 되는 것으로 볼 수 있는지 논란이 있다.

b. 학설

① 〈부정설〉

토지·물건의 인도의무는 대체적 작위의무가 아니므로 토지보상법 제89조의 규정에 불구하고 대집행할 수 없다는 견해이다. 의무자가 토지나 건물을 신체로 점유하며 인도를 거부할 때에는 그 신체에 실력에 의한 구속을 가함으로써 점유를 푸는 것이 필요하며, 그러한 작용은 대집행에 포함되지 않고 직접강제에 속하는 것으로서, 토지보상법 규정이 그러한 작용까지 허용하고 있다고 볼 수 없다고 한다.

② 〈긍정설〉

토지보상법 제89조 규정이 토지 등 소유자가 그 인도의무를 이행하지 않을 때 시장·군수의 행위에 의해 본인이 당해 토지를 인도한 것과 같은 법적 효과를 발생시키는 것을 인정한 데에 그 기본적 취지가 있다는 것을 전제로 하고 있다고 한다.

c. 판례

대법원은 '인도'에는 명도도 포함되는 것으로 보아야 하고, 이러한 명도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실력 행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 있는 것이 아니라 한다(대판 2005. 8. 19. 2004다2809).

d. 검토

인도의무는 성질상 비대체적 작위의무이므로 대집행의 개념상 인정되기 어려울 것이다. 토지보상법 제89조는 단지 의무라고만 규정하고 있으므로 법치행정의 원리상 명확한 법적 근거 없이 대집행을 비대체적 작위의무까지 확대하여 적용하는 것은 국민의 권익 보호 측면에서 문제가 있다고 판단한다. 따라서 토지보상법 제89조의 규정은 불완전한 규정이라 볼 수 있고, 사업시행자가 공익사업을 원활하게 수행하기 위해서는 악의의 점유행위를 강제할 수 있는 직접강제제도의 도입에 대한 검토가 요구된다.

01 개설

사법상 계약에 있어서 위험부담은 매도인이 진다(민법 제537조). 즉 소유권이 이전되기까지 계약목적물의 멸실·훼손에 의한 손해는 채무자가 부담하게 된다. 그러나 토지보상법 제46조는 민법상 채무자위험부담주의의 예외를 규정하여 피수용자를 보호하기 위한 제도를 마련하고 있다.

02 의의 및 취지

재결이 있다 하더라도 수용의 시기까지는 목적물의 권리가 피수용자에게 있기 때문에 목적물의 멸실·훼손에 대하여는 토지소유자나 관계인이 책임을 져야 한다. 그러나 공용수용의 경우에도 이러한 위험부담을 피수용자에게 지도록 하는 것은 공평의 원리에 비추어 보아 피수용자에게 너무 가혹한 결과가 되기 때문에 토지보상법은 피수용자의 손실과 부담을 최소화하여 완전보상을 실현하기 위하여 이 경우 부담을 사업시행자에게 전가하고 있으며, 이를 위험부담이라 한다(제46조).

03 적용

1) 재결이 있는 후

재결이 있는 후 수용 또는 사용의 목적물이 사업시행자에게 인도 또는 이전되기 이전에 멸실·훼손되었더라도 사업시행자는 재결에서 정한 보상금을 지급해야 하고, 이행불능을 이유로 보상금 지급을 거부하거나 보상금의 감면을 청구할 수 없다. 그러나 재결이 있기 전에는 사업시행자에게 위험부담의 책임이 있는 것은 아니다.

2) 피수용자의 고의나 과실이 없을 것

목적물의 멸실·훼손은 피수용자의 귀책사유에 의하지 아니한 모든 경우를 포괄한다.

따라서 사업시행자의 귀책사유로 인한 경우는 물론이고, 제3자의 불법행위에 의한 경우나 불가항력에 의한 경우 등과 같이 사업시행자나 피수용자 어느 한 쪽에도 귀책사유가 없는 경우도 포함한다. 사업시행자와 피수용자의 귀책사유가 경합하는 경우에는 과실상계의 법리가 적용될 것이다.

04 대상에 대한 검토

위험부담의 이전 문제는 오직 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 경우에 한하며, 목적물의 가격하락의 경우에는 해당되지 않는다. 토지보상법 제67조 제1항에 따라 손실보상액 산정은 재결 당시의 가격을 기준으로 정해지는 것이기 때문이다.

수용재결이 있는 후 목적물에 하자가 숨어 있을 경우도 위험부담의 대상이 되는가 문제된다.

예를 들어 수용목적물인 토지에 폐기물이 묻혀 있는 경우가 그러하다. 이 경우 비록 목적물의 훼손에 해당한다 하더라도 재결이 있기 전부터 하자가 숨어 있었기 때문에 위험부담의 문제가 아니라 손실보상금의 감액 문제로 된다. 목적물에 하자가 숨어 있었다면 사업시행자는 고의·과실을 불문하고 행정소송을 통해 손실보상금의 감액을 요구할 수 있을 것이다.

05 효과

재결 후 수용 또는 사용의 목적물이 사업시행자에게 인도 또는 이전되기 전에 멸실 또는 훼손되었더라도 사업시행자는 재결에서 정한 보상금을 지급하여야 하며, 이행불능을 이유로 보상금의 지급을 거부하거나 보상금의 감면을 청구할 수 없다. 재결이 있기 전에는 사업시행자에게 위험부담의 책임이 있는 것은 아니다. 판례는 댐건설로 인한 수몰지역 내의 토지를 매수하고 지상입목에 대하여 적절한 보상을 하기로 특약하였다면 보상금이 지급되기 전에 그 입목이 홍수로 멸실되었다고 하더라도 매수 또는 보상하기로 한 자는 이행불능을 이유로 위 보상약정을 해제할 수 없다고 판시하였다.

대법원 1977. 12. 27. 선고 76다1472 [재결 전 협의취득이나 위험부담 인정]

수몰예상지역 내의 토지만을 그 지상물과 별도로 매수 또는 보상한다는 것은 좀처럼 예상할 수 없는 것으로 토지와 그 지상물은 불가분의 일체가 되어 수몰의 대상으로서 매수 또는 보상의 대상으로 하였다고 봄이 상당한바 지상입목에 대하여 적절한 보상을 하기로 하고 그에 대한 보상금이 지급되기 전에 홍수로 인해서 멸실되었다고 해서 보상약정을 해제할 수 없다고 함이 마땅하다.

01 물상대위의 의미

물권은 물건을 직접 지배하는 권리이므로 물건이 멸실하면 물권도 소멸하게 된다.

물권 중에서도 교환가치지배권으로서의 본질을 가지는 담보물권에 있어서는 목적물에 대위(代位)하는 가치적 변형물에 미치는 것이 원칙인데, 이것을 물상대위(物上代位)라 한다.

02 물상대위의 인정 범위

수용의 목적물에 유치권·질권·저당권 등의 담보물권이 설정되어 있는 경우에 그 목적물이 수용됨으로 인하여 그 담보물권도 소멸한다(제45조). 토지보상법은 손실보상에 관한 개인별 보상원칙을 채택하고 있어(제64조) 담보물권도 그에 따라 보상을 받게 되는 것이므로, 개인별보상원칙이 적용되는 한 그 보호에 아무런 문제가 없다.

그러나 보상금을 개인별로 산정하지 못하는 경우(제64조 단서) 또는 사업인정고시 후 설정된 저당물권(이 경우 담보물권자는 관계인이 되지 못한다)에 대하여는 그 권리 보호를 위해 이 제도를 인정하고 있다.

03 보상금에 대한 물상대위

담보물권의 목적물이 수용되거나 사용된 경우 그 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금이 채무자에게 지급되기 전에 압류하여야 한다(제47조). 압류는 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있다.

04 물상대위의 효력이 미치는 보상의 범위

토지보상법 제47조의 ‘그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여’가 어떤 범위까지를 말하느냐 하는 것이 문제된다. 수용되는 토지의 가격 이외에 잔여지에 대한 보상금이 이에 포함되는 것은 별다른 의문이 없다. 그 밖에 다른 보상금에 대하여도 효력이 있겠느냐 하는 것인데, 담보물권의 목적물과 직접적 관련성이 없다는 점에서 소극적으로 해석하는 것이 옳다.

토지사용은 공익사업을 위한 일정 기간 사용을 전제로 하기 때문에 사용기간이 만료되거나 사용목적이 없게 되었을 때 본래의 토지소유자에게 반환하는 것이 마땅하다. 사업시행자는 토지의 사용기간이 끝났을 때나 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 지체 없이 그 토지나 물건을 그 토지나 물건의 소유자 또는 그 승계인에게 반환하여야 한다(제48조 제1항). 사업시행자는 토지소유자가 원상회복을 청구하면 미리 그 손실을 보상한 경우를 제외하고는 그 토지를 원상으로 회복하여 반환하여야 한다(제48조 제2항).

01 의미

토지보상법상 환매권(還買權)이란 협의나 수용절차가 완료되고 사업시행자가 토지소유권을 취득한 뒤 **사업의 폐지·변경 등에 의해 그 토지가 불필요하게 되거나 사업에 이용되지 않는 경우** 환매권자가 사업시행자 또는 현재의 소유자에게 일정한 가액을 지불하고 그 토지를 재취득할 수 있는 권리이다. 종전에는 사업인정 전·후 취득에 따라 환매권의 법적 근거를 달리하였으나, 토지보상법에서는 사업인정 전·후와 관계없이 통일적으로 규정을 두고 있다.

02 근거

1) 이론적 근거

피수용자의 감정의 존중에 있다고 보는 견해도 있고, 재산권의 존속보장을 드는 경우도 있으며, 판례와 같이 공평의 원칙을 채택한 견해도 있다. 그러나 다수설은 **피수용자의 감정 존중 및 공평의 원칙**의 견지에서 환매권을 인정한다고 한다.

2) 실정법적 근거

(1) 문제점

환매권은 헌법 제23조의 재산권의 내용에 속하는 것인데, 환매권의 실정법적 근거 없이도 헌법에 의해 환매권 행사가 가능한지 문제된다.

(2) 견해 대립

- ① 헌법원칙설은 헌법 제23조의 취지상 헌법상 요청이므로 헌법 규정이 실정법적 근거가 된다고 한다.
- ② 입법정책설은 헌법상의 요청이 아니라 입법정책에 의한 것이므로 실정법상 근거가 있어야 한다고 한다.

(3) 대법원 및 헌법재판소 입장

대법원은 개별 법령의 규정에 의하여 구체적으로 형성되어야만 인정되는 권리로 보는 반면(대판 1998. 4. 10. 96다52359), 헌법재판소는 헌법상 재산권 보장으로부터 도출되는 것으로서 헌법상의 권리로 보고 있다(헌재 1994. 2. 24. 92헌가15 내지 17 내지 24).

(4) 검토

환매권이 헌법상 당연히 도출되는 것으로 해석하기 어렵고, 개별 법률에 의해 구체적으로 형성되고 보장되어야 행사할 수 있는 것으로 봄이 타당하다. 이러한 점을 고려하여 토지보상법은 협의취득과 수용재결에 의한 취득을 구별하지 않고 다 같이 환매권을 부여하고 있다.

03 법적 성질

1) 공권설과 사권설

(1) 문제점

사업인정 전 협의취득의 경우는 사법상 권리로 보는 데 문제가 없으나, 사업인정 후 취득의 경우는 공권설과 사권설이 대립되고 있다. 쟁송의 형태, 적용법률 등에 논의의 실익이 있다.

(2) 견해 대립

① 〈공권설〉

이 견해는 환매권을 수용을 해제하여 원상회복을 시킬 것을 요구하는 권리로서 공법상 주체에 대하여 사인이 가지는 공법상 권리로 본다. 이 설이 다수설이며, 토지보상법에 의한 권리의 다툼이므로 행정소송법이 정하는 공법상 당사자소송에 의해 다룰 수 있다고 한다.

② 〈사권설〉

이 견해는 환매는 환매권자가 원래의 토지소유자와 포괄승계인에게만 한정되고, 환매권 행사에 의한 취득은 원시취득이 아니며, 개인적 이익을 위해 수용의 목적물을 다시 취득할 수 있는 권리이므로 사권의 성질을 갖는다고 한다.

(3) 대법원 및 헌법재판소

① 대법원의 주류적 입장은 환매권을 사권으로 보며,

② 헌법재판소는 피청구인이 청구인의 환매권 행사를 부인하는 어떤 의사표시를 하였더라도 이는 환매권의 발생 여부 또는 그 행사의 가부에 관한 사법관계의 다툼을 둘러싸고 사전에 피청구인의 의견을 밝히고, 그 다툼의 연장인 민사소송 절차에서 상대방의 주장을 부인한 것에 불과하므로 그것을 가리켜 헌법소원심판의 대상이 되는 공권력의 행사로 볼 수 없다고 하였다(헌재 1994. 2. 24. 92헌마283).

(4) 검토

① 〈사권설 입장〉

환매권은 수용해제권으로 구성되어 있지 않고, 원래의 토지소유자에 의한 토지의 재취득만을 인정하는 것이므로 수용 전 상태로 복원까지는 고려되고 있지 않다. 따라서 환매권자의 이익을 위해 존재하는 사법상 권리라 할 것이다.

② 〈공권설 입장〉

환매권은 이론상으로 볼 때 사업시행자라고 하는 공권력의 주체에 대하여 사인이 가지는 공법으로서의 토지보상법상 권리이므로 공권으로 봄이 타당하다.

2) 형성권

환매권은 환매기간 내에 환매의 요건이 발생하면 환매권자가 수령한 보상금 상당금액을 사업시행자에게 지급하고 일방적으로 의사표시를 함으로써 사업시행자의 의사에 관계없이 성립되는 형성권의 일종으로 보는 것이 타당하다. 대법원은 환매권은 일종의 형성권으로서 재판상이든 재판외이든 그 기간 내에 행사하면 이로써 매매의 효력이 발생한다고 하고 하여 일관되게 형성권으로 보고 있다(대판 1992. 4. 24. 92다4673). 환매권을 형성권으로 볼 때, 의사표시가 행사기간 내에 상대방에게 도달한 때에 비로소 환매권 행사의 효력이 발생한다.

3) 물건적 효력설과 채권적 효력설

(1) 문제점

환매권자는 보상금 상당금액을 지불하고 환매권을 행사하면 토지를 환매할 수 있다. 이 때 토지를 환매할 수 있다는 의미에 대하여 물건적 효력설과 채권적 효력설이 대립하고 있다.

(2) 견해 대립

① 〈물건적 효력설〉

환매는 환매권자의 의사표시만으로 성립하고, 수용토지 현재 소유자의 동의를 요하지 않으므로 바로 소유권이 환매권자에게 이전된다고 한다. 이 경우 소송은 소유권이전확인소송의 유형을 취하게 된다.

② 〈채권적 효력설〉

이 견해는 소유권이 환매권자의 의사표시에 의해 이전되는 것이 아니라, 수용토지 현재 소유자의 동의에 의해 양자 간에 매매계약이 성립하고, 당사자간 채권채무의 관계를 발생시키는 것으로 보는 견해이다. 이 때 소송은 소유권이전등기청구소송을 내지는 소유권이전등기말소청구소송의 유형을 취하게 된다.

(3) 검토

환매의 의사표시만으로 소유권을 회복할 수는 없고, 현재 소유자의 동의에 따라 양자 간에 매매계약이 성립하는 효력이 발생하는 채권적 효력설로 봄이 타당하다.

04 요건

1) 환매권자와 상대방

① 〈환매권자〉

환매권자는 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 “취득일”이라 함) 당시의 토지소유자 또는 포괄승계인이다(제91조 제1항). 환매권자에 관계인은 포함되지 않는다. 포괄승계인은 개인의 경우는 상속인, 법인의 경우는 합병 후의 존속법인 또는 신설법인이다. 환매권은 일신전속적인 성격을 지닌다. 따라서 환매권은 제3자에게 양도할 수 없다. 그러나 환매권자가 환매의 목적물을 환매 받는 것을 조건으로 목적물인 토지를 양도하는 계약의 체결은 가능하다 할 것이다.

② 〈환매의 상대방〉

환매권 행사의 상대방은 사업시행자이지만, 토지가 제3자에게 매각되는 경우도 있을 수 있으므로, 제3자인 현재의 소유자도 환매권 행사의 상대방이 될 수 있다. 그래서 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다고 규정되어 있다(제91조 제5항).

2) 환매의 목적물

(1) 토지소유권

환매의 목적물은 토지소유권이다. 토지의 소유권 이외의 권리 및 토지 이외의 물건 등은 환매의 대상이 되지 않는다. 헌법재판소는 입법자가 건물에 대한 환매권을 부인한 것은 헌법적 한계 내에 있는 입법재량권의 행사이므로 재산권을 침해하는 것으로 볼 수 없다고 한다(헌재 2005. 5. 26. 2004헌가10).

(2) 토지 일부에 대해 선택적 행사 불가능

취득한 토지 전부가 필요 없게 된 경우 환매권자는 그 중 임의의 일부에 대해서만 환매권을 행사할 수 있는지 문제되나, 토지수용에 의한 환매의 목적물을 토지소유권에 한정하고 환매요건에 해당하는 토지가 있을 경우 그 요건에 해당하는 토지 전부에 대하여 환매권을 행사하여야 하며, 그 중 일부만 선택적으로 환매권을 행사할 수는 없다고 할 것이다.

(3) 잔여지만의 환매 불가능

잔여지 매수 또는 수용청구에 관한 규정(제74조)에 의하여 잔여지를 수용한 경우 그 잔여지에 대하여는 잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우가 아니면 원래의 수용 토지를 제외하고 잔여지만을 환매할 수는 없다(제91조 제3항).

3) 행사요건

(1) 행사요건인지 성립요건인지

토지보상법 제91조의 요건에 대하여 환매권의 성립 또는 취득요건이라는 견해와 수용의 완성과 동시에 환매권이 성립하는 것이므로 단지 행사요건에 불과하다는 견해가 있다. 환매권은 취득의 완성과 동시에 법률상 당연히 성립하는 것이므로 행사요건으로 보는 견해가 다수설이다.

(2) 일정 기간 내 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우

a. 토지보상법 제91조 제1항 규정

공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 취득일(협의취득일 또는 수용의 개시일) 당시의 환매권자(토지소유자 또는 그 포괄승계인)는 다음에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

① 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 :

관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날,

② 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 : 사업완료일

헌재 2020. 11. 26.자 2019헌바131

헌법재판소는 토지보상법 제91조 제1항 중 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 “취득일”이라 한다)부터 10년 이내에’ 부분이 재산권의 최소침해원칙에 위배되고(외국 입법례에 비해 사익침해가 크고 10년이 경과하도록 완료되지 못한 공익사업이 150여개 이상인 점 등을 사유로 제시), 법익의 균형성을 충족하지 못한다고 하여 헌법불합치 판결을 하였다.

판례는 시행자 지정이 처음부터 효력이 없거나 토지의 취득 당시 해당 도시계획시설사업의 법적 근거가 없었던 것으로 볼 수 있는 등 협의취득이 당연무효인 경우, 협의취득일 당시의 토지소유자가 소유권에 근거하여 등기 명의를 회복하는 방식 등으로 권리를 구제받는 것은 별론으로 하더라도 토지보상법 제91조 제1항에서 정하고 있는 환매권을 행사할 수는 없다고 판시하였다.

b. '해당 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유'의 의미

'해당 사업'이란 토지 취득의 목적이 된 구체적인 특정 공익사업을 가리키는 것이다. '사업의 폐지·변경'이란 토지보상법상 사업의 폐지 및 변경 또는 개별법에 의한 사업인정이 의제되는 행위의 철회·변경을 말하는 것으로서, 해당 사업을 폐지하는 것만이 아니라 다른 사업으로 전환하는 것도 포함하고 있다. '그 밖의 사유'란 관계법에 의하여 사업의 폐지·변경 또는 그에 갈음하는 행위로 더 이상 목적사업에 제공할 필요가 없게 된 객관적 사유를 뜻한다.

c. '필요 없게 된 때'의 의미

'필요 없게 된 경우'란 토지를 사업에 이용할 필요가 없게 된 경우를 말하고, 당초부터 사업에 이용하고 있지 않은 경우와 일단 사업에 이용한 뒤 사후 불필요하게 된 경우를 포함한다. <대법원>은 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우란 사업시행자가 취득한 토지의 전부 또는 일부가 그 취득 목적 사업을 위하여 사용할 필요 자체가 없어진 경우를 말하며, 필요 없게 되었는지 여부는 사업시행자의 주관적인 의사를 표준으로 할 것이 아니라, 당해 사업의 목적과 내용, 협의취득의 경위와 범위, 당해 토지와 사업의 관계, 용도 등 제반 사정에 비추어 객관적·합리적으로 판단하여야 한다고 한다(대판 2010. 9. 30. 2010다30782).

d. 행사기간

환매권의 행사기간 준수 여부는 법원의 직권조사사항에 해당한다.

(3) 일정기간 경과 후 취득한 토지 전부를 이용하지 아니한 경우

a. 토지보상법 제91조 제2항 규정

취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 취득일부터 6년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금 상당 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

b. '사업에 이용하지 아니하였을 때'의 의미

사업에 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라, 단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우를 말한다. 사업시행자의 태만 등에 의해 사업을 착수하지 않은 것은 물론 통상의 사업실시보다도 현저하게 늦게 사업이 실시되고 있는 경우도 포함되는 것으로 보고 있다.

c. '토지의 전부'의 의미

취득된 토지의 일부만이 공익사업에 이용되고 있으면 이 요건에 해당하지 않게 된다. 즉 취득 토지의 일부만이 사업에 제공되고 나머지 일부가 객관적으로 불필요하게 된 때에는 이 규정이 아니라 동조 제1항 규정 요건에 해당되어 환매권을 행사할 수 있도록 하고 있다.

(4) 환매요건의 경합

위의 두 경우는 그 요건을 서로 달리하고 있으므로, 어느 한 쪽의 요건에 해당하면 다른 쪽의 요건을 주장할 수 없게 된다고 할 수는 없고, 양 쪽의 요건에 모두 해당된다고 하더라도 더 짧은 제척기간을 정한 토지보상법

제91조 제2항에 의하여 제1항의 환매권 행사가 제한된다고 할 수도 없다. 따라서 제2항 규정에 의한 제척기간이 경과되었다 하더라도 제1항 규정에 의한 환매권 요건에 해당할 경우 환매권을 행사할 수 있다(대법 1995.2.10. 선고94다31310 판결).

(5) 통지·공고한 경우 행사기간

환매권자는 제1항에 따른 통지를 받은 날 또는 공고를 한 날부터 6개월이 지난 후에는 제91조 제1항 및 제2항에도 불구하고 환매권을 행사하지 못한다(제92조 제2항). 대법원은 기업자가 환매권자가 통지하거나 공고한 경우에는 그 통지를 받은 날 또는 공고의 날로부터 6개월 이내에 환매권을 행사할 수 있고, 기업자가 환매통지나 공고를 하지 않은 경우라 하더라도 환매권자는 환매권을 행사할 수 있다고 판시한바 있다(대판 1993. 8. 24. 93다16192).

05 환매금액

1) 지급받은 보상금 상당금액

환매를 하기 위해서는 단지 환매의 의사표시만으로는 부족하고, 환매금액을 현재 소유자에게 지불해야 한다. 환매금액은 “그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액”이다(제91조 제1항).

2) 토지가격이 취득일 당시에 비해 현저히 변동된 경우

(1) 의미

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우는 환매권 행사 당시의 토지가격이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다(령 제48조). <대법원>은 이 경우 환매가격은 보상금에다 환매 대상 토지의 환매 당시의 감정평가금액에서 보상금에 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액을 공제한 금액을 더한 금액이고, 인근 유사토지의 지가변동률이란 환매 대상 토지와 지리적으로 인접하고 그 공부상 지목과 토지의 이용상황 등이 유사한 토지의 지가변동률을 말하나, 합리적인 지가변동률을 산출할 수 있을 정도의 토지를 선정하면 족하다고 한다(대판 2000. 11. 28. 99두3416).

(2) 금액의 협의 및 협의불성립 시 법원에 청구

토지보상법은 토지 등 가격이 현저히 변동되어 협의가 성립되지 아니할 때 환매 당사자가 법원에 청구하여 이 문제를 해결하도록 하고 있다. 즉 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다(제91조 제4항). 이는 사정변화가 발생한 뒤에도 취득일 당시의 보상금 상당액으로 환매를 인정하게 되면 지가 등 상승으로 인한 모든 이익을 환매권자에게 취득시키는 결과가 되어 현재 소유자에게 환매대금의 증액 청구권을 인정하는 것이다. 결국 공익사업의 시행으로 발생하는 개발이익은 그 비용의 부담자인 사업시행자를 통하여 궁극적으로는 공익에 귀속되어야 할 것이지 특정의 토지소유자에게 귀속될 성질의 것이 아니어서 환매권자에게 이를 보장해 줄 수 없다는 것이다(헌재 2005. 4. 28. 2002헌가25).

(3) 소송으로 증액청구

판례는 환매는 수용의 해제가 아니라 사법상의 행위라고 보아 금액 증감의 청구는 민사소송으로 해야 한다고 본다. 위 증감청구소송은 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증감청구소송과 다른 소송이다.

06 절차와 방법

1) 환매통지·공고 [★★]

(1) 사업시행자의 환매권 통지 의무

사업시행자는 환매할 토지가 생겼을 때에는 지체 없이 그 사실을 환매권자에게 통지하여야 한다.
다만, 사업시행자가 과실 없이 환매권자를 알 수 없을 때에는 공고하여야 한다(토지보상법 제92조 제1항).
판례는 환매권 통지규정이 단순히 선언적인 것이 아니라 사업시행자의 법적인 의무라고 한다. 이는 법률상 당연히 인정되는 환매권 행사의 실효성을 확보하기 위한 것으로 법적 의무로 봄이 타당하다. 사업시행자의 환매통지는 환매권 행사의 요건이 아니라 일종의 최고(催告)에 불과하기 때문에 사업시행자의 환매통지가 없는 경우라도 환매요건이 발생하면 환매권자는 환매권을 행사할 수 있다.

(2) 통지의무 위반으로 환매권 행사기간이 도과한 경우

a. 학설 및 판례

일부 견해는, 환매권은 형성권으로서 자기의 의사결정에 따라 행사 가능한 권리이며, 단순 통지의무 불이행이 불법행위를 구성하지는 않는다고 한다.

판례는 사업시행자가 통지, 공고를 하지 않아 환매권 행사가 불가능하게 되어 환매권을 상실하게 하는 손해를 가한 때에는 불법행위를 구성한다고 판시하고 있다.

b. 검토

환매권의 통지 의무는 법적의무이고, 환매권의 의의 및 기능을 감안할 때, 이를 위반한 것은 불법행위로 평가함이 타당하다.

2) 환매의 협의

사업시행자는 환매권자의 환매에 대한 의사표시가 있게 되면 서로 협의하여야 하고, 환매권자가 협의에서 정해진 환매가격을 지급함으로써 환매가 성립한다. 환매는 법률상 환매권자의 권리로서 인정되기 때문에 환매권자의 일방적인 의사표시로 성립하며, 사업시행자의 환매동의를 요하지 아니한다. 헌법재판소는 환매권의 행사는 형성권의 행사로서 사업시행자의 동의를 얻어야 하거나 의사여하에 따라 효과가 좌우되는 것이 아니라 한다(헌재 1995. 3. 23. 91헌마143).

3) 환매권의 행사방법 및 행사의 효력발생 시점

사업시행자는 협의취득 또는 수용 토지 전부 또는 일부가 사업을 위해 이용하지 않은 경우 이를 환매권자에게 통지할 의무가 있다. 이 통지는 환매권 행사의 최고이자 매매의 신청으로 볼 수 있다. 이에 대하여 환매권자가 법정 기간 내에 환매의 통지를 하면 바로 매매의 승낙에 상당하고, 매매계약이 성립하여 사업시행자는 그 토지 소유권을 환매권자에게 이전해야 할 의무가 발생하게 된다. 대법원은 환매 의사표시가 상대방에게 도달한 때 환매권 행사의 효력이 발생한다고 본다.

07 환매권 행사의 효과

1) 환매권 행사의 효력발생 시점

환매권자는 환매금액을 지급한 후 환매의사를 표시함으로써 환매권을 행사한다. 이 때 환매권 행사의 효력이 발생하는 시점은 **환매 의사표시가 상대방인 사업시행자에게 도달한 때가 될 것이다**(판례 동지).

2) 견해에 따른 환매권의 효과

- ① 물건적 효력설의 입장에서는 소유권 이전의 효과가 발생한다고 한다.
- ② 채권적 효력설의 입장에서는 **소유권이전등기청구** 또는 **소유권이전등기말소청구권**이 발생하는 효과가 있다고 한다. 판례는 환매권을 사권으로 보면서 환매권 행사의 효과를 채권적 효과로 보아, 사법상 매매계약의 효력이 생기는 것으로 보면서 **소유권이전등기 청구권**이 발생하고, 이 청구권은 10년을 시효로 소멸한다고 한다.

3) 대항력

환매권은 「부동산등기법」이 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 **협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때**에는 제3자에게 대항할 수 있다(제91조 제5항). 여기에서 ‘제3자에게 대항할 수 있다’고 하는 것은 토지 등 협의 취득 또는 수용의 목적물이 제3자에게 양도되더라도 등기 또는 환매권의 보류등기가 되어 있는 경우에는 제3자가 그 환매권자에 대하여 권리가 있음을 주장하지 못한다는 의미이다.

08 환매권의 소멸

1) 사업시행자의 통지나 공고가 있는 경우

환매권은 통지를 받은 날 또는 공고한 날로부터 6월의 기간이 경과함으로써 소멸하게 된다(제92조 제2항).

2) 사업시행자의 통지나 공고가 없는 경우

사업시행자의 통지나 공고가 없는 경우, 토지보상법 제91조 제1, 2항에서 정한 기간에 환매권을 행사하지 않으면 환매권은 소멸한다.

09 환매권에 대한 다툼

1) 행사요건에 관한 다툼

- ① 환매권을 공권으로 보는 입장에서는 공법상 당사자소송으로 다툼 수 있다.
- ② 환매권을 사권으로 보는 입장에서는 **민사소송**으로 다투되, **소유권이전등기청구권**에 대한 확인 또는 이행청구, **소유권이전등기말소청구권**에 대한 확인 또는 이행청구가 그 내용이 될 것이다. 실무상 민사소송으로 다루어지는 경우가 대부분이다. 그리고 판례는 사업시행자는 소로써 법원에 환매대금의 증액을 청구할 수 있을 뿐 환매권 행사로 인한 **소유권이전등기 청구소송**에서 환매대금 증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액을 지급할 것을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 없다고 판시하였다(대법원 2006다49277).

2) 환매금액에 관한 다툼 (91조 4항)

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의 하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 **법원에 청구**할 수 있다. 환매금액의 증감을 구하는 소송은 민사소송에 해당한다(대법원 2010두22368).

10 공익사업 변환 [★★★]

1) 의의 및 취지

공익사업변환이란 공익사업의 토지취득 후 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 취득절차 없이 다른 공익사업에 이용하도록 하는 제도이다(제91조 제6항). 공익사업을 위해 토지를 재취득하는 무용한 절차의 반복을 방지하기 위한 제도이다.

2) 제도의 내용

공익사업 변환은 새로운 공익사업에 관해서도 사업인정을 받거나 또는 사업인정을 받은 것으로 의제하는 다른 법률 규정에 의해 사업인정을 받은 것으로 볼 수 있는 경우에만 공익사업의 변환에 의한 환매권 행사의 제한을 인정할 수 있다(대판 2010. 9. 30. 2010다30782).

3) 요건

① <변경 전 사업시행자 요건>

사업인정을 받은 사업시행자가 국가·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이어야 한다.

② <대상사업 요건>

㉠ 변경 전 공익사업은 사업인정을 받아야 하고, 변경 후 공익사업은 토지보상법 제4조 제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업이어야 한다.

㉡ 새로운 공익사업은 사업인정을 받거나 받은 것으로 의제되어야 한다.

㉢요건은 토지보상법 규정상 없으나, 판례가 일관되게 요구하는 요건에 해당한다.

③ 다른 공익사업으로 변경된 경우 국가, 지방자치단체, 공공기관은 공익사업이 변경된 사실을 환매권자에게 통지하여야 한다(제91조 제6항 후단).

④ 변경된 사업시행자 아닌 제3자에게 처분되지 않아야 한다.

심화

구분	공익사업	사업시행자
변환전	사업인정 득	국가, 지자체, 공공기관
변환후	토지보상법 4조 1호~5호 사업 (공익성이 높은 사업) 사업인정 또는 사업인정 의제 득	국가, 지자체, 공공기관일 필요 없음 (대판 2014다201391) 변경전, 후 사업시행자가 바뀐 경우에도 인정됨 (대판 93다11760)

4) 기산일 규정의 해석

- ① ‘환매권 행사기간은 관보에 당해 공익사업 변경을 **고시한 날로부터 기산한다.**’는 의미는 새로 변경된 공익사업을 기준으로 다시 환매권 행사의 요건을 갖추지 못하는 한 환매권을 행사할 수 없고, 환매권 행사요건을 갖추어 행사할 수 있는 경우에 그 환매권 행사기간은 당해 공익사업 변경을 관보에 고시한 날로부터 기산한다는 의미로 해석해야 한다는 것이다(대판 2010. 9. 30. 2010다30782).
- ② 공익사업 변환을 인정한 입법 취지 등에 비추어 볼 때, 사업인정을 받은 당해 공익사업의 폐지·변경으로 인하여 취득한 토지가 필요 없게 된 때라도 위 규정에 의하여 공익사업 변환이 허용되는 다른 공익사업으로 변경되는 경우에는 환매권자에게 환매권이 발생하지 않는다는 취지를 규정한 것이다(대판 2010. 9. 30. 2010다30782).

5) 사업시행자의 동일성 문제

(1) 문제점

토지보상법 규정상 변경 전 사업시행자에 관한 규정은 존재하나, 변경 후 사업시행자가 누구인지에 대한 규정은 없기 때문에, 공익사업 변환이 사업시행자가 동일한 경우에만 인정될 수 있는 것인지 문제된다.

(2) 견해 대립

- ① 공익사업 변환은 그 인정 자체가 보다 높은 공익성을 갖는 사업으로의 전환을 의도하는 것이므로 사업시행자의 변경까지 제한하는 것은 아니어서 변경시에도 적용된다는 견해와
- ② 사업시행자 변경시 폐지된 공익사업시행자가 아무런 이유 없이 토지가액의 변동으로 차액을 얻게 되는 불합리함이 있으므로 동 규정은 적용할 수 없다는 견해가 있다.

(3) 대법원

대법원은 구「토지수용법」등 관계 법령의 규정 내용이나 그 입법 이유 등으로 미루어 볼 때 공익사업 변환이 국가, 지방자치단체 또는 정부투자기관 등 **사업시행자가 동일한 경우에만 허용되는 것은 아니라 한다** (대판 1994. 1. 25. 93다11760, 11777, 11778 병합 판결).

(4) 검토

공익사업변환제도는 공공필요의 소멸이라는 수용본질의 한계상 인정되는 것으로 이러한 취지에 반하는 예외적 규정은 좁게 해석함이 국민의 권리구제에 유리하다. 또한 현실적으로 행정청의 용도담합에 의해 환매권이 형해화(形骸化)되는 결과를 초래할 우려가 있으므로, 사업시행자 변경시에는 공익사업 변환은 인정되지 않는 것으로 봄이 타당하다.

6) 변환의 효과

공익사업 변환이 인정되면, 공익사업의 폐지·변경으로 인해 취득한 토지가 필요 없게 되더라도 환매권을 행사할 수 없다. 즉 변경된 공익사업의 내용을 관보에 고시한 때부터 환매권 행사기간을 다시 기산하여 **환매권 행사기간이 연장되는 효과가 발생하게 된다.**

7) 제도의 위헌성

(1) 문제점

환매권 행사기간의 기산점을 공익사업 변경고시일로 늦추도록 한 것은 실질적으로 환매권을 폐지하는 의미를 지니는 것으로 해석된다. 이는 헌법상 보장된 환매권을 법률로 제한하는 것으로서, 기본권의 본질적 내용을 침해하는 제한으로서 비례의 원칙에 위반되는지 문제된다.

(2) 합헌설 및 헌법재판소 입장

공익사업의 원활한 시행을 위한 목적에서 만들어진 것으로, 우선 그 입법 목적에 있어 정당하고, 사업 목적 또한 공익성이 높은 공익사업으로 한정하고 있어서 그 입법목적 달성을 위한 수단으로서 적정성이 인정될 뿐만 아니라, 피해최소성의 원칙 및 법익균형의 원칙에도 부합된다 할 것이므로 기본권 제한에 관한 과잉금지원칙에 위배되지 아니한다고 한다.

(3) 위헌설

원래의 공익사업의 폐지·변경 등을 이유로 원소유자가 환매권을 행사할 수 없도록 제한하는 것은 공익사업의 원활한 시행 확보라는 행정편의만을 중시한 일방적인 것이며, 비례의 원칙에도 위배될 뿐만 아니라 환매권의 본질적인 내용을 침해하는 제한으로 환매권 제도를 형해화하는 것이라 한다. 또한 공익사업이 변환되는 경우와 그렇지 않은 경우 사이에 형평이 취해지지 않아 평등권 침해 문제를 야기하므로 위헌의 소지가 있다고 한다.

(4) 검토

① 〈위헌설〉

이 제도는 사실상 환매권을 폐지하는 제도와 같으며, 적용되는 사업에 있어 형평의 문제로서 평등권 침해 문제, 행정편의만을 중시한 제도 등이라는 점 등을 고려할 때, 위헌소지가 있다.

② 〈합헌설〉

토지보상법은 공익사업의 원활화를 위해 제한적으로 공익사업 변환을 제도화하고, 변환 전 사업시행자 및 변환 후 공익성 높은 사업으로 한정하여 전환을 허용하는 점 등을 볼 때, 위헌으로 볼 것은 아니다. 그러나 이 제도는 어디까지나 예외적인 경우에 허용되는 것에 불과하므로, 공적 사업시행자의 편의를 앞세워 입법이 자행되어서는 안 될 것이다.

제1절

개설

토지수용에 대한 불복은 재결에 불복하는 자가 다른 행정행위와 마찬가지로 쟁송 절차에 따라 이의 취소·변경을 구하는 것을 말한다. 재결에 대한 불복수단은 토지보상법에 이의신청, 취소소송, 보상금증감청구소송으로 구성되어 있다. 토지보상법은 재결의 취소·변경을 구하는 행정쟁송에 대하여 행정심판법과 행정소송법에 대한 약간의 특례를 규정하고 있다. 따라서 토지보상법의 특례규정 외에는 행정쟁송에 관한 일반법인 행정심판법과 행정소송법이 적용된다. 재결에 대한 행정쟁송은 재결에 대한 불복수단에 불과하기 때문에 이에 대한 쟁송이 제기되더라도 사업의 진행 및 토지의 수용·사용은 정지되지 않는 처분효력부정지의 원칙이 적용된다(제88조). 이는 재결이 있는 후 피수용자의 불복에 불구하고 공익사업을 진행시켜 사업의 원활을 기하고자 함에 있다.

심화

수용재결 불복방법

1. 가능한 방법

- ① 수용재결 → 이의재결 → 보증소 (보상금증감청구소송)
- ② 수용재결 → 보증소

2. 불가능한 방법

- ① 수용재결 → 행정심판 (이의재결은 특별행정심판의 성격이 있기 때문,
이의재결이 아닌 일반적인 행정심판을 제기할 수 없음)
- ② 수용재결절차 없이 보증소 (불가!)
cf) 토지, 지장물, 영업보상, 잔여지, 사업폐지 보상 등 내용을 구분하지 않고 토지보상법에 따른 보상은
수용재결을 반드시 거쳐야 함. 잔여지 가치하락 및 매수청구의 경우 편입지에 대한 수용재결을 거쳤다
하더라도, 생략할 수 없음

심화

수용재결 전치주의

1. 문제점

수용재결을 거치지 않고 곧바로 이의신청이나 보상금증액청구소송을 제기할 수 있는지 문제된다.

2. 수용재결 전치주의의 개념

수용재결전치주의는 행정소송을 제기하기 앞서 토지수용위원회의 재결을 거쳐야 하는 것을 의미한다.

3. 토지보상법 제85조 제1항 태도

위 규정은 불복의 대상을 “84조 재결이 아닌 “제34조 재결”이라고 규정하는바,
수용재결 전치주의를 취한 것으로 볼 수 있다.

4. 관련 판례

판례 역시 토지보상법 제85조의 행정소송을 제기하기 위해서는 규정 문언상 수용재결을 반드시 거쳐야 한다고 판단하였고, 이는 행정감독의 효과를 도모하고, 사건을 전문적·기술적으로 처리함으로써 전체적으로 국민의 권리구제 도모에 그 취지가 있다고 보았다(94누1410판결 참조).

심화

보증소로 다투는 경우

1. 토지보상법 9조 6, 7항 준용 시 토지수용위원회의 재결에 불복하는 경우 보증소로 다툼

(애초에 보상액에 관해 협의가 안 돼서 신청한 재결이기 때문)

2. 토지보상법 9조 6, 7항 :

손실보상은 사업시행자와 손실 입은 자가 협의하여 결정한다.

협의 불성립 시 사업시행자나 손실 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

3. 동법 9조 6, 7항 준용 규정

① 타인토지 출입으로 인한 손실 발생 :

공익사업 준비 단계(9조), 장애물 제거 등(12조), 사업인정 고시 이후 토지물건 등 조사 시 발생한 손실(27)

② 실효로 인한 손실 발생 :

사업인정 고시가 된 날로 1년 이내 재결신청 하지 않아 사업인정 실효된 경우(23조),

사업의 전부 또는 일부 폐지·변경으로 인한 손실(24조), 재결의 실효로 인한 손실(42조)

③ 약식사용절차 :

천재지변 시 토지의 사용으로 인한 손실(38조)

④ 잔여지·잔여건축물 손실과 공사비보상 등 :

73조, 75조의2

4. 형성권적 성질로 인해 재결 불복 시 보증소로 다투는 경우 :

72조 완전수용, 74조 잔여지수용청구권

5. 토지보상법 9조 6, 7항과 동일 논리 :

80조 2항 재결에 불복

01 의의 및 취지

이의신청이란 토지수용위원회의 위법 또는 부당한 재결처분으로 인해 권리이익을 침해당한 자가 중앙토지수용위원회에 그 취소 또는 변경을 구하는 절차이다. 토지수용과 관련한 공익사업을 신속히 수행해야 할 특수성을 살리고, 간편한 절차로 분쟁을 신속히 해결하여 이해관계자의 권리관계를 조속히 안정시키고자 하는 목적의 정당성과 필요성에서 인정되는 제도이다.

02 법적 성격

- ① 쟁송을 제기한 자의 권리이익을 직접 목적으로 하는 주관적 쟁송이다.
- ② 판례는 재결처분의 위법 또는 부당을 이유로 그 시정을 구하는 절차로서 특별행정심판으로 본다.
- ③ 토지수용위원회의 재결처분의 위법 또는 부당함을 이유로 그 효력을 다투는 것이므로 복심적 쟁송이다.
복심적 쟁송이란 이미 행해진 행정작용의 하자를 이유로 그 재심사에 의한 시정을 구하는 쟁송을 말한다.
- ④ 이의신청은 심판절차를 서면심리주의에 의하고 구두변론은 원칙적으로 인정되지 않는 점에서 약식쟁송이다.
그러나 심판기관이 이해관계가 없는 제3자라는 점에서는 정식쟁송과 같다.

03 임의절차 여부

구 토지수용법은 이의신청을 필요적 전치절차로 규정하고 있었다. 현행 토지보상법 제83조는 “이의를 신청할 수 있다”라고 규정하고 있어, 행정소송법 제18조의 행정심판 임의주의와 균형을 유지하여 임의적 절차임을 규정하고 있다.

04 제기요건

- ① 재결에 대하여 이의가 있는 자가,
- ② 재결서正本 송달일로부터 30일 이내에(제83조 제3항),
- ③ 문서로써(령 제45조),
- ④ 처분청을 경유하여 중앙토지수용위원회에 제기하여야 하고(제83조 제1, 2항),
- ⑤ 사업시행자가 불복하는 경우 자기의 예정금액은 지급하고, 그 차액은 공탁한 후에 제기할 것의 요건이 있다.
이 경우 소유자가 공탁된 금액을 이의신청재결의 종결 시까지 수령하지 못한다.
- ⑥ 토지보상법에 없는 규정은 행정심판법을 따른다.

05 제기효과

이의신청이 제기되면 중앙토지수용위원회는 이의신청에 대하여 심리·재결해야 할 의무를 진다. 한편 이의신청 제기는 사업의 진행 및 토지의 수용 또는 사용을 정지시키지 아니한다(제88조). 다만, 행정심판법상 예외적으로 요건이 충족되면 집행정지가 가능할 것이다.

06 심리

토지보상법상 특별한 규정이 없는 바, 행정심판법에 따라 서면심리주의, 비공개주의, 변론주의 원칙에 따른 직권심리주의를 따른다. 심리범위는 불고불리의 원칙, 불이익변경금지 원칙이 적용된다. 요건심리는 이의신청제기 요건 충족 여부를 심리하는 것으로서, 제기요건이 부적법하면 이의신청을 각하하고, 제기 요건을 갖춘 적법한 것인 때에는 본안심리에 들어간다. 본안심리는 실질적 심사로서, 이의신청의 본안인 행정처분의 위법 또는 부당 여부를 심리하는 것이다. 중앙토지수용위원회는 이의신청서가 접수되면 이의신청의 상대방에게 이의신청에 대한 반대 의견과 재결심의에 필요한 자료를 요청한다. 이의신청 사유가 보상금의 다툼인 경우에는 재평가하되, 평가기관은 협의 평가나 수용재결 시 이미 평가한 기관은 제외시키며, 평가시점은 수용재결일(수용개시일, 가격조사완료일이 될 수 없다)이 된다.

07 이의재결

1) 이의재결의 내용

중앙토지수용위원회는 이의신청을 받은 경우 재결이 위법하거나 부당하다고 인정할 때에는 그 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다(제84조 제1항). 따라서 이의신청에 대한 재결은 재결로 정한 모든 사항에 대하여 가능하다(대판 1995. 12. 8. 95누5561).

2) 재결의 형식 및 종류, 재결서의 송부

재결은 주문(主文)과 재결 이유 및 재결 일자 등을 기재한 문서로 하여야 한다. 재결의 종류에는 각하재결, 기각재결, 인용재결, 사정재결이 있다. 변경재결은 이의신청에서 당사자 간의 다툼이 보상금인 경우 재평가 결과 재평가 금액이 수용재결액보다 많을 때 재평가한 금액으로 보상금을 변경하는 경우이다. 중앙토지수용위원회는 이의신청에 대한 재결을 한 경우에는 재결서의 정본을 사업시행자·토지소유자 및 관계인에게 송달하여야 한다(령 제46조).

3) 이의재결의 효력

(1) 증액된 보상금의 지급 또는 공탁

보상액을 변경할 수 있는 규정(제84조 제1항)에 따라 보상금이 늘어난 경우 사업시행자는 재결의 취소 또는 변경의 재결서 정본을 받은 날부터 30일 이내에 보상금 받을 자에게 그 늘어난 보상금을 지급하여야 한다(제84조 제2항). 다만,

- ① 보상금 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없을 때(제40조 제2항 제1호),
- ② 사업시행자가 과실 없이 보상금 받을 자를 알 수 없을 때(제40조 제2항 제2호),
- ③ 압류나 가압류에 의하여 보상금 지급이 금지된 때(제40조 제2항 제4호)에는 그 금액을 공탁할 수 있다(제84조 제2항).

(2) 이의재결의 확정

이의재결에 대하여 출소기간 규정(제85조 제1항)에 따른 기간 이내에 소송이 제기되지 아니하거나 그 밖의 사유로 이의신청에 대한 재결이 확정된 때에는 「민소소송법」상 확정판결이 있는 것으로 보며, 재결서 정본은 집행력 있는 판결의 정본과 동일한 효력을 가진다(제86조 제1항). 따라서 민사소송의 제기 없이 강제집행이 가능하다.

수용재결은 수용개시일까지 보상금을 지급하지 않으면 재결이 실효되므로 보상금 지급여부에 대한 다툼이 없다. 그러나 이의재결에 대하여는 그러한 규정이 없어 사업시행자는 이의재결 내용대로 보상금 지급의 이행을 마음대로 할 수 있고, 그렇게 되면 피수용자는 그 재결이 있었다 하더라도 그 내용의 이행 실현을 위해 그것을 근거로 다시 민사소송을 청구해야 하는 등 곤란을 겪어야 한다. 또한 사업시행자 입장에서도 피수용자가 언제 또 소송을 제기할지 그 지위가 불안정하므로, 이러한 문제들을 한꺼번에 해결하는 것에 이 제도의 취지가 있다. 즉 확정된 재결에 민사소송법상 확정판결과 동일한 효력을 부여함으로써 사업시행자가 보상금 지급을 게을리 하였을 때, 집행관에 의한 강제집행이 가능하도록 함으로써 피수용자의 보호에 획기적인 조치를 마련한 것이다.

이에 대하여 행정기관의 결정과 판결의 효력을 동일하게 규정하는 것은 권력분립의 원칙에 반하고, 국민의 재판청구권을 지나치게 봉쇄한다는 문제가 있다. 이와 관련하여 헌법재판소는 국가배상법 제16조의 “배상 심의회의 배상결정은 신청인이 동의한 때에는 민사소송법 규정에 의한 재판상 화해가 성립된 것으로 본다.”라는 규정에 대하여 위헌결정을 한 바 있으며, 이러한 헌재의 취지에 따를 때 이 규정은 위헌의 소지가 있다.

(3) 재결확정증명서의 청구와 교부

이의재결이 확정된 때 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 관할 토지수용위원회에 재결확정증명서의 발급을 청구할 수 있다(제86조 제2항). 이의재결에서 보상금이 늘어난 경우 그 늘어난 금액을 사업시행자가 이의신청인에게 지급하지 않더라도 재결의 효력에는 영향을 미치지 않는다. 따라서 재결확정증명서의 발급은 이의신청인 입장에서 강제적으로 증액된 보상금을 확보할 수 있도록 하기 위한 것이다.

(4) 행정소송의 제기

사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 수용재결에 불복할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 행정소송을 제기하기 전에 늘어난 보상금을 공탁하여야 하며, 보상금 받을 자는 공탁된 보상금을 소송이 종결될 때까지 수령할 수 없다(제85조 제1항). 따라서 이의신청에 대한 재결이 있은 후 이에 불복하는 자는 이의재결의 취소소송 또는 보상금증감청구소송을 제기할 수 있는 효과가 발생한다.

01 개설

행정소송은 재결에 대하여 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이 그 재결의 취소 또는 변경을 구하거나 손실보상액의 증액 또는 감액을 청구하는 소송이다. 보상금증감청구소송은 종래 「토지수용법」이 보상금증감에 관한 소송의 피고로 재결청을 규정하고 있었기 때문에 형식적 당사자소송에 해당하는가에 대하여 논란이 많았다. 그러나 토지보상법은 소송의 피고에서 재결청을 제외하였으므로, 이러한 논란의 여지는 사라지고, 현행 보상금증감청구소송은 순수한 의미의 형식적 당사자소송으로 이해되고 있다.

02 취소소송

1) 의의

재결에 대한 취소소송이란 관할 토지수용위원회의 위법한 재결 또는 중앙토지수용위원회의 위법한 이의재결의 취소나 변경을 구하는 소송이다(제85조 제1항).

2) 제소 요건

(1) 취소소송의 대상(원처분주의와 재결주의)

이의재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 경우 관할 토지수용위원회의 수용재결을 대상으로 해야 하는 것인지, 이의신청에 대한 재결을 대상으로 해야 하는 것인지 견해가 나뉜다. 토지보상법 제85조 제1항 규정이 원처분주의를 취하고 있는 것인지 재결주의를 취하고 있는 것인지에 대한 논란이다.

a. 원처분주의와 재결주의

원처분주의는 원처분에 대한 소송제기만을 허용하고, 재결의 취소소송은 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에만 인정하는 것을 말한다. 재결주의는 원처분에 대한 소송 제기는 허용하지 않고, 재결만을 취소소송의 대상으로 인정하는 것을 말한다. 행정소송법은 “취소소송은 처분 등을 대상으로 한다.

다만, 재결 취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다”(행정소송법 제19조)고 규정하고 있어 원처분주의를 취하고 있다.

b. 토지보상법의 해석

토지보상법은 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 제34조에 따른 재결에 불복할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다(제85조 제1항). 이 규정에 대해서는 원처분주의를 취하고 있다고 보는 견해와 재결주의를 취하고 있다고 보는 견해로 나뉜다. 대법원은 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하여 수용재결의 취소를 구하여야 한다는 원처분주의를 취하고 있다(대판 2010. 1. 28. 2008두1504).

c. 소결

종래 토지수용법은 “이의신청의 재결에 대하여 불복이 있을 때에는”이라는 표현을 사용하여 재결주의를 채택하고 있었다. 그러나 토지보상법은 이와 같은 문구를 삭제하고, “제34조에 따른 재결에 불복할 때”라고 규정하여, 행정소송법상 원칙대로 원처분주의를 명확히 규정하고 있다. 따라서 토지수용위원회의 재결에 대해 불복이 있을 때에는 이의재결을 거쳤는지 여부에 관계없이 처분청을 상대로 수용재결의 취소를 구하여야 하고, 이의재결의 취소를 구할 수는 없다. 다만, 이의재결 자체의 고유한 위법이 있을 경우에는 중앙토지수용위원회를 상대로 이의재결의 취소를 구할 수 있다.

(2) 행정심판 임의주의

토지보상법은 이의재결을 거치지 않고도 수용재결을 다투는 행정소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 피수용자의 신속한 권리구제와 쟁송의 조속한 분쟁 해결을 위해서이다. 행정소송은 토지수용위원회의 재결에 불복이 있는 때에 제기할 수도 있고, 이의신청을 거친 때에는 이의재결이 있는 다음에 제기할 수도 있다.

(3) 당사자

취소소송을 제기할 수 있는 자, 즉 원고는 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이다(제85조 제1항). 취소소송을 제기하는 자는 토지수용위원회의 재결에 불복이 있는 자로서 법률상 이익이 있는 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이다. 그러나 토지보상법은 취소소송의 상대방인 피고에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 그러므로 행정소송법이 규정하는 바에 따라 당해 처분을 행한 행정청이 피고가 된다. 즉 취소소송의 피고는 관할 토지수용위원회이다.

이의재결의 고유한 위법이 있는 경우는 중앙토지수용위원회가 피고가 되지만, 토지보상법이 소송의 대상을 원처분주의를 취함에 따라 이의재결이 있는 다음에 제기하는 취소소송의 경우도 결국 관할 토지수용위원회가 피고가 된다. 대법원은 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 때에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하여 수용재결의 취소를 구하여야 하고, 다만 이의 신청에 대한 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에는 그 이의재결을 한 중앙토지수용위원회를 피고로 하여 이의재결의 취소를 구할 수 있다(대판 2010. 1. 28. 2008두1504).

(4) 제소기간 (85조 1항)

재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기해야 한다. 사업시행자는 행정소송을 제기하기 전에 제84조에 따라 늘어난 보상금을 공탁하여야 하며, 보상금을 받을 자는 공탁된 보상금을 소송이 종결될 때까지 수령할 수 없다. 이의재결을 거친 후 취소소송은 이의재결이 있는 사실과 그 재결의 내용을 알 수 있었다고 하더라도 이의재결서 송달일부부터 제소기간이 진행된다(대판 1992. 7. 28. 91누12905).

2018. 12. 31. 개정 이전에는 제소기간이 현 규정에 비해 짧게(60일, 30일) 규정되어 있었는데, <대법원>은 제소기간을 짧게 규정한 것은 토지수용과 관련하는 공익사업을 신속히 수행할 그 특수성과 전문성을 살리기 위한 필요하다는 취지의 판결을 하였다(대판 1992. 8. 18. 91누9312).

(5) 재판관할

취소소송의 제1심 관할 법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원이나, 중앙행정기관 또는 그 장이 피고인 경우의 관할 법원은 대법원 소재지의 행정법원으로 한다(행정소송법 제9조 제1항). 그런데 행정법원이 설치되지 않은 지역의 행정법원 관할에 속하는 사건은 해당 지방법원의 본원이 관할하도록 되어 있으므로(법원조직법 개정 법률 부칙 제2조), 행정법원이 설치된 서울을 제외하고는 피고의 소재지를 관할하는 지방법원의 본원이 취소소송의 제1심 관할법원이 된다. 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분 등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다(행정소송법 제9조 제2항).

3) 제소 효과

① <법원에 대한 효과>

취소소송이 제기되면 당해 사건은 법원에 계속되며, 법원은 심리·판결할 의무를 진다.

당사자는 동일한 사건에 대하여 중복하여 소를 제기하지 못하게 된다.

② <처분에 대한 효과>

토지보상법은 취소소송이 제기되더라도 사업의 진행 또는 토지의 수용·사용은 정지되지 않는다는 집행부정지원칙을 채용하고 있다(제88조). 다만, 행정소송법에 따라 예외적으로 요건이 충족하는 경우 집행정지가 인정될 것이다.

4) 심리 및 판결

① <심리>

심리는 요건심리와 본안심리로 나눌 수 있다. 취소소송의 심리에 있어서는 변론주의 및 불고불리원칙이 적용된다. 법원은 원고의 청구범위를 넘어 심리·재판할 수 없다. 그러나 행정소송법은 변론주의 원칙에 직권탐지주의를 가미하고 있다. 또한 취소소송의 심리는 공개심리주의, 쌍방심리주의, 구술심리주의, 변론주의, 직권진행주의 등의 일반적 원칙이 적용된다.

② <판결>

소송요건을 갖추지 못하면 각하판결이 행해진다. 본안판결은 기각판결과 인용판결이다. 원고의 청구가 이유 있다고 인정되는 경우에는 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에 사정판결(행정소송법 제28조)이 인정된다.

5) 사업인정과 수용재결의 하자승계

사업인정과 수용재결은 연속된 행정행위로서 하자승계의 전제조건이 충족될 경우, 선행 행위인 사업인정의 하자를 수용재결에 승계시켜 다룰 수 있을지 여부가 문제된다. 하자승계에 대한 견해로는, 전통적 견해인 하자승계론과 구속력론이 있다. 판례는 연속된 행정처분이 서로 결합하여 하나의 법률효과를 완성하는 때에는 선행처분의 하자는 후행처분에 하자에 승계되어 선행처분의 하자를 이유로 후행처분의 효력을 다룰 수 있다고 한다.

별개의 법률효과를 목적으로 하는 경우에는 선행처분의 하자가 중대명백하여 당연무효인 경우를 제외하고는 선행 처분의 하자를 이유로 후행처분의 효력을 다룰 수 없다. 별개의 법률효과를 목적으로 하는 경우에도 예외적으로 수인성의 원칙, 예측가능성의 원칙을 적용하여 하자승계를 인정하고 있다. 사업인정과 수용재결에 대하여 판례는 사업인정 자체가 중대하고 명백하여 당연무효인 하자가 아닌 한, 이러한 하자는 수용재결의 선행처분인 사업인정 단계에서 다투어야 할 것이므로 그 쟁송기간이 이미 도과한 이후에 사업인정의 하자를 이유로 수용재결의 취소를 구할 수는 없는 것이라고 판시하였다(대판 1993. 6. 29. 91누2342).

사업인정은 공익사업의 원활한 실시를 위해 중대한 하자가 있는 경우를 제외하고 수용재결에 승계되지 않는 것이 합리적이다. 그러나 이러한 법리를 관철시키는 경우 피수용자에게 너무 가혹한 결과를 초래하거나, 피수용자가 예측하지 못한 결과를 가져오는 경우도 예상할 수도 있다.

6) 관련 문제

(1) 확정판결의 집행력

취소소송에서 인용판결을 하게 되면 소송 당사자와 관계 행정청은 판결의 내용에 따라 행해야 할 판결의 효력이 발생하고, 기존의 법률관계에 변동을 가져오는 형성력이 생긴다.

취소판결이 확정되면 당해 처분 효력은 별도의 행위를 기다릴 것 없이 처분시에 소급하여 소멸되고, 그래서 기존의 법률관계에 변동을 가져오게 된다. 당사자가 확정판결에 따라 이행하지 않을 때 강제집행할 수 있는 집행력도 발생하게 된다.

(2) 사업시행자의 법정이율 가산지급

사업시행자는 사업시행자가 제기한 행정소송이 각하·기각 또는 취하된 경우 ① 재결이 있은 후 소송을 제기하였을 때에는 재결서 정본을 받은 날, ② 이의재결이 있은 후 소송을 제기하였을 때에는 그 재결서 정본을 받은 날부터 판결일 또는 취하일까지의 기간에 대하여 「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조에 따른 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 보상금에 가산하여 지급하여야 한다(제87조). 가산금제도를 둔 것은 사업시행자가 보상금 지급을 지연시킬 목적 등으로 행정소송을 남용하는 사례를 막고, 토지소유자의 귀책사유 없는 행정소송으로부터 피수용자의 권리침해를 방지하기 위해서이다.

03 무효등확인소송

1) 의의

무효등확인소송이란 관할 토지수용위원회의 재결 또는 이의재결의 효력유무 또는 존재여부를 확인하는 소송이다. 토지보상법은 무효등확인소송을 규정하지 않고 있다.

2) 무효등확인소송의 인정

수용재결이 그 흠이 중대하고 명백한 경우에는 무효등확인소송을 제기할 수 있다.

3) 취소소송에 관한 사항의 일부 적용배제

무효등확인소송은 관계법에서 행정심판 필요적 전치를 규정하고 있는 경우에도 그 적용을 받지 않고, 제소기간의 제한도 적용되지 않는다. 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 소를 제기할 수 있고, 피고는 재결을 행한 행정청 즉 관할 토지수용위원회가 되며, 관할 법원은 원칙적으로 피고의 소재지를 관할하는 행정법원이다.

04 보상금증감청구소송

1) 의의 및 필요성

보상금증감청구소송은 보상금 증감의 다툼에 대하여 직접적 이해관계를 가진 당사자인 사업시행자와 토지소유자 및 관계인이 소송제기를 통해 직접 다투는 당사자소송이다. 종래 원고가 손실보상액만을 다투어 제소한 경우에도 법원은 재결 전부를 취소하였다. 이 경우 관할 토지수용위원회는 법원의 취소판결에 따라 다시 손실보상액을 정하는 재결을 하고, 여기에도 만족하지 못하는 당사자는 다시 취소소송을 제기하여야 하는 분쟁이 무한히 반복되는 불편이 있었다. 이러한 문제를 시정하기 위하여 보상금에 대해서만 불복하는 경우 보상금증감청구소송을 제기할 수 있도록 함으로써, 분쟁을 일회적으로 해결하고, 권리구제의 신속성·실효성 확보를 도모하고 있다.

2) 소송의 성질

(1) 형식적 당사자소송

당사자소송이란 행정청의 처분 등을 원인으로 형성된 법률관계에 대하여 그 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송을 말한다. 형식적 당사자소송은 실질적으로는 처분 또는 재결을 다투는 것이나, 그 소송구조에 있어서는 처분청을 피고로 하는 것이 아니라 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하며 형식적으로는 당사자소송형식을 취하는 소송을 말한다. 토지보상법 제85조 제2항은 “행정소송이 보상금의 증감에 관한 소송인 경우 그 소송을 제기하는 자가 토지소유자 또는 관계인일 때에는 사업시행자를, 사업시행자일 때에는 토지소유자 또는 관계인을 각각 피고로 한다.”라고 규정함으로써 형식적 당사자소송을 인정하고 있다. 손실보상에 관한 사항은 당사자의 자유로운 처분에 맡겨도 공익에 직접 영향을 끼치는 것이 아니라는 점에서 토지수용위원회가 관여할 필요 없이 직접적으로 이해관계를 지니는 당사자 쌍방에 맡기는 것이 오히려 적절하다는 것이 이 규정의 취지이다.

(2) 소송의 법적 성질

a. 문제점

형식적 당사자소송은 원래 항고소송과 실질적 당사자소송의 두 가지 성질을 아울러 가지기 때문에 그 법적 성질에 대하여는 견해가 나누어지는 바, 형성소송설과 확인·급부소송설이 대립한다. 이는 구체적 손실보상 청구권의 발생 근거를 어떻게 볼 것인가의 문제로서, 헌법 제23조 제3항의 법적 효력에 관한 해석 및 토지수용위원회가 행하는 재결의 처분성과 관련이 있다.

b. 학설

〈형성소송설〉

보상금증감청구소송은 실질적으로는 보상액의 취소·변경을 구하는 항고소송으로서, 법원이 재결을 취소하고 정당한 보상액을 판단함으로써 비로소 구체적 손실보상청구권이 형성된다고 한다. 즉 실질적으로는 토지수용위원회의 보상재결이라는 공권적 행정처분의 취소를 구함이 없이 보상액의 증감을 청구하는 것은 허용될 수 없다고 하는 견해이다. 이 견해는 재결의 공정력에 중점을 둔 견해이다.

〈확인·급부소송설〉

보상청구권은 헌법조항에 근거하여 당연히 발생하므로, 법원은 정당보상액을 직접 확인·급부하는 것에 대한 판단이면 충분하다 보는 견해이다. 보상재결의 취소·변경을 구할 필요 없이 피수용자가 재결에서 정한 보상액이 과소하다고 여겨지는 경우 재결액과 정당보상액과 차액의 급부를 청구할 수 있고, 사업시행자는 보상액이 과다하다고 여겨지는 경우 과잉보상금의 반환청구 내지는 정당보상액 초과부분의 보상채무부존재확인청구를 하면 된다는 입장이다.

c. 검토

보상당사자 사이에서 보상금의 증감에 관한 분쟁을 종국적으로 해결하도록 한 입법취지를 고려하고, 분쟁을 일회적으로 해결하도록 한 취지 등을 고려할 때, 〈확인·급부소송〉으로 봄이 바람직하다. 이와 같이 보면, 보상금증감청구소송의 소송물은 손실보상금청구권의 존부 또는 그 범위가 될 것이고, 수용재결 중 보상금 부분의 위법성 여부는 그 판단의 전제로서 작용할 뿐이다.

실무상 법원은 보상금 증액 청구소송의 경우, 정당한 보상액과 이의신청의 재결에 정한 보상금의 차액을 지급하라고 판시하고 있으며(예를들면 “피고는 원고에게 000원 및 이에 대한 지연이자를 지급하라.”라고 판시), 감액 청구소송의 경우에는 사업시행자에게 재결에서 정한 보상금 중 정당보상을 넘는 부분에 대해서는 지급할 채무가 없다는 형태의 판시를 하고 있어(예를 들면 “원고의 피고에 대한 손실보상금 채무는 000원을 초과하여서는 존재하지 아니함을 확인한다.”) 급부소송 또는 확인소송의 형태로 취급하고 있다.

3) 제소 요건

(1) 당사자

토지소유자 또는 관계인이 소송을 제기하면 사업시행자가 피고가 되고, 사업시행자가 소송을 제기하면 토지소유자 또는 관계인이 피고가 된다. 이와 같이 재결청을 소송당사자에서 제외된 것은 사업시행자와 피보상자 간의 당사자주의에 충실하도록 하기 위한 것이다.

(2) 소송의 대상 (원처분주의 논의가 적용되는지)

a. 문제점

보상금증감청구소송은 보상금의 증감에 관한 것만 대상으로 한다. 그러나 이의재결로 형성된 보상금에 불복하여 소송을 제기하는 경우, 관할 토지수용위원회의 수용재결로 형성된 보상금을 대상으로 해야 하는지 아니면 이의신청에 대한 재결로 형성된 보상금을 대상으로 해야 하는지에 관하여 토지보상법의 직접 규정이 없어 해석에 맡겨지고 있다.

b. 학설

- ① 취소소송과 마찬가지로 원처분주의를 취하여 수용재결에서 정한 보상금을 소송대상으로 보는 견해,
- ② 재결주의를 취하여 이의재결에서 정한 보상금을 소송대상으로 보는 견해,
- ③ 원처분주의·재결주의로 해석할 것이 아니라 보상금에 관한 법률관계를 소송대상으로 보아야 한다는 견해가 대립한다.

c. 검토

생각건대, 보상금증감청구소송은 보상금에 관한 법률관계만이 소송의 대상이 되는 것으로 보므로, 원처분주의 또는 재결주의로 해석할 것은 아니다. 따라서 관할 토지수용위원회의 수용재결에서 정한 보상금에 불복할 경우는 재결에서 정한 보상금 그 자체가 대상이 되고, 중앙토지수용위원회의 이의재결에서 정한 보상금에 불복할 경우는 이의재결에서 정한 보상금이 대상이 되는 것으로 보아야 할 것이다.

(3) 제소기간

당사자소송의 경우 행정소송법에 따르면 제소기간의 제한이 없으나, 보상금증감청구소송에도 재결에 대한 취소소송 제소기간이 적용되는지 문제된다. 토지보상법은 제85조 제1항에서 제소기간을 정하고 있고, 제2항에서 “제1항에 따라 제기하려는 행정소송”이 보상금의 증감에 관한 소송인 때라고 규정하고 있어, 보상금증감청구소송에도 제소기간을 적용함이 타당하다.

(4) 재판 관할

당사자소송은 취소소송과 마찬가지로 피고의 소재지를 관할하는 행정법원이 제1심 관할법원이 된다. 그러나 국가 또는 공공단체가 피고인 경우에는 관계 행정청의 소재지를 피고의 소재지로 한다(행정소송법 제40조 단서). 한편 행정소송법은 취소소송의 재판관할에 관한 규정은 당사자소송의 경우에 준용한다고 규정하므로, 토지의 수용에 있어서는 그 토지의 소재지를 관할하는 행정법원에 소송을 제기할 수 있다(행정소송법 제9조 제2항).

(5) 절차 및 형식

행정심판 임의주의가 적용되고, 사업시행자가 소송을 제기하는 경우 자신의 예정금액을 지급하고 차액을 공탁하여야 한다. 이의신청을 거친 때에는 이의재결에서 증액된 보상금을 공탁하여야 한다. 보상금 받을 자는 소송종결 시까지 공탁된 보상금을 수령할 수 없다.

4) 제소 효과

관할 법원은 심리·판결할 의무를 지고, 보상금증감청구소송의 제기는 사업의 진행 및 토지의 수용 또는 사용을 정지시키지 아니한다.

5) 심리 및 판결

(1) 심리 범위

a. 문제점

토지보상법은 보상금의 증감에 관한 소송이 구체적으로 무엇을 의미하는지에 관하여 규정하지 않아 해석상 논란이 될 수 있다. 보상액의 다소, 손실보상액 지급방법의 결정 등은 심리범위에 포함되고, 재결신청지연에 따른 가산금도 심리범위에 포함된다(판례). 이와 관련하여 확장수용청구의 손실범위가 심리범위에 포함되는지 견해대립이 있다.

b. 학설

① <긍정설>

확장수용청구의 실질은 피수용자의 이익을 고려한 손실보상의 문제이고, 손실의 범위와 보상의 금액은 밀접한 관련을 지니므로, 보상금증감청구소송 속에 보상의 원인인 손실의 범위 결정에 관한 다툼까지도 포함하는 것이라고 해석하고 있다.

② <부정설>

잔여지수용은 수용하는 토지의 구역이므로, 재결은 수용의 개시일까지 보상금을 지급하지 않으면 실효되는 점 등에 비추어 볼 때, 단순 보상의 문제로 볼 수 없으므로, 재결을 다투는 방법에 의하는 것이 타당하다고 한다.

c. 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 그 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 형성권적 성질을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 '보상금의 증감에 관한 소송'에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다(대판 2010. 8. 19. 2008두822).

d. 검토

잔여지 수용청구 등 보상의 원인인 손실범위는 보상금액과 밀접한 관련이 있으므로, 분쟁의 일회적 해결을 위하여 손실범위 결정에 관한 다툼까지도 포함하는 것으로 해석함이 바람직하다.

(2) 입증책임

행정소송에 있어서 입증책임은 행정소송법에 아무런 규정을 두고 있지 않아 입증책임을 어떻게 분배할 것인가에 대하여 견해가 대립한다. 원고가 책임을 진다는 견해, 원고와 피고가 분담하여 진다는 견해, 민사소송법상 입증책임 분배에 관한 일반원칙에 의하여야 한다는 견해, 독자적으로 정해야 한다는 견해로 나뉜다.

당사자소송에 있어서 입증책임은 민사소송법상 일반원칙에 따라 분배된다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 대법원은 보상금증감청구소송에 있어서 재결에서 정한 보상금액보다 정당한 손실보상액이 많다는 점에 대한 입증책임은 원고에게 있다고 판시하고 있다(대판 1997. 11. 28. 96누2255).

(3) 보상항목간의 유용

a. 문제점

수용재결에서 각 보상항목마다 각각 보상액이 명시되어 있는데, 그 중 한 항목의 보상액에 대해서만 불복이 있을 때 전체의 합계액으로서는 타당한 경우 보상항목 상호간 보상액산정의 유용을 인정할 수 있을까 문제가 된다. 보상금증감에 관한 소송물을 어떻게 보느냐에 따라 견해가 나뉜다.

b. 견해대립

- ① 보상금증감청구소송에서 소송물은 토지필지별, 물건별, 손실항목별로 나누어진다고 보아 그 상호간 유용을 허용하지 않는 견해,
- ② 동일인에 대한 일단의 토지를 기준으로 하여 필지별 총액을 기준으로 하는 견해,
- ③ 개인별보상원칙에 따라 항목간 유용을 허용하여 보상금액을 결정해야 한다는 개인별 총액주의적 견해가 있다.

c. 판례

보상은 수용대상이 되는 물건별로 하는 것이 아니라 피보상자의 개인별로 행하여지는 것이므로, 피보상자는 수용대상 물건 중 일부에 대하여만 불복이 있는 경우 그 부분에 대하여만 불복의 사유를 주장하여 행정소송을 제기할 수 있다고 할 것이나, 행정소송의 대상이 된 물건 중 일부 항목에 관한 보상액이 과소하고 다른 항목의 보상액은 과다한 경우에는 그 항목 상호간의 유용을 허용하여 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금의 합계액을 결정하여야 한다(대판 1998. 1. 20. 96누12597).

d. 검토

개인별보상원칙에 비추어 볼 때, 보상금에 관한 항목별로 액수가 정해져 있다 하더라도 소송물을 개개 항목별로 구분하는 것이 아니라 전체를 불가분의 1개 소송물로 보기 때문에 **개인별 총액**으로서 **보상액의 당부**를 소송물로 보아 항목간 유용을 허용함이 합리적일 것이다.

(4) 심판범위로서 전부취소와 일부취소

a. 문제점

토지보상법은 법원에서 정당보상액을 심리 확정할 것인지를 명문으로 규정하고 있지 않아, 보상재결의 전체를 취소하여야 하는 것인지 아니면 정당보상액과의 차액에 해당하는 부분만의 일부취소 또는 변경을 해야 하는 것인지 문제된다.

b. 견해대립

① <전부취소라고 주장하는 견해>

보상금증감청구소송은 토지수용위원회의 재결 중에서 **보상재결 부분은 완전히 소멸시키고** 법원이 시심적으로 정당보상액을 새로이 정하는 것이라고 한다.

② <일부취소라고 주장하는 견해>

토지보상법이 보상금증감에 관한 소송이라는 표현을 사용하고 있으므로, 법원에서 정당보상액을 심리하는 것을 전제로 하고 있다고 할 것이므로 법원에서 정당보상액을 심리확정해야 한다는 것이다. 따라서 감정기관의 보상액 평가가 보상액 평가에 관한 원칙에 위배되었다고 인정되는 경우에는 보상재결 전체를 취소할 것이 아니라 **정당보상액과의 차액에 해당하는 부분만의 일부취소 또는 변경을** 해야 한다고 주장한다.

c. 판례

구 토지수용법 하에서는 전부취소 취지의 판결이 있었지만 (83누315판결), 토지보상법 체계에서는, 사업시행자를 피고로 하여 제기하는 보상금의 증감에 관한 소송은 **법원이 정당한 보상액을 심리하는 것을 전제로 하고 있으므로** 감정인 등에게 적법한 감정평가 방법에 따른 재감정을 명하거나 사실조회를 하는 등의 방법으로 그 **정당한 보상액을 심리한 다음 재결시의 보상액과 비교하여 청구의 인용여부를 결정하여야** 한다고 판시하여(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008두9591판결), **일부취소가 가능하다고 본다.**

d. 검토

토지보상법의 입법취지나 토지수용재결에 대한 소송을 이원화하고 있는 점 등을 미루어 보면, 정당보상액과의 차액에 해당하는 부분만의 **일부취소**에 한정하는 것으로 파악하는 것이 타당할 것이다.

(5) 확정판결의 효력 (지연손해금의 문제)

a. 문제점

보상금증감청구소송의 경우 법원은 직접 보상금을 결정하므로, 소송당사자는 판결 결과에 따라 이행하면 된다. 그런데 이의재결을 거친 후 제기된 보상금증액청구소송에서 재결의 보상금이 정당보상액에 미치지 못한다고 인정될 때, 초과부분에 대하여 지연이자 발생하느냐에 대하여 견해대립이 있다.

b. 견해 대립 및 판례

- ① 이의재결에서 정한 보상액을 초과하는 부분만의 지급을 명하여야 한다는 견해가 있으나,
- ② 이의재결에서 증액된 보상금이 공탁되지 않은 경우, 그 차액 역시 수용과 대가관계에 있는 손실보상의 일부이므로 동 차액이 수용의 개시일에 지급되지 않는 이상 지연이자가 발생한다는 견해가 있다.
- ③ <판례> 대법원은 재결절차에서 정한 보상액과 행정소송 절차에서 정한 보상금액의 차액 역시 수용과 대가관계에 있는 손실보상의 일부이므로 동 차액이 수용의 시기에 지급되지 않은 이상 이에 대한 지연손해금이 발생하는 것은 당연하다고 판시하였고(대판 1991. 12. 24. 91누308).

c. 검토

피수용자의 권리보호를 중시하여 지연이자가 발생한다고 보는 판례 입장이 타당하다.

6) 관련 문제

(1) 화해 및 청구의 포기·인낙의 가능 여부

보상금증감청구소송에서 화해나 청구의 포기·인낙 등이 가능한지 문제된다. 인낙이란 피고가 원고의 청구내용인 권리·주장을 전면 긍정하는 것으로서, 인낙이 성립되면 원고가 승소하고 피고는 더 이상 상소할 수 없으면 판결이 확정된다. 생각건대 토지보상법이 당사자주의에 충실하기 위해 재결청을 피고에서 제외함으로써 순수하게 보상 당사자 사이에서만 다투어지는 소송구조를 갖추게 한 점, 수용재결과정에서도 권고에 따라 피수용자와 사업시행자 사이에 화해가 가능한 점(제33조) 등에 비추어 보면, 보상금증감청구소송에서 화해나 청구의 포기·인낙이 가능하다고 할 것이다.

(2) 소의 각하·기각 또는 취하의 효과

재결에 불복하여 보상금증감청구소송을 제기하였으나, 요건불비로 각하되거나 이유없어 기각된 경우 또는 원고가 취하한 경우에는 재결이 확정된다.

(3) 취소소송에 보상금증감청구소송을 예비적으로 병합하는 것의 가능성

주관적·예비적 병합이란 주위적으로 관할 토지수용원회를 피고로 하여 수용재결에 대한 취소소송을 제기하면서, 예비적으로 사업시행자를 피고로 하여 보상금의 증액을 청구하는 것과 같이 공동소송인 또는 공동소송인에 대하여 양립할 수 없는 수 개의 청구에 순서를 붙여 병합하는 형태를 말한다.

취소소송이 기각된 후 보상금증액청구소송을 별도로 제기할 수 있지만, 민사소송법이 주관적·예비적 병합을 인정하고 있으므로, 취소소송에 보상금증액청구소송을 예비적으로 병합할 수 있을 것이다.

제1절

토지수용위원회

01 개설

토지수용위원회는 사업시행자와 토지소유자 또는 관계인과의 사이에서 수용이나 손실보상에 관한 다툼을 당사자가 주장하는 바에 따라 공정·중립의 입장에서 판단하고, 이를 최종적으로 재결하는 준사법적 행정기관이다.

토지수용위원회의 역할은 공정한 심리 절차에 의하여 피수용자를 확정하고 손실보상을 결정하는 것을 주로 한다.

이와 같은 임무를 실현하기 위해 위원회는 독립성을 지니고, 이에 소속되는 위원의 신분을 보장하고 있다.

02 성격

토지수용위원회는 토지 등의 수용·사용에 관한 재결을 하는 행정기관이다. 수용 또는 사용에 관한 재결은 보상 문제 등에 대하여 사업시행자와 토지소유자 및 관계인과의 상호 대립하는 이해관계를 조정하는 준사법적인 작용이기 때문에, 그 조직도 공정하고 중립적인 일종의 행정위원회로 구성되어 있다. 따라서 토지수용위원회는 다음과 같은 성격을 지닌다.

1) 독립된 행정기관

토지수용위원회는 독립된 행정기관이다. 토지수용위원회는 공익사업에 필요한 토지등의 수용·사용에 대한 재결을 목적으로 설치되어 있다는 점에서 특별관청으로 이해되기도 한다. 중앙토지수용위원회가 국가행정기관임에는 틀림이 없으나, 지방토지수용위원회가 지방행정기관인지는 분명하지 않다. 지방토지수용위원회가 지방자치단체의 행정조직 체계 내에서 조직·운영되고 있기 때문에 지방행정기관으로 볼 수 있으나, 위원회가 일종의 행정위원회로서 독립적인 성격을 지니기 때문에 지방행정기관으로 보기 어려운 점이 있다.

2) 합의제 행정기관

토지수용위원회가 구성 위원의 합의에 의해 독립적으로 수용·사용에 관한 재결을 하는 점에서 합의제 행정기관으로서의 성격을 지닌다. 위원회는 공익의 실현을 위해 필요에 따라 활동을 계속하는 합의제 행정기관이다.

3) 준사법적 행정기관

토지수용위원회는 토지 등의 수용·사용에 관한 재결 사항을 판단하고 결정하는 것을 임무로 하기 때문에, 준사법적 행정기관으로서의 지위를 갖는다.

4) 독립성 및 전문성 인정

토지보상법은 토지수용위원회의 재결사항, 구성 위원의 자격 및 임명, 위원의 결격사유와 임기, 신분보장 등에 대하여 규정하고 있고, 위원의 공정성이 의심되는 경우에는 제척·기피·회피 제도를 두고 있으며, 판사·검사 또는 변호사의 직에 15년 이상 있었던 자나 토지수용에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 등이 위원이 된다.

5) 기타

이와 같은 성격을 지니고 있는 토지수용위원회는 다른 국가행정기관과는 그 성격을 달리 한다. 즉, 토지수용위원회는 행정청을 보조하는 임무를 수행하는 보조기관, 행정청의 자문에 응하거나 의견을 제공함을 임무로 하는 자문기관, 행정청이 표시할 의사를 단순히 의결하는 의결기관, 실력으로 행정을 집행함을 임무로 하는 집행기관과 구별된다.

03 설치와 구성

1) 위원회의 설치

토지 등의 수용과 사용에 관한 재결을 하기 위하여 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 지방토지수용위원회를 둔다.

2) 구성

중앙토지수용위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하며, 위원 중 대통령령으로 정하는 수의 위원은 상임으로 한다(토지보상법 제52조 제1항). 지방토지수용위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다(토지보상법 제53조 제1항).

04 관할

1) 관할의 의의 및 구분 (범위)

(1) 관할의 의의

토지수용위원회의 관할이란 토지의 수용·사용에 관한 사업시행자의 재결의 신청에 대하여 중앙토지수용위원회와 지방토지수용위원회 중 어디에서 심의하고 재결할 것인가를 정하는 것을 말한다.

(2) 관할의 구분

- ① 중앙토지수용위원회 : 국가 또는 시·도가 사업시행자인 사업, 수용하거나 사용할 토지가 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 사업
- ② 지방토지수용위원회 : 중앙토지수용위원회 이외의 사업의 재결(시·도 해당 관할의 사업)

2) 관할 범위 내 재결의 종류

- ① 중앙토지수용위원회는 관할 범위 내 재결과 1차적 재결에 대한 불복으로서 이의재결을 담당한다.
- ② 지방토지수용위원회는 관할 범위 내 재결만 담당한다.

05 재결사항 (토지보상법 제50조 제1항)

- 1. 수용하거나 사용할 토지의 구역 및 사용방법
- 2. 손실보상
- 3. 수용 또는 사용의 개시일과 기간
- 4. 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항

01 개설

공익사업을 위한 용지의 취득과 보상은 개인의 재산권과 직접 관련되고, 사업시행자와 토지소유자간에 이해관계가 대립하는 것이다. 따라서 토지보상법은 주민의 의견수렴과 민원 해소를 위하여 보상협의회를 설치·운영하도록 하고 있다.

02 의의 및 성격 등 (토지보상법 제82조)

1) 의의 및 취지

보상업무에 관한 사항을 협의하기 위해서 시·군·구에 설치하는 합의제 행정기관이다.

개정의 취지는 보상업무의 지연 초래를 방지하기 위함이다.

2) 성격

(1) 자문기관인지, 심의기관인지

심의기관으로 보는 견해는 일정 규모 이상의 공익사업을 시행하는 경우 위원회를 반드시 설치하도록 하는 것을 이유로 하고, 자문기관으로 보는 견해는 위원회가 보상업무에 대해 단순히 자문하는 기능을 갖는 것에 불과하고, 보상에 관한 의견을 제시 또는 건의하는 것을 이유로 하고 있었다. 위원회의 명칭에 심의라는 용어를 사용하고 있다 하더라도, 위원회의 기능과 심의 내용에 비추어 자문기관으로 보는 것이 설득력을 지니고 있었다. 다수의견을 위원회에서 논의하여 결정된 사항이라 하더라도 사업시행자를 결코 구속하는 것이 아니기 때문에 의결기관이나 심의기관으로 볼 수 없다는 것이었다. 토지보상법은 종래 보상심의위원회를 보상협의회라는 명칭으로 변경하고, 협의회의 기능 가운데 보상액의 산정을 삭제하였다. 이에 따라 보상협의회의 성격을 둘러싸고 의견 대립이나 논란의 여지는 없게 되었다. 보상협의회는 설치 목적이나 명칭에서 보는 바와 같이 의견 수렴 내지는 자문기관으로서의 성격을 갖는 것에 불과하다.

(2) 임의적 및 의무적 보상협의회

a. 의무적 보상협의회

대통령령이 정하는 규모이상의 공익사업을 시행하는 경우 의무적으로 설치하도록 규정한다.
(10만㎡이상이고, 토지소유자 50인 이상인 경우).

b. 임의적 보상협의회

공익사업이 시행되는 해당 지방자치단체의 장은 필요한 경우 보상협의회를 둘 수 있도록 규정한다.

03 협의 사항 (협의회의 기능)

보상액 평가를 위한 사전 의견수렴에 관한 사항, 잔여지의 범위 및 이주대책 수립에 관한 사항, 해당 사업지역 내 공공시설의 이전 등에 관한 사항, 토지소유자나 관계인 등이 요구하는 사항 중 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 사항, 그 밖에 지방자치단체의 장이 회의에 부치는 사항이 있다.

PART 02

손실보상

Chapter 01 손실보상제도

Chapter 02 행정상 손실보상

Chapter 03 토지보상법상손실보상

Chapter 04 손실보상각론(이주대책, 간접손실보상)

제1절 손실보상 일반론

01 의의 및 취지

‘행정상 손실보상’이란 공공필요에 의한 적법한 행정상의 공권력 행사에 의하여 사인에게 가해진 특별한 희생에 대하여 전체적 평등부담의 견지에서 행정주체가 행하는 조절적 전보제도를 말한다. 손실보상제도는 전체의 이익을 위해 특정한 이해관계인이 입은 특별희생을 조정하기 위하여 그 의의가 있다. 사회 이익을 위해 행정권에 의해 가해진 특정인에 대한 특별희생을 공평의 관념에 따라 사회 일반의 부담으로 보전하는 것이 손실보상제도이다. 손실보상제도의 기능적 의의는 첫째, 보상은 행정작용으로 인해 개인이 받은 손실을 전보하는 제도이기 때문에 피해자를 구제하는 기능을 갖는다. 둘째, 보상은 이해 조절적 기능을 갖는다. 개인에게 발생한 특별한 손실을 공공재정에 의해 보전하는 것은 공적 부담의 평등에 기인하고 공익과 사익의 이해 조절을 도모하는 것이다.

02 개념요소

손실보상은 개념적으로 다음과 같은 요소를 특징으로 한다.

- 1) 손실보상은 적법행위에 의거한 손실의 보상이다. 이 점에서 위법한 공권력의 행사에 따른 손해배상제도와 구별된다. 손해배상은 항상 사후적인데 비해 손실보상은 항상 사전적이다. 현대국가에서는 증대되는 위험에 대처하기 위하여 손해배상에서 발전한 수용유사침해의 이론에서 보는 바와 같이 양자가 다 같이 사회적 공평부담의 제도라는 새로운 각도에서 파악됨으로써, 이념면에서 대립이 점차 해소되어 융합의 경향을 보이고 있다.
- 2) 손실보상은 공권력 행사에 따른 손실의 보상이다.
- 3) 손실보상은 특별한 희생에 대해 전체적인 공평부담의 견지에서 행하는 조절적인 보상이다. 손실보상은 공공을 위해 특정한 사유재산에 대해 가해지는 특별·우연한 손실을 전체의 부담으로 조절하기 위한 제도이다. 따라서 국민의 일반적인 부담이나 재산권 그 자체에 내재하는 사회적 제약에 대하여는 손실보상의 문제가 발생하지 않는다.
- 4) 손실보상은 재산상의 손실을 보전하는 제도이다. 일반적으로 손실보상은 사람의 생명이나 신체에 대한 침해를 포함하지 않는다.

03 근거

1) 이론적 근거

손실보상의 이론적 근거는 종래 기득권설, 은혜설 등이 있었으나, 오늘날의 지배적인 견해는 특별희생설이다. 손실보상은 무엇보다도 사인에게 가해진 특별한 희생을 부담의 사회화를 통하여 조절함으로써 평등부담의 실현, 공익과 사익의 조절, 법률생활의 안정을 기하는 데 목적이 있다. 그 밖에 생활권보장의 원칙을 근거로 하는 학설도 나타나고 있다. 따라서 손실보상의 이론적 근거는 재산권보장을 비롯하여 평등부담, 생활권보장에서 찾을 수 있을 것이다.

2) 실정법적 근거

(1) 헌법적 근거

헌법 제23조 제3항은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.”고 하여 재산권의 제한과 보상에 대한 일반 원칙을 규정하고 있다.

현행 헌법 하에서는 국민의 재산권 침해에는 형식적 법률에 반드시 근거를 두어야 한다.

그러나 법률상 보상규정이 없거나 명확하지 않을 경우 직접 헌법상 규정에 의거하여 보상을 청구할 수 있는가가 문제가 된다. 헌법상 보상 규정에 관한 학설은 일치된 견해를 보이고 있지 않다.

(2) 법률상 근거

토지보상법은 헌법 제23조 제3항을 구체화한 법으로서, 공용침해의 근거 및 보상기준 및 절차 등을 정한 취득 및 보상에 관한 일반법이다. 토지보상법 이외에 하천법, 소방기본법 등 개별법에서 공공필요에 의한 재산권 침해에 대하여 보상이 규정되어 있다.

04 손실보상청구권의 성질

1) 문제점

손실보상청구권은 그 법적 성질을 공권으로 보는 견해와 사권으로 보는 견해로 나누어지고 있다. 적용 법률 및 소송형태 결정에 논의의 실익이 있다.

2) 견해 대립

① <공권설>

공권설은 손실보상이 행정상 손해배상의 경우와는 달리 적법한 공권력 행사로 인해 발생한 특별희생에 대하여 보전하는 것이기 때문에 공법상 법률관계의 문제로 본다. 따라서 공법상 법률관계에서 인정되는 손실보상을 청구할 수 있는 권리는 공권이라 하며, 우리나라의 통설로 되어 있다.

② <사권설>

사권설은 손실보상의 원인행위가 비록 공법적인 것이라 하더라도 그에 대한 보상은 당사자의 의사 또는 직접 법률 규정에 의거한 사법상 채권·채무관계이기 때문에 손실보상을 청구하는 권리는 사법적 성질의 것이라 한다.

3) 대법원 입장

종래 대법원은 하천법·징발법 등에 의한 손실보상청구권을 사법상 권리로 보았다. 그러나 최근 전원합의체 판결은 하천법상의 손실보상청구를 공법상 권리로 보아 행정상 당사자소송의 대상이 된다고 판시하여 하천법상 손실보상 청구권에 대한 판례를 변경하였다.

4) 검토

생각건대 행정상 손실보상은 공권력의 행사로 수반되는 효과이기 때문에 공법관계에 관한 제도이다.

또한 손실보상을 규정하고 있는 실정법이 손실보상 청구와 관련하여 전심절차로서 행정심판을 두고 있는 경우 (징발법 제24조의2, 토지보상법 제83조)가 많은 것도 손실보상청구권이 공권으로서의 성질과 관련을 갖는 것으로 볼 수 있다.

01 보상원인이 되는 재산권 침해의 유형

1) 개설

헌법 제23조 제3항은 공용침해로서 보상원인이 되는 것으로 수용·사용·제한의 3태양을 들고 있다.

수용은 공용수용을, 사용은 공용사용을, 제한은 공용제한을 말한다.

이 외에도 공용환지, 공용환권 등이 보상의 원인이 된다.

2) 공용수용

헌법 제23조 제3항의 수용은 공용수용 또는 공용징수를 말한다. 공용수용이란 공익사업 기타 복리목적을 위하여 타인의 토지 등 재산권을 법률의 힘에 의해 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 공용수용은 사유재산권을 보장하는 법치국가의 헌법에서는 반드시 법률의 근거가 있어야 하고, 법정 절차를 준수해야 하며, 정당한 보상을 해야 한다. 우리 헌법 제23조 제3항은 공용수용의 헌법적 근거를 규정하고, 공용수용에 관한 근거법률은 일반법으로 토지보상법이 있고, 그 외에 수많은 특별법이 있다.

3) 공용사용

헌법 제23조 제3항의 사용은 공용사용을 말한다. 공용사용이란 특정한 공익사업을 위하여 사업시행자가 타인 소유의 토지 등 재산권의 공법상 사용권을 취득하고, 재산권의 권리자는 사용을 수용하여야 할 공법상 의무를 부담하는 것이다. 사용제한이라고도 한다. 공용사용은 그 내용으로 보아 계속적 사용과 일시적 사용으로 나뉜다.

4) 공용제한

헌법 제23조 제3항의 제한이란 공용제한을 말한다. 공용제한이란 특정한 공익사업 기타 복리목적을 위하여 또는 일정한 물건의 효용을 보존하기 위하여 개인의 재산권에 가해지는 공법상의 제한이다. 공용제한은 당초 특정한 공익사업의 수요를 충족하기 위한 목적을 갖고 있었지만, 오늘날은 국토의 합리적 이용과 개발·보전을 통한 공공복리의 증진에 기여하고자 하는 목적으로 제도가 발전해 오고 있다. 공용제한에 있어 가장 중요하고 일반적인 대상은 토지재산권인데, 공용제한의 경우 공용수용과 사용과 달리 보상규정이 없는 경우가 많아 문제된다.

02 보상 원인으로서는 특별한 희생

재산권 침해로 인한 손실이 보상을 요하는 보상원인이 되는 것인가 여부는 그 침해가 재산권의 사회적 제약 또는 특별한 희생 중 어느 쪽에 해당하는 것인가의 구별문제이다. 재산권의 사회적 제약에 해당하면 보상할 필요가 없고, 특별한 희생에 해당하면 보상을 해야 한다. 그런데 이 양자를 구별하는 기준에 관해서는 형식적 기준설과 실질적 기준설이 대립되어 왔고, 양자를 종합하는 절충설이 있다. 이하 손실보상요건 내용 참조.

03 보상원인의 확대

1) 개설

헌법 제23조 제3항은 재산권 침해를 규정한 법률에서 보상규정을 둔 '적법한 재산권 침해'의 경우의 보상이다. 법률이 재산권에 대한 공권적 침해 규정을 두고, 보상규정은 두지 않은 '위법'한 경우에 피해자 구제가 문제된다. 이런 경우 독일의 판례를 통해 형성된 이론이 '수용유사적 침해' 이론이다. 또한 헌법 제23조 제3항은 보상이 '의도된 침해'에 대한 보상으로 보는 경우인데, 적법한 공권력 행사에 의한 '비의도적인 부수적 침해'에 대한 구제도 문제된다. 이 경우의 독일 판례를 통해 형성된 이론이 '수용적 침해' 이론이다.

오늘날은 국가작용의 위법·적법, 의도적·비의도적 부수적 침해 등을 구분하지 않고 공권력 작용에 의해 재산권 침해의 결과가 나타나면 이에 대해 광범위하게 손실보상을 함으로써 재산권을 보호하는 방향으로 나아가고 있어 손실보상의 원인이 점차 확대되어 가는 경향에 있다.

2) 수용유사적 침해

(1) 의의

수용유사적 침해란 법률이 공용침해에 대한 규정은 두고, 손실보상의 근거규정을 두지 않아 결과적으로 위법하게 된 특별한 희생에 대해 손실보상을 하자는 이론이다. 적법한 재산권의 침해가 보상된다면, 위법한 침해로 인한 손해는 당연히 구제되어야 한다는 형평적 논리를 기초로 하여, 수용과 유사한 공용침해로 보아 손실보상을 인정하는 이론이다.

(2) 인정요건

본래 행정상 손실보상의 모든 요건은 갖추어야 하고, 침해의 위법성 요건만이 다르다. 이 경우 침해의 위법성은 행정상 손해배상에 있어서의 위법개념이 아니라, 공용침해 자체는 법률에 근거하여 적법하나, 헌법이 요구하는 보상규정을 두지 않아 그 근거 법률이 위헌이라는 점에서 위법을 의미한다.

(3) 우리나라에서 인정여부

우리나라에서 이 이론을 수용할 수 있을지 견해가 대립된다. 이하 헌법 제23조 제3항의 효력논의 참조.

3) 수용적 침해

(1) 의의 및 법적 근거

수용적 침해란 적법한 공권력 행사의 비정형적이고 비의도적인 부수적 효과로서 발생한 개인의 재산권 손실에 대하여 손실보상을 인정하자는 이론이다. 이는 보상규정이 없는 경우에도 당해 행위의 위법성 문제를 제기하지 않고 그로 인한 손실을 전보해 주려는 데 의의가 있다. 우리나라의 경우 헌법상 기본권 보장, 법치국가 원리, 사회국가 원리 등에서 근거를 찾을 수 있다.

(2) 인정요건

공공필요에 의한 재산권의 침해로서, 적법한 공권력 행사로 의도하지 않은 비정형적·비의도적인 손실이 발생해야 한다. 손실은 사회적 제약을 넘은 특별한 희생이어야 한다. 예를 들어, 통행곤란 때문에 인근 상가의 매출에 타격을 주는 경우가 해당한다.

(3) 우리나라에서 인정여부

헌법 제23조 제3항의 규정을 엄격하게 해석하여, 의도된 적법한 공용침해만을 보상대상으로 한다면, 사실행위에 의한 침해나 간접적 침해 등 의도되지 않은 적법한 침해는 보상대상으로 하지 않고 있는 것이 된다. 보상여부에 대하여 견해대립이 있으나, 수용적 침해보상설은 예상치 못한 부수적 결과로 인한 피해에 보상입법이 없는 우리 현실을 고려하여 수용적 침해보상이론을 원용하자는 견해이며, 기타 견해는 헌법 제23조 제3항의 보상부정설, 직접효력설, 간접효력설(유추적용설)이 있다.

4) 희생보상청구권

희생보상청구제도는 행정기관의 고권작용으로 인해 생명·건강·명예·자유 등과 같은 비재산적 법익의 침해에 대하여 보상해 주는 제도이다. 독일에서 발달한 이론이다. 성립요건으로는 공공필요, 행정기관의 고권작용에 의한 비정형적 결과로서 비재산권에 대한 특별한 희생의 발생이 필요하다. 비재산권은 보호가치성이 있어야 한다. 손실의 내용으로는 치료비용, 요양비용, 일실이익 등이 되고, 정신적 피해를 이유로 한 위자료 청구는 인정되지 않는다. 직무행위로 인한 손해배상청구권과 희생보상청구권은 서로 배척하지 않고 병렬관계에 있다. 우리나라에서 실정법과 판례는 일반적 제도로써 희생보상청구권을 인정하지 않고 있다. 그러나 학설에서는 헌법의 기본권 규정(제10조, 제12조)과 평등조항(제11조)을 직접 근거로 하여 인정하자는 견해와, 이 조항들로부터 간접적으로 도출된다는 견해가 있다.

01 존속보장과 가치보장

1) 존속보장

(1) 의의

존속보장이란 재산권자가 재산권을 보유하고 향유(사용, 수익, 처분)하는 것을 보장하는 것을 말한다. 사유재산제도 하에서 재산권은 생활의 기초가 되므로, 존속보장은 중요한 의미를 갖는다.

(2) 헌법적 근거 및 내용과 한계

헌법 제23조 제1항은 재산권을 기본권으로 보장하고 있고, 재산권의 기본적 내용은 사용권, 수익권, 처분권이다. 그런데 오늘날 재산권은 공공복리상 사회적 제약을 받는다(헌법 제23조 제2항). 헌법은 재산권을 보장하되, 그 내용과 한계는 법률로 정하는 것으로 규정하고 있다.

(3) 존속보장 실현제도

존속보장의 실현제도로는 공용침해에서의 공공필요 요건, 환매제도, 분리이론, 위법한 재산권 침해행위에 대한 취소소송 등이 있다.

2) 가치보장

(1) 의의

가치보장이란 공공필요에 의해 재산권에 대한 공권적 침해가 행해지는 경우 재산권의 가치를 보장하기 위해 보상 등으로 가치보장조치를 취하는 것을 말한다.

(2) 헌법적 근거 및 내용과 한계

헌법 제23조 제3항은 공용침해시 손실보상 의무를 규정하고 있다. 특히 정당보상원칙을 선언하고 있다. 다만, 공용침해가 재산권의 사회적 제약에 그치는 경우는 보상이 주어지지 않는다.

(3) 요건

재산권에 대한 공공필요가 있어야 한다. 손실보상에 관한 법률규정이 반드시 필요한지에 관하여는 견해대립이 있다.

3) 존속보장과 가치보장의 관계

공공필요를 위해 공용침해가 행해져서 손실보상이 이루어지는 경우, 재산권의 존속보장은 가치보장으로 전환된다.

02 경계이론과 분리이론

1) 경계이론

(1) 개설

과거 독일의 연방통상최고법원은 오랫동안 판례를 통하여 수용과 재산권의 사회구속성, 손실보상 등에 영향을 미치는 많은 결정을 내림에 따라 기본법상 재산권 분야에 있어서 중요한 역할을 담당해 왔다. 이러한 연방통상최고법원의 판례를 통해 발전한 이론을 경계이론 또는 전환이론이라 한다.

(2) 의의

경계이론은 사회적 제약과 공용침해는 별개의 제도가 아니라 재산권자에 의한 효과, 즉 침해의 정도에 따라 구별된다고 보고, 재산권의 내용과 한계규정이 특별한 희생을 야기하는 경우 수용이 된다고 보는 이론이다. 사회적 제약은 재산권에 대한 침해가 적은 경우로서 보상 없이 감수해야 하는 반면, 공용침해는 재산권의 사회적 제약의 범주를 넘어서는 것으로서 보상을 필요로 하는 재산권에 대한 침해를 의미한다. 따라서 보상을 요하지 않는 사회적 제약은 '재산권 제한의 효과'가 일정한 강도를 넘기 때문에 자동적으로 보상을 요하는 공용침해로 전환하게 된다.

(3) 내용

이 이론의 핵심은 보상을 요하는 수용과 보상을 요하지 않는 사회적 제약간의 경계설정, 즉 보상의무가 시작되는 경계선을 찾는 데 있다고 한다. 이러한 경계를 확정하는 기준으로는 형식적 기준설, 실질적 기준설, 그리고 절충설이 존재한다. 경계이론은 결과적으로 재산권보장의 의미를 가치보장으로 이해하는 것에 바탕을 두고 있다.

(4) 위헌의 판단

재산권 제한의 정도가 일정한 강도를 넘어 보상을 요하는 수용으로 전환되는 경우에도 보상규정을 두지 않았을 때 위헌성은 헌법 제23조 제3항이 스스로 정하고 있는 조건에 따라 판단한다.

(5) 보상의 성격

공용침해의 효과로서 존속보장을 가치보장으로 전환시키는 것으로서, 정당보상 구현을 위해 원칙적으로 금전보상이어야 한다.

(6) 경계이론의 평가

경계이론에 의하면 재산권의 내용규정과 수용규정은 별개의 제도가 아니라 재산권 제한의 정도와 효과에 따라 전환이 가능한 관계에 있다고 본다. 따라서 법원은 특별한 희생에 해당한다고 판단하는 경우, 보상판결을 할 수 있게 된다고 한다. 그러므로 이 이론은 재산권에 대한 폭넓은 가치보장제도로써 긍정적 측면을 지니고 있는 것으로 평가된다. 그러나 입법자가 당초 의도하지 않은 재산권 침해가 사실상 야기되는 경우, 금전적 가치보장으로 재산권 침해라는 공법적 법률관계를 그대로 인정하게 된다는 점에서 재산권의 존속보장원칙의 약화를 초래하는 부정적 의미를 가지는 것으로 평가되고 있다.

2) 분리이론

(1) 개설

과거 독일의 연방헌법재판소는 1981년 자갈채취판결을 통해 헌법상 수용개념의 확대를 가져온 종래의 경계이론을 반박하고, 무엇이 내용규정이요 무엇이 수용규정인가는 행위형식에 관한 입법자의 결정에 따라 형식적으로 결정된다고 하는 분리이론을 제시하였다.

(2) 의의

분리이론은 재산권의 내용규정과 공용침해를 헌법적으로 서로 다른 독립된 제도로 보고, 입법의 목적과 형식에 따라 구분하려는 견해이다.

(3) 내용

분리이론은 재산권자에게 과도한 부담을 주는 내용 및 한계규정도 수용으로 전환되지 않고 위헌적 내용 및 한계규정으로 남는다는 입장을 취한다. 재산관련 법률은 ① 재산권의 내용과 한계를 규정하는 법률, ② 직접적으로 공용수용을 규정하거나 행정행위를 통해 공용수용을 인정한 법률, ③ 독일기본법 제14조에 따른 재산권의 내용과 한계규정의 범위를 넘었으나 공용수용을 예견하지 않아 보상규정을 포함하지 않은 법률 3가지 경우로 구분된다. ③의 법률은 위헌이 되며 이에 기한 수용적 처분도 위법이나 보상규정이 없으므로 보상은 청구할 수 없고 수용적 행위의 취소를 행정법원에 청구할 수 있게 된다.

(4) 위헌의 판단

재산권의 내용규정이 재산권에 내재하는 사회적 제약을 넘어 과도한 제한이 되는 경우에는 헌법상 비례의 원칙 및 평등원칙에 반하게 된다.

(5) 보상의 성격

법률의 위헌성을 제거하고 비례성을 회복하여 합헌적 내용규정이 되도록 하기 위한 정책적, 조절적, 균형적 보상의 성격을 가지므로, 일차적으로는 경과규정, 예외규정, 해제규정, 국가침해의 제한 등 비금전적 구제가 행해져야 하고, 이러한 구제조치들이 어려운 경우 이차적으로 손실보상, 매수청구의 보상이 주어져야 한다.

(6) 분리이론의 평가

분리이론은 재산권의 내용을 우선적으로 존속보장으로 이해함으로써 헌법 내에서 재산권의 기능에 보다 합치한다는 평가를 받는다. 분리이론은 보상의무 있는 재산권의 내용규정에 대하여 사전에 보상규정을 마련함으로써 재산권의 존속보장에 치중하고 있다.

분리이론은 헌법재판소, 입법자, 법원 간의 관계에 있어서 헌법상 권력분립 질서에 보다 부합한다고 할 수 있다. 헌법재판소에게는 법률에 대한 최종 심사권인 위헌심사권을, 입법자에게는 재산권의 내용규정과 공용침해라는 두 법제 간 형식에 관한 선택권을, 법원에게는 입법자가 공용침해의 형식을 택하여 보상규정을 둔 경우 구체적으로 정당한 보상인가의 판단권을 각각 부여함으로써 각 기관의 권력분립질서에 부합한다.

분리이론은 과도한 부담을 가져오는 재산권 제한에 대하여 다양한 권리구제 방법을 제공하게 된다.

경계이론에 따르면 과도한 부담을 가져오는 재산권 제한에 대하여 금전보상만이 고려될 뿐이나,

분리이론에 의하면 가혹한 부담을 완화하기 위해 입법적으로 다양한 가능성을 제공할 수 있게 된다.

예를 들어 공용침해를 수반하는 구역 지정의 부분적 해제와 같은 대상조치, 경과규정, 예외적인 가혹함을 완화하는 다른 조치 등이 고려될 수 있다.

(7) 우리나라에의 도입

분리이론은 독일 연방헌법재판소에서 취해진 이론인데, 이 이론에 대하여 찬성하는 견해는 존속보장을 강화하는 분리이론이 재산권보장에 기여할 수 있다고 한다. 도입에 반대하는 견해는 우리나라 헌법 제23조 제3항은 독일 기본법 제14조 제3항과 달리, 재산권의 수용뿐만 아니라 사용 및 제한도 규정하고 있기 때문에 공공필요에 의한 재산권의 제한은 공용제한과 손실보상의 문제로 보아야 한다고 주장한다.

03 헌법 제23조 제3항이 불가분 조항인지 [★]

1) 의의 및 기능

불가분조항이란 공용침해의 근거규정과 이에 대한 손실보상규정이 하나의 법률로 규정되어야 하고, 서로 불가분의 관계를 형성하고 있어야 한다는 것이다. 이는 재산권보장의 실효성 확보 및 가치보장 실현 등에 의의가 있고, 재산권자의 권리보호, 입법자에 대한 경고기능 등을 한다.

2) 우리 헌법상 인정여부

(1) 학설 및 판례

① <긍정설>

손실보상의 기준과 범위의 내용 등은 본질적 사항에 해당하므로, 반드시 입법자가 스스로 규율하는 데 의의가 있다고 하여 긍정한다.

② <부정설>

우리 헌법과 독일 기본법상의 표현이 다르고, 우리 헌법 제23조 제3항은 수용규정과 보상규정이 별개의 법률에서 규정될 수 있다고 새겨질 여지가 있으므로 불가분조항이 아니라 한다.

③ 판례는 “헌법 제23조 제3항 규정은 보상청구권의 근거에 관하여서뿐만 아니라 보상의 기준과 방법에 관하여서도 법률의 규정에 유보하고 있는 것으로 보아야 하고, 구 토지수용법과 지가공시법의 규정들은 바로 헌법에서 유보하고 있는 그 법률의 규정들로 보아야 할 것이다.”라고 하여 불가분조항으로 보고 있는 입장이다(대판 1993. 7. 13. 93누2131).

(2) 검토

헌법 제23조 제3항은 공용침해의 근거규정과 보상규정이 하나의 법률 안에 규정될 것을 요구한다고 해석되므로, 불가분조항으로 봄이 타당하다.

01 서

헌법 제23조 제3항은 재산권에 대한 공용침해 허용요건을 규정하고 있는 동시에 손실보상요건의 원칙적 규정이다. 손실보상청구권이 인정되려면, 공공필요에 의한 적법한 재산권의 공권적 침해가 있고, 그로 인한 특별한 희생이 발생하고 보상규정이 존재해야 한다.

02 공공필요 (공공성)

1) 개념

헌법 제23조 제3항에 따른 공공필요는 공용침해의 '실질적 허용요건이자 본질적 제약요소'이다. '공공필요'란 공익사업을 시행하거나 공공복리를 달성하기 위해 재산권의 침해가 불가피한 경우로서, 오늘날 공공필요는 국가안전보장, 질서유지, 공공복리 외 지역경제상 이익도 포함하는 넓은 의미로 사용되고 있다. 공익성이란 대표적 불확정 개념으로서 적극적으로 무엇을 의미하는가를 밝히기는 매우 어렵고, 소극적으로 개념규정을 하는 것이 일반적이다. 공익성은 시대에 따라 그 개념 및 해석을 달리하여 오고 있다.

2) 토지보상법 제4조의 공공성의 개념

토지보상법 제4조는 전통적으로 공공성을 지닌 공익사업 및 사인이 임대 등 목적으로 시행하는 주택건설 등 사업 등을 규정하여 공공성 개념을 반영하고 있다. 동조 제8호는 그 밖에 별표에 규정된 법률에 따라 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업을 공익사업으로 규정하여, 개별 법률에 따라 공공필요가 인정되는 수용적격사업을 규정하고 있다.

3) 공공성의 확대화 경향

오늘날에는 공공성 개념이 사회정의 실현과 사익과의 적절한 조절과 규제를 통한 국민 전체의 공공복리 증진이라는 복리국가주의의 요청, 행정기능 확대에 의한 행정수요의 증대 등으로 인해 그 개념이 확대·변화되고 있다. 따라서 공익사업의 범위도 넓어지고, 사유재산권의 침해가능성도 커지게 된다. 특히 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 등 개발사업법에서 공익사업에 대한 투자유치 필요성에 의하여 민간사업자에게도 광범위하게 수용권을 인정해 가는 추세에 있다. 따라서 토지 취득을 전제로 하는 공익성의 판단은 엄격하게 이루어져야 할 것이며, 그 구체적 개념의 정립 및 해석이 매우 중요하다.

4) 판단기준

토지보상법 제4조상의 판단기준과 아울러, 이 조항에 해당하는 공익사업이라 할지라도 실질적으로 공익성이 있는지 여부를 비례의 원칙에 따라 개별적·구체적으로 판단하여야 할 것이다. 즉 단계적 심사구조에 의하되, 공익사업으로 인한 공익과 침해되는 재산권의 사익간 비교형량에서 공익이 더 커야만 공공필요가 인정될 것이다.

03 재산권에 대한 공권적 침해

1) 재산권의 의의

재산권이란 토지소유권 및 그 외 재산적 가치가 있는 일체의 권리를 의미한다. 재산가치는 현존하는 것으로서, 기대이익은 재산권에 포함되지 않는다. 토지보상법은 보상대상이 되는 재산권에 대하여 제3조에 규정하고 있다.

2) 공권적 침해성

공권적 침해란 행정청에 의한 공권력 행사로 인한 재산권의 박탈 등 재산권에 대한 일체의 감손행위를 말한다. 우리 헌법 제23조 제3항은 공권적 침해로서 수용, 사용, 제한을 규정하고 있으나, 이에 한정되지 않고 공용환지, 공용환권으로 인한 재산적 가치의 감소, 토지출입 및 장애물 제거 등도 포함한다고 할 것이다.

3) 침해의 직접성·의도성

침해의 직접성이란 재산권에 대한 침해가 공권력 주체에 의하여 의욕되고 지향되었거나, 최소한 상대방의 손실에 대한 직접적 원인이 되는 경우를 말한다. 따라서 개인이 입은 재산상 손실이 공권력 발동을 통하여 직접 의도된 것이 아니고 그 밖의 부수적 사정이 가미되었거나, 간접적·결과적으로 야기된 경우에는 침해의 직접성이 인정되지 않는다. 의도되지 않은 침해의 보상은 손실보상청구권의 또 다른 확장의 문제가 된다(독일에서는 수용적 침해 보상청구권의 문제로 다룬다).

04 적법한 침해

적법한 침해란 법률에 근거한 침해를 의미한다. 헌법 제23조 제3항에서는 공용침해 및 그에 대한 보상은 법률로써 하여야 함을 명시하고 있다. 여기서 법률은 형식적 의미의 법률을 의미한다. 공용침해의 일반법으로서 토지보상법이 존재한다.

05 특별한 희생

1) 문제점

공공필요에 의해 개인의 재산권에 대한 공용침해가 이루어진다 하더라도 모든 공용침해행위가 손실보상대상이 되는 것은 아니다. 공용침해가 개인이 감수하기 어려운 특별한 희생을 발생시킨 경우에만 공평부담 견지에서 조절적 보상이 주어지는 것이다. 즉 그 침해의 정도가 헌법이 예정한 재산권의 내용과 한계 내에 머무른다면 손실보상대상이 될 수 없다. 따라서 재산권의 사회적 제약과 특별한 희생을 어떻게 구별할지 그 구별기준이 중요해진다.

2) 특별한 희생의 의미

특별한 희생이란 특정 개인에 대한 수용, 사용, 제한이 사람들이 수인할 수 있는 정도를 넘는다는 점에서 특별한 것이라는 의미이다.

3) 판단기준

(1) 형식적 기준설

형식적 기준설은 평등의 관점에서 판단하며, 개별행위설 또는 특별희생설이라고도 한다. 공용수용에 해당 하는가를 가리기 위해서는 먼저 재산권의 침해를 받는 자가 특정되어 있는가 일반적인가라는 점에서부터 출발한다. 특정인에게 가해지는 재산권의 침해는 그 자에 대해서만 가해지는 침해이기 때문에 당사자에게 불평등하게 과하는 개별적 침해이다. 또한 전체와의 대비에서 소수의 자 및 특정집단에 대한 침해가 일반인과 비교했을 때 평등원칙을 깨면서 이루어진 경우 특별희생을 야기하는 것으로 본다.

(2) 실질적 기준설

실질적 기준설은 재산권을 침해하는 행위의 실질적 내용(침해의 본질성 및 강도)에 따라 공용수용의 개념을 규정하려고 하는 이론이다. 이러한 학설들은 고찰 방법이 일면적이고 확실성을 결하고 있기 때문에 약점이 지적되고 있기는 하나, 공용수용에 해당하는 특별희생을 구별하는 기준으로 높이 평가되고 있다. 논자에 따라 특히 사적효용설, 목적위배설, 상황구속성설, 수인한도설을 종합적으로 적용하는 것이 타당하다는 주장도 있다.

a. 보호가치성설

보호가치성설은 역사, 일반적 가치관, 법률의 취지 등을 통하여 침해되는 재산권이 보호가치가 있는가 없는가를 기준으로 하여 보상을 요하는 공용수용의 개념을 규정하려 한다.

b. 수인한도성설

수인한도성설은 재산권의 침해가 재산권 주체에게 보상없이 수인가능한 것인지 아니면 수인한도를 넘는 것인지에 따라 특별한 희생과 사회적 제약을 구별하려는 견해이다.

c. 사적 효용설

사적 효용을 재산권의 본질적 내용으로 보고, 재산권이 제한되고 있는 상태에서도 아직 재산권의 기능에 합당한 사적 효용이 유지되면 사회적 제약에 불과하지만, 재산권 침해가 사적 효용을 본질적으로 침해하는 경우 특별한 희생이 된다고 본다.

d. 목적위배설

재산권을 침해하는 행위가 당해 재산권에 대하여 종래부터 인정되어 온 목적에 위배되는 경우에는 보상을 요하는 특별한 희생으로 본다. 이 설은 재산권을 침해하는 행위가 종래 인정되고 있었던 것과는 다른 목적을 위해 이용되는 것인가 아닌가에 따라 공용수용의 개념을 규정하려는 것이다.

e. 사회적 제약설

사회적 제약 또는 사회적 구속이란 개념은 “보상없이 행하는 것이 헌법상 가능한 것과 같은 재산권의 고권적 제약”을 의미하는 것이라 한다. 사회적 제약설은 사회적 제약을 넘어선 모든 재산권의 침해에 대하여는 보상을 요하는 침해행위로 보나, 일반적인 기본권 이론에 비추어 허용되는 경우에 해당하게 되면 보상을 요하지 않는 사회적 제약으로 본다.

f. 상황구속성설

상황구속성이란 토지의 사회적 구속의 내용 정도는 그 토지가 놓여 있는 상황, 종래의 이용 형태 등에 따라 다르다는 것이다. 재산권이 처한 특수한 상황에 비추어 재산권 주체가 이미 예상할 수 있는 단순한 재산권 행사상의 제한이 가해지면 그 제한은 사회적 제약에 불과하다는 입장이다.

(3) 절충설

절충설은 형식적 기준설과 실질적 기준설이 일면적으로 타당성을 갖더라도 완전한 구별기준으로서 기능할 수 없다는 데서 비롯되는 견해이며, 이 양 설을 함께 고려하여 판단해야 한다는 주장이다. 왜냐하면 재산권의 관념이나 그에 대한 평가는 시대나 사회, 상황에 따라 변하기 때문에 재산권의 제한과 보상도 일정한 기준의 적용이 불가능하기 때문이다. 절충설이 우리나라의 다수설이다.

(4) 검토

양 설의 공통적 문제점은 그 내용이 불확정적이라는 평가를 받고 있다는 것이다. 따라서 공용침해에 대한 보상 여부의 판단은 양 설의 기준을 동시에 고려해서 판단해야 한다. 그러나 어떠한 기준에 의하더라도 과잉금지의 원칙, 특히 비례의 원칙을 어기는 재산권의 제한은 단순한 사회적 제약이라고 평가하기 어렵다는 주장이 설득력을 갖는다.

이론적으로는 절충설이 타당하다 하더라도 그 구별기준이 추상적이어서 객관성을 갖기에는 부족함이 많다. 따라서 이들 기준이 실제 활용에서 유용성을 지니지 못함을 인지하고, 이러한 기준은 보상 입법을 위한 전제가 될 따름이고, 어떠한 공용침해에 대하여 보상을 해야 하는가 명백한 해답을 주지 못하기 때문에, 양 설을 중심으로 보상 여부를 결정할 수 있는 구체적 기준을 설정할 필요가 있다.

06 보상규정의 존재

1) 문제점

손실보상을 하려면 반드시 법률에 보상규정이 있어야 한다. 헌법 제23조 제3항이 “법률로써” 정당한 보상을 지급하도록 규정하고 있다. 이는 손실보상의 기준과 방법 및 내용 등의 사항이 법률상 존재해야 한다는 것을 의미한다. 그러나 공공필요에 의한 공용침해가 행해졌는데, 법률에 손실보상규정이 없을 경우 국민이 손실보상청구를 할 수 있는가 문제된다. 이는 현실적으로 헌법 제23조 제3항의 법적 효력 문제와 관련된 논의로서, 이에 대해서는 견해가 나뉘고 있다.

2) 학설

(1) 입법지침설 (방침규정설)

손실보상에 관한 헌법 규정은 입법에 대한 방침규정에 불과하다는 견해로서, 공용침해는 규정하는 법률에 보상 규정이 없더라도 위헌이 아니며, 본래 입법자는 보상규정이 없으면 보상청구권도 없는 것으로 본다. 이 설의 특징은 헌법의 손실보상 조항을 단순히 사유재산권의 보호를 선언한 것에 불과하다고 보며, 법의 침묵은 손실보상을 인정하지 않는 것으로 해석하는 데에 있다. 오늘날 이 설을 취하는 학자는 찾아보기 드물다.

(2) 위헌무효설

헌법 제23조 제3항의 공용침해의 경우 정당한 보상을 당연한 것으로 전제한 다음, 그 보상의 구체적 기준과 방법은 법률로 정하도록 유보하고 있기 때문에 재산권의 침해를 규정하면서 보상 규정을 두지 않은 것은 위헌이라는 것이다. 따라서 법률의 근거 없이 손실보상청구권은 구체화될 수 없으며, 손실보상청구권도 행사할 수 없다고 본다. 따라서 피해자는 재산권 침해행위의 취소를 구하는 취소소송을 제기하고, 그 취소소송절차에서 위헌심판제청을 신청하여 헌법재판소에서 위헌결정이 내려진 경우에 침해행위의 취소판결에 의하여 재산권 자체의 회복을 기할 수 있을 것이라 한다. 또한 법률상 손해배상 또는 원상회복을 청구할 수 있는 것으로 보는 것이 일반적이다.

(3) 직접효력설

공용침해에 관한 법률이나 이에 의거한 행위가 보상 규정을 두지 않았다 하여 바로 위헌무효라 해석할 것이 아니라, 이것이 일반적으로 당연히 수인하여야 할 범위를 넘고 특정인에게 특별한 희생을 과한 것인 때는 헌법의 보상규정을 직접 근거로 하여 손실보상을 청구할 수 있다고 보는 견해이다. 헌법 제23조 제3항이 명시적으로 '정당한 보상'을 규정하고, 보상 자체를 필수적인 것으로 하고 단지 그 기준과 방법을 법률에 위임하고 있으며, 동조 제1항에서는 사유재산제도를 보장하고 있으므로 보상청구권 그 자체가 직접 효력을 갖는다는 것이다. 따라서 보상의 법률 근거가 없어서 직접 국가에 대하여 보상을 청구할 수 있고, 행정청이 보상을 하지 않는 경우 피해 당사자는 법원에 소송을 제기하여 결국 법원이 보상 여부와 보상액을 정하게 된다고 한다.

또한, 현행 헌법 규정에 미루어 볼 때 법률이 적극적으로 보상을 하지 않는다는 뜻으로 보상규정을 두지 아니한 때에는 위헌무효이나, 당해 법률이 보상을 배제하는 취지의 것이 아닌 한 위헌무효로 단정지을 수 없으며, 직접 헌법 규정에 의거하여 보상을 청구할 수도 있다고 한다. 그러나 이 설은 우리 헌법 제23조 제3항의 변천에 비추어 보면 타당하지 아니하다는 비판이 있다. 헌법 제23조 제3항에서 보상을 법률로써 정하라는 것은 보상해야 하는 특별한 희생이나의 여부를 입법자가 정하는 것임에도 불구하고, 이 설은 입법자가 정하지 아니한 경우 법원이 정하도록 한다는 것은 현행 헌법 아래서 불가능하다는 것이다.

(4) 간접효력설 (유추적용설)

간접효력설은 공용침해에 따른 보상 규정이 없을 때 헌법 제23조 제1항의 재산권보장조항 및 제11조 평등원칙에 근거하여, 헌법 제23조 제3항 및 관계 규정의 유추적용을 통하여 보상을 청구할 수 있다는 주장이다. 이 설은 수용유사침해의 법리를 받아들여 문제를 해결하고자 하는 견해로서, 위법·무책의 공용침해에 대한 보상과 국가배상과는 그 성립요건·범위 등에서 구별된다는 것을 배경으로 하고 있다.

그러나 이설에 대해서는 비판이 있다. 논자에 따라서는 보상을 법률에 유보한 헌법 제23조 제3항 규정에 불구하고 구체적으로 무엇을 어떻게 유추적용할 것인지가 분명하지 않다는 비판이다. 또한 독일과 같이 판례법이나 관습법으로서의 희생보상청구권의 법리 발전이 없는 우리나라에서는 인정하기 어렵다는 비판도 있다.

(5) 보상입법부작위위헌설

보상입법부작위위헌설은 재산권 침해를 규정하면서 손실보상 규정을 두지 않았다 하더라도 그 자체는 헌법에 위반하지 않으나, 손실보상 규정을 두지 않은 입법부작위가 위헌이라는 견해이다. 이 설은 재산권 침해를 규정하는 법률이 보상 규정을 두지 않았을 때 입법부작위에 대한 헌법소원을 통해 문제를 해결해야 하는 것으로 보고 있다.

3) 판례

〈대법원〉은 제3공화국에서 당시 헌법 제20조 제3항이 직접적 효력이 있는 규정이라고 보았고, 제4공화국에서는 이를 부정하였다. 현행 제23조 제3항의 직접효력 여부에 관하여는 대법원 판례가 나오지 않고 있다. 대법원은 공용침해로 인한 특별한 손해에 대한 보상규정이 없는 경우에 관련 보상법령규정을 유추적용하여 보상하려는 경향이 있다(유추적용설). 〈헌법재판소〉는 헌법은 수용 등에 대한 보상규정을 법률이 정하도록 국가에게 명시적으로 입법 의무를 부과하고 있는 점에 비추어 보면, 분리이론에 입각하여 보상입법부작위위헌설을 취하고 있다고 볼 수 있다.

4) 소결

① 〈위헌무효설〉

헌법 제23조 제3항 규정에 따르면 입법자가 재산권을 침해하는 입법을 행할 때 보상에 관한 규정을 두지 않았으면 그 법률은 위헌무효가 된다 할 것이다. 직접효력설이 직접 헌법 제23조 제3항 규정을 근거로 보상을 청구할 수 있다고 하고, 유추적용설이 헌법 제23조 제1항과 제11조를 근거로 보상을 청구할 수 있다고 하나, 이는 어디까지나 공용침해로 인해 발생한 특별희생에 대하여 보상하여야 한다는 이론적 근거일 따름이지 이들 헌법 규정을 근거로 실제 보상청구를 할 수 있는 것으로 볼 수 없다. 법률이 재산권을 침해하는 규정을 두면서 보상에 관하여 규정하지 않았다면 그 법률은 위헌무효이며, 이 법률에 의한 재산권 침해에 대하여는 손실보상을 청구할 것이 아니라 손해배상을 청구할 수 있을 따름이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 공용침해로 인해 발생한 손실이 특별한 희생에 해당하는 것에 대하여는 보상입법을 통해 해결하는 것이 가장 바람직할 것이다.

② 〈간접효력설〉

헌법 규정이 보상규정은 법률로써 정하라고 규정하며, 보상에 관한 법률규정 유무를 불문하고 공공필요를 위한 특별한 희생은 동일하게 보상해 주어야 한다는 점을 고려할 때, 관련 보상규정을 유추적용하는 간접효력설이 타당하다.

01 헌법상 기준

1) 정당보상

(1) 의의 및 문제점

헌법 제23조 제3항은 공용침해시 정당보상을 지급할 것을 규정하고 있어 그 의미가 무엇인지에 대하여 논의가 있다. 침해된 재산가치에 대하여 어느 정도로 보상할 것인가에 대하여는 각국의 입법 태도나 헌법을 뒷받침하는 사회 논리적 가치관에 따라 서로 다르다. 어떤 보상이 정당보상인가에 대하여는 한 마디로 말하기는 어려우므로 견해가 대립한다.

(2) 견해 대립

a. 완전보상설

손실보상은 피침해 재산이 가지는 재산적 가치에 대하여 완전한 보상을 해야 한다는 주장이다. 다시 말해 침해 전후에 있어 과부족이 없는 상태의 실현을 위해 침해 재산의 완전한 보상이어야 한다는 것이다. 정당한 보상이란 원칙적으로 피수용재산의 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하는 완전보상을 의미하며, 완전보상액을 하회할 수 있는 내용의 상당보상을 의미할 수 없다고 한다. 완전보상의 논거는 인권보장과 평등원칙의 실현 등에서 찾고 있다. 완전보상설은 손실보상의 목적은 평등원칙의 실현에 있으므로 부대적 손실을 포함하여 발생한 손실 전부를 보상해야 한다는 견해와, 손실보상은 재산권의 보장에 대응하는 것이므로 부대적 손실을 포함하지 않아도 피침해 재산의 객관적 가치를 보상하는 것이면 된다는 견해 나뉜다.

b. 상당보상설

상당보상설은 재산권에 대한 제한을 가하는 목적인 공공필요의 정도, 이를 필요로 하는 사회적·경제적 사정 등을 고려하여 산정되는 바의 상당 또는 합리적인 보상액이면 된다는 주장이다. 보상액 산정의 기초가 합리적이면 반드시 그 재산의 실세가격인 전액을 보상하지 않아도 된다는 주장이다. 보상액의 산정이 자의적인 것이 아니라 사회국가원리에 비추어 합리적 근거에 의거한다고 인정되는 것이라면 보상액이 때로는 완전한 보상을 밑돌더라도 위헌이 아니라고 한다. 이 견해는 재산권의 사회적 제약성 내지는 의무성을 바탕으로 하면서 사회국가적인 요청에서 오는 사회정책적 배려에 의한 것으로 파악할 수 있다.

상당보상설의 논거는 재산권보장과 정당보상이라는 표현에서 찾고 있다. 현행 헌법 조항이 완전한 보상이라 되어 있지 않고, 정당한 보상이라 표현하고 있으므로 반드시 완전보상을 말하는 것이 아니라 한다.

상당보상설은, 정당한 보상이란 그 당시 사회통념에 비추어 객관적으로 공정·타당하면 족하다는 합리적 보상결과, 사유재산제 아래에서는 완전보상을 원칙으로 하지만 합리적 이유가 있을 때 예외적으로 그것을 밑도는 것도 허용된다고 하는 완전보상원칙설이 있다.

c. 절충설

절충설은 손실보상의 원인이 되는 재산권의 침해를 완전한 보상을 필요로 하는 경우와 상당한 보상을 필요로 하는 경우로 나누어 생각하는 견해이다. 절충설은 주장하는 내용이 일치하지 않기 때문에 그 유형은 매우 다양하다. 전형적인 주장은 개인의 재산권에 대한 개별적 침해에 대해서는 완전보상을 요하나, 공익상 합리적 사유가 있거나 공익과 사익을 조정하는 견지에서 완전보상을 하회할 수 있다고 한다.

(3) 판례

① <대법원>

보상의 시기·방법 등에 어떠한 제한도 없는 완전한 보상을 의미한다고 하였다.

② <헌법재판소>

원칙적으로 피수용재산의 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하는 것이어야 한다는 완전보상을 뜻하는 것으로서 보상금액 뿐만 아니라 보상의 시기나 방법 등에 있어서도 어떠한 제한을 두어서는 아니 된다는 것을 의미한다고 하였다(헌재 1990. 6. 25. 89헌마107).

(4) 검토

헌법 제23조 제3항의 정당보상이 상황에 따라 상회·하회한다는 상당보상설은 평등원칙에 위배될 소지가 있다. 따라서 피침해자의 재산적 가치를 완전하게 보상하는 완전보상설이 타당하다.

2) 정당보상 의미의 확대

(1) 개설

보상대상은 일반적으로 당해 재산권에 대한 객관적 가치로 이해되어 왔다. 손실보상 이론에 사회복리국가 이념이 도입됨에 따라 보상은 부대적 손실까지 포함하는 재산권보상은 물론 피수용자의 생활안정까지 확대하여 생활보상도 포함해야 한다는 주장이 일반화되고 있다. 따라서 정당보상의 의미는 부대적 손실을 포함하는 재산권보상에서 한 걸음 나아가 생활권보상으로까지 확대되는 경향을 보이고 있다.

(2) 부대적 손실을 포함하는 재산권보상

재산권보상은 재산권의 객관적 가치에 대한 보상을 의미한다. 부대적 손실이란 수용으로 인한 재산권의 손실에 부수하여 발생하는 손실을 말한다. 부대적 손실은 공용수용에 일반적으로 수반하는 것으로서 정당보상에 포함되는 것으로 보아야 할 것이다. 보상법제가 채용하고 있는 부대적 손실보상에는 농업보상, 영업보상, 어업보상, 이전료보상 등이 있다. 부대적 손실은 반드시 피수용자측에서 발생하는 손실에 한정되지는 않고, 공익사업 시행으로 그 주변지역에 손실이 발생하였다면 이는 사업에 부대하여 발생하는 사업손실로서 마땅히 보상의 대상이 될 것이다.

(3) 생활보상으로의 확대

생활보상은 현재 당해 장소에서 현실적으로 누리고 있는 생활이익의 상실로서 재산권보상으로 채워지지 않는 손실에 대한 보상을 말한다. 보상법제에서 채용하고 있는 생활보상의 유형으로는 이농비, 이여비, 이주대책, 이사비·주거이전비 보상, 휴직 또는 실직보상 등이 있다. 정당보상은 피수용자의 생존권 확보와 불가분의 관계에 놓여 있다고 할 수 있다. 따라서 보상이 피침해 재산의 재산적 가치만 대상으로 하는 것이 완전한 보상에 이른다고 말할 수 없으므로, 피수용자의 본래 생활을 유지할 수 있게 할 때 비로소 '정당한 보상'이 이루어지게 된다.

02 토지보상법상 손실보상기준

1) 개설

토지보상법은 정당보상 실현을 위하여 손실보상 기준에 대한 규정을 두어 헌법상 정당보상을 구체화하고 있다.

2) 공시지가기준보상 (제70조)

협이나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 적정가격으로 보상한다. 이는 개발이익 배제를 위한 취지가 있다.

3) 시가보상 (제67조 제1항)

보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다. 시가보상의 취지는 개발이익 배제, 보상액의 공평화, 수용절차의 지연방지에 있다.

4) 개발이익의 배제 (제67조 제2항)

보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다. 개발이익 배제를 위한 공시지가 기준보상, 지가변동률의 적용 등 방법을 규정하고 있다.

판례는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제67조 제2항은 '보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지 등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다'라고 규정하고 있는바, 수용 대상 토지의 보상액을 산정함에 있어 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인, 고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 정하여야 하나, 해당 공익사업과는 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 포함한 가격으로 평가하여야 하고, 개발이익이 해당 공익사업의 사업인정고시일 후에 발생한 경우에도 마찬가지라고 판시한바 있다(대법원 2014. 2. 17. 선고 2013두21182 수용보상금증액).

5) 생활보상

재산권보상만으로는 전보되지 않는 생활보상을 위해 인정되는 보상기준으로서, 견해에 따라 생활보상의 범위가 다르다. 토지보상법 제78조의 이주대책, 제79조의 기타 공익사업으로 인한 손실보상 등을 대표적 생활보상의 형태로 볼 수 있다.

01 개설

침해된 재산가치에 대한 보상의 정도는 손실보상의 기준에 따라 결정된다. 손실의 보상이 정당보상에 이르기 위해서는 보상액 산정의 기준이 적정성을 지녀야 한다.

02 개발이익 배제 필요성 및 토지보상법 태도

개발이익이란 개발사업의 시행이나 토지이용계획의 변경, 그 밖에 사회적·경제적 요인에 따라 정상지가 상승분을 초과하여 사업시행자나 토지 소유자에게 귀속되는 토지 가액의 증가분을 말한다(개발이익 환수에 관한 법률 제2조 제1호). 개발이익은 일정 기간 동안 토지의 증가 가운데 토지소유자의 투자나 노력과 관계없이 발생한 것으로서 소유 불로소득에 해당한다. 손실보상은 현재화된 재산적 가치만을 보상하므로, 아직 미실현된 잠재적 가치인 잠재적 손실은 대상이 포함되지 않는다고 보아야 한다. 또한 개발이익은 토지소유자 노력과는 관계없는 이익이므로 이러한 이익은 투자자 또는 사회에 귀속되도록 하는 것이 바람직하다. 우리 토지보상법은 제67조 제2항에서 개발이익 배제를 보상 기준으로 명시하고 있다. 그러나 개발이익배제는 형평원칙에 반하고, 대토 등 어려움에 대한 문제점이 존재하여 개발이익 배제제도가 위헌인지에 대한 논란이 있다.

03 개발이익의 배제의 정당보상 합치여부

1) 문제점

사업시행자는 사업을 원활히 하기 위해 사업용지의 취득비용을 최소화하려 하고, 피수용자는 자신의 의사와 관계 없이 박탈되는 재산가치의 회복을 위해 보다 많은 보상을 요구한다. 이러한 사업시행자와 피수용자의 갈등 관계를 해소하기 위해서 보상의 정도를 적절한 수준으로 해야 하는데, 이 때 보상의 정도는 보상기준에 의해 결정된다.

이 때 개발이익이 당해 토지의 객관적 가치의 일부로서 보상액 산정에 포함되어야 하는지 문제된다.

이는 토지보상법상 개발이익 배제제도가 헌법상 정당보상원칙에 위반되는지의 논의이다.

2) 견해 대립

① 〈위헌설〉

어떤 사업으로 주변의 지가가 상승하면 그 상승이익은 일반적으로 토지소유자가 취득하므로 피수용자에 대해서 개발이익을 거부해야 할 이유가 없다고 한다. 또한 공익사업 주변지역 지가는 크게 상승하므로 피수용자가 보상금으로 주변지역의 대체토지를 취득할 수 없다는 점을 논거로 한다. 따라서 주변지역 토지소유자에 비해 상대적으로 손실을 수인하도록 하는 것은 형평에 반할 뿐만 아니라 정당보상원칙에 반한다고 한다.

② 〈합헌설〉

개발이익을 포함하여 보상함으로써 피수용자에게 이중의 이익을 주는 것을 배제하여 공평부담이라는 보상원리에 따르는 것을 논거로 한다. 개발이익은 미실현이익으로서 이를 포함한 보상은 토지의 사업시행 당시의 객관적 가치를 초과하여 보상하는 것이고, 공익사업 시행을 불모로 한 주관적 가치인 바, 배제함이 마땅하다는 것이다.

3) 판례

(1) 대법원

대법원은 개발이익을 배제한 보상액 산정이 타당하다는 입장을 유지해 오고 있다. 개발이익을 배제하고 손실 보상액을 평가하는 것이 정당보상의 원리에 합당하다거나(대판 1993. 7. 13. 93누227), 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 고려하지 아니하여야 한다고 한다. (대판 1999. 10. 22 98두7770)

(2) 헌법재판소

헌법재판소는 투기적 거래에 의하여 형성되는 가격은 정상적인 객관적 재산가치로 볼 수 없으므로 이를 배제한다고 하여 완전보상의 원칙에 어긋나는 것은 아니라고 하였다. 공익사업의 시행에 따른 지가 상승에 의하여 발생하는 개발이익은 사업시행자의 투자에 의하여 발생하는 것으로서 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생하는 것은 아니므로 이러한 개발이익은 형평의 관념에 비추어 볼 때 오히려 투자자인 사업시행자 또는 궁극적으로는 국민 모두에게 귀속되어야 할 성질의 것이고, 보상액 산정에서 당해 공익사업 시행으로 인한 개발이익을 배제하도록 규정하였다 하여 헌법이 규정한 정당한 보상의 원칙에 어긋나는 것이라거나 계약자유의 원칙, 평등원칙, 조세법률주의, 사회국가원리에 위배된다고 할 수 없다고 하였다. (헌재 2009. 12. 29. 2009헌바142 결정, 헌재 2010. 3. 25. 2008헌바102 등)

4) 검토

생각건대, 개발이익은 피수용 토지의 객관적 가치에 포함될 성질의 것이 아니어서 완전보상의 범위에 포함되는 피수용자의 손실이라고 볼 수 없고, 형평의 관념에 비추어 보더라도 이를 배제하고 손실보상액을 산정한다 하여 헌법상 정당보상원리에 어긋나는 것은 아니다. 개발이익의 배제는 입법정책상의 문제이고, 개발이익을 배제하는 입법을 하더라도 보상제도의 본질에 반하거나 정당보상 원칙에 어긋나는 것은 아니다.

04 개발이익 배제를 위한 법제

1) 공시지가 기준의 보상액 산정

토지보상법은 협의나 재결에 의해 취득하는 토지에 대하여 부동산가격공시법에 따른 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하도록 하고 있다(제70조 제1항). 사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 하고(제70조 제3항), 사업인정 후의 취득의 경우는 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로써, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제4항).

2) 지가변동률에 의한 시점수정

보상액은 공시지가를 시점수정하여 산정하도록 하고 있다. 즉 토지보상법은 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률과 그 밖에 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다(제70조 제1항)고 규정하고 있다. 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다(령 제37조 제2항). 대법원 역시 공시기준일부터 수용재결일까지 기간 동안 지가변동률을 당해 사업으로 인한 영향을 배제한 적정 변동률을 적용하도록 하고 있다(대판 1995. 4. 11. 94누262 등)

3) 당해 사업과 관계없는 공시지가에 의한 보상액 산정

토지보상법 제70조 제3항 및 제4항에 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득해야 할 토지 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제5항 및 령 제38조의2). 보상액 산정시 적용할 공시지가를 일정 시점으로 규정한 것은 당해 사업으로 인한 개발이익을 배제하기 위한 것이라 한다.

대법원 역시 “토지수용으로 인한 손실보상액을 산정함에 있어서 당해 공익사업 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인, 고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 수용재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 정하여야 하나, 당해 공익사업과 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 배제하지 아니한 가격으로 평가하여야 한다.”고 판시한 바 있다(대판 1993. 5. 14. 92누7795 등).

4) 공법상 제한 토지의 평가규정

공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다. 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(칙 제23조). 이 규정은 개발이익 배제를 위한 규정이다.

05 현행 개발이익배제제도의 문제점과 개선책

1) 문제점

(1) 피수용자와 사업 주변 지역 토지소유자간 형평성의 검토

최근 보상액 산정에서 개발이익을 배제하면 안 된다는 반대론이 제기되고 있다. 토지소유자가 보상액으로 대체지를 취득할 수 없는 상황에서 개발이익 배제는 토지소유자의 희생만 강요하는 것이라 한다. 그렇다면 개발이익을 배제한 보상액이 정당보상에 합치하는가에 대해 새로운 검토가 요구된다. 당면 과제는 피보상자의 권리구제와 공익사업의 원활화를 어떻게 조화시켜 나갈 것인가, 피수용지 주변 토지에서 발생하는 개발이익을 어떻게 환수할 것인가에 있다.

피수용자로부터 개발이익을 배제하면서 주변 지역의 토지소유자에게 사업으로 인해 발생하는 개발이익을 보유하게 하는 것은 평등원칙에 반하는 것임에 틀림없다. 보상이 공평·정익에 반하는 결과를 제거하기 위한 제도임을 생각할 때 수용당하는 자와 수용당하지 않는 자 간의 조정은 불가결하다 할 것이다. 이는 사업의 주변지에서 발생하는 개발이익을 어떻게 환수하여 피수용자와 형평을 유지하도록 할 것인가에 관심이 모아진다.

(2) 개발이익 배제의 불완전성

보상액 산정과정에서 당해 사업으로 인한 개발이익을 완전히 배제하기 어렵고, 각 개별법에서 재결신청기간의 특례를 두고 있어 사업이 장기화되는 경우 당해 사업으로 인한 개발이익이 보상액 산정시 포함될 가능성이 크다.

2) 개발이익 배제를 위한 법제의 개선책

개발이익이 적극적으로 배제될 수 있도록 하려면 시점수정 방법과 보상액 산정 기준일을 개선하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 아울러, 형평성을 고려하여 공익사업 주변 지역에서 발생하는 개발이익을 환수할 수 있는 제도가 필요하다.

01 개설

보상액의 결정은 시장가격주의를 기본원칙으로 해야 한다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 보상액은 시장가격원칙을 직접 채택하지 않고 단지 공시지가를 기준으로 시점수정하여 산정하도록 하고 있다. 따라서 공시지가의 적정성 여부가 정당보상과 직접 관련을 지닌다. 또한 토지보상법이 보상의 방법을 제약하는가와 관련되어 공시지가기준보상을 검토하여야 한다.

02 공시지가의 특성

공시지가는 토지특성상 가격형성요인이 복잡하여 적정가격을 판단하기 어려운 점을 극복하고 지가체계를 일원화하기 위한 제도이다. 공시지가는 정부가 객관적인 기준을 정하여 조사된 적정가격을 공시하는 것으로, 토지거래의 지표로 활용될 뿐만 아니라 국가 등의 행정목적을 위한 지가산정의 기준으로 활용되고 있다. 그러나 공시지가는 시장가치를 완전히 반영하지 못하기 때문에 이를 기준으로 보상금을 산정하는 것은 정당보상에 합치하지 않는 것으로 인식되고 있다.

03 공시지가기준보상과 정당보상

1) 문제점

공시지가가 일반적으로 시가에 미달한다는 점과 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하는 것이 보상 방법의 제한인가와 관련하여 공시지가기준보상이 정당보상에 합치하는지 문제된다.

2) 학설

① <위헌설>

공시지가기준보상은 보상액 산정방법을 제한하고, 공시지가는 시가에 미달하므로 공시지가기준보상 역시 완전보상이 되기 어려울 수 있으므로 정당보상이라 할 수 없는 견해와

② <합헌설>

공시지가기준보상은 개발이익을 배제하기 위한 방법으로서 보상액 산정방법의 제한이 아니라고 하여 정당보상에 합치한다고 보는 견해가 있다.

3) 판례

① 대법원은 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하는 것은 개발이익을 배제하기 위한 것으로 보상액 산정방법의 제한이 아니라고 하고, 공시지가는 인근 토지의 거래가격 등 제 요소를 종합적으로 고려하여 산정되므로 정당보상에 해당한다고 판시하였다.

② 헌법재판소는 공시지가가 적정가격을 반영하지 못하고 있다면 이는 제도운영상 문제로써 정하여진 절차에 의해 시정할 수 있으므로 공시지가 기준보상이 정당보상과 괴리되는 것은 아니라고 하였다.

4) 검토

공시지가기준보상은 개발이익배제라는 입법 취지가 인정되고, 공시지가가 시가에 미달한다고 하여도 인근 토지의 거래가격 등 제 요소를 모두 고려하여 보상액이 산정되므로, 공시지가 기준보상은 정당보상에 합치한다고 보는 견해가 타당하다.

01 개념과 근거

그 밖의 요인 보정이란 토지보상법 제70조 규정상 그 토지의 위치·형상·이용상황 등의 개별요인을 제외한 요인으로서 그 토지의 가치에 영향을 미치는 사항을 의미한다.

02 인정여부

1) 문제점

토지보상법은 공시지가가 시가와 괴리되는 경우, 그 차이를 보정할 수 있는 명시적 근거를 두고 있지 않다. 따라서 보상액 산정에서 고려할 수 있는 그 밖의 사항으로 인근 유사토지의 정상거래가격, 보상선례, 호가 등 기타사항 고려 가능성이 문제된다.

2) 견해 대립

① 〈부정설〉

공시지가 자체가 인근 유사토지의 정상적 거래가격 등 그 밖의 사항을 반영하고 있고, 토지보상법은 개별요인의 비교항목을 열거하고 있으며, 감정평가법인등의 자의성이나 재량을 배제하기 위해서는 법정 고려항목 이외에 어떤 요인도 고려할 수 없다고 한다.

② 〈긍정설〉

공시지가는 매년 1월 1일을 기준으로 가격시점 현재 적정시가에 미달할 수도 있으므로 정당보상이 되기 위해서는 그 밖의 사항을 고려할 수 있도록 해야 하고, 토지보상법은 개별요인의 비교항목을 예시한 것에 지나지 않는다고 한다. 따라서 이를 통해 공시지가를 기준으로 보상하는 방법이 정당보상에 이른다고 보고 있다.

3) 대법원 입장

(1) 인근 유사토지의 정상거래가격

첫째, 인근 유사토지의 정상거래가격의 고려이다.

대법원은 인근유사토지가 거래되거나 보상이 된 사례가 있고, 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 인근 유사토지의 정상거래가격을 고려할 수 있고, 보상선례가 인근 유사토지에 관한 것으로서 당해 수용대상토지의 적정가격을 평가하는 데 있어 중요한 자료가 되는 경우에는 이를 고려하는 것이 상당하다고 한다(대판 2007. 7. 12 2006두11507). 이와 관련하여 '인근 유사토지'란 그 토지가 수용대상토지의 인근지역에 위치하고, 자연적, 사회적 조건이 수용대상토지와 동일하거나 유사한 토지이며, '정상거래가격'이란 통상의 거래에서 성립된 가격으로 개발이익이 포함되지 아니하고 투기적 거래에 의해 형성된 것이 아닌 가격이라 한다(대판 2002. 4. 12 2001두9783).

(2) 보상선례

둘째, 보상선례의 고려이다.

대법원은 정당한 보상액을 산정함에 있어 보상선례를 반드시 고려하여야 하는 것은 아니고, 다만 인근 유사 토지가 보상된 사례가 있고 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 이를 고려할 수 있다고 한다(대판 2010. 4. 29 2009두17360).

그리고 경우에 따라서는 보상선례가 인근 유사토지에 관한 것으로서 수용대상토지의 적정가격을 평가하는 데 있어 중요한 자료가 될 수도 있을 것이므로 이러한 경우에는 이를 고려하는 것이 상당하다고 한다.

(대판 2007. 7. 12 2006두11507)

(3) 호가

셋째, 호가의 고려이다.

대법원은 단순한 호가시세나 담보목적으로 평가한 가격에 불과한 것까지 고려할 것은 아니라 한다.

(대판 2003. 2. 28 2001두3808) 따라서 보상액 산정시 고려할 수 있는 호가는 그것이 인근 유사토지에 대한 것으로, 투기적 가격이나 당해 공익사업으로 인한 개발이익 등이 포함되지 않은 정상적인 거래가격 수준을 나타내는 것임이 입증되는 경우에 한정된다고 한다(대판 1993. 10. 22 93누11500).

(4) 자연적 지가상승률

넷째, 자연적 지가상승률의 고려이다.

대법원은 공시지가에 당해 수용사업의 시행으로 인한 개발이익이 포함되어 있을 경우 그 공시지가에서 그러한 개발이익을 배제한 다음 이를 기준으로 하여 손실보상액을 평가하고, 반대로 그 공시지가가 당해 수용사업의 시행으로 지가가 동결된 관계로 개발이익을 배제한 자연적 지가상승분도 반영하지 못한 경우에는 그 자연적 지가상승률을 산출하여 이를 기타사항으로 고려하여 손실보상액을 평가하는 것이 정당보상의 원리에 합당하다고 한다(대판 1993. 7. 27. 92누11084).

4) 헌법재판소 입장

헌법재판소는 토지의 지가산정은 위치나 용도가 비슷하여 가장 근사한 가치를 지닌 것으로 예상되는 인근 유사 토지의 거래가격을 기준으로 하여 추산하는 방법에 의할 수밖에 없다고 한다(헌재 1990. 6. 25. 89헌마107).

또한 부동산가격공시법 제9조 제1항 단서 조항의 표준지공시지가를 적용하여 산정된 가격에 대해 가감조정이 '필요하다고 인정하는 때'란 "정당한 보상의 관점에서 보상대상자 사이의 형평, 보상선례 등을 고려하여 토지가격의 조정이 필요하다고 인정하는 경우"로 판단하였고, 이러한 "가감조정을 거쳐 헌법 제23조 제3항의 정당한 보상이 산정된다."라고 결정한 바 있다(헌재 2009. 11. 26. 2009헌마141).

5) 검토

생각건대 헌법 제23조 제3항의 정당보상을 '시가보상'으로 볼 때, 그 밖의 사항의 고려는 적정보상액의 산정을 통해 정당보상의 실현을 위한 것이므로 적정보상에 영향을 미칠 것으로 판단될 때 고려할 수 있는 것이라 생각된다. 나아가, 입법적으로 그 밖의 요인 보정에 관한 근거 규정을 마련하는 것이 필요하다고 생각된다.

01 보상대상의 변천

손실보상 대상은 역사의 변천에 따라 대인보상에서 대물보상으로, 대물보상에서 생활보상으로 변천해 왔다. 20세기 후반에 들어서면서부터는 새로운 생활보상의 관념이 등장하여 피수용자의 생활안정을 보상의 대상으로 생각하는 경향이 뚜렷하게 되었다.

1) 대인보상

대인보상이란 토지 등 수용 목적물의 객관적 가치를 기준으로 보상하지 않고, **피수용자의 수용 목적물에 대한 주관적 가치를 기준으로 하는 것을 말한다.** 즉 피수용자가 당해 토지를 사용함으로써 현저 얻고 있는 편익가치를 뜻한다. 손실보상은 개인의 입장을 대상으로 보상금액을 산출함으로써 보상액 산정에 객관적 기준이 적용되지 않아 대물보상에 비해 보상액의 수준이 높았다.

2) 대물보상

대물보상이란 수용 목적물에 대한 보상이 피수용자의 주관적 가치에 의하지 않고, **객관적 시장가치를 기준으로 보상하는 것을 말한다.** 대물보상은 수용의 대상과 보상의 대상이 대부분 일치하고, 피수용자에게 만족할 만한 보상이 되지 못하는 경우가 많다. 이를 보완하기 위해 등장한 것이 생활보상이다.

3) 생활보상

생활보상은 대물보상의 문제를 보완하기 위해 등장한 개념이다. 이러한 보상이론의 등장에 가장 많은 영향을 준 것이 사회복리국가이념이다. 손실보상은 사회복리국가적 관점에서 수용이 없었던 것과 같은 재산 상태로는 불충분하고, **수용이 없었던 것과 같은 생활상태를 회복시켜 주는 보상개념이다.**

02 생활보상

1) 의의

생활보상은 공익사업 시행으로 인하여 생활 기반을 상실한 자에게 종전의 생활 상태를 유지·회복시키기 위해 행하는 **보상을 말한다.** 생활보상은 피수용자나 관계인이 현재 당해 장소에서 현실적으로 누리고 있는 생활 이익의 상실로 인해 재산권보상으로 채워지지 아니하는 손실보상을 내용으로 한다. 따라서 생활보상은 수용으로 인해 발생한 손실에 대하여 재산보상 이외에 현재와 동일한 정도의 생활재건을 위해 행하는 것을 중심으로 하고 있다. 실정법 역시 단편적이거나 이에 관한 제도를 두고 있다.

2) 성격과 특징

(1) 성격

생활보상은 피수용자의 생활 안정을 보상 대상으로 하는 것으로, 제2차 세계대전 이후 여러 나라가 제도화하고 있고, 재산권보상과 함께 불가결한 것이라 해도 과언이 아니다. 생활권보상의 성격은 **인간다운 생활보장의 성격, 원상회복적 성격, 생활안정적 성격 그리고 사업 원활화의 성격으로 요약할 수 있다.**

(2) 특징

① 〈보상기준의 객관성〉

대인보상이 주관적 선택채가 농후한 반면, 생활보상은 일정한 수입, 이윤, 생활비 등을 기준으로 하여 보상액을 객관적으로 산출하므로 상당히 객관적이다.

② 〈보상 대상의 확대성〉

생활보상은 대물보상과 달리 수용 대상과 보상 대상이 일치하지 않는 점이 특징이다.

생활보상은 보상 대상이 수용 대상을 포함할 뿐만 아니라 이보다 넓은 범위에까지 미치고 있다.

③ 〈대인보상과의 유사성〉

생활보상은 피수용자에게 종전의 생활 회복을 위한 것이므로, 대물보상에 그치지 않고 사람에 대한 보상을 포함하는 경우가 적지 않으므로 대인보상에 가깝다.

④ 〈최종 단계의 보상성〉

보상이 인적에서 물적으로, 물적에서 생활로 변전한 것에서 보는 바와 같이, 생활안정을 도모하기 위한 할보상은 수용이 없었던 것과 마찬가지로의 생활상태를 재현하기 위해 지불되는 보상의 궁극이라 할 수 있다.

3) 법적 근거

(1) 헌법적 근거

생활보상이 정당보상의 범위에 포함하는가 정당보상의 범위 밖에 있는가와 관련하여 헌법적 근거에 대하여 견해가 나뉘고 있다.

a. 견해 대립

① 〈헌법 제34조설(생존권설)〉

이 견해는 생활보상의 근거를 헌법 제34조 제1항의 사회권적 기본권조항에서 찾는다. 생활보상은 헌법 제23조 제3항의 정당보상에 포함되지 않는다고 한다. 정당보상은 재산권의 객관적 가치를 지향하고 있으며, 생활보상이 정당보상에 포함된다고 하면 경제적 약자가 아닌 자에게도 생활보상을 해야 하므로 생활보상의 취지에 반하기 때문이라 한다. 이 견해에 의하면 헌법 제34조 제1항을 근거로 직접 법원에 생활보상을 청구할 수 있는 권리는 부정되고, 단지 이를 권리로 주장할 수 있는 실정법의 입법화를 요구할 수 있다고 한다.

② 〈헌법 제23조, 제34조 통일설〉

우리나라가 손실보상이 대물보상을 주축으로 하되, 생활보상을 지향하는 것에서 찾고 있다. 헌법 제23조 제3항은 대물보상 즉 재산권보상을 대전제로 하고, 헌법 제34조 제1항은 생활권적 기본권의 이념적 바탕을 제시함과 동시에 헌법 제23조 제3항이 정당보상을 명시하는 것은 결국 우리나라의 손실보상이 복리국가적 관점에서 생활보상을 지향하는 것이라는 것이다. 실정법에 보상규정이 없는 경우에도 이를 청구하려고 하면 헌법 제34조 제1항에 부가하여 직접 헌법에 의하여 보상이 가능하다고 해석되고 있는 헌법 제23조 제3항을 근거로 생활보상의 청구를 인정할 수 있다고 한다.

③ 〈헌법 제23조설(정당보상설)〉

이 견해는 헌법 제23조의 정당한 보상이 완전보상이라는 견해에 입각하여, 완전보상을 수용이 행해지기 전의 상태와 유사한 생활상태를 실현하는 보상으로 이해하여 생활보상도 완전보상의 하나로 본다.

b. 판례

- ① 헌법재판소는 이주대책은 공익사업의 시행으로 생활근거를 잃게 된 사람들에게 **생활보호 차원에서 실시하는 시혜적인 조치**에 불과하므로 헌법 제23조 제3항에서 말하는 정당보상에 해당하지 아니한다고 한다(헌재 1993. 7. 29. 92헌마30).
- ② 대법원은 이주대책의 본래 취지는 이주자들에 대하여 종전의 생활 상태를 원상으로 회복시키면서 동시에 **인간다운 생활을 보장해 주기 위한 이른바 생활보상의 일환**으로 국가의 적극적이고 정책적인 배려에 의하여 마련된 제도라 하여(대판 1994. 5. 24 92다35783) **제34조설**을 취하고 있다.

c. 검토

보상은 단순히 재산가치의 보상만이 아니라 피수용자의 종전 생활을 회복시키는 생활보상이 불가결하게 되었다는 점을 고려하면 **생활보상은 단순한 정책적 배려가 아니라 정당보상의 범위에 포함되는 것으로 보아야 할 것이다**. 따라서 생활보상의 근거는 헌법 제23조 제3항과 제34조 제1항에서 찾는 것이 타당하다. 그렇지만 법적 근거를 갖지 않는 생활보상이 헌법 조항을 근거로 청구할 수 있는 것은 아니므로, 이는 입법적으로 해결할 수밖에 없을 것이다.

(2) 법률적 근거

생활보상의 법적 근거는 명확하지 않다. 단편적이거나 토지보상법과 각 개별 법률에 찾아 볼 수 있다. 토지보상법은 비용보상 또는 공익사업시행지구 밖에서 발생한 손실보상규정(제79조)을 두고 있다. 이 규정은 손실보상에 관한 일종의 포괄적 규정으로 생활보상의 근거 규정으로 이해하고 있는 것이 일반적인 경향이다. 이 규정은 아울러 ‘사업손실보상’ 또는 ‘간접보상’의 근거이기도 하다.

4) 대상

(1) 문제점

생활보상의 대상은 학문적 개념과 일치하지 않을 뿐만 아니라 실정법상으로 제도가 정비되어 있지 않아 일률적으로 말하기 어렵다. 실정법을 중심으로 그 대상을 협의로 보는 견해와 광의로 보는 견해로 나뉜다. 이는 생활보상의 개념을 광의로 보느냐 협의로 보느냐에 따른 구별이다.

(2) 견해 대립

a. 생활보상의 의미

협의설은 생활보상의 개념을 현재 당해 장소에서 현실적으로 누리고 있는 생활이익의 상실로서 재산권보상으로 메워지지 않은 손실에 대한 보상으로 파악한다. 광의설은 수용 전과 같은 생활상태의 보장으로 파악한다. 광의설이 다수설과 판례의 태도이다.

b. 협의의 생활보상

재산권보상을 재산권 상실과 그에 부대하는 부대적 손실에 대한 보상으로 보고, 이 재산권보상 이외의 추가적인 보상을 생활보상으로 본다.

c. 광의의 생활보상 (생활재건조치)

금전적 보상에서 나아가 다른 지역에서 종전과 같은 생활을 유지할 수 있도록 피보상자의 생활재건을 위해 유도하는 각종 조치를 생활재건조치라 한다. 여기에는 이주대책의 수립, 국민주택자금의 지원, 직업훈련 고용 또는 고용알선, 각종 상담 및 보상금에 대한 조세감면조치 등이 포함된다.

(3) 검토

생활보상은 종전의 생활을 유지·회복하는 데 목적이 있으므로, 재산권보상이나 정신적 보상을 제외한 광의의 범위로 파악하는 것이 타당할 것이다. 양자는 본질적 사항에 대해서 견해를 달리하는 것이 아니라, 일부 보상 항목을 재산권보상으로 보느냐 생활보상으로 보느냐의 차이를 나타낼 뿐이다.

5) 대상에 대한 검토

몇 가지 논쟁점은 간접보상과 소수잔존자보상, 생활재건조치, 부대적 손실보상이 생활보상이 될 수 있는가이다.

(1) 사업손실보상(간접보상)과 소수잔존자보상의 대상여부

광의설은 소수잔존자보상, 이직자보상, 생활재건조치를 생활보상으로 보나, 협의설은 재산권보상으로 본다. 그러나 사업손실보상은 침해의 대상이나 정도가 직접적 침해와 같으므로 재산권보상으로 보고 정당보상의 내용을 이루는 것으로 보고, 소수잔존자보상은 유형·무형의 재산적 이익 침해에 대한 재산권보상으로 보아 생활보상에 포함하지 않는 것이 일반적이다.

(2) 부대적 손실보상

부대적 손실보상이란 공익사업을 위한 수용 목적물의 취득이 원인이 되어 부수적으로 발생하는 손실의 보상으로서, 광의로는 잔여지 및 잔여건축물 보상, 이전비보상, 광업권·어업권 및 물 등 사용에 관한 권리 보상, 영업손실의 보상, 농업손실의 보상, 휴직 또는 실직자 보상 등이 있고, 협의로는 이전료보상, 잔여지보상, 영업보상 등이 있다. 부대적 손실은 재산권의 직접적 침해로 인하여 발생하므로, 재산권보상에 포함될 성질의 것으로 봄이 타당하다. 주거이전비는 부대적 손실보상이기는 하나, 주거대책 일환으로 지급하는 것이므로 생활보상의 대상으로 파악할 수 있을 것이다.

(3) 생활재건조치

생활재건조치는 이주대책의 수립·시행을 비롯하여 국민주택기금의 우선지원, 고용 또는 알선, 직업훈련, 각종의 상담, 보상금에 대한 조세의 감면조치 등을 말한다. 광의설은 생활재건조치를 생활보상의 전형적 대상으로 보고 있다.

그러나 생활재건조치가 생활보상의 대상인가에 대하여, 그 자체로서는 생활보상과 직접적 연관성은 없으나 손실보상의 흠결상태를 어느 정도 보완해 주는 측면이 있으므로 긍정해야 한다는 견해와, 생활재건조치는 보상금이 아니고, 생활재건을 위하여 보상금이 가장 유효하게 사용되도록 유도하는 각종 조치로서 재산권보상도 생활보상도 아닌 제3의 영역이므로 부정하는 견해가 있다. 생각건대 토지보상법을 비롯하여 각 개별법률이 재산보상 외에 이주대책 등을 제도화하고 있는 점을 고려하면 생활재건조치는 생활보상의 정책수단으로 이해함이 바람직할 것이다.

6) 내용

실정법에서 규정하고 있는 생활보상은 해당 사업지구 안의 토지소유자 등에 대한 것으로서 주거안정을 위한 것과 생활안정을 위한 것으로 구분할 수 있다.

(1) 주거안정을 위한 생활보상으로는 이주대책(이주단지조성, 이주정착금, 이주정착지원금), 주거대책비 보상(주거이전비, 이사비, 주거용 건축물의 최저보상)을 들 수 있다.

(2) 생활안정을 위한 생활보상으로는 생활비보상(이농비, 이어비), 생활대책을 위한 용지의 공급, 국민주택기금의 지원, 고용 또는 고용알선, 이직자보상, 보상금에 대한 조세감면을 들 수 있다.

7) 결론

복리국가주의의 실현을 위하여 시행하는 공익사업의 결과로 생활권이 오히려 위협받게 되는 경우가 생기는 것은 헌법가치에 위배됨은 물론 보상제도의 존재 의의에도 부합되지 않는 것이라 할 수 있다. 손실보상은 대물적 보상을 당연한 전제로 하되, 공익사업의 시행이 없었던 것과 같은 생활상태의 확보를 가능하게 하는 생활보상이 이루어져야 한다. 이는 헌법상 복리국가주의의 당연한 요구라 보아야 할 것이다.

제1절 손실보상의 원칙 [★★]

01 개설

헌법 제23조 제3항의 정당보상원칙에 의거하여 공용수용의 일반법인 토지보상법은 손실보상에 관하여 기본원칙을 정하고, 손실보상의 내용에 관하여 구체적인 규정을 두고 있다.

02 토지보상법상 손실보상 원칙

1) 사업시행자 보상 원칙

공익사업에 필요한 토지 등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다(제61조). 사업시행자수용권설에 의하면 보상해야 할 손실의 원인을 제공한 자가 사업시행자이기 때문에 손실의 보상도 사업시행자가 해야 하는 것으로 보고 있다.

2) 사전보상의 원칙

(1) 의의 및 취지

사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액의 전액을 지급하여야 한다(제62조 본문). 사전보상원칙은 피수용자가 권리를 상실하기 전에 보상받을 수 있도록 하여 보상 받지 않은 상태에서 권리를 상실하는 일이 없도록 하고, 피수용자의 대체지 취득 등을 고려하여 피수용자를 보호하기 위한 입법정책상 배려라 할 수 있다.

(2) 사전보상원칙 보장제도

토지보상법은 사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급 또는 공탁하지 않으면 재결의 효력이 실효되도록 규정함으로써 사전보상원칙을 보장하고 있다.

(3) 사전보상원칙의 예외

a. 62조 단서에 의한 경우

공익적 요청이 큰 천재지변시 토지사용에 대한 보상(제38조)과 시급한 토지사용의 경우의 보상(제41조)은 사전보상의 예외가 인정된다. 또한 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 사후 보상이 가능하다.

b. 사전보상이 불가능한 경우

사업시행자가 손실을 의도하지 않았으나 결과적으로 손실이 발생한 경우 사전보상의 예외로서 토지보상법은 보상규정을 두고 있다. ① 타인토지출입의 측량 및 조사로 인한 손실(제9조 제4항), 장애물 제거로 인한 손실(제12조 제4항), 사업인정 실효로 인한 손실(제23조 제2항), 사업의 폐지 및 변경으로 인한 손실(제24조 제7항), 재결의 실효로 인한 손실(제42조 제2항) 등의 경우에 사전보상의 예외가 인정된다.

3) 현금보상의 원칙

(1) 의의 및 취지

손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다(제63조 제1항). 재산권의 침해에 따른 보상이 현금으로 이루어지는 것이 가장 간편하고, 종전 생활을 회복하는데 용이하며, 자유로운 유통이 보장되고, 대체치를 신속하게 취득할 수 있는 수단이며, 현금의 물건 가치를 측정할 수 있는 기능을 지니므로, 재산권 침해로 인해 상실된 재산가치를 복원하는 데 가장 유효한 수단이 될 수 있다. 그러나 모든 경우에 현금보상이 피수용자에게 유리하고, 사업시행자에게 합리적이라고는 말할 수 없다. 따라서 보상수단은 현금보상원칙 아래에서 예외적으로 채권보상을 비롯하여 대토보상 등이 채용되고 있다.

(2) 현금보상의 문제점

현금보상은 피수용자를 보호하기 위해 도입된 제도이므로, 현금보상보다 현물보상이 오히려 사업시행자와 피수용자 모두에게 유리한 경우에는 현물보상을 인정하는 것이 현금보상원칙의 제도 취지에 부합한다. 대규모 공익사업이 시행되면 개발지역과 인근지역은 지가상승요인이 생긴다. 따라서 인근지역에 일시에 대토수요, 투기적 수요의 증대로 지가상승이 탄력을 받게 되는 문제가 있다. 또한 인근지역의 지가가 급등하면 보상금으로는 편입면적과 동일한 대체지 구입이 사실상 어렵게 된다.

(3) 현금보상원칙의 예외

① <채권보상>

채권보상이란 일정한 요건에 해당하는 피수용자에 대하여 채권으로 보상하도록 하는 방법이다. 이 방법은 피수용자의 권리구제를 고려할 때 그 요건을 엄격하게 규정할 필요가 있다.

② <대토보상>

토지보상법상 현물보상의 방법에는 대체지보상, 공사대행에 의한 보상, 이전대행에 의한 보상이 있다. 이 외에도 조선택지의 공급에 의한 보상등도 현물보상에 해당한다. 이는 당사자 쌍방의 편의, 특히 생활의 재건을 완전하게 함으로써 얻어지는 피수용자의 이익 및 사회경제상의 편리를 고려한 것이다.

4) 개인별 보상의 원칙

손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하여야 한다. 다만 개인별로 보상액을 산정할 수 없을 때에는 그러하지 아니하다(제64조). 현행법이 개인별보상 원칙을 채용하는 이유는

- ① 현실적으로 소유권과 그 위에 설정된 그 밖의 권리는 제각기 독립의 경제적 기능 및 재산가치를 지니므로 이들 권리 가격 합계는 권리가 존재하지 않는 단독의 소유권 가격을 넘을 수 있으므로 대위주의의 방법으로는 피수용자가 완전한 보상을 받을 수가 없다는 점,
- ② 토지소유자에게 일괄하여 지불한 보상금이 원활하고 신속하게 각 권리자에게 주어질 수 있다는 보증이 반드시 존재하고 있다고 말하기 어려운 사회 실태의 점에서이다.

5) 일괄보상의 원칙

사업시행자는 동일한 사업지역에 보상시기를 달리하는 동일인 소유의 토지 등이 여러 개 있는 경우 토지소유자나 관계인이 요구할 때에는 한꺼번에 보상금을 지급하도록 하여야 한다(제65조). 하나의 사업지역에서 보상의 시기를 달리하여 보상금이 시차를 두고 지급되었을 때 대토가 어렵게 되어 사실상 정당보상에 이르지 못하는 경우도 예상할 수 있어 이러한 문제를 해소하기 위해 토지보상법은 일괄보상원칙을 채용하고 있다.

6) 사업시행 이익과의 상계금지원칙

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부를 취득하거나 사용하는 경우 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 그 이익을 그 취득 또는 사용으로 인한 손실과 상계할 수 없다(제66조). 이 원칙은 공익사업의 시행으로 인하여 잔여토지의 가격이 상승하였을 때 개발 이익을 차감하고 보상할 수 없도록 하여 피수용자를 보호하기 위한 제도적 장치이다. 수용대상이 되지 않는 토지와 보상금은 직접 관계가 없으므로, 사업시행 이익과는 상계될 수 없다. 잔여지의 개발이익은 비록 공익사업으로 발생한 것이라 하더라도 국가가 개발이익으로 환수할 수는 있어도 사업시행자가 취득한 목적물에 대한 보상과는 상계할 것이 아니다(대판 1998. 9. 18 97누13375).

7) 시가보상의 원칙

보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다(제67조 제1항). 현행법은 시가(時價)보상원칙을 채용하고 있으며, 이는 헌법에서 수용에 대하여 정당보상을 하도록 규정하고 있는 것과 합치하는 것이라고 보는 것이 일반적이다.

01 개설

토지보상법은 정당보상 실현을 위해 현금보상원칙을 채용하고 있으나, 현금보상원칙은 인근지역에 일시에 대토수요, 투기적 수요의 증대로 지가상승이 탄력을 받게 되는 문제가 있다. 이러한 현금보상원칙의 문제점을 해결하고, 사업시행자의 자금 확보를 지원하고자 채권보상이 도입되었으나, 그 위헌성 여부에 대하여 논란이 있다.

02 의의 및 취지

채권보상이란 **보상금 지급시 일정한 경우 채권으로 지급하는 것이다**. 채권보상은 사업시행자의 자금 확보를 지원하고, 공익사업에 필요한 용지보상비가 사업비에서 차지하는 비율이 점차 증가됨에 따라 사회간접자본시설의 설치에 어려움을 겪고 있는 현실을 반영한 제도이다.

03 요건

1) 임의적 채권보상 (토지보상법 제63조 제7항)

사업시행자가 국가, 지방자치단체, 대통령령으로 정하는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 공공기관 및 공공단체인 경우로서 ①토지소유자나 관계인이 원하는 경우 또는 ②사업인정을 받은 사업의 경우 부채부동산 소유자의 토지에 대한 보상금이 1억 원을 초과하는 경우로서 그 초과금액에 대하여 사업시행자가 발행하는 채권으로 지급할 수 있다.

2) 의무적 채권보상 (토지보상법 제63조 제8항)

토지투기가 우려되는 지역(대통령령으로 별도 정함)에서 공공기관 및 공공단체((대통령령으로 별도 정함)가 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발사업 등 대규모 개발사업(대통령령으로 별도 정함)을 시행하는 경우, 부채부동산 소유자의 토지에 대한 보상금 중 1억 원 이상의 일정금액 초과 부분에 대하여는 해당 사업시행자가 발행하는 채권으로 지급하여야 한다.

04 내용

1) 상환기한과 이율 (토지보상법 제63조 제9항)

채권의 상환기한은 5년을 넘지 않는 범위 안에서 정하여야 한다. 이율은

- ① 상환기한이 3년 이하인 채권은 부채부동산소유자에게 지급시는 3년 만기 정기예금이자율을, 부채부동산소유자가 아닌 자가 원하여 지급하는 경우는 3년 만기 국고채 금리와 3년 만기 정기예금 이자율 중 큰 이율을 적용한다.
- ② 상환기한이 3년 초과 5년 이하인 채권은 5년 만기 국고채 금리를 적용한다.

2) 보상채권의 발행 (토지보상법 제69조)

채권은 회계를 관리하는 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 기획재정부장관이 발행한다. 기획재정부장관은 채권을 발행하려는 경우 회계별로 국회의 의결을 받아야 한다. 보상채권은 토지소유자 및 관계인에게 지급함으로써 발행한다. 채권은 무기명증권으로 발행하고, 최소액면금액은 10만원으로 한다.

05 효과

채권보상제도 역시 현금보상과 마찬가지로 보상금 지급의 효과를 가지고, 사업시행자는 수용 또는 사용의 개시일에 토지나 물건의 소유권 또는 사용권을 취득한다.

06 채권보상제도의 위헌성 여부

1) 문제점

헌법상 정당보상에 대하여 판례는 보상금액 및 보상의 시기·방법에도 어떠한 제한을 두어서는 안 된다고 판시한다. 채권보상제도가 보상방법의 선택권을 제한하여 정당보상원칙에 위배되는지와 부채지주 토지에 대하여 다른 재산권과 구별하여 채권보상을 하게 함으로써 평등원칙에 위배되는가에 대하여 위헌성 논란이 있다.

2) 견해 대립

① 〈위헌설〉

채권보상은 사실상 사후보상으로서, 보상방법의 제한이며, 부채부동산 소유자에 대한 불평등은 헌법상 주거 이전의 자유를 부정하는 것으로서, 환가면에서 물가나 기타 사정에 의한 수익률 영향을 받게 되므로 정당보상으로 보기 어려워 위헌이라는 견해,

② 〈합헌설〉

통상적 수익만 보장되면 사후보상이라도 정당보상으로 볼 수 있고, 부채부동산 소유자는 거주자와는 달리 취급할 합리적인 사유가 존재하고, 공익성과 정기에금 이자를 통한 정상적 수익률보장에 비추어 완전보상이 될 수 있으므로 합헌이라는 견해가 있다.

3) 검토

생각건대, 채권보상은 대체 토지 수요증가로 인한 인근지역 지가상승 억제 취지가 존재하고, 대상, 상환기간 등 요건을 강화하고 있는 점을 고려할 때, 위헌이라 보기는 어렵다고 할 것이다. 또한 채권보상도 침해 전후의 과부족이 없는 상태가 실현될 수 있다면 완전보상이 이루어지는 것으로 볼 수 있다.

07 현행 채권보상의 문제점

채권보상제도의 채권의 이율이 시장 실세금리를 적용하도록 하고 있으므로 완전보상에 이르지 않는다고 말하기는 어렵다. 그러나 상환기간을 5년을 넘지 아니하는 범위로 제한하고, 이자율은 3년 만기 정기에금 이자율로 하도록 규정하여 현실적으로는 사업시행자의 재정적 부담을 완화하지 못할 뿐 아니라, 채권이 즉시 현금으로 교환되고 있어 보상금이 일시에 대체지 수요로 전환되는 것을 막는다는 제도 목적을 달성하기 어렵다는 문제점이 있다.

01 개설

채권보상의 중요한 기능 및 취지로서, 보상금의 일시적 투기자금화를 방지하려는 목적은 현실적으로 보상채권이 즉시 현금으로 교환되고 있어, 대체지 전환으로의 수요를 막지 못하고, 오히려 정당보상을 훼손할 개연성만 높이는 문제가 있다. 이에 이러한 문제점을 해결하기 위하여 대토보상제도가 도입되었다.

02 의의, 근거 및 취지

대토보상이란 공익사업으로 조성된 토지로 보상받을 수 있는 제도를 말한다. 63조 1항 단서 등에 근거를 둔다. 손실보상 자금을 효율적으로 관리하고 현지 주민의 재정착과 해당 지역 주민이 개발혜택을 공유할 수 있도록 하는 데 취지가 있다. 보상은 금전보상을 원칙으로 하고 있으나, 사업지에 따라서는 피수용자가 대체지를 요구하는 경우도 적지 않다. 보상이 가치보상에만 의존하는 경우 종전의 생활기능을 회복하는 것이 불가능할 경우도 있다. 이와 같은 경우에도 대체지의 제공 등 현물보상에 의해 상실된 종전의 생활기능을 보전할 필요가 있다. 그러나 대체지 보상은 많은 제약이 따르게 되고, 설령 대체지로 보상한다 하더라도 보상 후 과부족에 대한 청산이 수반되어야 하기 때문에 그 운용에는 어려움이 많으며, 제도화에 한계가 있다.

03 내용

1) 받을 수 있는 경우

토지소유자가 원하는 경우로서 사업시행자가 해당 공익사업의 토지이용계획 및 사업계획 등을 고려하여 공익사업의 시행으로 조성된 토지로 보상이 가능한 경우, 토지소유자가 받을 보상금 중 현금 및 채권보상액을 제외한 부분에 대하여 그 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상할 수 있다.

2) 받을 수 있는 자

공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날의 1년 전부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 토지를 소유한 자로서, 건축법에 따른 대지분할제한 면적 이상의 토지를 사업시행자에게 양도한 자가 된다.

다만, 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날 당시 국토교통부, 사업시행자 등의 기관에 종사하는 자 및 종사하였던 날부터 10년이 경과하지 아니한 자는 제외된다.

대상자가 경합할 때에는 부재부동산 소유자가 아닌 자 중 해당 공익사업지구 내 거주하는 자로서 토지 보유기간이 오래된 자 순으로 토지로 보상하며, 그 밖의 우선순위 및 대상자 결정방법 등은 사업시행자가 정하여 공고한다.

3) 보상면적과 기준금액

토지로 보상하는 면적은 사업시행자가 그 공익사업의 토지이용계획과 사업계획을 고려하여 정하고, 이 경우 주택용지는 990㎡, 상업용지는 1,100㎡를 초과할 수 없다. 보상하는 토지가격 산정 기준금액은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 일반 분양가격으로 한다.

4) 대토보상 결정 권리의 전매제한과 형사처벌 (제63조 제3항)

토지로 보상받기로 한 권리는 그 보상계약 체결일부터 소유권이전등기를 완료할 때까지 전매할 수 없다(다만, 상속과 부동산투자회사법에 근거한 부동산투자회사에 현물출자를 하는 것은 제외). 이를 위반(농지법 등 일부 규정 위반도 포함)할 때에는 사업시행자는 현금으로 보상하여야 하고, 위반자는 형사처벌(93조의 2, 3년 이하 징역 또는 3,000만 원이하 벌금에 처함)을 받게 된다. 현금보상액에 대한 이자율은 3년 만기 정기예금이자율의 1/2로 한다.

5) 현금보상으로 전환

(1) 토지소유자의 현금보상으로 전환 요청

- ① 보상계약체결일부터 1년이 지나면 이를 현금으로 전환하여 보상해 줄 것을 요청할 수 있고(법63조 4항),
- ② 사업시행자는 토지소유자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 토지로 보상받기로 한 보상금에 대하여 현금보상을 요청한 경우에는 현금으로 보상하여야 한다(법63조 6항).
 - 1호. 국세 및 지방세의 체납처분 또는 강제집행을 받는 경우
 - 2호. 세대원 전원이 해외로 이주하거나 2년 이상 해외에 체류하려는 경우
 - 3호. 그 밖에 제1호 · 제2호와 유사한 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우

(2) 사업시행자가 현금보상으로 전환

사업시행자는 해당 사업계획의 변경 등 국토교통부령으로 정하는 사유로 보상받기로 한 토지의 전부 또는 일부를 토지로 보상할 수 없는 경우에는 현금으로 보상할 수 있다(법63조 5항).

제1절

보상평가의 의뢰 및 평가

01 보상평가의 의뢰

1) 감정평가법인등의 선정 및 의뢰

사업시행자는 토지 등에 대한 보상액을 산정하려는 경우에는 감정평가법인등 3인(시·도지사와 토지소유자가 모두 감정평가법인등을 추천하지 아니하거나 시·도지사 또는 토지소유자 어느 한 쪽이 감정평가법인등을 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. 다만, 사업시행자가 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 직접 보상액을 산정할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다(제68조 제1항). 상기 규정에 따라 사업시행자가 감정평가법인등을 선정할 때 해당 토지를 관할하는 시·도지사와 토지소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 감정평가법인등을 각 1인씩 추천할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 추천된 감정평가법인등을 포함하여 선정하여야 한다(제68조 제2항). 토지소유자가 보상평가를 할 감정평가법인등을 선정하도록 한 것은 토지소유자들의 불만을 해소하고, 보상액산정의 객관성과 타당성을 담보하여 보상금의 적정평가를 도모하기 위해서이다.

2) 평가의뢰의 절차와 방법 등

사업시행자는 대상물건에 대한 평가를 의뢰(제68조 제1항)하고자 하는 때에는 보상평가의뢰서에 대상물건의 표시, 대상물건의 가격시점, 평가서 제출기한, 대상물건의 취득 또는 사용의 구분, 건축물 등 물건에 대하여는 그 이전 또는 취득의 구분, 영업손실을 보상하는 경우에는 그 폐지 또는 휴업의 구분, 보상액평가를 위한 사전 의견수렴에 관한 사항, 그 밖의 평가조건 및 참고사항을 기재하여 감정평가법인등에게 평가를 의뢰하여야 한다(칙 제16조 제1항).

감정평가법인등은 평가를 의뢰받은 때에는 대상물건 및 그 주변의 상황을 현지조사하고 평가를 하여야 한다. 이 경우 고도의 기술을 필요로 하는 등의 사유로 인하여 자기가 직접 평가할 수 없는 대상물건에 대하여는 사업시행자의 승낙을 얻어 전문기관의 자문 또는 용역을 거쳐 평가할 수 있다(칙 제16조 제3항).

감정평가법인등은 평가를 한 후 보상평가서를 작성하여 심사자 1인 이상의 심사를 받고 보상평가서에 당해 심사자의 서명날인을 받은 후 제출기한 내에 사업시행자에게 이를 제출하여야 한다(칙 제16조 제4항).

심사자는 보상평가서의 위산·오기 여부, 대상물건이 관계법령이 정하는 바에 의하여 적정하게 평가되었는지의 여부, 대상물건에 대한 평가액의 타당성을 성실하게 심사하여야 한다(칙 제16조 제5항).

보상액의 산정은 각 감정평가법인등이 평가한 평가액의 산술평균치를 기준으로 한다(칙 제16조 제6항).

02 재평가의 요구와 의뢰

사업시행자는 제출된 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 관계법령에 위반하여 평가되었거나 부당하게 평가되었다고 인정되는 경우에는 당해 감정평가법인등에게 그 사유를 명시하여 다시 평가할 것을 요구하여야 한다(칙 제17조 제1항). 사업시행자는 상기 사유로서 당해 감정평가법인등에게 평가를 요구할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우, 대상물건의 평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 110퍼센트를 초과하는 경우(대상물건이 지장물인 경우 최고평가액과 최저평가액의 비교는 소유자별로 지장물 전체 평가액의 합계액을 기준으로 한다) 및 평가를 한 후 1년이 경과할 때까지 보상계약이 체결되지 아니한 경우에 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 대상물건의 평가를 다시 의뢰하여야 한다(칙 제17조 제2항).

제2절

토지의 일반적 보상평가 기준

01 보상의 기준시점

보상액의 산정은 협의성립 당시의 가격과 재결 당시의 가격을 기준으로 하고 있다(제67조 제1항). 이 규정에 의한 보상액 산정의 기준이 되는 시점을 가격시점이라 한다(제2조 제6호). 보상협의를 성립되면 계약을 체결하기 때문에 협의성립 당시의 가격을 기준으로 보상액을 산정하도록 하는 것은 정당보상과 함께 개발이익을 배제하기 위한 것이다. 또한 협의를 성립되지 않아 재결을 신청한 경우 재결 당시의 가격을 기준으로 보상액을 산정하도록 하는 것도 정당보상을 하기 위한 것이다. 그러나 보상액의 산정시 공시지가를 기준으로 시점수정하는 방법에 의거하도록 함으로써 개발이익을 배제하는 보상기준을 채용하고 있다.

02 일반원칙

1) 현실적인 이용상황 및 일반적 이용방법에 의한 산정

(1) 의미 및 근거

토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적 이용방법에 의한 객관적 상황을 고려하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 아니한다(제70조 제2항).

(2) 현실적인 이용상황

a. 원칙

토지에 대한 보상액은 현황평가주의가 채용되고 있다. “현실적인 이용상황”이란 지적공부상의 지목에 불구하고 가격시점에 있어서의 당해 토지의 주위환경이나 공법상 규제 정도 등으로 보아 인정 가능한 범위의 이용상황을 말한다. 대법원은 현황을 기준으로 보상액을 산정하는 것이 보상에 관한 일반적인 법리에 부합한다고 한다(대판 2001. 9. 25. 2001다30445). 토지가격의 평가를 함에 있어서 공부상 지목과 실제 현황이 다른 경우에는 공부상 지목보다는 실제 현황을 기준으로 하여 평가하여야 함이 원칙이라 한다(대판 1994. 4. 12. 93누6904). 또한 현실 이용상황은 법령의 규정이나 토지소유자의 주관적 의도 등에 의하여 의제될 것은 아니라고 하였다(대판 1998. 9. 18. 97누13375).

b. 예외

취득할 토지에 대한 평가는 지목에 불구하고 현실적인 이용상황에 따라 평가하여야 하나, 일시적인 이용 토지, 가격시점에 형질이 변경된 토지, 허가 없이 금지된 행위를 한 토지 등은 그 예외로서 본래의 지목에 따라 평가한다.

- ① “일시적인 이용상황”이란 관계 법령에 의한 국가 또는 지방자치단체의 계획이나 명령 등에 의하여 당해 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지 또는 제한되어 그 본래의 용도 외의 다른 용도로 이용되고 있거나 당해 토지의 주위환경의 사정으로 보아 현재의 이용방법이 임시적인 것을 말한다(령 제38조).

대법원은 채석지의 경우 산림복구가 법령상 예정되어 있어 이용상황은 일시적인 것에 불과하므로 공부상 지목에 따라 임야로 평가하는 것이 마땅하다고 한다(대판 2000. 2. 8 97누15845).

이와는 달리 불법으로 개간하여 농지로 이용하여 오던 중 공익사업과 관련 없이 개발제한구역이 해제되었고, 그 후 공익사업시행지구로 편입된 당해 토지가 농지법상 농지로 이용되고 있는 경우라면, 현실 이용상황(농지)대로 보상함이 타당하다고 한다.

- ② 미지급용지와 같이 가격시점에 대상 물건의 형질이 변경된 토지는 종전의 이용 지목을 기준으로 평가한다. 미지급용지로서 가격시점에 있어서의 현황 지목이 도로이더라도 도로로 평가하지 아니하고 공사 시공 이전의 이용 지목을 기준으로 평가하여야 한다.

- ③ 관계 법령에 의하여 행위 제한이 가해진 토지를 허가 없이 금지행위를 하였을 때에는 행위 이전의 지목에 의해 평가한다(대판 1999. 7. 27 99두4327). 피보상자가 사업계획의 공고·고시 이후에 법률에 의하여 금지된 행위를 하거나 허가를 요하는 행위를 허가 없이 행한 경우에는 가격시점 당시의 현황에 의하지 아니하고 공고 또는 고시 당시의 지목에 의하여 평가한다.

c. 현황평가 예외의 정당성

현황평가가 정당보상의 기준으로서 원칙인데, 보상방법에 제한을 둬으로써 정당보상에 위반될 수 있느냐 문제된다. 이에 대하여 현황평가 예외 사유들은 위법행위의 합리화 조장 방지, 토지소유자 보호 등의 취지가 반영된 것으로서 정당보상에 해당한다고 봄이 타당하다.

(3) 일반적인 이용 방법

일반적인 이용 방법이란 토지가 놓여 있는 지역(공간적 상황)에서 당시(시간적 상황)의 당해 토지를 이용하는 사람들의 평균인이 이용할 것으로 기대되는 이용 방법으로 정의되고 있다. 이는 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치나 특별한 용도로 사용예정인 것을 보상액의 산정에서 고려하여서는 안 된다는 것을 의미한다.

2) 표준지공시지가 기준 평가

취득하는 토지를 평가함에 있어서는 평가대상 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 한다(칙 제22조 제1항). 부동산가격공시법은 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상을 위하여 토지가격을 산정하는 경우에 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지공시지가를 기준으로 평가하도록 하고 있다(부동산가격공시법 제8조). 공시지가에 의한 보상액의 산정이 헌법에 위배되는지 논란이 있으나, 보상액은 적정가격인 공시지가를 기준으로, 감정평가법인등이 평가하여 산정하기 때문에 공시지가에 의한 보상액 산정은 헌법상 정당보상에 합치하는 것으로 보아야 할 것이다. 헌법재판소는 수용된 토지에 대한 보상액의 산정을 공시지가를 기준으로 하도록 한 것이 헌법에 위반되지 아니한다는 입장을 취하고 있다.

3) 나지상정평가와 구분평가

(1) 나지상정평가

토지에 건축물 등이 있는 때에는 그 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 토지를 평가한다(칙 제22조 제2항). 토지 위에 아무런 정착물이 없는 상태로써 당해 토지의 최유효이용이 가능한 상태의 토지를 나지라 한다. 나지상정평가원칙은 취득할 토지 위에 정착물이 있는 경우 건부감가를 고려하지 아니하도록 하기 위한 조치이다. 공익사업에서는 당해 토지가 필요하지 그 토지 위의 정착물이 필요한 것은 아니며, 보상평가에서 건부감가를 토지소유자의 부담으로만 돌리는 것은 공평하지 못할 뿐 아니라 정당보상에 이르지 못하게 되는 모순이 있기 때문이다.

(2) 구분평가

취득할 토지에 건축물·입목·공작물 그 밖에 토지에 정착한 물건이 있는 경우에는 토지와 그 건축물 등을 각각 평가하여야 한다. 다만, 건축물 등이 토지와 함께 거래되는 사례나 관행이 있는 경우에는 그 건축물등과 토지를 일괄하여 평가하여야 하며, 이 경우 보상평가서에 그 내용을 기재하여야 한다(칙 제20조 제1항). 토지와 건축물 등을 구분하여 평가하도록 하는 것은 보상액 산정을 위한 평가의 원칙이 상이하기 때문이다. 즉 토지는 나지를 상정하여 평가하고, 건축물과 공작물은 건부감가 혹은 건부증가에 의해 평가하기 때문이다. 입목은 그 종류와 수령에 따라 따로 평가하여야 할 성질의 것이기 때문이다. 건축물 등의 면적 또는 규모의 산정은 건축법 등 관계 법령이 정하는 바에 의한다(칙 제20조 제2항).

01 개설

협이나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 부동산공시법에 따른 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하도록 하고 있다(제70조 제1항).

02 공시지가에 대한 판례

보상액 산정의 기준이 되는 공시지가는 표준지공시지가이다(대판 1994. 10. 14. 94누2664).

헌법재판소는 토지수용으로 인한 손실보상액의 산정을 개별공시지가가 아닌 표준지공시지가를 기준으로 하도록 한 것은 개발이익이 배제된 수용 당시 피수용재산의 객관적 재산가치를 가장 정당하게 보상하기 위한 것으로 청구인의 재산권을 침해한다고 볼 수 없고, 헌법 제23조 제3항에 위반되지 않는다고 한다.

대법원은 보상액 산정의 기준이 되는 표준지공시지와 관련하여 다음과 같이 판시하고 있다.

다른 특별한 사정이 없는 한 용도지역이 같은 토지를 당해 토지에 적용할 표준지로 선정함이 상당하다(대판 2004. 5. 14. 2003다38207). 표준지가 수용대상토지와 상당히 떨어져 있다는 것만으로는 표준지 선정이 위법하다고는 볼 수 없다(대판 2002. 4. 12. 2000두5982). 공시지가를 기준으로 보상액을 산정한 금액이 개별공시지가보다 낮게 되었다 하더라도 이것만으로 정당보상에 위배되는 것은 아니다(대판 2001. 3. 27. 99두7968).

03 공시지가의 선정

1) 사업인정 전 협의취득의 경우

공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제3항). 일반적으로 협의취득의 경우 보상액 산정은 이 기준에 의하고 있다. 그러나 협의취득은 사법상 계약이기 때문에 당사자 간 협의에 의해 매매대금을 따로 정하여 보상액으로 한다고 하여 위법한 것은 아니다(대판 1998. 5. 22. 98다2242,2259). 따라서 당사자 간 합의로 손실보상의 요건을 완화하는 약정도 가능하고, 손실보상의 기준에 의하지 아니하는 매매대금도 정할 수 있다(대판 1999. 3. 23. 98다48866).

2) 사업인정 후 취득의 경우

(1) 기준, 취지

사업인정 후 취득의 경우 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제4항). 이는 사업인정 후에 발생한 개발이익을 보상액 산정에서 배제하기 위한 목적으로 두어진 규정이다.

(2) 관련 헌법재판소 판례

헌법재판소는 이 규정에 대하여 공시지가에 개발이익이 포함되는 것을 방지하기 위한 것으로 개발이익이 배제된 손실보상액을 산정하는 적절한 수단에 해당되므로 헌법 제23조 제3항에 위반된다고 할 수 없다고 한다(헌재 2009. 12. 29. 2009헌바142, 헌재 2009. 9. 24. 2008헌바112, 헌재 2009. 7. 30 2007헌바76).

(3) 관련 대법원 판례

대법원은 공시지가에 대하여 다음과 같이 판시하고 있다.

- ① 공시지가는 표준지의 공시지가이며, 표준지는 지목, 용도, 주위환경, 위치 등 제반 특성을 고려하여 자연적, 사회적 조건이 수용대상토지와 동일하거나 유사한 토지를 선정하여야 한다(대판 1996. 5. 14. 95누14350).
- ② 비교표준지는 도시지역의 경우 용도지역을 우선으로 하며, 도시지역 외의 경우 실제 지목을 우선하고 용도, 주위환경, 위치 등 제반 특성을 고려하여야 한다(대판 2001. 3. 27. 99두7968).
- ③ 당해 토지와 같은 용도지역의 표준지가 있으면 다른 특별한 사정이 없는 한 용도지역이 같은 토지를 당해 토지에 적용할 표준지로 선정하면 되고, 표준지와 당해 토지의 이용상황이나 주변 환경 등에 다소 상이한 점이 있더라도 지역요인이나 개별요인의 분석 등 품등비교에서 고려하면 된다(대판 2009. 3. 26. 2008두22129). 또한 표준지가 수용대상토지로부터 상당히 떨어져 있다는 것만으로는 표준지 선정이 위법하다고 할 수 없다(대판 1999. 1. 15. 98두8896).
- ④ 보상액이 낮게 평가된 것은 인근 유사토지에 대한 거래사례 또는 보상사례 등의 정상적인 거래가격 수준을 고려하거나 그 공시지가가 현실적인 가격수준과 어느 정도의 괴리율이 있는지에 대하여 충분한 입증이 있어야 한다(대판 1996. 9. 20 96다22594).

3) 당해 사업으로 인한 가격변동시 적용 공시지가

상기 규정에 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득해야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제5항, 시행령 제38조의2). 이 규정에서 “공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여”라 함은 관계 법령에 의하여 당해 토지에 공익사업이 시행된다는 사실을 불특정 다수인이 알 수 있도록 확정 공고 또는 고시된 날을 의미한다.

헌법재판소는 이 조항들이 공익사업을 위한 토지 취득에 있어 정당한 보상을 불가능하게 하여 청구인들의 재산권 등을 침해하지 않는다고 한다. 즉 공시지가의 적용 기준시점을 규정하고 있지만, 이 자체만으로 보상가격이 확정적으로 결정되는 것이 아니라 한다.

04 시점수정에 의한 산정

1) 의의 및 기준

보상액의 산정방법은 공시지가를 기준으로 협의성립시 또는 재결시까지 시점수정하도록 하고 있다.

즉 공시기준일부터 가격시점까지의 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 지가변동률, 생산자물가상승률 등을 고려하여 평가하도록 하고 있다(제70조 제1항).

2) 지가변동률의 적용

지가변동률이라 함은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제 125조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 지가변동률로서 평가대상 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 해당 평가대상 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지(이하 "비교표준지"라 한다)가 소재하는 시(행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 용도지역별 지가변동률을 말한다.

다만, 비교표준지와 같은 용도지역의 지가변동률이 조사·발표되지 아니한 경우에는 비교표준지와 유사한 용도지역의 지가변동률, 비교표준지와 이용상황이 같은 토지의 지가변동률 또는 해당 시·군 또는 구의 평균지가변동률 중 어느 하나의 지가변동률을 말한다(령 제37조 제1항). 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다. 다만, 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가변동률이 인근 시·군 또는 구의 지가변동률보다 작은 경우에는 그러하지 아니하다(령 제37조 제2항, 동조 제3항 참조). 이는 개발이익의 배제를 의도한 입법이다.

3) 생산자물가상승률의 적용

생산자물가상승률이란 한국은행법에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다. 보상액을 산정할 때 생산자물가상승률의 적용은 절대적인 것이 아니라 단지 고려할 사항이다. 대법원은 생산자물가상승률을 고려하는 취지는 지가변동률이 지가추세를 적절히 반영하지 못한 특별한 사정이 있는 경우 이를 보완하기 위한 것이며(대판 1999. 8. 24. 99두4754), 생산자물가상승률이 지가변동률보다 낮거나 미미한 때에는 이를 고려하지 않아도 된다고 한다(대법 1991.2.8 선고90누6767 판결). 토지 보상평가에서 생산자물가상승률을 시점수정자료로 활용하지 않는 경우에도 이를 지가변동률과 비교하여 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

05 지역요인의 비교 및 개별요인의 비교

1) 지역요인 비교

토지보상법은 지역요인의 고려에 대하여는 규정하고 있지 않다. 그러나 대법원은 **보상액의 산정시 지역요인의 비교를 긍정하고 있다**(대판 1995. 7. 25. 93누4786). 그리고 개별요인 및 지역요인을 대비하여 분석하려면 공시기준일 현재의 표준지 상태와 수용재결될 당시의 수용대상토지의 상태를 비교하여야 한다고 한다(대판 1993. 2. 9. 92누5485).

2) 개별요인 비교

보상액은 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 정하여야 한다고 규정하고 있다. 토지에 대한 보상은 사업시행자로부터 감정평가의뢰를 받은 감정평가법인등이 가격형성에 영향을 미치는 여러 요인을 종합적으로 고려하여 평가한 가격으로 보상해야 한다. 개별요인의 비교와 관련하여 대법원은 보상액을 평가하면서 어떤 개별요인을 어떻게 품등비교하였는지에 대하여 실시하지 아니한 적용은 위법하다고 한다(대판 1996. 5. 28. 95누13173).

3) 감정평가서 기재정도

보상평가에서는 관련 법령에서 들고 있는 모든 가격산정요인들을 구체적·종합적으로 참작하여 그 각 요인들이 빠짐없이 반영된 적정가격을 산출하여야 한다. 따라서 **감정평가서에는 모든 가격산정요인의 세세한 부분까지 일일이 실시하거나 그 요소가 감정평가에 미치는 영향을 수치로 표현할 필요는 없다고 하더라도, 적어도 그 가격산정요인들을 특정·명시하고 그 요인들이 어떻게 참작되었는지를 알아볼 수 있는 정도로 지역요인 및 개별요인의 비교내용을 기술한다**(대판 2000. 7. 28. 98두6081). 개별요인 비교에 관하여 구체적으로 어떤 요인들을 어떻게 품등비교하였는지에 관하여 아무런 이유 설시를 하지 않은 감정평가는 위법하고(대판 1996. 5. 28. 95누13173), 수용대상 토지 자체가 표준지인 경우 지역요인·개별요인 비교는 있을 수 없으며(대판 1995. 5. 12. 95누2678), 개별요인 비교시 용도지역의 차이점을 보정하지 않은 것은 위법하다(대판 1993. 10. 12. 93누197).

06 보상액의 결정

보상액의 산정은 각 감정평가법인등이 평가한 평가액의 산술평균치를 기준으로 한다(칙 제16조 제6항).

재평가 규정에 의하여 평가를 행한 경우 보상액의 산정은 각 감정평가법인등이 다시 평가한 평가액의 산술평균치를 기준으로 한다(칙 제17조 제4항).

제1절

공법상 제한받는 토지 평가 [★★]

01 의의 등

1) 의의

공법상 제한을 받는 토지란 개별 법률에 의해 이용 규제를 받고 있는 토지를 말한다.

공법상 제한에는 일반적 계획제한과 개별적 계획제한이 있다.

일반적 계획제한은 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적 사업시행이 필요하지 않은 제한을 말한다.

개별적 계획제한이란 그 제한이 구체적 사업시행을 필요로 하는 제한이다.

2) 구체적 예

① 〈일반적 계획제한〉

그 예로서, 국토계획법에 따른 용도지역 등 지정 및 변경, 「군사기지 및 군사시설보호법」에 따른 군사시설보호구역의 지정 및 변경, 「수도법」에 따른 상수원보호구역의 지정 및 변경, 「자연공원법」에 따른 자연공원 및 공원보호구역의 지정 및 변경 등이 있고, 그 밖에 이와 유사한 토지이용계획제한 등이 있다.

② 〈개별적 계획제한〉

그 예로서, 국토계획법에 따른 도시·군계획시설 및 도시·군 관리계획의 결정고시, 토지보상법상 사업인정고시, 그 밖에 관련 법령에 따른 공익사업 계획 또는 시행의 공고 또는 고시, 공익사업시행을 목적으로 한 사업구역·지구·단지 등의 지정고시 등이 있다.

02 보상평가기준

1) 원칙

공법상 제한받는 토지는 제한받는 상태대로 평가한다(칙 제23조 제1항 본문).

2) 예외

(1) 해당 공익사업시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우

다만 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다(칙 제23조 제1항 단서). 즉 당해 사업으로 가해진 제한으로 인한 가격 변동은 고려하지 않고 감정평가한다. 그 이유는 토지보상법 제67조 제2항의 해당 공익사업으로 인한 토지가치 변동시 이를 고려하지 않는다는 원칙 때문이며, 이는 정당보상을 실현하기 위한 조치로 볼 수 있다.

(2) 해당 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 경우

해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(칙 제23조 제2항). 이와 같이 감정평가하는 이유는 토지보상법 제67조 제2항의 해당 공익사업으로 인한 토지가치 변동시 이를 고려하지 않는다는 원칙 때문이다.

3) 관련 판례

- ① 당해 공익사업 시행을 직접 목적으로 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(칙 제23조 제2항). 예를 들어 수용대상 토지가 보전용도에서 개발용도로 전환된 것이 당해 공익사업의 시행으로 인해 이루어진 경우 보상액은 개발용도로 해제되기 전의 용도지역에 대한 공법상 제한이 가해지고 있는 상태대로 평가하여야 한다(대판 1999. 3. 23. 98두13850).
- ② 이와 같이 당해 사업을 직접 목적으로 하는 제한을 제외하는 것은 공법상 제한이 가해짐으로써 지가가 하락하고, 당해 사업을 위한 제한까지 하락된 가격수준으로 보상하게 되면 피보상자에게 부당한 피해를 가져다주기 때문이다. 대법원은 이와 같은 규정을 둔 것은 정당보상을 실현하기 위한 조치라 한다(대판 2000. 4. 21. 98두4504).
- ③ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(2012. 1. 2. 국토해양부령 제427호로 개정되기 전의 것) 제23조 제1항, 제2항의 규정 내용, 상호 관계와 입법 취지, 용도지역, 지구, 구역(이하 '용도지역 등'이라 한다)의 지정 또는 변경행위의 법적 성질과 사법심사의 범위, 용도지역 등이 토지의 가격형성에 미치는 영향의 중대성 및 공익사업을 위하여 취득하는 토지에 대한 보상액 산정을 위하여 토지가격을 평가할 때 일반적 계획제한에 해당하는 용도지역 등의 지정 또는 변경이라도 특정 공익사업의 시행을 위한 것이라면 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아야 하는 점 등을 종합적으로 고려하면, 어느 수용대상 토지에 관하여 특정 시점에서 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 것이 특정 공익사업의 시행을 위한 것일 경우 이는 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아 용도지역 등의 지정 또는 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다.
여기에서 특정 공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않았다고 볼 수 있으려면, 토지가 특정 공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈남용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만 한다(대판 2015. 8. 27. 2012두7950).

03 일반적 계획제한과 개별적 계획제한

1) 일반적 계획제한

일반적 계획제한은 제한받는 상태를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 해당 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우는 제한이 없는 상태를 상정하여 감정평가한다.

2) 개별적 계획제한

개별적 계획제한은 제한을 받지 않는 상태를 기준으로 하여 감정평가한다. 여기에서 “당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우”는 확장 해석하는 경향을 보이고 있다. 예를 들어 당초 목적사업은 물론 다른 목적의 공익사업에 편입 수용되는 경우에도 그 제한을 받지 않는 상태대로 평가하여야 한다고 한다(대판 1989. 7. 11. 88누11797). 이와 같이 확장해석하는 것은 사업변경 내지 고의적 사전제한 등으로 인한 토지소유자의 불이익을 방지하기 위한 것으로 보고 있다. 이 규정에서 적용되는 ‘공법상 제한’의 범위는 그 제한이 구체적인 사업의 시행을 위하여 필요로 하는 것에 한정된다.

01 무허가건축물 등의 부지

1) 의의

건축이란 건축물을 신축·증축·개축·재축하거나 건축물을 이전하는 것을 말하며(건축법 제2조 제1항 제8호), 이들 행위를 하고자 하는 자는 허가권자로부터 허가를 받거나 신고하고 하여야 한다. 건축허가란 본래 자유로운 건축물의 건축을 건축 법규에서 금지하고, 일정한 요건을 갖춘 자에게 그 금지를 해제하여 적법하게 건축행위를 할 수 있게 하는 행정행위이다.

무허가건축물 등이란 허가를 받거나 신고하고 건축해야 함에도 이러한 절차 없이 불법적으로 건축한 건축물을 말하며, 무허가건축물 등의 부지란 이들 불법건축물의 부지를 말한다. 그러나 허가나 신고를 하지 않고 건축할 수 있는 건축물이나 양성화과정을 거쳐 적법한 건축물로 전환된 종전의 불법건축물의 부지는 무허가건축물 등의 부지에 해당하지 않는다.

2) 보상평가기준

(1) 건축당시 이용상황 상정 평가원칙

무허가건축물 등의 부지에 대하여는, 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다(칙 제24조). 이는 무허가건축물 등의 부지를 현실 이용상황에 따라 평가하게 되면 불법이 적법으로 전환되어 공정하지 못한 보상이 행해질 수 있기 때문에 현황평가의 예외로서 인정된다.

(2) 예외

토지보상법은 1989년 1월 24일 이전에 건축된 무허가건축물 등의 부지는 현실적 이용상황을 기준으로 평가한다(2002.12.31 규칙개정 부칙 제5조).

(3) 부지의 범위

대법원은 '무허가건물 등의 부지'란 당해 무허가건물 등의 용도·규모 등 제반 여건과 현실적인 이용상황을 감안하여 무허가 건물 등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 의미하는 것이라고 해석하고 있다(대법원 2002.9.4 선고 2000두8325 판결).

3) 입증책임의 문제

기준시점(1989년 1월 24일) 이전에 건축된 사실을 누가 주장하고 입증해야 하는지 문제된다. 토지소유자에게 있다는 입장은 사업시행자가 작성한 조서의 이용상황에 대하여 다른 의견이나 사실이 있는 경우 그것을 주장하는 사람이 입증하여야 할 책임이 있다고 보며, 사업시행자에게 있다는 입장은 취득할 토지에 대한 평가는 현실적인 이용상황에 따라 평가하여야 하는 것이기 때문에 그와 같이 토지평가의 대원칙에 대한 예외로서 건축할 당시의 이용상황을 상정하여 평가하기 위해서는 그것을 주장하는 사업시행자가 입증하여야 한다고 한다. 생각건대, 토지평가의 대원칙인 현황평가주의의 예외를 인정하려면 그것을 주장하는 자인 사업시행자가 입증하여야 할 것이다.

02 불법형질변경토지

1) 의의

국토의 계획 및 이용에 관한 법률은 토지형질변경 등 개발행위를 하고자 하는 자는 시장·군수의 허가를 받도록 하고 있으며, 개별 법률도 개발행위를 허가제로 하고 있다. ‘토지의 형질변경’이란 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립(경작을 위한 토지의 형질변경을 제외)을 말한다. 농지는 농지법에 따라 농업생산 또는 농지개량 외의 목적에 사용하기 위한 농지전용은 허가를 받거나 신고를 할 수 있도록 하고, 산지는 산지관리법에 따라 산지의 조림 등 및 임산물 생산용도 외로 사용하거나 산지전용을 하는 경우는 허가를 받거나 신고하고 할 수 있도록 제도화되어 있다.

불법형질변경토지라 함은 개발행위 허가를 받지 않고 토지형질을 변경하거나 농지 또는 산지를 전용허가를 받지 않거나 신고하지 않고 형질변경된 토지를 말한다. 불법형질변경토지는 법령에서 규정한 허가나 신고절차를 이행하지 아니하였으므로, 원상회복은 물론 이를 이행하지 아니하였을 때 대집행의 대상이 되는 것은 말할 나위 없다.

2) 보상평가기준

(1) 형질변경당시 이용상황 상정 평가원칙

관계 법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 해야 하는 토지를 허가받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지에 대하여는 토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다(칙 제24조). 이는 조성된 가치는 물론 조성비도 인정하지 않도록 하는 것이다. 그것은 위법행위가 합리화되어 공정성을 상실하여 불합리한 보상이 될 우려가 있기 때문이다.

(2) 예외

1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 불법형질변경토지 또는 무허가개간토지(관계 법령에 의하여 허가·인가 등을 받고 개간을 하여야 하는 토지를 허가·인가 등을 받지 아니하고 개간한 토지를 말함)에 대하여는 무허가건축물 등의 부지 또는 불법형질변경된 토지의 평가규정(칙 제24조) 또는 국유지 또는 공유지를 적법하게 개간하여 점유하고 있는 경우 개간비보상규정(칙 제27조)에 불구하고 이를 현실인 이용상황에 따라 보상하거나 개간비를 보상하여야 한다(2002.12.31 규칙개정 부칙 제6조).

대법원은 시행규칙 부칙 제6조는 공익사업시행지구에 편입된 토지의 소유자들은 당해 토지가 공익사업을 위한 용지 취득의 대상이 된 것으로 인식하고 관련 법령에 정한 보상기준이 적용될 것이라는 신뢰를 지니게 되므로 이를 보호하기 위하여 제정된 조항이라 한다(대판 2008. 5. 15. 2006두16007, 16014).

3) 관련문제

(1) 현황평가 예외가 정당보상원칙 위반인지

불법형질변경토지는 위법하게 토지가치를 상승시켜 놓은 상태이므로, 현황을 기준으로 보상액을 산정하면 정상보상이 되지 않을 수 있다. 결국, 현황평가의 예외가 정당보상에 위반된다고 볼 수 없다.

(2) 소급입법에 의한 재산권박탈금지 원칙에 위배되는지

헌법 제13조 제2항은 모든 국민은 소급입법에 의하여 재산권을 박탈당하지 아니한다고 한다. 헌법재판소는 소급입법에 의한 재산권 박탈이 금지되는 것은 진정소급효입법이고, 부진정소급효입법의 경우에는 원칙적으로 허용된다고 보고 있다. 불법형질변경 토지의 평가방법이 진정소급효로서 소급입법에 의한 재산권 박탈금지 원칙을 어긴 것이 아닌가 문제된다.

불법형질변경토지는 일반적으로 국민이 소급입법을 예상할 수 있어서 보호할 신뢰이익이 작고, 신뢰보호 요청에 우선하는 심히 중대한 공익성의 사유로 보아 소급입법이 예외적으로 허용되는 경우라 할 수 있다.

(3) 입증책임의 문제

불법으로 형질변경되었는지 여부를 사업시행자와 토지소유자 중 누가 입증해야 하는지 문제된다.

이는 입증을 하지 못할 경우 어떻게 평가해야 하는지 달라짐에 논의의 실익이 있다. 토지소유자에게 입증책임이 있다고 하여 지적공부상의 지목과 다르게 이용되고 있는 토지를 소유자가 그 이용상태가 적법한 것으로 입증하지 못하는 경우 불법형질변경된 토지로 보아 형질변경 당시 이용상황을 상정하여 평가하는 것은 상위법에서 정하고 있는 현황평가주의를 위반하는 것으로 볼 수 있다. 이와 같이 불법형질변경토지의 평가방법이 잘못 행사되면 지적공부상 지목과 달리 이용되는 모든 토지가 불법형질변경된 토지로 취급되어 상위법의 현황평가주의를 무용화시킬 우려가 있고, 사업시행자의 토지조서작성권은 반증 없이는 현황평가주의를 따라야 하므로 원칙적으로 사업시행자가 불법으로 형질변경되었다는 것을 입증하여야 한다고 할 것이다(판례 동지). 따라서 사업시행자가 입증하지 못한다면 현황평가하여야 한다고 해석하는 것이 옳다고 할 것이다.

01 의의 및 취지

미지급용지란 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지를 말한다(칙 제25조).

미불용지는 같은 토지에 대하여 둘 이상의 공익사업이 시행되고, 새로운 공익사업이 시행되기까지 종전 시행된 공익사업에 의하여 보상금이 지급되지 아니한 토지를 말한다(대판 2009. 3. 26. 2008두22129).

02 평가규정의 취지

오늘날 무보상에 의해 공익사업이 이루어지는 것은 생각할 수 없는 일이다. 그러나 지난 날 공익사업을 수행하면서 어떠한 이유에서든지 보상이 행해지지 못한 경우도 있었다. 이러한 용지는 용도가 공익사업 부지로 제한되고 있어 거래도 불가능할 뿐만 아니라 가격시점의 이용상황에 따라 공익사업의 부지로 평가하게 되면 적정가격으로 보상액을 산정할 수 없게 되어 피보상자에게 지나친 희생을 강요하게 되는 결과가 된다(대판 1992. 11. 10. 92누4833).

이와 같은 경우 피보상자를 구제하기 위해 특별히 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가하도록 하고 있다. 토지보상법은 미지급용지에 대하여 가격시점 현재의 현실 이용상황에 따라 평가하는 것이 아니라 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 기준하여 평가하여 현황평가의 예외를 규정하고 있다.

이는 이미 이루어진 공익사업용 토지에 대하여 현황평가한다면 상당히 감가됨으로써 결국 그 소유자에게 너무 불이익이 크게 되므로 이를 방지하여 적정하게 보상이 이루어지도록 하는데 그 제도적 의의가 있다.

03 미지급용지의 판단기준

미지급용지에 대한 개별적인 사례에 대해서는 사업시행자가 사실 관계를 조사하여 판단·결정할 사항이다. 예를 들어 도로의 경우 사업시행자가 도로의 개설 경위, 이용상황 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항으로 보고 있다.

04 미지급용지 적용 범위에 대한 논의

1) 문제점

종전의 공익사업으로 인해 지가가 상승하였을 때에도 미지급용지로 보아 평가해야 하는지 적용범위에 논란이 있다.

2) 학설

- ① 무제한적으로 적용되어야 한다는 견해는 미지급용지에 대한 적용을 토지소유자의 이익 여부와는 관계없이 모두 적용되어야 한다고 보는 반면,
- ② 제한적으로 적용되어야 한다는 견해는 토지소유자에게 불리한 경우에는 적용이 제한된다고 보며 이 견해가 다수설이다.

3) 판례

대법원은 종전의 공익사업의 시행으로 인하여 토지의 현실적인 이용상황을 변경시킴으로써 가격이 상승하였다면 미불용지에 포함되지 않는 것으로 보고 있다(대판 1992. 11. 10. 92누4833).

05 미지급용지의 보상평가기준

1) 평가기준

(1) 원칙

종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

(2) 예외

다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편입될 당시의 지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작하여 평가한다(칙 제25조 제1항). ‘종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황’을 상정하는 때에는 편입당시의 지목·실제 용도·지형·지세·면적 등의 개별요인을 고려하여야 한다. 인근지역의 표준적 이용상황이 변경된 경우는 가격시점에서의 인근토지의 표준적 이용상황을 기준으로 판단하되 그 형질변경에 드는 비용을 고려해야 한다.

대법원도 도로에 편입된 이후 대상토지의 위치나 주위 토지의 개발 및 이용상황 등에 비추어 도로가 개설되지 아니하였더라도 당해 토지의 현실적 이용상황이 주위 토지와 같이 변경되었을 것임이 객관적으로 명백하게 된 경우, 변경된 이용상황을 상정하여 토지가격을 감정평가해야 하는 것이 타당하다고 판시하고 있다(대판 2002. 10. 25. 2002다31483).

2) 가격시점

가격시점은 일반보상과 마찬가지로 계약체결 당시를 기준으로 한다.

따라서 편입될 당시의 가격을 소급평가하여 다시 보상금 지급시로 시점수정하는 것은 아니다.

3) 공법상 제한 등

공법상 제한이나 주위환경 그 밖에 공공시설 등과의 접근성 등은 종전의 공익사업(그 미지급용지가 새로운 공익사업에 편입되는 경우에는 그 사업을 포함한다)의 시행을 직접 목적으로 하거나 당해 공익사업의 시행에 따른 절차 등으로 변경 또는 변동이 된 경우 외에는 가격시점 당시를 기준으로 한다. 용도지역 등이 종전 또는 새로운 공익사업과 관계없이 변경된 경우에는 가격시점에서의 용도지역 등을 기준으로 감정평가한다.

4) 개발이익의 배제

미지급용지의 평가시 종전 및 당해 공익사업으로 인한 가격변동이 포함되어 있는 경우 이를 모두 배제하고 평가한다.

1) 보상의무자

미지급용지는 종전에 시행된 공익사업에서 보상되지 않은 토지이기 때문에 마땅히 당시의 사업시행자가 보상하여야 한다. 그렇지만 현실적으로 볼 때 이미 당해 공익사업은 완료된 상태이고, 그 공익사업이 실제로 존재하지 않기 때문에 당시의 사업시행자는 보상할 수 없는 불능 상태에 있다 해도 과언이 아니다. 따라서 원칙적으로는 종전 공익사업시행자가 보상의무자이나, 미지급용지 보상이 새로운 공익사업이 시행됨에 따라 종전에 보상받지 못한 토지소유자 등의 권리구제를 위한 제도 취지를 고려하여 종전 사업시행자의 보상의무가 새로운 공익사업의 시행자에게 전가된 것으로 볼 수 있다.

2) 보상대상자

종전 공익사업 시행시점과 새로운 공익사업의 가격시점 사이에 미지급용지의 소유자가 변경되었을 경우, 새로운 소유자에게도 미지급용지의 평가규정을 적용하여 산정한 보상금을 지급하는 것이 타당한지 논란이 있다. 새로운 소유자는 미지급용지가 공익사업용지라는 것을 알고 매수하였으므로, 편입당시 이용상황으로 보상하면 과다보상이 될 우려가 있어 부정하는 견해가 있고, 새로운 소유자를 제한한다는 규정이 없으니 적용되어야 한다는 견해가 있다. 미지급용지의 소유자는 새로운 공익사업에 편입되지 않는 한 보상청구를 할 수 없게 되므로, 새로운 소유자에게 적용을 부정하게 되면, 미불용지의 거래를 더욱 어렵게 하여 원소유자에게 더 큰 피해를 줄 수 있으므로 적용함이 바람직하다. 국토교통부는 소유권의 변동이 미지급용지 여부를 판단하는 기준이 되지 않는다고 유권해석하고 있다.

3) 미지급용지에 대한 인도청구권 행사

「도로법」 제3조는 “도로를 구성하는 부지, 옹벽, 그 밖의 물건에 대하여는 사권(私權)을 행사할 수 없다. 다만, 소유권을 이전하거나 저당권을 설정하는 것은 그러하지 아니하다”라고 규정하여 도로에 편입된 토지는 사권을 행사할 수 없다. 따라서 미지급된 도로부지에 대하여 인도청구를 하지 못한다.

4) 미지급용지에 대한 부당이득반환청구권 행사

(1) 행사여부

미지급용지 중 부당이득과 관련하여 주로 문제가 생기는 부분은 미지급된 도로부지이다. 도로를 구성하는 부지는 그 사용·수익을 침해당함으로써 입은 손해에 상당한 금액을 부당이득으로 반환청구할 수 있다.

(2) 판례 입장

대법원은 어느 사유지를 국가 또는 지방자치단체가 점유하여 사실상의 도로로서 일반 공중의 교통에 제공함으로써 그 토지소유자의 독점적·배타적인 사용·수익이 제한되고 있는 경우에는 그 소유자가 그 토지에 대한 독점적·배타적인 사용수익권을 포기하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 국가 또는 지방자치단체는 그 토지를 점유하여 사용·수익하는 이득을 얻고 토지소유자는 그만큼의 손해를 입고 있는 것으로 보아야 한다고 한다 (대판 2008. 2. 1. 2007다8914).

(3) 부당이득 평가

즉 공공이 사인의 토지를 토지소유자의 점유·관리를 배제한 채 일반 공중의 통행로로 제공한 경우에는 임료(차임) 상당의 이익을 법률상 원인 없이 이득을 보고 있는 것이므로 부당이득금 반환의무가 있는 것이다. 부당이득금 산정을 위한 기초가격은 사실상의 공익사업에 의하여 도로로 편입된 경우에는 편입될 당시의 현실적 이용상황에 따라 평가하며, 종전부터 공중의 통행에 이용되던 토지가 편입된 경우에는 도로로서 제한받는 상태로 평가하도록 판시하고 있다.

01 도로부지의 의미

도로란 일반인의 교통을 위하여 제공되는 도로로서 도로의 종류와 등급에 관한 규정(도로법 제8조)에 열거한 것을 말한다(도로법 제2조 제1호). 사도란 도로법 규정에 의한 도로나 도로법의 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 길을 말한다(사도법 제2조). 사도법에 의한 사도가 되기 위해서는 도로가 공로에 연결된 사실만으로 안 되고, 특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)의 개설허가가 있어야 한다.

02 보상평가기준

1) 개설

도로부지도 개인에게 사유재산권이 인정되는 토지의 하나이므로, 손실보상이 주어져야 함은 당연하다.

그러나 도로부지로 이용된다는 사실만으로 획일적인 평가기준을 적용하기에는 많은 어려움이 따른다.

도로개설로 인하여 인접 토지에의 가치이전정도에 따라 도로부지의 보상가치가 결정되기 때문이다.

따라서 토지보상법에서는 인접 토지에의 가치이전정도에 따라 3가지 유형의 도로로 분류하여 각기 평가기준을 달리 정하고 있다.

2) 사도법상 사도의 평가

(1) 사도법상 사도의 의미

사도법상 사도란 사도법에 따라 개설허가권자의 개설허가를 받은 도로를 말한다. 일반의 교통에 공용되는 도로 중 고속국도·일반국도·특별시도·지방도 등과 대통령령이 정하는 바에 따라 위의 도로 외의 도로 중 도로법의 준용을 받는 도로는 사도법상 사도가 아니다. 사도법상 사도는 비록 토지대장상 지목이 도로라고 하더라도 사도개설 허가를 얻지 않은 것은 사도로 볼 수 없다고 할 것이다.

(2) 평가방법

인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내로 평가한다(칙 제26조 제1항). "인근토지"라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).

(3) 감가보상의 논거 (화체이론)

사도부지는 토지소유자가 자기 소유의 다른 토지의 효용을 증진시키기 위하여 스스로 개설허가권자의 허가를 받아 설치한 도로이므로, 허가받아 설치한 사도는 토지소유자의 다른 토지의 가치 증진에 이바지한 것이기 때문에 감가평가하도록 하고 있다

3) 사실상 사도의 평가

(1) 사실상 사도의 의의

"사실상의 사도"란 그 효용은 사도법상 사도와 같으나 관할 시장 등의 허가를 받지 않고 개설하거나 형성된 도로를 말한다. 즉 「사도법」에 의한 사도외의 도로(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시·군관리 계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 것을 제외한다)로서,

- ① 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로,
- ② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로,
- ③ 「건축법」 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로,
- ④ 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로의

어느 하나에 해당하는 도로를 말한다(칙 제26조 제2항).

(2) 사실상 사도의 개념과 관련된 판례

a. 자기토지 편익을 위해 스스로 설치한 토지의 의미 (1호)

토지 소유자가 자기 소유 토지 중 일부에 도로를 설치한 결과 도로 부지로 제공된 부분으로 인하여 나머지 부분 토지의 편익이 증진되는 등으로 그 부분의 가치가 상승됨으로써 도로부지로 제공된 부분의 가치를 낮게 평가하여 보상하더라도 전체적으로 정당보상의 원칙에 어긋나지 않는다고 볼 만한 객관적인 사유가 있다고 인정되어야 하고, 이는 도로개설 경위와 목적, 주위환경, 인접토지의 획지 면적, 소유관계 및 이용상태 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단할 것이다(대법원 2011두7007).

b. 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로의 의미 (2호)

법률상 소유권을 행사하여 통행을 제한할 수 없는 경우뿐만 아니라 사실상 통행을 제한하는 것이 곤란하다고 보이는 경우도 해당한다고 할 것이나, 적어도 도로로의 이용상황이 고착화되어 당해 토지의 표준적 이용상황으로 원상회복하는 것이 용이하지 않은 상태에 이르러야 할 것이어서 단순히 당해 토지가 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고 이를 소유자가 용인하여 왔다는 사정만으로는 사실상의 도로에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2006두18492).

c. 기타

‘사실상의 사도’의 부지로 보고 인근토지 평가액의 3분의 1 이내로 보상액을 평가하려면, 도로법에 의한 일반 도로 등에 연결되어 일반의 통행에 제공되는 등으로 사도법에 의한 사도에 준하는 실질을 갖추고 있어야 하고, 나아가 위 규칙 제26조 제2항 제1호 내지 제4호 중 어느 하나에 해당하여야 할 것이다(대법원 2011두7007).

(3) 평가방법

인근 토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다(칙 제26조 제1항). "인근토지"라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).

(4) 감가보상의 논거 (도로개설의 자의성, 화체이론)

감가보상을 규정한 취지는 현실 이용상황이 도로이기 때문에 이를 감가한다는 뜻이 아니고, 도로의 가치가 그 도로로 인하여 보호되고 있는 토지의 효용이 증가됨으로써 보호되고 있는 토지의 가치에 화체되었기 때문에 그 평가액은 낮아야 한다는 이유를 배경으로 일반 토지에 비하여 감가평가하고 있다.

4) 그 외의 도로

그 외의 도로란 사도법상 사도 및 사실상의 사도가 아닌 모든 도로라 할 수 있다. 평가기준상 그 외의 도로로는 공도와 공도가 아닌 기타 도로로 구분될 수 있다. 공도부지는 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지공시지가를 기준으로 평가하되, 공도부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 한다. 이 경우 인근지역에 있는 표준적 이용상황의 표준지 공시지가에 당해 도로 개설로 인한 개발이익이 포함되어 있는 경우에는 이를 배제한 가격으로 평가한다.

01 구거부지에 대한 평가

1) 의의

구거란 “용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속시설물의 부지와 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지”를 의미한다.

2) 보상평가기준

구거(도랑)부지에 대하여는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다(칙 제26조 제3항).

“인근토지”라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).

3) 적용 범위

모든 구거 부지가 감가평가의 대상이 된다고 보기 어려운 점이 있다. 토지소유자가 독점적으로 이용하는 구거로서, 언제든지 다른 용도로 전환이 가능한 것에 대하여는 감가평가하여야 할 상당한 이유가 존재하지 않는다.

또한 농업용수나 생활용수의 공급을 위해 토지소유자가 제공한 구거부지는 감가의 타당성은 지니나, 자신이 이의 공급 혜택을 직접 받지 아니하는 경우에는 감가평가의 타당성을 결하고 있다. 대법원은 토지소유권자가 소유권을 행사하여 사용을 금지시킬 수 있는 상태에 있는 토지는 사실상의 구거에 해당되지 않는다고 한다(대판 1983. 12. 13. 83다카1747).

02 관행용수권에 의한 도수로부지의 평가

1) 의의 및 보상평가기준

관행용수권이란 공유하천으로부터 생활용수나 농업용수의 관개(灌漑)를 위하여 취수·인수하는 권리를 말한다. 도수로부지란 구거 중에서 관행용수권에 의하여 농업용수나 생활용수를 취수 또는 인수를 위해 인공적으로 조성된 부지를 말한다. 용수를 위한 도수로부지(개설당시 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도수로부지를 제외)에 대하여는 취득하는 토지의 평가 규정(칙 제22조)에 의하여 평가한다(칙 제26조 제3항 단서).

2) 도수로부지 판단기준

대법원은 도수로부지에 대해 감가평가를 하기 위해서는 그 도수로의 개설 경위·목적·주위환경·소유관계·이용상태 등 객관적인 사유가 있어야 하며, 도수로부지에 소유자의 의사에 의하지 아니한 채 생활오폐수가 흐르는 사정만으로 감가평가할 만한 객관적 사유가 있다고 보기 어렵다고 한다(대판 2001. 4. 24. 99두5085).

01 개설

개간이라 함은 저가이용의 토지를 고가이용의 토지로 만드는 것 외에 종전 이용가치를 보다 높이는 협의의 개간·매립·간척 기타 모든 토지형질변경행위를 가리키는 것이다. 개간비 보상은 토지 등이 개간됨으로써 경제적 가치가 증가하게 되고, 개간된 토지가 공익사업에 편입되어 보상받는 경우 국가나 지방자치단체는 자기의 노력과 상관없이 개간비 상당액의 부당이득을 갖게 되는 결과가 되어 바람직하지 않으므로 그 이익을 당초 개간한 자에게 되돌려 주도록 하는 제도이다. 개간비보상은 잔여지 공사비보상 등과 함께 실비변상적 성격을 갖는다.

02 개간비 보상

1) 보상대상이 되는 개간의 요건 (칙 제27조)

(1) 국유지 또는 공유지의 개간

개간비 보상은 국유지와 공유지의 경우에만 해당한다. 이 제도가 사유지에 대하여 유추적용할 수 있는지 문제된다. 사유지에 대한 개간으로 토지가격이 상승했을 때, 그 당사자 간에 부당이득의 성립이나 배분에 관한 문제는 별론으로 하고 토지는 현실적인 이용상태에 따라 평가하여 보상되어야 하므로, 이와 같은 제도를 사유지에 대하여 적용할 수 있는 명문 규정이 없는 현재로서는 사유지에 유추적용할 수 없는 것으로 보아야 할 것이다.

(2) 토지가치의 상승

토지보상법 시행규칙 제27조 제1항에서 ‘개간’이란 협의의 개간뿐만 아니라 매립 및 간척 등의 광의의 개간을 포함하고 있다. 즉 개간에는 토지의 증가(增價)를 가져오는 모든 개량행위가 포함된다고 보아야 한다.

(3) 적법한 개간

1995년 1월 7일 (구)공특법시행규칙 개정일부터는 불법개간에 대하여는 그 개간비를 보상하지 않으며, 관계 법령에 의하여 적법하게 개간한 경우에만 보상한다. 다만 1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에서 편입된 무허가개간토지에 대하여는 예외적으로 개간비를 보상하도록 하고 있다(칙 부칙 제6조).

(4) 계속 점유

개간한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있어야 한다. 개간한 자가 사망한 경우에는 그 상속인이 개간한 자가 사망한 때부터 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우를 포함한다. 따라서 보상 당시 사실상 점유하고 있지 아니한 때에는 원칙적으로 보상대상이 되지 않는다.

2) 개간비 평가 기준

개간비는 지장물과는 별도로 개간에 소요된 비용으로 평가한다. 그러나 보상액은 개간 후의 토지가격에서 개간 전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못한다(칙 제27조 제1항). 개간비를 평가함에 있어서는 개간전과 개간후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 한다(칙 제27조 제2항).

03 개간지에 대한 보상

개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 보상액은 개간후의 토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 한다(칙 제27조 제3항). 이는 이중보상을 방지하기 위한 규정이다.

01 소유권 외의 권리의 내용

소유권 외의 권리란 사용·수익권인 용익물권, 즉 지상권·지역권·전세권과 채권인 사용대차 또는 임대차에 관한 권리, 그리고 담보물권인 저당권 그 밖에 소유권 외의 권리를 말한다. 여기서 '권리'는 지하 및 공중공간에 설정되는 구분지상권 등 소유권을 제외한 모든 경제적 가치가 있는 권리를 포함하고, 법률행위에 의한 물건변동은 등기하여야 효력이 발생하기 때문에(민법 제186조), 물권은 등기하여야 하지만 채권은 등기하였는지 여부를 묻지 않는다. 그러나 점유는 사실상 권리가 아니므로 점유를 할 수 있는 본권을 제외하고는 권리로 보지 아니한다(칙 제28조 제1항).

02 소유권 외 권리의 평가

취득하는 토지에 설정된 소유권외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다(칙 제28조 제1항). 토지에 관한 소유권외의 권리에 대하여는 거래사례비교법에 의하여 평가함을 원칙으로 하되, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 당해 권리의 유무에 따른 토지의 가격차액 또는 권리설정계약을 기준으로 평가한다(동조 제2항). 이 규정 취지는 소유권 외 권리목적인 토지의 감정평가방법을 정함으로써, 개인별 보상의 원칙에 보다 충실하기 위함에 있다.

03 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가

1) 소유권 외의 권리가 설정된 토지

소유권 외의 권리가 설정된 토지란 용익물권, 즉 지상권·지역권·전세권과 채권인 임차권 그리고 담보물권인 저당권 등의 권리가 설정된 토지를 말한다. 이 때 소유권 이외의 권리에는 사용대차의 경우를 포함하되, 점유는 이 경우의 권리로 보지 아니한다.

2) 소유권 이외의 권리가 설정된 토지의 평가

취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지에 대하여는 당해 권리가 없는 것으로 하여 취득하는 토지의 평가 규정(칙 제22조), 공법상 제한을 받는 토지의 평가 규정(칙 제23조), 무허가건축물 등의 부지 또는 불법형질변경된 토지의 평가 규정(칙 제24조), 미지급용지 평가 규정(칙 제25조), 도로 및 구거부지의 평가 규정(칙 제26조), 개간비 평가 등 규정(칙 제27조)에 의하여 평가한 금액에서 토지에 관한 소유권 외의 권리의 평가 규정(칙 제28조)에 의하여 평가한 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다(칙 제29조).

이와 같이 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가에서 공제주의를 택하고 있는 것은 소유권 외의 권리자를 보호하기 위한 것이다. 또한 개인별 보상원칙을 실현하기 위한 것이라고도 한다.

01 일반 토지의 사용료 평가**1) 의의**

공익사업시행을 원인으로 타인의 토지를 사용하게 되는 경우 당해 토지의 소유권을 완전히 취득하는 정도에는 이르지 않으나, 결국 소유권의 행사에 제한을 주게 되므로 이에 대한 보상으로 사용료를 지급하여야 한다.

이 경우 토지사용료의 보상범위는 지표상의 토지사용만이 대상이 되는 것이 아니라, 토지의 입체적 소유권 개념에 기초하여 토지의 지상 및 지하부분의 사용을 포함하게 된다. 또한 공중공간의 사용에 대한 보상평가는 사용기간이 일시적인가 영구적인가(구분지상권 설정)에 따라 기준을 달리하고 있으므로 설정된 사용기간의 장단(長短)에도 주의하여야 한다.

2) 보상기준

협의 또는 재결에 의하여 사용하는 토지에 대하여는 그 토지와 인근 유사토지의 지료·임대료·사용방법·사용기간 및 그 토지의 가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다(제71조 제1항). 사용하는 토지와 그 지하 및 지상의 공간 사용에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법은 투자비용, 예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 국토교통부령으로 정한다(제71조 제2항). 토지의 사용이란 토지보상법이 정한 절차에 따른 적법한 사용만을 의미한다. 토지의 사용료는 임대사례비교법으로 평가한다. 다만 적정한 임대사례가 없거나 대상 토지의 특성으로 보아 임대사례비교법으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다(칙 제30조).

02 토지의 지하·지상공간의 사용에 대한 보상평가**1) 지하·공중공간 이용 관련 보상기준**

지하철 건설 등으로 지하·지상(공중)공간의 보상에 대한 필요성이 제기됨에 따라, 토지보상법은 토지의 지하사용뿐만 아니라 지상공간 사용에 대한 평가 규정을 신설하였다. 토지의 가격에 '입체이용저해율'을 곱하여 산정하되, 사실상 영구적으로 사용하는 경우와 일정한 기간 동안 사용하는 경우로 구분하여 평가하도록 하고 있다(칙 제31조).

2) 영구적으로 사용하는 경우

토지의 지하 또는 지상공간을 사실상 영구적으로 사용하는 경우 당해 공간에 대한 사용료는 표준지의 공시지가를 기준으로 하여 산정한 당해 토지의 가격에 당해 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 비율(이하 "입체이용저해율"이라 함)을 곱하여 산정한 금액으로 평가한다(칙 제31조 제1항).

3) 일시적으로 사용하는 경우

토지의 지하 또는 지상공간을 일정한 기간 동안 사용하는 경우 당해 공간에 대한 사용료는 임대사례비교법이나 적산법 등을 적용하여 산정한 당해 토지의 사용료에 입체이용저해율을 곱하여 산정한 금액으로 평가한다(칙 제31조 제2항).

4) 관련 문제

대심도란 토지소유자의 통상적인 이용행위가 예상되지 아니하고 지하시설물을 따로 설치하더라도 일반적인 토지 이용에 지장이 없을 것으로 판단되는 지하공간을 의미한다. 대심도는 개인의 사용·수익·처분권이 미치지 않는 범위로 무보상·무승낙의 개념으로 이해되고 있는 문제가 있다. 토지보상법에서는 입체이용저해율에 의한 보상액 산정방법을 규정하고 있으나, 구체적 입체이용저해율 산정방법에는 언급이 없다. 지하공간의 사용에 따른 보상평가액은 깊이에 따른 입체이용저해율에 의해서 산정하되 그 깊이와 토질의 종류, 지상 토지이용의 용도, 지하시설물의 구조 등을 고려한 보다 구체적인 기준이 필요하다.

01 잔여지의 손실 및 비용보상

1) 의의

사업시행자는 동일한 소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등 신설 등 그 밖의 공사가 필요할 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다.

다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다(제73조 제1항).

‘일단의 토지’란 연속된 토지로서 그 전체가 어떤 단일의 목적에 공용되고 있는 것으로 전체로서 경제상의 이용가치를 지니는 것을 말하며, 반드시 공부상의 한 필지임을 요하지 않는다(대판 1999. 5. 14. 97누4623). 그러나 일단의 토지는 동일한 소유자에게 속하는 것이어야 한다.

2) 보상청구 기간

잔여지의 손실 또는 비용의 보상은 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제73조 제2항).

3) 잔여지 매수의 효과

사업인정고시가 된 후 사업시행자가 잔여지를 매수하는 경우 그 잔여지에 대해서는 사업인정 및 사업인정고시가 된 것으로 본다(제73조 제3항).

4) 보상방법과 불복절차

잔여지의 손실 또는 비용의 보상이나 토지의 취득에 관하여는 손실에 대한 협의 및 협의 불성립시 재결신청에 관한 규정을 준용한다(제73조 제4항). 즉 손실보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하며, 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. 수용재결에서 정한 손실보상금에 불복하고자 하는 경우 이의신청(제83조) 또는 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 다툴 수 있다.

5) 잔여지 등의 보상평가기준

(1) 보상액 산정과 평가방법의 준용

매수하는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법 등에 대하여는 취득하는 토지의 보상(제70조), 건축물 등 물건에 대한 보상(제75조), 권리의 보상(제76조), 영업의 손실 등에 대한 보상(제77조) 및 이주대책의 내용과 비용부담, 주거이전비 등의 보상, 농·어민에 대한 보상특례(제78조제4항부터 제6항까지)의 규정을 준용한다.

(2) 보상액의 산정에 대한 대법원 판례

잔여지의 보상하여야 할 손실은 수용재결 당시의 현실적 이용상황의 변경뿐만 아니라 장래의 이용 가능성이나 거래의 용이성 등에 의한 사용가치 및 교환가치의 하락도 포함하여야 한다(대판 1998. 9. 8. 97누10680).

(3) 손실 등에 대한 평가

a. 잔여지의 차액 평가

잔여지 손실은 공익사업시행지구 편입 전의 잔여지의 가격에서 공익사업시행지구 편입된 후의 잔여지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다(칙 제32조 제1항). 이는 잔여지를 사업시행자가 취득하지 않고, 공익사업으로 인해 잔여지의 가격이 하락된 만큼 보상하도록 하기 위한 조치이다.

b. 잔여지에 대한 공사비 보상

잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가한다(칙 제32조 제2항). 이는 사업으로 인해 발생한 피해를 구제하기 위한 조치로서 사업보상 또는 비용보상의 성격을 갖는다.

02 잔여지의 취득 평가

동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란하게 된 잔여지에 대하여는 그 일단의 토지의 전체가격에서 공익사업시행지구 편입되는 토지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다(토지보상법 시행규칙 제32조 제3항). 이는 잔여지의 가격이 하락하더라도 하락되지 않은 가격수준으로 보상하기 위한 조치이다.

01 토지에 매장된 토석

토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈(흙·돌·모래 또는 자갈이 해당 토지와 별도로 취득 또는 사용의 대상이 되는 경우만 해당함)에 대해서는 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다(제75조 제3항). 토지를 취득하는 경우 토석과 모래·자갈 등은 본래 토지에 부착되어 토지와 일체를 이루고 있어 토지를 취득하면 그에 포함되어 취득 되는 것이므로 토석과 모래·자갈 등이 특별한 가치를 가지고 있는 때에는 그 함유량, 수익성, 채취허가의 난이도 등을 참작하여 보상액을 산정하여야 한다고 할 것이다(대판 1989. 3. 14. 88누2168).

02 온천의 존재가 확인된 토지

온천이 있다는 것이 확인되더라도 그것을 토지와 분리하여 별도의 보상 대상이 된다고 할 수는 없으나, 일반적으로 온천이 개발되고 온천지구로 지정되면 당해 토지의 가격은 급격히 상승되는 것이 경험칙상 명백하므로 온천이 있다는 것이 확인된 토지에 대하여는 그러한 사정을 반영하여 토지의 보상가격을 산정하여야 할 것이다(대판 2000. 10. 6. 98두19414).

03 문화적·예술적 가치

문화적·예술적 가치는 특별한 사정이 없는 한 그 토지의 부동산으로서의 경제적·재산적 가치를 높여 주는 것이 아니므로 손실보상의 대상이 될 수 없다(대판 1989. 9. 12. 88누11216).

01 개설

‘건축물 등’이라 함은 건축물·입목·공작물과 그 밖에 토지에 정착한 물건을 말한다(제75조 제1항). 건축물 등은 공익사업 시행을 위하여 직접 필요한 경우도 있으나 대부분은 당해 공익사업 수행을 위하여 직접 필요로 하지 않는 지장물이다. 토지보상법은 건축물 등 물건에 대하여는 이전에 필요한 비용으로 보상하도록 규정하고, 예외적으로 물건의 가격으로 보상하는 방법을 규정하고 있다.

02 건축물에 대한 보상평가

1) 건축물의 의의

‘건축물’이란 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고 등을 말한다(건축법 제2조 제1항 제2호). 건축물(담장 및 우물 등의 부대시설을 포함한다. 이하 같다)에 대하여는 그 구조·이용상태·면적·내구연한·유용성 및 이전가능성 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다(칙 제33조 제1항).

2) 보상평가기준

(1) 건축물 가격의 평가

a. 이전비 보상의 원칙

건축물 등에 대한 보상은 이전비로 보상함이 원칙이다(제75조 제1항).

b. 물건가격으로 보상하는 경우

건축물의 가격은 원가법으로 평가한다. 다만, 주거용 건축물에 있어서는 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액(공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택임주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서의 당해 사유로 인한 가격상승분은 제외하고 평가한 금액을 말한다)이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우와 구분소유권의 대상이 되는 건물의 가격은 거래사례비교법으로 평가한다(칙 제33조 제2항).

거래사례비교법 규정의 취지는 경제적 내용연수가 이미 경과한 건축물이라 하더라도 계속 사람이 거주하는 건물을 원가법으로 평가하면 사실상 가격이 산정되지 아니한다. 그러나 소유자 입장에서 이에 수급할 수 없고, 실제로는 수년간 더 거주가 가능하고, 원가법으로 가격이 산정되지 않는다는 이유만으로 아무런 보상 없이 건축물을 철거할 수는 없으므로, 주거용 건축물인 경우에는 경제적 내용연수의 만료시에도 생활보상의 차원에서 그 거래가격으로 평가하여 보상하도록 한 것이다.

c. 개발이익의 배제

주거용 건축물을 거래사례비교법으로 평가함에 있어 공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택임주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서의 당해 사유로 인한 가격상승분은 제외하고 평가하도록 규정하고 있다(칙 제33조 제2항).

이는 공익사업이 없었더라면 발생하지 아니하였을 일종의 ‘개발이익’이라 볼 수 있으므로 이를 배제하고 평가하여야 한다는 취지이다.

(2) 건축물의 사용료

건축물의 사용료는 임대사례비교법으로 평가한다. 다만, 임대사례비교법으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다(칙 제33조 제3항).

(3) 건축물의 철거비용

물건의 가격으로 보상한 건축물의 철거비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 건축물의 소유자가 당해 건축물의 구성부분을 사용 또는 처분할 목적으로 철거하는 경우에는 건축물의 소유자가 부담한다(칙 제33조 제4항).

03 무허가건축물에 대한 보상 [★]

1) 무허가건축물의 의의

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물이다(칙 제24조).

2) 무허가건축물의 보상여부

(1) 문제점

무허가건축물은 불법건축물이다. 무허가건축물의 보상여부에 대해서는 명문 규정이 없기 때문에, 손실보상요건 중 허가유무에 따른 재산권 충족여부가 문제된다.

다만, 89. 1. 24 이전 건축된 무허가건축물은 적법건축물로 보므로, 보상대상이다.

(2) 견해 대립 판례

a. 보상대상이라는 견해

건축법은 위반건축물에 대하여 건축물의 철거 등 조치를 명할 수 있고, 시정명령을 이행하지 아니하였을 때 이행강제금을 부과하여 이행을 강제하는 방법을 취하고 있다. 그러나 건축법이 비록 불법건축물에 대한 제재조치를 강구한다 하더라도 공익사업시 보상의 대상과 직접 관련지을 것은 아니라고 한다.

무허가건축물은 위반건축물로서 제재를 받을 따름이므로 보상에까지 확대하여 보상대상에서 제외할 이유는 없다는 것이다. 결국 위반건축물에 대한 제재와 보상은 별개의 것으로 보아야 한다고 한다.

b. 사업인정을 기준으로 하는 견해 및 판례

토지보상법은 사업인정고시가 된 후에는 토지보전의무를 규정하고 있다. 토지보전의무에 관한 규정과 관련하여 사업인정 후의 무허가건축물은 원상회복명령 대상으로서, 원상회복하지 않았을 때 행정대집행법에 의한 대집행 대상이므로 보상대상이 아니라는 해석과 사업인정 전의 무허가건축물은 토지보상법상 보전의무의 대상이 되지 않으므로 보상의 대상이 된다고 한다.

대법원도 같은 입장을 취하고 있다(대판 2000. 3. 10. 99두10896).

c. 보상대상이 아니라는 견해

건축법의 허가 및 사용승인의 일련의 조치는 적법한 건축물만이 존재하도록 함으로써 사회질서와 공공의 안녕을 도모하기 위한 것이다. 이러한 입법취지를 볼 때 적법한 건축물에 한하여 보상대상으로 하는 것이 타당하다고 할 수 있다. 만약 무허가건축물을 보상한다면 결과적으로 무질서한 건축행위까지 승인하는 결과로 되기 때문이다.

d. 검토

생각건대 허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관하므로 재산권 요건을 충족하므로, 사업인정을 기준으로 하여 판단하는 견해가 타당하다.

3) 보상평가기준

보상대상이 되는 무허가건축물은 당해 무허가건축물이 허가를 받지 않은 사정을 고려하지 않은 상태로 평가하여야 할 것이므로, 결국 평가방법에 있어 적법한 건축물의 평가방법과 동일한 평가방법을 적용해야 할 것이다.

그러나 무허가 건축물은 통상 그 구조·재료 등이 적법한 허가나 신고를 득하고 건축한 건축물에 비하여 시공의 정도가 떨어지고, 최초 허가·신고에 소요되는 비용 및 사용승인에 소요되는 비용과 보유기간 동안의 재산세 등은 이를 부담하지 않았으므로, 이를 고려하여 평가하여야 한다.

04 주거용 건축물 등의 보상에 관한 특례

1) 주거용 건축물의 최저 보상에 관한 특례

주거용 건축물에 대하여는 최저 보상의 한계를 정하여 철거 대상자의 생계대책을 기하고 공익사업의 원활화를 위해 사회정책적 보상을 하도록 하고 있다. 즉 주거용건축물로서 건축물 평가 규정에 따라 평가한 금액이 6백만원 미만인 경우 그 보상액은 6백만 원으로 한다. 다만, 무허가건축물 등에 대하여는 그러하지 아니하다(칙 제58조 제1항). 그러나 1989년 1월 24일 당시 무허가건축물 등에 대하여는 적법한 건축물로 본다고 규정하고 있으므로(규칙 부칙 제5조), 당시 무허가건축물에 대해서도 이 특례규정이 적용된다.

2) 재편입 주거용 건축물에 대한 가산금

공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물에 대한 보상을 받은 자가 그 후 당해 공익사업시행지구밖의 지역에서 매입하거나 건축하여 소유하고 있는 주거용 건축물이 그 보상일부터 20년 이내에 다른 공익사업시행지구에서 편입되는 경우 그 주거용 건축물 및 그 대지(보상을 받기 이전부터 소유하고 있던 대지 또는 다른 사람 소유의 대지위에 건축한 경우에는 주거용 건축물에 한한다)에 대하여는 당해 평가액의 30퍼센트를 가산하여 보상한다.

다만, 무허가건축물등을 매입 또는 건축한 경우와 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 경우에는 그러하지 아니하다(칙 제58조 제2항).

가산금이 1천만 원을 초과하는 경우에는 1천만 원으로 한다(칙 제58조 제3항). 1989년 1월 24일 당시의 무허가 건축물 등에 대하여는 적법한 건축물로 본다고 규정하고 있으므로(규칙 부칙 제5조), 당시 무허가건축물에 대해서도 특례를 적용하여 보상금이 가산지급된다.

01 건축물의 소유권 외의 권리 등 평가

지장물인 건축물은 이전비로 보상하는 것이 원칙이고, 이를 이전하는 경우 소유권 외의 권리도 이전하게 되기 때문에 건축물에 관한 소유권 외의 권리에 대한 보상평가는 문제가 없는 것으로 보고 있다. 그러나 취득가격으로 보상하는 경우에 그에 대한 소유권 외의 권리의 보상이 문제로 되며 이는 보상대상이 된다. 이 경우 토지에 관한 소유권 외의 권리의 평가 규정(칙 제28조)을 준용한다. 취득하는 건축물에 설정된 소유권 외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 이에 의한 건축물에 관한 소유권 외의 권리에 대하여는 거래사례비교법에 의하여 평가함이 원칙이나, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 당해 권리의 유무에 따른 토지의 가격차액 또는 권리설정계약을 기준으로 평가한다.

02 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 건축물의 평가

취득하는 건축물에 설정된 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 건축물에 대하여는 당해 권리가 없는 것으로 한 일반 건축물의 보상평가 규정에 의하여 평가한 금액에서 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다.

01 잔여 건축물의 손실에 대한 보상**1) 의의 및 근거**

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다. 다만, 잔여 건축물의 가격 감소분과 보수비(건축물의 나머지 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는 데에 일반적으로 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용을 말한다. 다만, 「건축법」 등 관계 법령에 따라 요구되는 시설 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)를 합한 금액이 잔여 건축물의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여 건축물을 매수할 수 있다. 제75조의2에 근거를 둔다.

2) 보상청구 기간

잔여 건축물의 손실에 대해서는 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날(이하 '사업완료일'이라 한다)부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제75조의2 제4항에서 제73조 제2항을 준용).

3) 잔여 건축물 매수의 효과

사업인정고시가 된 후 사업시행자가 잔여 건축물을 매수하는 경우 그 잔여 건축물에 대해서는 사업인정 및 사업인정고시가 된 것으로 본다(제75조의2 제4항에서 제73조 제3항을 준용).

4) 보상방법 등

잔여 건축물의 손실에 대한 보상 및 취득에 관하여는 협의 및 협의 불성립시 재결신청에 관한 규정을 준용한다(제75조의2 제3항에서 제9조 제6, 7항을 준용). 즉, 손실보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하며, 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

5) 보상평가기준

동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소된 경우의 잔여 건축물의 손실은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격(해당 건축물이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격을 말한다)에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여 건축물의 가격을 뺀 금액으로 평가한다(칙 제35조 제1항).

02 잔여건축물의 보수가 필요한 경우의 보수비

동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물에 보수가 필요한 경우의 보수비는 건축물의 잔여부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용(「건축법」 등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)으로 평가한다(칙 제35조 제2항).

보수비는 건물의 잔여 부분을 종래의 목적대로 사용기능을 유지함으로써 그 유용성의 동일성을 유지하는 데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사를 하는 데 소요되는 비용이라 한다(대판 2000. 10. 27. 2000두5104).

01 권리의 적정가격 보상원칙

광업권·어업권 및 물(용수시설을 포함한다) 등의 사용에 관한 권리에 대하여는 투자비용, 예상 수익 및 거래가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다. 보상액의 구체적인 산정 및 평가방법은 국토교통부령으로 정한다(제76조).

02 광업권의 보상평가

광업권에 대한 손실의 평가는 「광업법 시행령」 제30조에 따른다(토지보상법 시행규칙 제43조 제1항).

1) 광업권에 대한 손실의 평가

광업법 시행령 제30조에 따라야 하며, 그 내용은 아래와 같다.

- ① 광업권자나 조광권자 조업 중이거나 정상적으로 생산 중에 휴업한 광산으로서 광물의 생산실적이 있는 경우 :
법 제34조제4항제1호에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 자가 광산의 장래 수익성을 고려하여 산정한 광산 평가액에서 이전(移轉)이나 전용(轉用)이 가능한 시설의 잔존가치(殘存價值)를 뺀 금액에 이전비를 합산한 금액.
이 경우 평가된 지역 외의 지역에 해당 광산개발을 목적으로 취득한 토지·건물 등 부동산이 있는 경우에는 그 부동산에 대하여 토지보상법에서 정하는 보상기준을 준용하여 산정한 금액을 더한 금액으로 한다.
- ② 탐사권자가 탐사를 시작하였거나 탐사실적을 인정받은 경우와 채굴권자가 채굴계획 인가를 받은 후 광물의 생산실적이 없는 광산인 경우 :
해당 광산개발에 투자된 비용과 현재시설의 평가액에서이전이나 전용이 가능한 시설의 잔존가치를 뺀 금액에 이전비를 합산한 금액
- ③ 탐사권자가 등록을 한 후 탐사를 시작하지 아니하였거나 채굴권자가 채굴계획 인가를 받지 아니한 경우 :
등록에 든 비용

03 어업권의 보상평가**1) 어업권의 의의**

어업권이라 함은 수산업법의 면허어업에 관한 규정에 따라 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다(수산업법 제2조 제9호). 어업을 하고자 하는 자는 면허를 받거나 허가 또는 신고하도록 되어 있으며, 전자를 면허어업이라 하고 후자를 허가어업 또는 신고어업이라 한다.

2) 어업권 등에 대한 평가기준**(1) 어업권 등 손실의 평가**

공익사업의 시행으로 인하여 어업권이 제한·정지 또는 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우 해당 어업권 및 어선·어구 또는 시설물에 대한 손실의 평가는 「수산업법 시행령」 별표 10에 따른다(칙 제44조 제1항).

(2) 시설 이전하여 어업이 가능한 경우의 손실평가

공익사업의 시행으로 인하여 어업권이 취소되거나 「수산업법」 제14조 또는 「내수면어업법」 제13조에 따른 어업면허의 유효기간의 연장이 허가되지 아니하는 경우로서 다른 어장에 시설을 이전하여 어업이 가능한 경우 해당 어업권에 대한 손실의 평가는 「수산업법 시행령」 별표 10 중 어업권이 정지된 경우의 손실액 산출방법 및 기준에 의한다(규칙 제44조 제2항).

(3) 사업인정고시일 이후 어업권 면허자에 대한 비적용

토지보상법 제15조제1항 본문의 규정에 의한 보상계획의 공고(동항 단서의 규정에 의하는 경우에는 토지소유자 및 관계인에 대한 보상계획의 통지를 말한다) 또는 동법 제22조의 규정에 의한 사업인정의 고시가 있는 날(이하 "사업인정고시일등"이라 한다) 이후에 어업권의 면허를 받은 자에 대하여는 토지보상법 시행규칙 제44조 제1항 및 제2항의 규정을 적용하지 아니한다.

왜냐하면, 보상계획의 공고 또는 사업인정의 고시가 있는 후에 어업면허나 어업허가를 받았거나 어업신고를 하였다면, 위 신고 등은 공익사업으로 인한 제한 내지는 허가 등의 취소를 전제하는 것이기 때문이다.

대법원은 이러한 경우 손실보상의 대상이 되는 특별한 손실을 입게 되었다고 할 수 없어 손실보상을 청구할 수 없다고 한다(대법 2002.2.26 선고 2000다72404 판결).

3) 허가어업 및 신고어업의 손실평가에의 준용

위 내용들은 허가어업 및 신고어업(「내수면어업법」 제11조제2항의 규정에 의한 신고어업을 제외한다)에 대한 손실의 평가에 관하여 이를 준용한다(칙 제44조 제4항).

4) 허가 등을 받지 아니한 어업의 보상

허가 등을 받지 아니한 영업의 손실보상에 관한 특례 규정(칙 제52조)은 어업에 대한 보상에 관하여 이를 준용한다(칙 제44조 제5항). 이는 무허가 등의 영세어업자를 보호하기 위한 규정이다.

5) 관행에 의한 어업

수산업법에서는 면허어업·허가어업 및 신고어업의 방법만을 규정하여 놓고 누구든지 수산업법에 의한 어업 외의 방법으로 수산동식물을 포획·채취 또는 양식하여서는 안 된다고 하고, 그에 위반한 경우에는 처벌하도록 규정하고 있다. 다만, 면허, 신고, 허가어업 외 수산업법 규정에 의한 어업권이 설정되기 전부터 수면에서 계속적으로 수산동식물을 포획·채취하여 온 사실이 대다수 사람들에게 인정되어 있다는 관행이 있다면, 이를 인정하고, 관행에 의한 어업권도 손실보상 대상으로 봄이 타당하다.

그러나 관행에 의한 어업은 면허에 의하여 인정되는 어업권과 같이 일정한 공유수면을 전용하면서 그 수면에서 배타적으로 수산동식물을 체포할 수 있는 독점적인 권리라기보다는 다만 다른 사람의 방해를 받지 않고 일정한 공유수면에 출입하면서 수산동식물을 체포할 수 있는 권리에 지나지 않는다. 따라서 면허어업과 저촉되지 아니하는 마을어업이 설정된 어장 및 어업권이 설정되지 아니한 수면에서만 인정된다고 보아야 할 것이다.

또한 수산업법의 개정으로 관행에 의한 입어자는 1993년 2월 1일까지 어업권원부에 등록을 한 경우에 한하여 인정된다. 그러므로 관행에 의하여 어업을 하고 있으나 어업권원부에 등록을 하지 않은 자는 관행에 의한 어업권자가 될 수 없다(대판 1995. 11. 10. 94도2458).

6) 공익사업시행지구 밖의 어업피해에 대한 보상

공익사업의 시행으로 인하여 해당 공익사업시행지구 인근에 있는 어업에 피해가 발생한 경우 사업시행자는 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상하여야 한다. 이 경우 실제 피해액은 감소된 어획량 및 「수산업법 시행령」 별표 10의 평년수익액 등을 참작하여 평가한다(칙 제63조). 토지보상법은 종전과 같이 피해액을 예측하여 피해발생 전에 보상함으로 인하여 발생하는 문제점을 해소하기 위하여 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상하도록 규정하고 있다. 이는 최근의 판례에서 그 발생을 예견하기가 어렵고 그 손실의 범위도 쉽게 확정할 수 없는 간접손실에 대한 손실보상을 인정하지 않은 것과 같은 취지로 보인다.

7) 공익사업에 관한 계획의 고시 등이 있는 후의 무면허어업 등의 보상

토지보상법에서는 무면허어업 등 불법영업시설에 대한 보상규정이 존재하지 않는다. 이는 불법영업시설에 대해서는 어떠한 경우에도 보상대상이 될 수 없음을 시사하는 것으로 볼 수 있다.

8) 이어비

공익사업 시행으로 인하여 영위하던 어업을 계속할 수 없게 되어 다른 지역으로 이주하는 어민이 받을 보상금이 없거나 그 총액이 국토교통부령으로 정하는 금액에 미치지 못하는 경우에는 그 금액 또는 그 차액을 보상하여야 한다(제78조 제7항). 이는 영세어민에게 최소한의 생계유지를 위한 보상으로서 생활보상 차원에서 토지보상법에서 규정하고 있는 것으로 볼 수 있겠다.

01 의의 및 취지, 성격

영업이라 함은 일정한 장소에서 인적·물적 설비를 갖추고 행하는 일체의 경제활동이다.

영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지·건물 등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 말한다(대판 2006. 1. 27. 2003두13106).

영업손실보상(제77조 제1항)은 주로 재산권보상 중에서 일실손실의 보상이며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가지고 있다.

02 영업손실의 보상대상인 영업

1) 요건

영업손실을 보상하여야 하는 영업은 다음 모두에 해당하는 영업으로 한다(칙 제45조).

- ① 사업인정고시일등 전부터 **적법한 장소**(무허가건축물등, 불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말한다)에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업. 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업을 말한다.
- ② 영업을 행함에 있어서 관계법령에 의한 허가등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업

2) 요건의 의미

(1) 시간적 요건

영업손실보상 대상은 사업인정고시일등(사업인정고시와 보상계획공고일 중 빠른 날, 칙 제44조 제3항) 이전부터 영업을 행하여야 한다.

(2) 장소적 요건

영업손실보상 대상은 **적법한 장소**에서 한 영업이어야 한다. 이는 불법행위에 의한 영업은 보상대상에 제외하는 것에 그 취지가 있다. 다만, 무허가건축물의 영업이라도, 불법의 책임을 물을 수 없는 임차인이 영업의 주체라면, 보상대상이 된다.

(3) 시설적 요건

영업손실보상 대상은 일정한 정도의 인적·물적시설을 갖추어야 한다.

(4) 계속적 요건

영업손실보상 대상은 계속적으로 영업을 하여야 한다. 영업을 하기 위하여 투자한 비용이나 그 영업을 통하여 얻을 것으로 기대되는 이익에 대한 손실은 보상의 대상이 될 수 없으며(대판 2006. 1. 27. 2003두13106),

(5) 허가 등의 요건

관계 법령에 의한 허가 등을 받아 행하고 있는 영업이어야 한다(대판 1998. 2. 10. 96누12665).

그러나 관계 법령에 의하여 허가 등이나 일정한 자격이 없이도 행할 수 있는 자유영업이나 행위 또는 공익사업 시행을 위한 고시 등에 불구하고 금지되지 않거나 허가를 받을 필요가 없는 영업이나 행위는 영업보상의 대상으로 제한을 받지 않는다.

03 영업의 폐지와 휴업의 구분

1) 토지보상법상 기준

토지보상법은 다음 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 영업의 폐지로 보상하고 있다(칙 제46조 제2항).

따라서 영업손실보상 요건을 갖춘 영업 중 폐지 대상이 아닌 경우는 모두 휴업으로 볼 수 있다.

- (1) 영업장소 또는 배후지(당해 영업의 고객이 소재하는 지역을 말한다. 이하 같다)의 특수성으로 인하여 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 당해营业을 할 수 없는 경우. 여기에서 ‘배후지’란 당해 영업의 수익을 올리는 고객이 소재하는 지역적 범위를 말하고, ‘배후지의 특수성’이란 도정공장·양수장·창고업 등과 같이 제품원료 및 취급품목의 지역적 특수성으로 인하여 배후지가 상실되면 영업행위를 할 수 없는 경우와 같이 배후지가 당해 영업에 갖는 특수한 성격을 말한다고 할 것이다. ‘다른 장소에 이전하여서는 당해營業을 할 수 없는 경우’란 법적으로나 물리적인 제약으로 불가능한 경우는 물론이고, 다른 장소에 이전하여서는 수익의 감소로 사실상營業을 할 수 없는 경우도 포함한다.
 - (2) 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 당해營業의 허가 등을 받을 수 없는 경우. 예를 들어, 문화재보호법, 산림법 등에 의한 지역제한이나 규제로 허가를 받을 수 없는 경우는 물론이고, 영업허가를 받은 관계 법령에 의한 제한으로 허가 또는 면허를 받을 수 없는 경우 및 당해營業의 신고가 수리되지 않는 경우 등이 있다.
 - (3) 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우. 다른 장소로 이전하여營業하는 것이 현저히 곤란한 경우에 해당한지 여부는 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 판단하여야 한다.
- ㉠ <대법원>은 양계장을 이전할 경우 예견되는 인근 주민들의 반대민원의 정당성 유무를 심리하지 아니한 채 주민들의 반대민원의 가능성 혹은 그 제기만으로 곧 양계장 이전이 사실상 불가능하다고 판단하여 폐업보상을 인정한 원심판결을 파기하였다(대판 2003. 1. 24. 2002두8930).
- ㉡ 양돈장이 이전·신축될 경우 악취, 해충발생, 농경지 오염 등 환경공해를 우려한 주민들의 반대가 있을 가능성이 있다는 가정적인 사정만으로 양돈장을 인접지역으로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 단정짓기는 어렵다고 판시하였다(대판 2002. 10. 8. 2002두5498).

2) 영업의 폐지와 휴업의 구별 기준 : 이전가능성

대법원은 영업의 폐지로 볼 것인지 아니면 영업의 휴업으로 볼 것인지를 구별하는 기준은 당해 영업을 그 영업소 소재지나 인접 시·군·구 또는 그 지역 안의 다른 장소로 이전하는 것이 가능한지 여부에 달려 있고, 이러한 이전 가능성 여부는 법령상의 이전 장애 사유 유무와 당해 영업의 종류와 특성, 영업시설의 규모, 인접 지역의 현황과 특성, 그 이전을 위하여 당사자가 들인 노력 등과 인근 주민들의 반대 등과 같은 사실상의 이전 장애 사유 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다고 한다(대판 2005. 9. 15. 2004두14649 등).

3) 시행규칙 제47조 제2항의 '실제 휴업기간'의 의미

(1) 휴업기간의 의의, 근거

휴업기간은 폐업이 아닌 휴업보상에서 당해 공익사업의 시행으로 인하여 영업을 행할 수 없거나 손실이 예상되는 기간을 의미한다. 토지보상법 시행규칙 제47조 제2항에 근거를 둔다. 4개월 이내를 원칙적으로 하고, 영업의 고유한 특수성으로 인해 4개월 이내에 다른 장소로 이전하는 것이 어렵다고 객관적으로 인정되는 경우 2년의 범위 내에서 실제 휴업기간으로 한다고 규정한다.

(2) 취지

휴업기간의 취지는, 피수용자 개개인의 구구한 현실적인 이전계획에 맞추어 휴업기간을 평가하는 경우 그 자의에 좌우되기 쉬워 평가의 공정성을 유지하기가 어려운 점에 비추어 통상 필요한 이전기간으로 누구든지 수급할 수 있는 것으로 보이는 기간(4월)의 기준을 정하여 통상의 경우에는 이 기준에서 정한 4월의 기간 내에서 휴업기간을 정하도록 하되, 그 이상이 소요될 것으로 누구든지 수급할 수 있는 특별한 경우에는 입증된 기간을 휴업기간으로 정할 수 있도록 하는 데 있다(대법원 2006두17123).

04 보상평가기준

1) 개설

영업을 폐지하거나 휴업함에 따른 영업손실에 대하여는 영업이익과 시설의 이전비용 등을 고려하여 보상하여야 한다(법 제77조 제1항). 보상액의 구체적인 산정 및 평가 방법과 보상기준, 제2항에 따른 실제 경작자 인정기준에 관한 사항은 국토교통부령으로 정한다(제77조 제4항).

2) 폐업보상

(1) 평가기준

2년간의 영업이익(개인영업인 경우에는 소득을 말함)에 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 더한 금액으로 평가한다(칙 제46조 제1항).

(2) 영업이익 및 소득의 산정

영업이익은 해당 영업의 최근 3년간(특별한 사정으로 인하여 정상적인 영업이 이루어지지 아니한 연도를 제외한다)의 평균 영업이익을 기준으로 하여 이를 평가하되, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일전 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 평가한다. 이 경우 개인영업으로서 최근 3년간의 평균 영업이익이 다음 산식에 의하여 산정한 연간 영업이익에 미달하는 경우에는 그 연간 영업이익을 최근 3년간의 평균 영업이익으로 본다.

연간 영업이익 = 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 같은 법 제18조에 따른 승인을 받아 작성·공표한
제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)
영업이익의 산정은 실제의 영업이익을 반영할 수 있는 합리적인 방법에 의하면 된다고 대법원은 판시하였다
(대판 2004. 10. 28. 2002다3662).

3) 휴업보상

폐업보상의 요건에 해당되지 아니하는 것은 모두 휴업보상 대상이 된다.

즉 공익사업으로 영업장소가 편입되어 다른 장소로 옮겨 영업을 계속할 수 있는 경우에는 영업장소의 이전에 따른
손실액을 휴업보상으로 지급하여야 한다. 이에 대한 손실의 평가는 영업을 이전하는 경우, 영업소의 일부 시설을
보수하는 경우, 임시영업소를 설치하는 경우로 구분하여 평가한다.

05 무허가건축물 임차인의 영업에 대한 보상

① <폐업보상>

무허가건축물 등에서 임차인이 영업하는 경우 폐업보상액 중 영업용 고정자산 등 매각손실액을 제외한 금액은
1천만 원을 초과하지 못한다(칙 제46조 제5항).

② <휴업보상>

영업시설의 이전비용 및 감손상당액을 제외한 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다(칙 제47조 제6항).

06 무허가영업의 손실보상에 관한 특례

1) 3개월 수준의 가계지출비 수준의 보상

사업인정고시일등 전부터 허가 등을 받아야 할 수 있는 영업을 허가등 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로
인하여 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 「통계법」에 따른 가계조사통계의 도시근로자가구
월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한
보상금으로 지급하되, 영업시설 등의 이전비용은 별도로 보상한다(칙 제52조 본문).

2) 무허가영업에 대한 손실보상의 배제 및 한도

본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존속·비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한
보상을 받은 경우에는 영업시설 등의 이전비용만을 보상하여야 한다(칙 제52조 단서).

07 공익사업시행지구 밖의 영업손실에 대한 보상

1) 보상기준

공익사업시행지구 밖에서 영업손실 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가, 공익사업의 시행으로 인하여,

- ① 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우,
- ② 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하면, 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구로 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.
(칙 제64조 제1항).

2) 보상금의 환수

사업시행자는 영업자가 보상을 받은 이후에 그 영업장소에서 영업이익을 보상받은 기간 이내에 동일한 영업을 하는 경우에는 실제 휴업기간에 대한 보상금을 제외한 영업손실에 대한 보상금을 환수하여야 한다
(칙 제64조 제2항).

08 관련 문제

1) 가설건축물 안에서의 영업이 보상대상이 되는지

이에 대해서는 가설건축물 안에서 하는 영업에 대하여는 보상할 수 없는 것으로 해석하는 것이 타당하다는 견해가 있고, 대법원도 가설건축물의 철거는 물론 이에 다른 영업손실의 보상도 청구할 수 없다는 입장을 취하고 있다.

가설건축물은 허가 등을 받아 건축한 건축물이므로 무허가건축물에 해당하지 않는다. 그렇지만 가설건축물에서의 영업은 당해 공익사업이 시행될 때 건축물의 원상회복과 함께 종료가 예정되어 있으므로 영업보상의 대상은 아니다.

2) 자유영업의 경우 사업자등록이 영업의 적법요건인지

영업을 하는 경우 부가가치세법에 의하여 사업장마다 관할 세무서에 사업자등록을 하여야 하므로, 이 사업자등록도 적법요건에 해당하기 때문에 자유영업도 보상대상이 되기 위해서는 최소한 사업자등록은 되어 있어야 한다고 한다. 다른 견해는 사업자등록은 조세행정의 편의를 위한 것일 뿐 영업의 적법성과는 관련이 없다고 한다. 생각건대, 사업자등록은 납세의무와 관련이 있는 것이지 영업의 적법요건으로 볼 수는 없다. 따라서 자유영업은 사업자등록을 하지 아니하였다고 하여 영업보상 대상에서 제외할 수 없을 것이다.

01 의의 및 취지

농업손실이란 공익사업 시행으로 인하여 당해 토지가 공익사업시행지구로 편입되어 영농을 계속할 수 없게 됨에 따라 발생하는 손실로서, 농업손실보상이란 농민에게 영농손실액을 보상하는 것을 말한다. 농업손실에 대하여 보상하는 취지에 대하여는 공익사업 시행 전의 생활유기체가 복원되는 데 필요한 생활재건조치의 실시라는 면, 대체농지의 구입에 소요되는 기간 동안의 일실손실의 지급이라는 면, 상실된 기대이익의 전보라는 면 등이 있다.

02 보상대상

1) 물적 대상

지목에 불구하고 「농지법」 제2조 제1호 가목 및 같은 법 시행령 제2조 제3항 제2호 가목에 해당하는 토지를 말한다(토지보상법 시행규칙 제48조 제1항). "농지"란 전·답, 과수원, 그 밖에 법적 지목(地目)을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지(「초지법」에 따라 조성된 초지 등 대통령령으로 정하는 토지는 제외한다)를 말한다.

다음 어느 하나에 해당하는 토지는 보상대상인 농지로 보지 아니한다.

- ① 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지,
- ② 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지,
- ③ 타인소유의 토지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지,
- ④ 농민이 아닌 자가 경작하고 있는 토지,
- ⑤ 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지(칙 제48조 제3항).

2) 인적 대상

자경농지의 경우 농지 소유자에게 지급한다. 자경농지가 아닌 농지에 대하여는 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우 농지소유자와 실제 경작자의 협의 내용에 따라 보상하는 것이 원칙이나, 협의 불성립시 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입으로 영농손실액이 결정된 경우는 각각 영농손실액의 50%에 해당하는 금액을 보상하고, 실제소득을 입증하여 실제소득의 2년분의 영농손실액으로 결정된 경우 농지 소유자에게는 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입의 50%의 금액을 보상하고, 실제 경작자에게는 실제소득의 2년분의 영농손실액 중 농지 소유자에게 지급한 금액을 제외한 나머지에 해당하는 금액을 보상한다. 농지 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우는 실제 경작자에게 보상한다(토지보상법 시행규칙 제48조 제4항).

실제 경작자란 농지의 임대차계약서, 농지소유자가 확인하는 경작사실확인서, 직접지불금의 수령 확인자료, 농어업경영체 등록 확인서 등 그 밖에 실제 경작자임을 증명하는 객관적 자료에 의하여 사업인정고시일 등 당시 타인소유의 농지를 임대차 등 적법한 원인에 의하여 점유하고 자기소유의 농작물을 경작하는 것으로 인정된 자를 말한다.

3) 관련 판례

사업시행자가 보상금 지급이나 토지소유자 등의 승낙 없이 공사에 착수하여 영농을 계속할 수 없게 한 경우 농업손실보상과 별도로 손해배상책임이 있다(대판 2013. 11. 14. 2011다27103).

03 보상평가기준

1) 원칙적인 산정방법

공익사업시행지구 편입되는 농지면적에 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입의 직전 3년간 평균의 2년분을 곱하여 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다(칙 제48조 제1항).

2) 예외적 산정방법

농작물실제소득인정기준에서 정하는 바에 따라 실제소득을 입증하는 자가 경작하는 편입농지에 대하여는 그 면적에 단위경작면적당 실제소득의 2년분을 곱하여 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다.

다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호의 구분에 따라 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다(칙 제48조 제2항).

(1) 단위경작면적당 실제소득이 농축산물소득자료집의 작목별 평균소득의 2배를 초과하는 경우 :

해당 작목별 단위경작면적당 평균생산량의 2배를 판매한 금액을 단위경작면적당 실제소득으로 보아 이에 2년분을 곱하여 산정한 금액

(2) 농작물실제소득인정기준에서 직접 해당 농지의 지력(地力)을 이용하지 아니하고 재배 중인 작물을 이전하여 해당 영농을 계속하는 것이 가능하다고 인정하는 경우 :

단위경작면적당 실제소득의 4개월분을 곱하여 산정한 금액

3) 규제의 재검토

국토교통부장관은 제48조에 따른 농업의 손실에 대한 보상 기준에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다(칙 제69조).

04 농기구의 매각손실에 대한 보상

당해 지역에서 경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구 편입됨으로 인하여 농기구를 이용하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우 해당 농기구에 대해서는 매각손실액을 평가하여 보상하여야 한다. 다만, 매각손실액의 평가가 현실적으로 곤란한 경우에는 원가법에 의하여 산정한 가격의 60퍼센트 이내에서 매각손실액을 정할 수 있다(칙 제6항). 농업폐지의 경우뿐만 아니라 종전의 농업경영형태를 계속하기 어려운 경우도 포함된다. 따라서 소유 농지의 3분의 2 이상이 공익사업시행지구 편입되더라도 농업을 계속할 수 있는 경우에는 농기구의 매각손실액은 별도로 보상하지 않는다.

05 공익사업시행지구 밖의 농업손실에 대한 보상

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구 편입됨으로 인하여 당해 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구 밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 영농손실액을 보상하여야 한다(칙 제65조).

01 서

대규모 산업단지, 택지개발사업 등 공익사업에 주거용 건축물을 제공한 자는 정당보상을 받는다 하더라도 거주이전에 따른 대체지의 마련과 이주정착에 상당한 시일이 소요된다. 특히 조상대로 내려오던 혈연·지연 등 생활근거를 상실하고 안정된 정착지를 찾지 못하는 사람들은 그 일대 사회문제화 될 가능성도 없지 않다. 이들에 대한 생활재건의 대책으로서 여러 가지 방안이 마련되어 왔으나, 가장 근본적인 이주대책은 미흡한 점이 있었다. 이러한 사정을 고려하여 형식적 이주대책이 아닌 생활정착지를 마련해 주기 위하여 사업시행자에게 주택지 조성 등 이주대책을 의무적으로 시행하도록 하고 있다. 최근에는 주거용 건축물을 제공하여 생활근거를 상실한 자뿐만 아니라, 공장부지를 제공한 자에게도 사업시행자가 공장의 이주대책을 수립·실시하도록 하고 있다.

02 의미

이주대책이란 공익사업 시행으로 인해 생활의 근거를 상실한 자에게 사업시행자가 기본적 생활시설이 포함된 택지를 조성, 주택 건설 공급, 인근 산업단지 공장에 입주 등을 하게 하는 생활보상을 의미한다.

03 근거

1) 이론적 근거

이론적으로는 원상회복, 생활보상, 생활안정, 감정존중 등의 근거를 들 수 있고, 판례는 이주자들에 대하여 종전의 생활상태를 원상으로 회복시키는 동시에 인간다운 생활을 보장하여 주기 위한 생활보상의 일환으로 국가의 적극적이고 정책적인 배려라고 하였다.

2) 헌법적 근거

(1) 문제점

생활보상이 정당보상의 범위에 포함하는가 정당보상의 범위 밖에 있는가와 관련하여 헌법적 근거에 대하여 견해가 나뉘고 있다.

(2) 학설

① 〈헌법 제34조 생존권설〉

정당보상은 재산권의 객관적 가치를 지향하는 바, 이주대책은 이에 포함되지 않아 사회권적 기본권 조항에서 도출된다고 한다.

② 〈제34조 및 제23조 통일설〉

우리나라는 재산권보상을 대전제로 생활보상을 지향하는 바, 헌법 제23조의 정당보상은 손실보상이 복리국가적 관점에서 생활보상을 지향한다는 점을 근거로 한다.

(3) 판례

〈헌법재판소〉는 이주대책은 헌법 제23조 제3항에 규정된 정당한 보상에 포함되는 것이라기보다는 이에 부가하여 이주자들에게 종전의 생활상태를 회복시키기 위한 생활보상의 일환으로서 국가의 정책적인 배려에 의하여 마련된 제도라고 한다(헌재 2006. 2. 23. 2004헌마19).

〈대법원〉은 공익사업으로 인해 주거용 건축물을 잃게 되는 자가 종전 생활을 회복하여 인간다운 생활이 보장될 수 있도록 생활보상의 일환으로 정책적인 배려에서 마련된 제도라 한다(대판 2003. 7. 25. 2001다 57778).

(4) 검토

종전 생활을 회복시키는 생활보상이 현대의 손실보상에서는 불가결한 점을 고려하여 생활보상 역시 정당보상의 범위에 포함시키는 것이 타당하여 통일설입장이 타당하다.

3) 개별법적 근거

토지보상법 제78조 및 제78조의2, 전원개발촉진법 등 개별법에 이주대책에 관한 근거를 두고 있다.

04 수립·실시

1) 이주대책의 수립 대상자

(1) 이주대책대상자

사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 "이주대책대상자"라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다(제78조 제1항).

(2) 이주정착지에 이주를 희망하는 자

이주대책은

- ① 공익사업시행지구의 인근에 택지 조성에 적합한 토지가 없는 경우 또는
- ② 이주대책에 필요한 비용이 당해 공익사업의 본래의 목적을 위한 소요비용을 초과하는 등 이주대책의 수립·실시로 인하여 당해 공익사업의 시행이 사실상 곤란하게 되는 경우(칙 제53조 제1항)를 제외하고는 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구 수가 10호(戶) 이상인 경우에 수립·실시한다(령 제40조 제2항).

(3) 이주대책 제외 대상자 (령 제40조 제5항)

다음 어느 하나에 해당하는 자는 이주대책대상자에서 제외한다.

- ① 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경을 한 건축물의 소유자,
- ② 해당 건축물에 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니한 건축물의 소유자. 다만, 질병으로 인한 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학, 해당 공익사업지구 내 타인이 소유하고 있는 건축물에서의 거주, 그 밖에 이들에 준하는 부득이한 사유로 거주하고 있지 아니한 경우에는 제외대상자가 아니다.
- ③ 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자. 다만, 해당 공익사업지구에 주거용 건축물을 소유한 자로서 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자는 제외한다.

(4) 이주대책 수립·실시의 의제

사업시행자가 「택지개발촉진법」 또는 「주택법」 등 관계 법령에 따라 이주대책대상자에게 택지 또는 주택을 공급한 경우(사업시행자의 알선에 의하여 공급한 경우를 포함한다)에는 이주대책을 수립·실시한 것으로 본다(령 제40조 제2항 단서). 이 경우에는 이주정착금의 지급 대상도 아니다.

2) 수립·실시

(1) 수립 시 사업시행자의 재량

사업시행자는 이주대책을 수립하려면 미리 관할 지방자치단체의 장과 협의하여야 하며(제78조 제2항), 사업시행자가 이주대책을 수립하려는 경우에는 미리 그 내용을 이주대책대상자에게 통지하여야 한다(령 제40조 제1항). 사업시행자는 이주대책을 수립할 의무를 지지만(제78조 제1항), 이주대책의 내용 결정에 대해서는 재량권을 갖는다. 대법원은 일관되게 사업시행자가 이주대책의 내용 결정에 재량을 갖는다는 입장을 취하고 있다.

(2) 이주정착지의 조성·공급

이주대책을 수립하는 자는 사업시행자이다. 사업시행자는 이주대책이 수립되면 이에 따라 이주단지 조성사업을 실시한다. 이주단지조성사업이란 주택·공장 등의 이주단지 조성에 관한 사업이다.

이주대책의 내용에는 이주정착지(이주대책의 실시로 건설하는 주택단지를 포함한다)에 대한 도로, 급수시설, 배수시설, 그 밖의 공공시설 등 통상적인 수준의 생활기반시설이 포함되어야 하며, 이에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 행정청이 아닌 사업시행자가 이주대책을 수립·실시하는 경우에 지방자치단체는 비용의 일부를 보조할 수 있다(제78조 제4항).

이주단지조성사업이 완료되면 이주대상자에게 이주택지를 분양한다. 국가나 지방자치단체는 이주대책의 실시에 따른 주택지의 조성 및 주택의 건설에 대하여는 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증금을 우선적으로 지원하여야 한다(제78조 제3항). 이주정착지 안의 택지나 주택의 취득 또는 사업시행자가 이주대상자에게 택지 또는 주택을 공급한 경우 택지나 주택의 취득에 소요되는 비용은 이주대책대상자의 희망에 따라 지급받을 보상금과 상계할 수 있다(령 제40조 제4항).

3) 절차

사업시행자는 이주대책계획을 수립하려는 경우 미리 그 내용을 이주대책대상자들에게 통지하여야 한다(령 제40조 제1항). 사업시행자는 이주대책계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 관할 지방자치단체의 장과 협의하여야 하고, 공익사업 면적이 10만 제곱미터 이상이고, 토지등의 소유자가 50인 이상인 공익사업 시행시는 보상협의회를 두어야 하는데, 이주대책 수립에 관한 사항에 대해 보상협의회의 협의를 거쳐야 한다(제82조 제1항).

4) 이주대책 권리(주택지 또는 주택을 공급받기로 결정된 권리)의 전매제한과 형사처벌

이주대책 권리는 제78조 제5항에 따라 소유권이전등기를 완료할 때까지 전매할 수 없다(다만, 상속은 제외).

이를 위반(토지보상법, 한국토지주택공사법 등 일부 규정 위반도 포함)할 때에는 사업시행자는 이주대책의 실시가 아닌 이주정착금으로 지급하여야 한다.

5) 이주대책 기준

사업시행자는 이주대책의 내용 등에 관한 기준을 내부적으로 마련할 수 있다. 대법원은 한국토지주택공사가 수립한 이주대책기준에 대하여 사업시행자 내부의 사무처리준칙에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없을 뿐 아니라, 법원으로서 토지보상법 규정 취지를 감안하여 기준에 나타난 사업시행자의 의사를 합리적으로 해석할 수 있다고 판시하였고(대법원 96누140672), 사업시행자가 설정한 이주대책기준은 그것이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 한다고 하였다(대법원 2008두12610).

05 이주자의 법적 지위

1) 이주대책수립청구권

이주대책은 법상 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자가 10호 이상인 경우 수립·실시를 의무로 하고 있다. 따라서 이주대책대상자는 사업시행자에게 이주대책을 수립할 것을 청구할 권리, 즉 이주대책수립청구권을 갖는다.

2) 수분양권의 발생시기

(1) 수분양권의 의의 및 수분양권이 공법상 권리인지

수분양권이란 이주단지조성사업에 의해 조성된 택지의 분양권이나 아파트입주권 등을 취득할 수 있는 구체적 권리이다. 이주대책의 수립 및 집행은 공행정사무로 보아야 하므로 수분양권은 공법상 권리로 보는 것이 타당하다(대판 전원합의체 1994. 5. 24. 92다35783). 따라서 수분양권의 확인을 구하는 소송은 공법상 당사자소송에 의하여야 한다.

(2) 수분양권의 발생시기

a. 문제점

수분양권 발생시기에 따라 이주대상자 확인결정행위의 법적성질 및 쟁송방법에 차이가 있다.

b. 학설

- ① 토지보상법 제78조 및 동법 시행령 제40조 요건을 충족하는 때에 실체적 권리인 수분양권이 발생한다는 <이주대책계획수립이전시설>,
- ② 토지보상법 규정에 의한 추상적·포괄적 권리가 사업시행자가 이주대책을 수립·실시한 때 구체적 권리인 수분양권으로 발생한다는 <이주대책계획수립시설>,
- ③ 이주대책 수립 이후 이주자가 이주대책대상자 선정을 신청하고 사업시행자가 확인·결정하여야 수분양권이 발생한다는 <확인·결정시설>이 대립한다.

c. 판례 [대법원 1994. 5. 24. 선고 92다35783]

대법원은 이주대책상의 수분양권이 직접 발생하는가에 대하여 다수의견은 확인·결정시에 발생한다는 입장을 취하고 있으나, 반대의견은 이미 취득하고 있는 것이라는 입장을 취하고 있다. 즉, 사업시행자의 분양처분의 성질은 이주자에게 수분양권을 비로소 부여하는 처분이 아니라, 이미 이주자가 취득하고 있는 수분양권에 대하여 그의 의무를 이행한 일련의 이행처분에 불과하고, 이는 이주자가 이미 취득하고 있는 수분양권을 구체화시켜주는 과정에 불과하다는 것이다. 반대보충의견은 이주대책을 수립하기 이전에는 추상적 권리이나, 수립한 이후에는 추상적 수분양권이 구체적 권리로 바뀌게 된다고 한다.

d) 소결

생각건대 이주자가 법상 요건을 충족할 때는 이주대책대상자로서의 지위를 가질 뿐 실제적 수분양권이 존재하다고 보기는 어렵다. 이주대책계획에 의해 수분양권이 구체적 권리로 전환되므로, 이주대책대상자로 확인·결정되어야만 수분양권을 취득한다고 할 수는 없다. 따라서 수분양권은 이주대책계획 수립 시에 취득한다고 봄이 타당하다.

06 이주대상자 확인·결정행위의 법적성질

1) 학설

- ① 확인결정행위를 수분양권 취득을 위한 요건이 되는 행정작용인 처분으로 보아, 확인결정이라는 처분에 의해 비로소 수분양권이라는 권리가 발생하는 <형성처분>으로 보는 견해,
- ② 토지보상법 제78조 규정에 충족되면 이주자는 수분양권을 가지므로, 확인결정은 이주대책 수립·실시절차를 이행하기 위해 발하는 <확인·이행처분>으로 보는 견해가 있다.

2) 판례 태도

대법원 다수의견은 확인·결정시 수분양권이 발생한다는 입장이므로, 확인결정행위는 재량행위로서 형성적 행정처분으로 본다. 반대의견 및 반대보충의견은 확인결정 이전에 이미 취득하고 있는 것이라는 입장이므로 확인·이행처분과 계속행위로 보는 입장이다.

3) 검토

어느 견해에 따르더라도 이주대상자 확인·결정행위는 행정쟁송법상 처분이므로 항고소송의 대상이 된다. 수분양권은 법상 요건이 충족된 상태에서 이주대책계획수립시에 발생하므로, 확인·결정행위는 확인·이행처분으로 봄이 타당하다.

07 이주대책에 대한 권리구제

1) 이주대책 수립청구 거부 시

이주대책대상자가 이주대책의 수립을 청구하였음에도 사업시행자가 이를 수립하지 아니하거나 거부한 경우 권리구제가 문제된다. 이주대책 수립실시 의무는 사업시행자의 법적 의무인 바, 이주대책을 수립하지 아니한 경우에는 의무이행심판 또는 부작위위법확인소송을 제기할 수 있고, 거부한 경우에는 의무이행심판 또는 거부처분취소심판 또는 거부처분취소소송을 제기할 수 있다.

2) 수립실시 후 이주대책대상자 선정신청을 거부한 경우

(1) 이주대책계획수립이전시절

거부처분에 관한 항고소송이 가능하고, 구체적 이주대책계획에서 제외된 이주대책대상자는 자기 몫이 참칭 이주대책대상자에게 이미 분양되어 분양신청을 하더라도 거부할 것이 명백한 특수한 경우에는 이주대책대상자로서 분양을 받을 권리 또는 그 법률상 지위의 확인을 구하는 당사자소송의 제기가 가능하다.

(2) 이주대책계획수립시절

이주대책계획 수립 이전에는 아직 추상적 권리나 법률상 지위 내지 이익에 불과한 것이어서 이 단계에 있어서는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 그 권리나 지위의 확인을 구할 수 없다고 할 것이다. 그러나 이주대책계획을 수립한 이후에는 이주대책대상자는 수분양권에 터잡은 분양신청을 하여 거부당한 경우에는 그 거부의 취소를 구하는 항고소송을 제기할 수 있을 것이고, 신청기간을 도과한 경우, 사업시행자가 미리 수분양권을 부정하거나 이주대책에 따른 분양절차가 종료되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 경우, 또는 분양신청을 묵살당한 경우, 기타 확인판결을 얻음으로써 분쟁이 해결되고 권리구제가 가능한 경우 당사자소송으로 수분양권 또는 그 법률상 지위의 확인을 구할 수 있다고 보아야 한다.

(3) 확인·결정시절

이주대책대상자 선정신청에 대한 거부는 거부처분이 되므로 거부는 거부처분에 대한 항고소송을, 부작위인 경우에는 부작위위법확인소송을 제기하여야 한다. 이주자가 사업시행자에 대한 이주대책대상자 선정신청 및 이에 따른 확인·결정 등 절차를 밟지 아니하여 구체적인 수분양권을 아직 취득하지도 못한 상태에서 곧바로 분양의무의 주체를 상대방으로 하여 민사소송이나 공법상 당사자소송으로 이주대책상의 수분양권의 확인 등을 구하는 것은 허용될 수 없고, 나아가 그 공급대상인 택지나 아파트 등의 특정부분에 관하여 그 수분양권의 확인을 소구하는 것은 불가능하다.

3) 확인·결정행위에 대한 다툼

사업시행자의 확인·결정행위는 어느 견해에 의하던지 행정쟁송법상 처분에 해당하므로, 이주대책대상자 선정신청의 거부처분이 위법한 경우에는 항고소송으로 그 취소를 구할 수 있다.

01 간접손실 및 간접손실보상의 개념

1) 간접손실의 개념

공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실이 간접손실이다. 간접손실은 공익사업의 시공 또는 완성 후의 시설이 사업시행지구 외에 미치는 손실이다. 손실의 발생은 직접 또는 간접적으로 발생할 수 있고, 손실은 재산가액의 감소는 물론 생활피해, 정신적 피해 등을 막론한다.

2) 간접손실의 유형

일반적으로 물리적·기술적 손실과 사회적·경제적 손실로 구분한다. 또한 공익사업의 시행시 발생하는 피해와 사업이 완료된 후 발생하는 피해로 구분할 수 있다. 사업시행시 발생하는 피해는 사업 과정 중의 소음·진동·먼지 등으로 인한 피해이고, 사업 완료 후 발생하는 손실은 토지와 건물의 경우 지가하락, 지반변동, 주거 및 생활의 불편, 영업 등의 영위 곤란, 전파수신장애, 지하수고갈, 소음·진동 등이 있다.

3) 간접손실보상의 개념, 제도의 배경

간접손실보상이란 공익사업지구 밖에 위치하여 당해 사업으로 인하여 토지·건물 등이 본래의 기능을 발휘할 수 없을 때 그 소유자 등이 입는 손실에 대한 보상이다. 실정법인 토지보상법은 ‘공익사업시행지구 밖의 토지 등의 보상’으로 규정하고 있다.

이 제도는 댐건설사업에 따른 수몰로 인하여 그 주변 지역에서 발생하는 손실을 보상하기 위하여 도입된 간접보상 제도에서 비롯되었다. 최근은 간접손실보상이 확대됨에 따라 토지개발사업(예를 들어, 택지개발사업, 도시개발사업 등)을 비롯하여 고속도로사업의 주변 지역에서도 적용되고 있다. 간접손실보상은 사업시행지 밖의 토지소유자 등이 입는 손실의 보상이므로, 사업시행지 내의 토지소유자가 입는 부대적 손실의 보상과는 구별하여야 한다.

4) 수용적 침해와의 관계

통상 수용적 침해를 “적법한 행정작용의 결과 발생한 비의도적 침해”라고 정의하는데, 수용적 침해와 간접손실의 관계가 문제된다. 간접손실을 공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 필연적으로 가해지는 손실로 본다면 간접손실은 수용적 침해의 일부에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

02 간접손실보상의 필요성

간접손실은 토지 등이 비록 공익사업에 편입되지 않았으나, 그 침해가 수인의 한도를 넘을 때 보상의 대상이 된다. 공익사업으로 인해 손실이 발생하였음에도 보상하지 않게 되면 이들에게 희생만 강요하는 것이 되고, 사업지 내의 토지 등의 소유자와 비교하더라도 불공평하게 된다. 또한 이들에게는 다른 지역으로 옮아가 살 수 있는 터전을 마련해 준다거나 종래와 마찬가지로 영농 또는 영업활동 등을 할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

대법원은 종래 간접손실과 관련하여 다음과 같이 판시하고 있었다.

- ① 고속도로 소음으로 인한 간접침해에 대해 “그 침해가 사회통념상 일반적으로 수인할 정도를 넘어서는지의 여부는 피해의 성질 및 정도, 피해 이익의 공공성, 가해행위의 태양, 가해행위의 공공성, 가해자의 방지조치 또는 손해 회피의 가능성, 인·허가 관계 등 공법상 기준에의 적합 여부, 지역성, 토지이용의 선후 관계 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다”고 한다(대판 2007. 6. 15. 200437904).
- ② 공익사업 시행으로 인하여 간접손실이 발생하리라는 것을 쉽게 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 이를 특정할 수 있는 경우라면 그 손실의 보상에 관하여 토지보상법의 관련 규정 등을 유추적용할 수 있다고 하였다(대판 1999. 10. 8. 99다27231).

03 간접손실보상의 법적 성격과 논거

1) 간접손실보상의 법적 성격

보상은 사인에게 가해진 특별한 희생을 공평부담을 통해 조절함을 목적으로 하기 때문에, 간접손실보상도 보상의 일반적 논거가 적용된다. 간접손실보상은 비록 공익사업의 비용 부담을 가중시키나, 그로 인해 발생한 피해가 구제되는 것이 공평의 원칙에서 보더라도 타당하다. 간접손실보상의 법적 성질에 대해서는 손해배상설, 손실보상설, 결과책임설 등이 주장되고 있으나, 손실보상설이 합리적이라 할 수 있다. 그러나 논자에 따라서는 특별한 수인한도를 넘는 경우에는 그 피해에 대하여 손실보상이 아닌 손해배상이 주어져야 한다는 주장도 있다.

2) 간접손실보상의 논거

간접손실보상의 논거는 생활권보상에서 찾을 수 있다. 첫째, 공익사업이 시행됨으로 인하여 생활의 기반을 상실하게 될 때 종전과 같은 생활을 영위할 수 없는 것은 말할 것도 없고, 인간다운 생활을 유지할 수 없게 되는 경우도 있을 수 있다. 생활보상이 피수용자나 관계인의 인간다운 생활을 회복시켜 주기 위한 것이라면 간접손실도 마땅히 인간다운 생활을 보장하기 위해 보상되어야 하는 것이다. 둘째, 생활보상이 수용이 없었던 것과 같은 생활상태를 재현하는 것이라는 것을 전제하고 있다. 셋째, 종래와 같은 수준을 유지할 수 있을 정도의 생활안정을 위해 간접손실보상이 이루어져야 한다. 넷째, 생활보상은 지역 주민의 갈등을 해소하고, 사업의 원활한 시행에 협조를 구하는 수단이 될 수 있으므로, 이는 간접손실보상에도 타당한 것이므로 공익사업의 원활화를 위해 필요하다.

04 간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는지 여부

1) 문제점

간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는 손실이라면 헌법 제23조 제3항의 정당보상이 주어져야 하므로, 이하 견해대립을 검토한다.

2) 학설

헌법 제23조 제3항은 공용침해로 인하여 재산권자에게 직접적으로 발생한 손실만을 보상하는 것으로 규정하고 있다고 보는 부정설, 간접손실도 적법한 공용침해에 의해 필연적으로 발생한 손실이므로 헌법 제23조 제3항의 손실보상에도 포함시키는 것이 타당하다는 긍정설이 있다.

3) 판례 및 검토

판례는 간접손실을 헌법 제23조 제3항에서 규정한 손실보상의 대상이 된다고 본다. 간접손실도 적법한 공용침해로 인하여 예견되는 통상의 손실이고, 헌법 제23조 제3항을 손실보상에 관한 일반적 규정으로 보는 것이 타당하므로, 간접손실을 헌법 제23조 제3항의 손실에 포함시키는 것이 타당하다.

05 간접손실보상의 법률적 근거

공익사업이 시행되는 지역 밖에 있는 토지등이 공익사업의 시행으로 인하여 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다(제79조 제2항).

공익사업시행지구 밖에서 발생한 손실보상에 관하여는, 잔여지의 손실 또는 비용보상이 사업 공사완료일로부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다는 규정(제73조 제2항)을 준용한다(제79조 제5항).

손실이나 토지의 취득에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정한다(제80조 제1항).

협의불성립시 사업시행자나 손실을 입은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다(제80조 제2항).

06 간접손실보상의 요건

1) 일반적 요건

한편 간접손실보상은 일반적으로

- ① 공익사업의 시행에 수반된 사업지구 밖의 제3자가 입은 손실이 존재할 것,
- ② 공익사업의 시행으로 그러한 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있을 것이라는 간접손실존재의 요건을 요구한다. 이와 더불어 헌법 제23조 제3항의 손실보상의 일반적 요건, 즉 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인한 재산권에 침해로 특별한 희생이 발생하고, 보상규정이 존재해야 하는 요건을 요구한다.

2) 보상규정 존재와 관련한 요건

(1) 토지보상법 제79조 제4항을 일반근거규정으로 볼 수 있는지

a. 개괄수권조항설

토지보상법 제79조 제4항은 공익사업 시행으로 인하여 발생하는 손실 중 보상해야 하는 손실이지만 법률에 규정되지 못한 경우에 대한 개괄수권조항일 뿐 법령에 규정되지 않은 직접 또는 간접의 손실에 대한 보상의 직접적인 근거가 될 수 없다는 견해이다. 이 견해에 의하면 보상해야 하는 손실을 국토교통부령에서 규정하지 않은 경우 보상규정이 없는 경우의 문제로 보아야 한다.

b. 일반근거조항설

동 규정을 기타 손실의 보상에 관한 일반근거조항으로 해석하는 견해이다. 이 견해에 의하면 보상하여야 하는 손실을 국토교통부령에서 규정하지 않은 경우에도 토지보상법상 보상절차 및 불복절차를 통하여 손실보상을 받을 수 있다.

c. 검토

〈개괄수권조항설〉

구체적인 손실보상의 내용, 기준 등이 없는 점에서 동 조항은 보상해야 하는 손실이지만, 법률에 규정되지 못한 손실에 대한 개괄수권조항으로 봄이 타당하다.

(2) 보상규정 흠결시 보상청구가능성

a. 학설

① 보상부정설

토지보상법 시행규칙 제59조 이하의 간접보상규정을 제한적 열거규정으로 보고, 동 규정에 의해 간접손실보상의 문제가 전부 해결된 것으로 보며, 동 규정에서 규정되지 않은 간접손실은 보상의 대상이 되지 않는다고 한다. 이 견해는 동법 시행규칙의 규정이 간접손실보상을 망라하고 있다고 볼 수는 없고, 간접손실을 보상하지 않는 것은 재산권 보상규정과 평등원칙에 반하여 위헌이라는 비판이 가능하다.

② 유추적용설

구법하에서 대법원은 간접손실에 대한 보상규정이 없는 경우 기존의 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법상의 보상규정을 유추적용하여 보상할 수 있다고 보았다. 즉 공공사업의 시행결과 공공사업의 기업지 밖에서 발생한 간접손실에 대하여 사업시행자와 협의가 이루어지지 아니하고, 그 보상에 관한 명문의 규정이 없는 경우 피해자는 공특법 시행규칙상의 손실보상에 관한 규정을 유추적용하여 사업시행자에게 보상을 청구할 수 있다고 보았다. 현행법하에서도 보상규정이 결여된 간접손실에 대하여 헌법 제23조 제3항 및 토지보상법상의 간접손실보상에 관한 규정을 유추적용하여 그 손실보상을 청구할 수 있다고 볼 수 있다.

③ 헌법 제23조 제3항의 직접적용설

손실보상에 관하여 헌법 제23조 제3항의 직접 효력을 인정하고, 간접손실도 제23조 제3항의 손실보상의 범위에 포함된다고 본다면 보상규정이 없는 간접손실에 대하여는 헌법 제23조 제3항에 근거하여 보상청구권이 인정된다고 볼 수 있다.

④ 평등원칙 및 재산권보장규정근거설

공적 부담 앞의 평등원칙 및 재산권 보장규정이 손실보상의 직접적 근거가 될 수 있다면 간접손실도 헌법상 평등원칙 및 재산권 보장규정에 근거하여 보상해 주어야 한다. 간접손실도 공익사업이 직접 원인이 되어 발생한 손실이라고 볼 수 있으므로 직접 손실과 달리 볼 이유가 없다.

⑤ 수용적 침해이론

간접손실을 수용적 침해로 보고 독일법상의 수용적 침해이론을 적용하여 구제해 주어야 한다는 견해이다. 그러나 독일법상의 수용적 침해이론은 독일 관습법상의 희생보상청구권에 근거하는 것인데, 우리나라는 그러한 관습상 권리가 존재하지 아니하므로, 독일법상의 수용적 침해이론을 간접손실에 대한 손실보상의 법적 근거로 보기 어렵다. 또한 우리나라의 실정법은 독일과 달리 간접손실보상을 인정하고 있으므로, 간접손실을 인정하지 않고 수용적 침해로 보는 것은 타당하지 않다.

⑥ 손해배상설

간접손실에 대하여 명문의 보상규정이 없는 경우에는 손해배상을 청구하여야 한다는 견해이다. 그러나 간접손실은 위법한 손해가 아니고, 만일 보상규정을 두지 않고 간접손실을 야기한 것이 위법이라고 하더라도 과실을 인정하기 어려워 손해배상을 인정하기 어렵다는 문제가 있다.

b. 판례의 입장

판례는 구 토지수용법하에서 간접손실을 헌법 제23조 제3항에 규정한 손실보상의 대상이 된다고 보고, 공공용지의 취득 및 보상에 관한 특례법 시행규칙상의 각 간접손실보상규정을 유추적용하여 그에 관한 보상을 인정하는 것이 타당하다고 보았다.

c. 검토

특별한 희생에 대하여 손실보상을 하는 것은 당연한 바, 간접손실보상도 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함된다고 보아 헌법 제23조 제3항의 직접효력을 인정하여 직접 헌법 제23조 제3항에 근거하여 손실보상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

07 간접손실보상의 한계

종래 간접보상은 댐건설사업의 경우를 중심으로 규정을 두었으나, 지극히 제한적이었고, 현재 대규모 공익사업의 주변 지역에서는 피해의 양상이 다양하게 나타나고 있다. 이러한 손실에 대한 보상 확대가 당면 과제로 되고 있으나, 손실보상이 수용 손실의 보상을 중심으로 하고 있고, 일조 등에 의한 피해는 손해의 범위를 정하기 어렵고, 보상액이 과다하다는 한계를 지니고 있다. 이러한 점을 고려할 때 사업계획단계에서 간접손실의 발생을 미연에 방지하기 위한 조치의 강구가 요구된다. 수인 범위를 넘는 손실의 발생이 예측되는 경우 계획 및 공법 변경의 검토나 손실 발생이 명백한 경우 사전 보상조치의 강구가 필요하다. 그리고 사업과정에서 수인 범위를 넘는 피해가 발생할 때 응급조치를 강구하고 손해나 영향의 최소화를 위해 노력해야 할 것이다.

08 토지보상법상 간접손실의 보상내용

1) 공익사업시행지구 밖의 대지 등에 대한 보상 (칙 제59조)

공익사업시행지구 밖의 대지·건축물·분묘 또는 농지가 공익사업의 시행으로 인하여 산지나 하천 등에 둘러싸여 교통이 두절되거나 경작이 불가능하게 된 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구로 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다. 다만, 그 보상비가 도로 또는 도선시설의 설치비용을 초과하는 경우에는 도로 또는 도선시설을 설치함으로써 보상에 갈음할 수 있다. ‘경작이 불가능하게 된 경우’라 함은 그 농경지가 공익사업의 시행으로 인하여 산지나 하천 등에 둘러싸이는 등으로 경작 자체가 불가능하게 되는 경우를 의미한다(대판 2004. 10. 27. 2002다21967). 도로 또는 도선시설의 설치에 보상비가 이의 설치비용을 초과하는 경우에 한하는 것으로 해석할 수 있다.

2) 공익사업시행지구 밖의 건축물에 대한 보상 (칙 제60조)

소유농지의 대부분이 공익사업시행지구로 편입됨으로써 건축물만이 공익사업시행지구밖에 남게 되는 경우로서 그 건축물의 매매가 불가능하고 이주가 부득이한 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구로 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다. 소유농지의 대부분이란 그 농지로서 농업을 영위할 수 없는 정도에 이르는 것을 말한다. 건축물의 매매가 불가능하다는 것은 공익사업으로 인해 그 지역에 주거할 수 없게 됨에 따라 건축물의 수요를 기대할 수 없는 것을 말한다. 이주가 부득이하다는 것은 그 지역에서 주거할 수 없는 상황, 즉 잔여 가옥의 생활환경이 현저히 불편하게 되는 경우이다.

공익사업 시행으로 인하여 소음과 진동의 발생, 일조량의 감소 등으로 기존에 재배하고 있는 농작물의 비닐하우스 부지로는 부적당하더라도 다른 농작물을 재배하는 데에 별다른 지장이 없어 보이는 경우까지를 포함하는 것은 아니다. 또한 ‘도로 또는 도선시설’의 규모 등은 경작 또는 출입에 지장이 없을 정도라면 충분하다고 할 것이다.

3) 소수잔존자에 대한 보상 (칙 제61조)

공익사업의 시행으로 인하여 1개 마을의 주거용 건축물이 대부분 공익사업시행지구로 편입됨으로써 잔여 주거용 건축물 거주자의 생활환경이 현저히 불편하게 되어 이주가 부득이한 경우에는 당해 건축물 소유자의 청구에 의하여 그 소유자의 토지 등을 공익사업시행지구로 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다. 소수잔존자의 범위는 종전의 생활공동체, 잔존 규모, 지리적·자연적 조건 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있을 것이다. 1개 부락의 개념은 법정리동을 대상으로 하지 않고, 자연발생적으로 형성된 마을을 중심으로 판단하여야 할 것이다.

댐건설사업으로 마을 대부분이 수몰되어 주민 대다수가 마을을 떠나 이전함으로써 남은 주민들은 당해 마을에서의 사회생활을 유지하기가 곤란한 경우가 있다. 이를테면 주민감소로 인한 버스노선의 폐지, 일용품점도 또는 진료소의 이전 등으로 생활의 불편을 겪거나 농지 대부분이 수몰되어 농업을 계속할 수가 없는 경우 등이다.

소수잔존자보상은 남겨준 주민들에게 수인의 범위는 넘는 현저한 손실이 있는 경우 행해진다. 기존 마을과의 사회적·경제적 결합이 강해서 마을이 붕괴됨으로써 당해 마을에서 생활이 곤란하거나, 경제적 부담이 현저히 큰 경우가 이에 해당한다.

4) 공익사업시행지구 밖의 공작물 등에 대한 보상 (칙 제62조)

공익사업시행지구밖에 있는 공작물 등이 공익사업의 시행으로 인하여 그 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

5) 공익사업시행지구 밖의 어업피해에 대한 보상 (칙 제63조)

대법원은 공익사업 시행으로 인하여 사업지구 밖의 어업자가 입은 간접손해에 대하여도 그 손실의 범위를 구체적으로 특정할 수 있는 경우라면 간접보상의 대상이 된다고 하였다. 그러나 간접손실의 발생을 예견하기 어렵고 손실의 범위도 쉽게 확정할 수 없을 때는 보상청구권을 갖지 않는다고 한다(대판 1998. 1. 20. 95다29161).

(1) 실제 피해액의 보상

공익사업의 시행으로 인하여 해당 공익사업시행지구 인근에 있는 어업에 피해가 발생한 경우 사업시행자는 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상하여야 한다. 이 경우 실제 피해액은 감소된 어획량 및 「수산업법 시행령」 별표 10의 평년수익액 등을 참작하여 평가한다(칙 제63조 제1항).

실제 피해액은 사업시행자가 확인해야 하는 것인지 아니면 피해자가 입증해야 하는 것인지에 대해 논란이 있다. 생각건대 사업시행자가 조사한 결과를 토대로 실제 피해액을 확인할 수 있지만, 그렇지 못할 때 피해자가 사업시행자로 하여금 실제 피해액을 확인할 수 있도록 입증하여야 할 것이다.

(2) 보상액의 한계 및 보상 배제

제1항에 따른 보상액은 「수산업법 시행령」 별표 10에 따른 어업권·허가어업 또는 신고어업이 취소되거나 어업면허의 유효기간이 연장되지 아니하는 경우의 보상액을 초과하지 못한다(칙 제63조 제2항).

사업인정고시일등 이후에 어업권의 면허를 받은 자 또는 어업의 허가를 받거나 신고를 한 자에 대하여는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다(칙 제63조 제3항).

6) 공익사업시행지구 밖의 영업손실보상 (칙 제64조)

(1) 요건

공익사업시행지구 밖에서 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여

- ① 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우 또는
- ② 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

한편, '배후지의 3분의2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우'에 대하여 '영업을 할 수 없는 사정'에 대한 예시규정으로 보아야 하는지 문제된다. 간접손실보상은 공공필요를 위한 희생이라는 점에 보상원인이 있기 때문에 당해 공익사업으로 인해 현실적으로 영업을 할 수 없는 그 밖의 사정을 포함하는 예시규정으로 보아야 할 것이다. 즉 배후지가 3분의2 이상 상실되었더라도 나머지 배후지만으로 여전히 손익분기점을 상회하여 당해 영업을 계속할 수 있다면 이 요건에 해당하지 않는 것으로 보아야 하고, 반대로 3분의2 미만이 상실되었더라도 손익분기점을 하회하여 더 이상 영업을 할 수 없는 상황이라면 영업손실보상청구가 가능하다고 할 것이다. 공익사업 시행으로 진출입로가 단절되었더라도 이에 대체하는 시설을 설치함으로써 계속하여 영업을 행할 수 있는 경우에는 보상대상에서 제외된다.

(2) 영업손실 보상금의 환수

사업시행자는 영업자가 보상을 받은 이후에 그 영업장소에서 영업이익을 보상받은 기간 이내에 동일한 영업을 하는 경우에는 실제 휴업기간에 대한 보상금을 제외한 영업손실에 대한 보상금을 환수하여야 한다.

7) 공익사업시행지구 밖의 농업손실보상 (칙 제65조)

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구내 편입됨으로 인하여 당해 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구 밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 영농손실액을 보상하여야 한다. 당해 지역에서 영농을 계속할 수 없게 되었을 때의 농경지의 범위는 필지 단위의 개념이 아니라 당해 농민이 경작하는 농경지로서 공익사업시행지구내 편입되는 농경지와 공익사업에 편입되지 아니하는 농경지를 합한 농경지 전체의 면적을 의미한다.

09 공사비보상

1) 공사비보상의 대상과 범위

사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 취득하거나 사용하는 토지(잔여지를 포함한다) 외의 토지에 도로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 비용의 전부 또는 일부를 보상하여야 한다.

다만, 그 토지에 대한 공사의 비용이 그 토지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 토지를 매수할 수 있다(제79조 제1항). 공사비보상의 대상은 공익사업으로 인해 그 주변 지역에서 공사가 필요한 경우가 그 대상이다. 공사비보상의 범위는 공사비용의 전부 또는 일부이다. 어떠한 경우에 전부 또는 일부를 보상할 것인가에 대하여는 법령에 규정하고 있지 않으나, 당해 사례의 구체적 상황을 판단하여 사업시행자가 결정할 수밖에 없다.

2) 비용보상의 청구기한

비용보상 또는 공익사업시행지구 밖에서 발생한 손실의 보상규정에 따른 비용 또는 손실의 보상에 관하여는 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년 내 청구해야 한다. 비용보상의 청구기한은 제79조 제5항에 근거를 두고 있으며, 제73조 3항(잔여지의 손실과 공사비 보상 규정)을 준용한다.

3) 손실보상의 협의와 재결 (토지보상법 제80조)

제79조제1항 및 제2항에 따른 비용 또는 손실이나 토지의 취득에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정한다. 협의 불성립시 사업시행자나 손실을 입은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용 위원회에 재결을 신청할 수 있다.

01 공작물의 개념

공작물이란 지상 또는 지하에 인공작업으로 제작된 물건을 말한다.

건축물은 여기에서 말하는 공작물에 포함되지 않는다.

02 보상평가기준

토지보상법 시행규칙 제33조 내지 제35조의 규정은 공작물등의 평가에 관하여 이를 준용한다(칙 제36조).

03 보상대상에서 제외하는 공작물

1) 공작물등의 용도가 폐지되었거나 기능이 상실되어 경제적 가치가 없는 경우

예를 들어, 구조가 허술하고 수질도 오염되어 살수 등에 사용하고 있음에 지나지 않는 우물, 판자로 밤이슬을 피하는 정도에 지나지 않는 공작물, 지표까지 이미 완전히 매몰되어 그 기능이 상실된 우물 등이다.

2) 공작물등의 가치가 보상이 되는 다른 토지등의 가치에 충분히 반영되어 토지등의 가격이 증가한 경우

예를 들어, 석축이나 제방 등에 의해 토지 등이 보호되어 토지가격이 증가되어 있는 경우, 물리토지 가격에 화체된 저수지의 시설, 물리답의 가격에 화체된 관행용수군의 시설 등의 경우이다.

3) 사업시행자가 공익사업에 편입되는 공작물등에 대한 대체시설을 하는 경우

도로·철도·교량 등과 같은 시설이 공익사업지구에 편입되어 사업시행자가 위 시설에 대체하는 시설을 설치하는 경우 등은 이를 별도로 보상하지 아니한다.

4) 손실보상만을 목적으로 설치되었음이 명백한 경우

사업시행자의 보상계획공고 등으로 공익사업의 시행과 보상 대상 토지의 범위 등이 객관적으로 확정된 후 해당 토지에 지장물을 설치하는 경우에 그 공익사업의 내용, 해당 토지의 성질, 규모 및 보상계획공고 등 이전의 이용실태, 설치되는 지장물의 종류, 용도, 규모 및 그 설치시기 등에 비추어 그 지장물이 해당 토지의 통상의 이용과 관계 없거나 이용 범위를 벗어나는 것으로 손실보상만을 목적으로 설치되었음이 명백하다면, 그 지장물은 예외적으로 손실보상의 대상에 해당하지 아니한다고 보아야 한다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012두22096 판결).

01 보상평가기준

농작물을 수확하기 전에 토지를 사용하는 경우의 농작물의 손실은 농작물의 종류 및 성숙도 등을 종합적으로 고려하여 평가한다(직 제41조).

02 다른 지장물과 다른 규정을 둔 취지

농작물은 파종 후 통상 몇 개월에서 1년이면 수확이 가능하다. 따라서 농지가 수용되더라도 수확을 하기 전에 사업자가 실제로 그 토지를 사용하지 않는 경우에는 농작물의 수확과 관련하여 경작자에게 아무런 피해나 손실이 발생하지 않는다는 것을 전제로 하고 있다.

01 휴직 또는 실직보상의 의미

공익사업 시행으로 사용자의 귀책사유 없이 영업이 폐업되거나 휴업됨으로 근로자가 휴직 또는 실직하게 되는 경우에 대한 근로자의 손실을 사업시행자가 생활안정적 차원에서 보상하는 것이다.

02 휴직 또는 실직보상의 대상자

사업인정고시일 등 당시 공익사업시행지구 안의 사업장에서 3월 이상 근무한 근로자(소득세법에 따른 소득세가 원천징수된 자에 한한다)로서 당해 공익사업 시행으로 인하여 영업의 폐지 또는 휴업으로 실직 또는 휴직하게 되는 자이다. 따라서 근로자가 아닌 사업주 또는 대표이사는 실직 또는 휴직보상의 대상에서 제외되며, 사업인정고시일등 이후에 근무한 근로자도 보상대상이 아니다.

03 보상평가기준

1) 휴직보상기준 (칙 제51조 제1호)

휴직일수(휴직일수가 120일을 넘는 경우에는 120일로 본다)에 「근로기준법」에 의한 평균임금의 70퍼센트에 해당하는 금액을 곱한 금액. 다만, 평균임금의 70퍼센트에 해당하는 금액이 「근로기준법」에 의한 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 기준으로 한다.

2) 실직보상기준 (칙 제51조 제2호)

「근로기준법」에 의한 평균임금의 120일분에 해당하는 금액

01 의의 및 취지

주거이전비는 공익사업지구에 편입되는 주거용 건축물에 실제 거주하고 있는 소유자 및 세입자에 대하여 가구원수에 따라 지급하는 보상이다. 주거이전에 필요한 비용과 가재도구 등 동산의 운반에 필요한 비용의 보상으로 **실비변상적 보상**의 성격을 가진다. 판례는 공익사업지구 안에 거주하는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 **정책적인 목적**과 주거이전으로 인해 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 **사회보장적인 차원의 생활보상**의 성격도 가진다고 본다.

02 소유자에 대한 보상

1) 보상평가기준

공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 당해 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다 (칙 제54조 제1항).

2) 요건의 의미

(1) 주거용 건축물, 무허가건축물

‘주거용 건축물’에서 ‘주거용’의 실제 의미는 실제 그 건축물의 공부상 용도와 관계없이 실제 주거용으로 사용되는지 여부에 따라 결정해야 한다.

불법으로 주거용으로 용도변경한 건축물 소유자도 보상대상자에서 제외되는지가 문제된다. 허가나 신고 없이 건축된 위법한 건축물의 소유자에 대하여는 비록 공익사업 시행으로 주거용 건물의 이전이 불가피한 경우라 하더라도 주거이전비 보상대상자에게 제외하여 법에 의한 보호대상에서 배제하겠다는 것이 시행규칙 제54조 제1항 단서의 취지라고 보이므로, 여기에서 말하는 무허가·무신고 건축물에는 당초 법에 의하여 요구되는 허가나 신고 없이 건축된 건축물은 물론이고, 건축 당시에는 적법하게 허가를 받거나 신고를 하여 건축된 건축물이라도, 그 후 법에 의하여 요구되는 허가나 신고 없이 위법하게 용도를 변경하여 주거용으로 사용하는 건축물도 포함된다.

89. 1. 24 당시 무허가건축물 등에 대하여는 이를 적법한 건물로 보므로(칙 부칙 제5조), 주거이전비 보상대상에 해당한다.

(2) 보상의 시기

보상시기는 **주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때**이다.

(3) 실제 거주 요건

사업인정고시 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 당시 실제 거주하고 있었더라도 주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때, 즉 **이전 당시 실제 거주하고 있지 않았다면** 주거이전비의 보상대상이 아니다. 주거이전비 보상의 제도적 취지는 이주기간 동안 주거용 건물을 임차함에 필요한 비용을 지급하는 데에 있기 때문이다.

03 세입자에 대한 보상

1) 보상기준

공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 3개월 이상 거주한 자에 대하여는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대하여는 본문에 따라 주거이전비를 보상하여야 한다(칙 제54조 제2항).

2) 요건의 의미

(1) 사업인정고시일등 당시 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시

토지수용절차에 토지보상법을 준용하는 관계 법령 중에 주민공람공고 등 없이 바로 사업인정고시를 하는 법률이 있는 반면, 사업인정고시 이전에 주민 등에 대한 공람공고를 예정한 법률도 있기 때문에 그러한 경우를 모두 포섭하기 위한 것으로 보인다. 또한 고시가 있기 전이라도 공익사업 시행이 사실상 확정되고 외부에 공표되어 누구나 공익사업 시행을 알 수 있게 된 후 공익사업지구 내로 이주한 자를 주거이전비 보상대상자로 보호할 필요가 없는 데다가, 공익사업이 있을 것을 알고 보상금을 목적으로 공익사업 시행예정지역에 이주, 전입하는 방지함으로써 정당보상을 행하기 위함으로 볼 것이다.

(2) 계속 거주 요건 : 불필요

세입자에 대하여 주거이전비 산정통보일이나 수용재결일까지 계속 거주해야 한다는 주장이 있다. 그러나 '사업인정고시일 등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 등이 있을 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 3월 이상 거주한 자'에 해당하는 세입자는 이후의 사업시행자의 주거이전비 산정통보일 또는 수용개시일까지 계속 거주할 것을 요함이 없이 위 사업인정고시일 등에 바로 규칙 제54조 제2항의 주거이전비와 규칙 제55조 제2항의 이사비 청구권을 취득하므로(대법원 2006. 4. 27. 선고 2006두2435 판결), 위 주장은 타당하지 않다.

(3) 무허가건축물 등이 아닐 것

89.1.24 이후 건축된 무허가건축물 등에 입주한 세입자가 아니어야 한다. 그러나 무허가건축물 등이라 하더라도 사업인정고시일등 당시 관계법령에 의한 고시등이 있을 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대하여는 주거이전비를 보상하여야 한다(칙 제54조 제2항 단서). 물론 이 경우에는 계속 거주 요건은 필요없고, 지급기준일에 바로 주거이전비청구권을 취득한다고 볼 것이다.

04 주거이전비에 대한 쟁송

1) 쟁송방법과 법적성질

주거이전비 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 당사자소송에 의하여야 한다. 주거이전비는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적 차원에서 지급되는 금원의 성격을 가지므로, 주거이전비 보상청구권은 공법상 권리이다(대판 2008. 5. 29. 2007다8129).

2) 불복방법 (아래 방법은, 주거이전비, 이사비, 이주정착금 모두에 적용 가능)

(1) 공법상 당사자소송

주거이전비는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적 차원에서 지급되는 공법상 권리이므로, 주거이전비 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 당사자소송에 의하여야 한다.

(2) 재결절차를 거친 경우 이의신청 및 보상금증액청구소송

주거이전비는 토지수용위원회의 재결사항에 해당하므로, 만약, 주거이전비에 대해 수용재결절차를 거쳤다면, 토지보상법 83조의 이의신청 및 85조 2항 보상금증액청구소송이 가능하다.

3) 세대주가 아닌 가구원이 직접 주거이전비를 청구할 수 있는지 여부

대법원은 시행규칙의 내용, 형식, 구체적 산정방식 등에 비추어 소유자와 세입자가 지급청구권을 가지는 것으로 보아야 하고 가구원은 사업시행자를 상대로 직접 주거이전비의 지급을 구할 수 없다고 하였다.

05 주거이전비와 부동산 인도의무

사업시행자는 수용재결로 피수용자의 부동산 소유권을 원시취득한 다음, 공사를 위해 피수용자에게 거주하는 부동산의 인도의무 이행을 요구한다. 이때, 피수용자는 주거이전비, 이사비, 이주정착금을 지급받지 않음을 이유로 부동산 인도의무 이행을 거절할 수 있는지, 그리고 사업시행자는 주거이전비 등을 지급하기 위해 어떤 절차를 거쳐야 하는지 문제된다.

판례는 “① 주택재개발사업의 사업시행자가 공사에 착수하기 위하여 현금청산대상자나 세입자로부터 정비구역 내 토지 또는 건축물을 인도받기 위해서는 협의나 재결절차 등에 의하여 결정되는 주거이전비 등도 지급할 것이 요구된다. 만일 사업시행자와 현금청산대상자나 세입자 사이에 주거이전비 등에 관한 협의가 성립된다면 사업시행자의 주거이전비 등 지급의무와 현금청산대상자나 세입자의 부동산 인도의무는 동시이행의 관계에 있게 되고, 재결절차 등에 의할 때에는 주거이전비 등의 지급절차가 부동산 인도에 선행되어야 할 것이다.”

② “사업시행자는 협의나 재결절차를 거칠 필요 없이 현금청산대상자나 세입자에게 주거이전비 등을 직접 지급하거나 현금청산대상자나 세입자가 지급을 받지 않거나 받을 수 없을 때에는 민법 제487조에 따라 변제공탁을 할 수도 있다.”고 판시한 바 있다(대법원 2021. 8. 26. 선고 2019다235153 판결, 2022. 6. 30. 선고 2021다310088 판결 등 참조).

01 보상평가기준

공익사업의 시행으로 인하여 건축물의 건축을 위한 건축허가 등 관계법령에 의한 절차를 진행 중이던 사업 등이 폐지·변경 또는 중지되는 경우 그 사업 등에 소요된 법정수수료 그 밖의 비용 등의 손실에 대하여는 이를 보상하여야 한다(칙 제57조).

02 보상된 예

동 규정은 사업폐지 등에 대한 보상의 범위 및 보상내용에 대하여 명확하게 규정하고 있지 않다.

참고로 국민권익위원회에서는 공익사업 시행으로 인하여 진행 중이던 사업 등이 폐지 또는 중지된 경우에 이로 인하여 발생된 '설계조사용역비, 설계비 등의 손실제비용' 또는 '당해 사업과 직접적으로 관련되어 지출한 감정평가수수료, 대출금융비용, 보유세세금, 소유권이전등기 관련 비용 등'을 그 손실로 보고 있다. 판례는 사업폐지 등으로 손실을 입은 자가 보상을 받기 위해서는 반드시 재결절차를 거쳐야 한다고 보았다(대판 2012. 10. 11. 2010다23210 판결). 재결전치주의가 적용되는 것이다.

Chapter 01 표준지공시지가

Chapter 02 개별공시지가

Chapter 03 토지가격비준표

Chapter 04 부동산가격공시위원회

Chapter 05 타인토지출입 및 공시제도

01 의미

"표준지공시지가"라 함은 국토교통부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다(「부동산 가격 공시에 관한 법률」(이하 "부동산공시법"이라 함. 제3조 제1항). 공시지가는 모든 토지가격의 산정에 기준이 되는 공적 지가로서, 부동산의 적절한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 조사·평가된 가격이다. 공시지가는 협의로는 표준지의 가격을 조사·평가한 것을 의미하나, 광의로는 공시 지가와 토지가격비준표를 기초로 산정한 개별공시지가까지 포함하는 것으로 이해되고 있다.

02 표준지공시지가 결정·공시행위의 법적성질

1) 논의의 실익

공시지가가 행정쟁송법상 처분이 됨으로써, 행정쟁송이 제기 가능한지 여부에 논의의 실익이 있다.

2) 학설

(1) 행정행위설

보상액 등 산정에 사실상 한정액으로 작용하여 구속적 기능을 갖게 되는 점을 논거로 행정행위로 보는 견해

(2) 행정규칙설

지가정책 집행을 위해 일반·추상적으로 정해지는 행정규칙으로 보는 견해

(3) 법규명령성질을 가지는 고시로 보는 견해

개별공시지가 등 행정처분의 구속력 있는 기준이 되므로 법규명령성질을 가지는 고시에 준하는 것으로 보는 견해

(4) 행정계획설

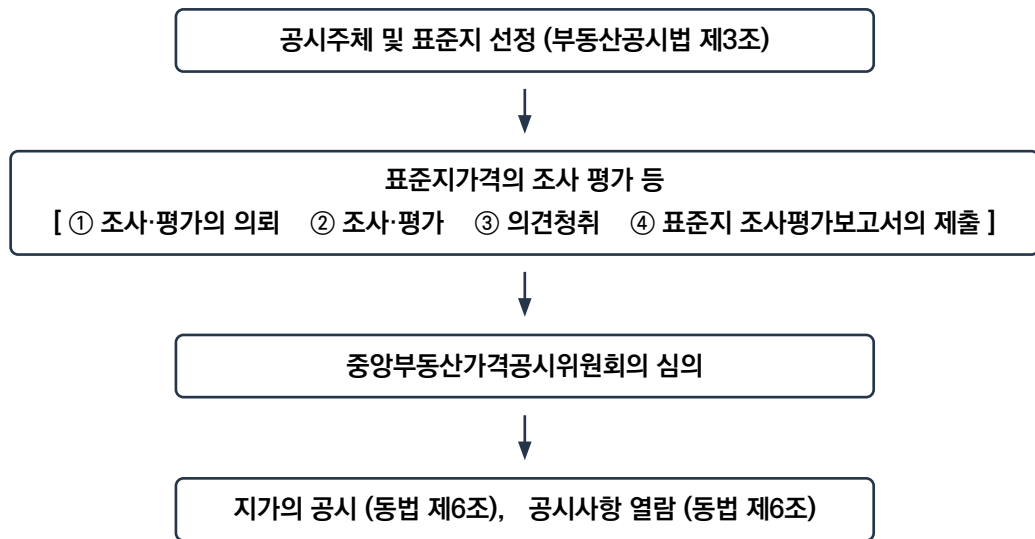
표준지공시지가는 개별공시지가 결정에 있어 목적에 따라 가감적용이 가능한 것이므로 구속력을 인정할 수 없고, 당사자의 권리·의무에 영향을 미치지 않는 행정계획으로 보는 견해

3) 판례

판례는 표준지 공시지가결정의 처분성을 인정하는 이유에 대하여는 언급하지 않고, 공시지가에 불복하기 위해서는 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 한다고 하여 처분임을 긍정하고 있다.

4) 검토

표준지공시지가를 전제로 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 향후 처분이 예정되어 있으므로, 조속히 다투어 법률관계의 조기 확정을 통한 법적 안정성을 기하게 하는 것이 필요한 바, 처분으로 보아야 한다.



대법원 2009. 12. 10. 선고 2007두20140 판결 [공시지가확정처분취소]

표준지 공시지가의 결정절차 및 그 효력과 기능 등에 비추어 보면, 표준지 공시지가는 당해 토지뿐 아니라 인근 유사 토지의 가격을 결정하는 데에 전제적·표준적 기능을 수행하는 것이어서 특히 그 가격의 적정성이 엄격하게 요구된다. 이를 위해서는 무엇보다도 적정가격 결정의 근거가 되는 감정평가업자의 평가액 산정이 적정하게 이루어졌음이 담보 될 수 있어야 하므로, 그 감정평가서에는 평가원인을 구체적으로 특정하여 명시함과 아울러 각 요인별 참작 내용과 정도가 객관적으로 납득이 갈 수 있을 정도로 설명됨으로써, 그 평가액이 당해 토지의 적정가격을 평가한 것임을 인정할 수 있어야 한다.

건설교통부장관이 2개의 감정평가법인에 토지의 적정가격에 대한 평가를 의뢰하여 그 평가액을 산술평균한 금액을 그 토지의 적정가격으로 결정·공시하였으나, 감정평가서에 거래선례나 평가선례, 거래사례비교법, 원가법 및 수익환원법 등을 모두 공란으로 둔 채, 그 토지의 전년도 공시지가와 세평가격 및 인근 표준지의 감정가격만을 참고가격으로 삼으면서 그러한 참고가격이 평가액 산정에 어떻게 참작되었는지에 관한 별다른 설명 없이 평가의견을 추상적으로만 기재한 사안에서, 평가요인별 참작 내용과 정도가 평가액 산정의 적정성을 알아볼 수 있을 만큼 객관적으로 설명되어 있다고 보기 어려워, 이러한 감정평가액을 근거로 한 표준지 공시지가 결정은 그 토지의 적정가격을 반영한 것이라고 인정하기 어려워 위법하다

04 효력

표준지공시지가는 토지시장의 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 국가·지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 된다(부동산공시법 제9조).

05 적용

감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 되고(감정평가법 제3조 및 제10조), 개별공시지가 산정의 기준이 되며(부동산공시법 제10조), 국가 등이 행정 목적을 위하여 적용하는 경우의 기준이 된다.

06 불복

1) 문제점

부동산공시법은 행정쟁송에 대한 규정 없이 이의신청만(부동산공시법 제7조)을 규정하고 있는 바, 이의신청은 공시지가의 처분성 여부와 상관없이 부동산공시법 규정에 의해 인정되는 불복수단으로서, 그 성격을 규명한다. 이하 공시지가의 처분성을 긍정하는 견해에 따라 불복수단을 논한다.

2) 이의신청

(1) 의의 및 취지

표준지 공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 국토교통부장관에게 이의를 신청하고 국토교통부장관이 이를 심사하는 제도이다(부동산공시법 제7조). 지가로서의 객관성을 확보하고, 공시지가의 공신력을 높이기 위한 제도이다.

(2) 성격

a. 학설 및 판례

이의신청의 실질적 내용에 비추어 특별행정심판 성격을 갖는다고 보는 견해, 이의신청은 표준지공시지가가 처분임을 전제한 권리구제는 아니고, 국민의 권리구제 확립을 위해 강학상 이의신청으로 보는 견해가 있다.

〈판례〉는 부동산공시법이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 제3조 제1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 ‘다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우’에 해당한다고 볼 수 없다고 하여 강학상 이의신청으로 본다.

b. 검토

이의신청은 부동산공시법 규정에 의해 인정되는 제도이고, 국민의 권리구제 확립을 위하여 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

(3) 제기요건

- ① 부동산공시법 제7조 제1항에서는 '이익이 있는 자'라고 규정하고 있고, 시행령 제12조는 '이의신청을 하려는 자'라 규정한다.
「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 시행령」 제11조 제1항에서는 '토지소유자, 토지의 이용자 그 밖에 법률상 이해관계를 가진 자'라고 규정하고 있다.
따라서 토지소유자 외에 제3자라도 법률상 이해관계가 인정되면 이의신청을 할 수 있다.
이의신청의 상대방은 국토교통부장관이다.
- ② '공시일로부터 30일 이내'에 신청해야 한다.
이 기간에 대하여 헌법재판소는 조속하고 일률적인 확정을 위한 합리적 필요에 기인한 것으로 헌법에 위배되는 것은 아니라고 하였다.
- ③ 이의신청의 관할은 국토교통부장관이다.
- ④ 이의신청의 형식 및 내용은 사유를 적은 이의신청서와 이의신청의 사유를 증명하는 서류로 한다.

(4) 심리 등

국토교통부장관은 이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 당해 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다(부동산공시법 제7조 제2항).

(5) 이의신청 후 제소기간 (행정기본법 제36조 제4항)

이의신청에 대해 불복하고자 하는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다. 이의신청을 거친 경우 제소기간(행정심판 청구 기간)의 기산일은 이의신청에 대한 결과 통지일이 되는 것이다.

3) 항고심판

부동산공시법 제7조의 이의신청이 특별행정심판에 해당하면, 행정심판법 제51조에 따라 그 이의신청을 제기한 후 행정심판의 청구가 불가능하게 된다.
따라서 항고심판 제기가능 여부에서 이의신청의 성격논의가 중요한 논점이 된다.
다만, 최근에 개별공시지가 판례에서 이의신청을 강학상 이의신청이라 보았고, 표준지공시지가의 재결례에서도 강학상 이의신청이라 보았으므로, 강학상 이의신청이라 볼 경우에는 행정심판 재청구금지와 관련 없이 행정심판의 청구기간 내라면 행정심판의 제기가 가능하다.
이때에는 행정심판법을 따른다(행정심판법 제4조 제2항).

4) 항고소송

표준지공시지가 결정에 중대·명백한 하자가 존재하는 경우 무효등확인소송을, 그에 이르지 않은 경우는 취소소송을 제기할 수 있고, 이때에는 행정소송법을 따른다(행정소송법 제8조 제1항).

07 취소소송에 있어 하자승계 관련 판례

1) 표준지공시지가와 수용재결 관련 판례

(1) 기존 판례

판례는 전통적 견해에 따라 법률효과의 동일성 측면에서 하자승계를 인정한다.

표준지공시지가결정과 수용재결은 별개의 법률효과를 지녀 하자승계를 부정하여 왔다.

(2) 표준지공시지가와 수용재결 판례

토지소유자는 수용재결 등 구체적 불이익이 현실적으로 나타났을 경우 권리구제의 길을 찾는 것이 우리 국민의 권리의식이고, 항상 토지가격을 주시하여 시정하도록 요구하는 것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이며, 수용재결 등 후행 행정처분에서 표준지공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서, 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장하기 위하여 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서도 표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있다고 판시하였다.

2) 표준지공시지가와 개별공시지가

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 대하여 불복하기 위하여는 지가공시및토지등의평가에관한법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청을 상대로 공시지가결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하고, 그러한 절차를 밟지 아니한 채 개별 토지가격 결정을 다투는 소송에서 개별 토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가의 위법성을 다툴 수는 없다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95누9808 판결).

3) 표준지공시지가와 과세처분

개별토지가격에 대한 불복방법과는 달리 표준지의 공시지가에 대한 불복방법을 지가공시및토지등의평가에관한 법률 제8조 제1항 소정의 절차를 거쳐 처분청을 상대로 다툴 수 있을 뿐 그러한 절차를 밟지 아니한 채 조세소송에서 그 공시지가결정의 위법성을 다툴 수 없도록 제한하고 있는 것은 표준지의 공시지가와 개별토지가격은 그 목적·대상·결정기관·결정절차·금액 등 여러 가지 면에서 서로 다른 성질의 것이라는 점을 고려한 것이므로, 이러한 차이점에 근거하여 표준지의 공시지가에 대한 불복방법을 개별토지가격에 대한 불복방법과 달리 인정한다고 하여 그것이 헌법상 평등의 원칙, 재판권 보장의 원칙에 위반된다고 볼 수 없다(대법원 1997. 9. 26. 96누7649 판결).

08 부동산 가격정보 등의 조사 (제15조)

국토교통부장관은 부동산의 적정가격 조사 등 부동산 정책의 수립 및 집행을 위하여

부동산 시장동향, 수익률 등의 가격정보 등을 조사·관리하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공할 수 있다.

01 의미

개별공시지가란 표준지의 공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 가격을 말한다. 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별 토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다(부동산공시법 제10조 제1항).

02 법적성질

1) 논의의 실익

종전 개별공시지가가 국무총리훈령인 ‘개별토지가격합동조사지침’에 근거하였던 때에는 처분성을 부정하는 견해가 다수 입장이었으나, 그 근거가 구 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 마련됨에 따라 논의의 양상이 새로워졌다. 논의의 실익은 행정쟁송법상 처분이 됨으로 인한 항고쟁송의 제기가가능성 여부이다.

2) 학설

(1) 행정행위설

개별토지가격은 가감조정 없이 그대로 과세기준이 되므로 그 자체에 의하여 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치므로 행정행위에 해당한다.

(2) 행정규칙설

개별토지가격은 직접 국민의 권리·의무에 영향이 없고, 후행 행정처분의 부과기준으로서 역할을 하는 일반적·추상적 규율에 불과하다고 한다.

(3) 사실행위설

지가정보를 제공하는 의사작용을 요소로 하는 정신적 사실행위에 해당한다고 한다.

(4) 행정계획설

개별공시지가는 행정의 지침이 되고, 구속력이 있으므로 구속적 행정계획에 해당한다고 본다.

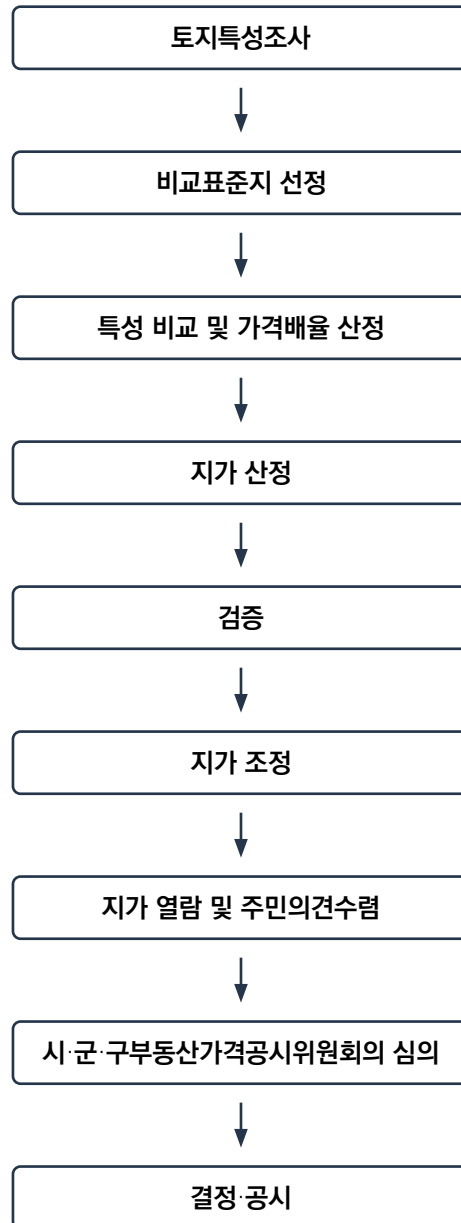
3) 판례

대법원은 개별토지가격 결정은 관계법령에 의한 토지초과이득세, 택지초과소유부담금 또는 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리나 의무 또는 법률상 이익에 직접 관계되는 것으로서 행정소송법 제2조 제1항 제1호 소정의 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사이므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 하였다(대법원 1993. 6. 11. 선고 92누16706 판결).

4) 검토

개별공시지가는 이후 과세처분 등의 직접적 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로
항고소송의 대상인 처분으로 보아 항고쟁송으로 다룰 수 있도록 해야 할 것이다.

03 공시절차



04 적용

개별공시지가는 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용한다(부동산공시법 제10조 제1항). 개별공시지가는 토지 관련 국세인 양도소득세 등의 부과기준과 지방세인 토지분 재산세 과세표준액의 결정 자료로 활용됨은 물론 각종 부담금이나 국·공유재산의 대부료·사용료의 기준으로 사용된다.

05 정정

1) 정정 사유

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오 그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다(부동산공시법 제12조).

"그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류"라 함은

- ① 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우,
- ② 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요요인의 조사를 잘못된 경우,
- ③ 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우(시행령 제23조 제1항)를 말한다.

2) 정정절차

시장·군수 또는 구청장은 법 제12조에 따라 개별공시지가의 오류를 정정하려는 경우에는 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다. 다만, 틀린 계산 또는 오기(誤記)의 경우에는 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다(시행령 제23조 제2항).

3) 정정의 효력

대법원은 정정의 결정공시가 있으면 당초의 결정·공시된 개별공시지가는 그 효력을 상실하고 경정재결된 새로운 공시지가가 공시기준일에 소급하여 그 효력을 발생한다고 한다.

4) 입법적 평가

(1) 신청에 의한 정정 규정이 없는 것

행정청은 처분에 오기(誤記), 오산(誤算) 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 잘못이 있을 때에는 직권으로 또는 신청에 따라 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다(행정절차법 제25조). 행정절차법에서는 직권 또는 신청에 의하여 처분의 정정을 규정하는 바, 이는 국민의 권익구제 및 행정의 적법성 보장을 위하여 필요하다. 개별공시지가 정정 규정에 신청에 의한 정정규정이 없는데, 이는 일반법인 행정절차법에서 신청에 따른 정정을 인정하므로, 개별공시지가 정정에서 인정함이 타당하다.

(2) 소송단계에 이르지 않고 권리구제를 위한 것

개별공시지가의 정정사유에 개별공시지가의 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우도 부동산공시법 시행령에서는 포함하고 있다. 이는 절차가 완전하지 못한 개별공시지가의 위법성을 소송단계에 이르지 않고 정정할 수 있도록 규정한 것으로 이해된다.

5) 정정신청에 대한 행정청의 거부행위에 대한 불복가능성

거부행위가 행정쟁송법상 처분이기 위해서 판례의 요건인 공권력행사의 거부일 것, 그 거부가 신청인의 권리·의무에 영향을 미칠 것, 법규상·조리상 신청권이 있을 것의 요건과 관계된다. 특히 신청권 존부와 관련해서 판례는 신청권을 부정하였고, 국민의 정정신청은 행정청의 직권 발동을 촉구하는 것에 지나지 않는다고 하여 이른 바 관념의 통지에 불과할 뿐 항고소송의 대상이 되는 처분이 아니라고 판시하였다. 그러나 행정절차법 제25조에 따를 때 신청권이 인정될 수 있어 판례 태도는 비판의 여지가 있다.

6) 토지특성조사 착오가 명백한 경우만 정정결정을 할 수 있는지

(1) 관련 판례

대법원은 개별토지가격 합동조사지침 제12조의3 규정에서 토지특성조사의 착오 또는 위산, 오기는 지가산정에 명백한 잘못이 있는 경우의 예시로서, 이러한 사유가 있으면 경정 결정할 수 있는 것으로 보아야 하고, 그 착오가 명백하여야 비로소 경정 결정할 수 있다고 해석할 것은 아니라고 판시한 바 있다.

(2) 검토

부동산공시법 시행령 제23조 제1항은 명백한 오류의 예시규정이다. 여기서 제시된 사유가 명백한 경우에 한하여만 정정할 수 있다고 보는 것은 법규정에 대한 해석의 오류라고 볼 수 있다. 따라서 판례처럼 이 규정에 예시된 사유가 발생한 경우에는 명백한 오류인지를 불문하고 정정할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

1) 문제점

부동산공시법은 행정쟁송에 대한 규정 없이 이의신청(제11조)만을 규정하고 있는 바, 이의신청은 개별공시지가의 처분 여부와 상관없이 동법 규정에 의해 인정되는 불복수단으로서, 그 성격을 규명한다. 이하 공시지가의 처분성을 긍정하는 견해에 따라 불복수단을 논한다.

2) 이의신청

(1) 의의 및 취지

개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 시장·군수, 구청장에게 이의를 신청하고 시장·군수, 구청장이 이를 심사하는 제도이다(부동산공시법 제11조). 지가로서의 객관성을 확보하고, 공시지가의 공신력을 높이기 위한 제도이다.

(2) 성격

a. 학설 및 판례

이의신청 실질적 내용에 비추어 특별행정심판 성격을 갖는다고 보는 견해,
이의신청은 공시지가가 처분임을 전제하는 것은 아니므로 국민의 권리구제 확립을 위해
강학상 이의신청으로 보는 견해가 있다.

최근 개별공시지가 이의신청에 대하여 강학상 이의신청으로 본 판례가 등장하였다.

대법원 2010. 1. 28. 선고 2008두19987 판결 [개별공시지가결정처분취소]

부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제12조, 행정소송법 제20조 제1항, 행정심판법 제3조 제1항의 규정 내용 및 취지와 아울러 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당 기관에 차이가 있는 점을 종합하면, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 제3조 제1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 '다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우'에 해당한다고 볼 수 없으므로, 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 곧바로 행정소송을 제기하거나 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판법에 따른 행정심판청구 중 어느 하나만을 거쳐 행정소송을 제기할 수 있을 뿐 아니라, 이의신청을 하여 그 결과 통지를 받은 후 다시 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기할 수도 있다고 보아야 하고, 이 경우 행정소송의 제소기간은 그 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 기산한다.

b. 검토

이의신청은 부동산공시법 규정에 의해 인정되는 제도이고, 국민의 권리구제 확립을 위하여
강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

(3) 제기요건

부동산공시법 제11조 제1항에서는 '이의가 있는 자'라고 규정하고 있고, 시행령 제22조 제1항은 '이의신청을 하려는 자'라 규정한다. 구 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 시행령 제21조 제1항에서는 '토지소유자 등'이라고 규정하고 있었다. 생각건대 개별공시지가는 전국의 모든 토지에 공시되는 것이므로 토지소유자에 한정해서 개별공시지가에 대하여 이의신청을 할 수 있다고 보아야 할 것이다.

이의신청의 상대방은 시장·군수, 구청장이다. '결정·공시일로부터 30일 이내'에 서면으로 신청해야 한다.

이의신청의 형식 및 내용은 사유를 적은 이의신청서와 이의신청의 사유를 증명하는 서류로 한다.

(4) 심리 등

시장·군수 또는 구청장은 이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 해당 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다(부동산공시법 제11조 제2항).

(5) 이의신청 후 제소기간 (행정기본법 제36조 제4항)

이의신청에 대한 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

제소기간(행정심판 청구 기간의 기산일은 이의신청에 대한 결과 통지일이 되는 것이다).

3) 항고심판

부동산공시법 제11조의 이의신청이 특별행정심판에 해당하면,

행정심판법 제51조에 따라 그 이의신청을 제기한 후 행정심판의 청구가 불가능하게 된다.

따라서 항고심판 제기가능 여부에서 이의신청의 성격논의가 중요한 논점이 된다.

다만, 최근에 개별공시지가 판례에서 이의신청을 강학상 이의신청이라 보았고,

표준지공시지가의 재결례에서도 강학상 이의신청이라 보았으므로,

강학상 이의신청이라 볼 경우에는 행정심판 재청구금지와 관련 없이 행정심판의 청구기간 내라면

행정심판의 제기가 가능하다. 이때에는 행정심판법을 따른다(행정심판법 제4조 제2항).

4) 항고소송

개별표준지공시지가 결정에 중대·명백한 하자가 존재하는 경우 무효등확인소송을,

그에 이르지 않은 경우는 취소소송을 제기할 수 있고, 이때에는 행정소송법을 따른다(행정소송법 제8조 제1항).

5) 개별공시지가의 취소소송 제소기간

(1) 문제점

행정소송법 제20조 제1, 2항에 따르면, 취소소송은 처분등이 있음을 안날(행정심판을 거친 경우 재결서 정본을 송달 받은 날)로부터 90일(불변기간) 이내, 있는 날(행정심판을 거친 경우 재결이 있는 날)로부터 1년(불변기간 아님, 정당한 사유가 있으면 적용 예외) 이내에 제기하여야 한다.

개별공시지가는 토지소유자에 대한 개별적 통지가 강제되지 않기에, 제소기간 또한 통지여부에 따라 나누어 검토하여야 한다. 개별통지를 받았다면, 그 때부터 90일 이내에 취소소송을 제기하여야 하나, 개별통지를 하지 않은 경우 처분이 있음을 안 날을 언제로 보아야 할지 문제된다.

(2) 학설

- ① 개별공시지가가 결정, 공시되더라도 통지를 하지 않으면 알았다고 보기 어려우므로, 행정소송법 제20조 제2항에 따라 판단해야 한다고 보는 견해,
- ② 공시지가의 이해관계인마다 현실적으로 안 날이 다른 경우 법률관계의 조기 확정이 어려우므로, 공시일에 처분이 있음을 알았다고 보는 견해가 있다.

(3) 판례

대법원 1993. 12. 24. 선고 92누17204 판결 [개별토지가격결정처분취소]

개별토지가격결정에 있어서는 그 처분의 고지방법에 있어 개별토지가격합동조사지침(국무총리훈령 제248호)의 규정에 의하여 행정편의상 일단의 각 개별토지에 대한 가격결정을 일괄하여 읍·면·동의 게시판에 공고하는 것일 뿐 그 처분의 효력은 각각의 토지 또는 각각의 소유자에 대하여 각별로 효력을 발생하는 것이므로 개별토지가격결정의 공고는 공고일로부터 그 효력을 발생하지만 처분 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정 처분이 있음을 알았다고까지 의제할 수는 없어 결국 개별토지가격결정에 대한 재조사 또는 행정심판의 청구기간은 처분 상대방이 실제로 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 할 것이나, 시장, 군수 또는 구청장이 개별토지가격결정을 처분 상대방에 대하여 별도의 고지절차를 취하지 않는 이상 토지소유자 및 이해관계인이 위 처분이 있음을 알았다고 볼 경우는 그리 흔치 않을 것이므로, 특별히 위 처분을 알았다고 볼만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 재조사청구 또는 행정심판청구는 행정심판법 제18조 제3항 소정의 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 이를 제기하면 된다.

대법원 1995. 8. 25. 선고 94누13121 판결 [개별공시지가결정처분취소등]

개별토지가격결정에 대한 재조사 또는 행정심판의 청구기간은 그 처분의 상대방이 실제로 그 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 하므로, 개별토지가격합동조사지침(국무총리훈령 제241호, 제248호) 제12조의2 제1항 소정의 "개별토지가격이 결정된 날로부터"는 위와 같은 의미로 해석하여야 하고, 시장, 군수 또는 구청장이 상대방에 대하여 별도의 고지절차를 취하지 않는 경우에는 원칙적으로 특별히 그 처분을 알았다고 볼만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 재조사청구 또는 행정심판청구는 행정심판법 제18조 제3항 소정의 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 이를 제기하면 되나, 나아가 개별토지가격결정의 경우에 있어서와 같이 그 처분의 통지가 없는 경우에는 그 개별토지가격결정의 대상토지 소유자가 심판청구기간 내에 심판청구가 가능하였다는 특별한 사정이 없는 한 행정심판법 제18조 제3항 단서 소정의 정당한 사유가 있는 때에 해당한다.

(4) 검토

생각건대, 공시일에 처분이 있음을 알았다고 보는 것은, 국민에게 매년 개별공시지가를 확인할 의무를 부당히 부여하는 것이므로, 행정소송법 제20조 제2항에 따라 있는 날로부터 1년 이내에 제소할 수 있다고 봄이 타당하다.

07 취소소송에 있어 하자승계 관련 판례

1) 표준지공시지가와 개별공시지가

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 대하여 불복하기 위하여는 지가공시및토지등의평가에관한법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청을 상대로 공시지가결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하고, 그러한 절차를 밟지 아니한 채 개별 토지가격 결정을 다투는 소송에서 개별 토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가의 위법성을 다룰 수는 없다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95누9808 판결, 1995. 3. 28. 94누12920 판결).

2) 개별공시지가와 과세처분

(1) 대법원 1998. 3. 13. 선고 96누6059 판결

두 개 이상의 행정처분이 연속적으로 행하여진 경우 선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 때에는 선행처분에 불가쟁력이 생겨 그 효력을 다룰 수 없게 되면 선행처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효인 경우를 제외하고는 선행처분의 하자를 이유로 후행처분을 다룰 수 없는 것이 원칙이나, 이 경우에도 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹함을 가져오고 그 결과가 당사자에게 예측가능한 것이 아닌 경우에는 국민의 재판받을 권리를 보장하고 있는 헌법의 이념에 비추어 선행처분의 후행처분에 대한 구속력은 인정될 수 없다고 봄이 타당하므로, 선행처분에 위법이 있는 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상으로 삼아 위법 여부를 다룰 수 있음은 물론 이를 기초로 한 후행처분의 취소를 구하는 행정소송에서도 선행처분의 위법을 독립된 위법사유로 주장할 수 있다. 개별토지가격 결정에 대한 재조사 청구에 따른 감액조정에 대하여 더 이상 불복하지 아니한 경우, 이를 기초로 한 양도소득세 부과처분 취소소송에서 다시 개별토지가격 결정의 위법을 당해 과세처분의 위법사유로 주장할 수 없다고 한 사례.

(2) 대법원 1994. 1. 25. 선고 93누8542 판결

가. 두 개 이상의 행정처분이 연속적으로 행하여지는 경우 선행처분과 후행처분이 서로 결합하여 1개의 법률효과를 완성하는 때에는 선행처분에 하자가 있으면 그 하자는 후행처분에 승계되므로 선행처분에 불가쟁력이 생겨 그 효력을 다룰 수 없게 된 경우에도 선행처분의 하자를 이유로 후행처분의 효력을 다룰 수 있는 반면 선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 때에는 선행처분에 불가쟁력이 생겨 그 효력을 다룰 수 없게 된 경우에는 선행처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효인 경우를 제외하고는 선행처분의 하자를 이유로 후행처분의 효력을 다룰 수 없는 것이 원칙이나 선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우에도 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹함을 가져오며, 그 결과가 당사자에게 예측가능한 것이 아닌 경우에는 국민의 재판받을 권리를 보장하고 있는 헌법의 이념에 비추어 선행처분의 후행처분에 대한 구속력은 인정될 수 없다.

나. 개별공시지가결정은 이를 기초로 한 과세처분 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 것이나, 개별공시지가는 이를 토지소유자나 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 토지소유자 등이 개별공시지가결정 내용을 알고 있었다고 전제하기도 곤란할 뿐만 아니라 결정된 개별공시지가가 자신에게 유리하게 작용될 것인지 또는 불이익하게 작용될 것인지 여부를 쉽사리 예견할 수 있는 것도 아니며, 더욱이 장차 어떠한 과세처분 등 구체적인 불이익이 현실적으로 나타나게 되었을 경우에 비로소 권리구제의 길을 찾는 것이 우리 국민의 권리의식임을 감안하여 볼 때 토지소유자 등으로 하여금 결정된 개별공시지가를 기초로 하여 장차 과세처분 등이 이루어질 것에 대비하여 항상 토지의 가격을 주시하고 개별공시지가결정이 잘못된 경우 정해진 시정절차를 통하여 이를 시정하도록 요구하는 것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이라고 아니할 수 없고, 위법한 개별공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여 시정하도록 요구하지 아니하였다는 이유로 위법한 개별공시지가를 기초로 한 과세처분 등 후행 행정처분에서 개별공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니라고 할 것이므로, 개별공시지가결정에 위법이 있는 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다룰 수 있음은 물론 이를 기초로 한 과세처분 등 행정처분의 취소를 구하는 행정소송에서도 선행처분인 개별공시지가결정의 위법을 독립된 위법사유로 주장할 수 있다고 해석함이 타당하다.

08 개발부담금 처분의 하자치유

개별공시지가는 개발부담금, 과세처분의 산정기준이 되므로, 개별공시지가결정이 위법하다면, 이에 기초한 개발부담금, 과세처분 또한 위법하게 될 수 있다. 이와 관련하여, 대법원은 “선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 그 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 적법하게 된다고 볼 수 없다.”고 판시한 바 있다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99두11592 판결).

09 검증제도

1) 의의 및 제도의 배경

검증제도는 개별토지가격에 대하여 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 토지특성조사, 비교표준지선정, 토지가격비준표의 적용 등을 종합적으로 검토하여 지가의 적정성을 판단하는 과정이다.

감정평가법인등은 검증을 함으로써 개별토지가격이 적정하지 못하다고 인정될 경우 적정한 가격을 제시한다.

검증제도는 개별공시지가의 전문성을 제고시키기 위해 도입되었다.

또한 개별공시지가 조사·산정 기준의 미비점을 보완하여 적정한 지가를 결정하는 취지가 있다.

2) 법적 성질

검증 자체는 사실행위로서 법적 효과를 가져오지는 않는다. 따라서 항고쟁송의 대상이 될 수는 없다.

감정평가법인등이 국가의 지도·감독을 수탁하여 행하는 행정지도적 성질을 가지고 있다.

검증절차는 개별공시지가 결정·공시의 필수적 절차로서, 검증을 거치지 않은 개별공시지가 결정행위는 하자 있는 행정처분이 된다.

3) 주체

검증은 감정평가법인등이 행하고, 시장·군수 또는 구청장이 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에게 의뢰하여야 한다.

4) 유형 및 절차

(1) 유형

검증에는 시·군·구의 장이 산정한 개별토지가격에 대하여 지가열람 전에 실시하는 검증(산정지가 검증)과 토지소유자 등의 의견제출에 대한 검증(의견제출 검증), 이의신청에 따른 검증(이의신청 검증)이 있다. 개별공시지가 결정·공시 전에 검증하고 토지소유자 등에게 열람하게 함으로써 이의신청을 최소화시키고, 행정의 효율성을 제고하고자 하며, 토지소유자 등이 제출한 의견을 존중하여 지가 적정성을 기하기 위해 검증을 단계별로 구분한다.

(2) 절차

검증의뢰를 받은 감정평가법인등은 비교표준지의 선정에 관한 사항, 개별토지의 가격산정의 적정성에 관한 사항, 산정한 개별토지의 가격과 표준지공시지가의 균형유지에 관한 사항, 산정한 개별토지의 가격과 인근토지의 지가와와의 균형유지에 관한 사항, 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항을 검토하여 의견을 제시하여야 한다. 산정지가 검증은 도면 등을 통한 약식검증이나, 의견제출 검증 및 이의신청 검증은 현장조사를 요하는 정밀검증이다.

(3) 생략 및 생략의 예외

시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증을 생략하고자 하는 때에는 개별토지의 지가의 변동률과 국토교통부장관이 조사·공표하는 해당 토지가 있는 읍·면·동의 연평균 지가변동률의 차이가 작은 순으로 대상토지를 선정하여 검증을 생략한다.

다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·지구가 변경되는 등의 사유가 발생한 토지에 대하여는 검증을 실시하여야 한다.

01 의의 및 취지, 근거

토지가격비준표란 표준지와 개별토지의 지가형성요인에 관한 표준적인 비교표이다.

이는 표준지를 기준으로 개별토지의 대량평가를 위하여 작성된 객관적인 지가산정표이며,

평가 전문가가 아니라도 누구나 신속하게 지가를 산정할 수 있는 계량화된 평가 잣대이다.

대량 토지에 대한 지가 산정시 결여되기 쉬운 지가산정의 객관성과 합리성을 일정 수준 이상으로 끌어올릴 수 있고, 신속히 지가를 산정할 수 있는 장점을 지닌다.

부동산공시법 제3조 제8항은 “국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “토지가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에 제공하여야 한다.”고 규정하여 그 근거를 마련하고 있다.

02 법적 성질

대법원은 국세청장의 훈령인 재산제세사무처리규정의 법적성질에 대하여 법령보충규칙으로

법규명령의 성질을 갖는다고 판시한 이래 법령보충규칙에 대해 법규명령으로 보는 태도로 일관하고 있다.

대법원은 과거 개별토지가격합동조사지침을 지가공시및토지등의평가에관한법률의 시행을 위한 집행명령으로서 법률보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 할 것이라 판시하였고

(대법원 1994. 2. 8. 선고 93누111 판결, 1995. 11. 10. 선고 95누863 판결),

토지가격비준표는 동법 제10조의 시행을 위한 집행명령인 개별토지가격 합동조사지침과 더불어

법령보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 한다고 판시하고 있다.

심화

표준지공시지가 조사·평가 기준도 토지가격비준표와 같이 법령보충적 행정규칙으로 이해하면 된다.

03 하자와 권리구제

1) 문제점

개별공시지가는 표준지를 기준으로 비교방식에 의해 산정한다. 즉 조사대상 필지의 토지특성을 조사하고, 비교표준지와 개별 토지의 특성 차이에 따른 토지가격비준표상의 가격배율을 산출하여 산출된 총 가격배율을 표준지공시지가에 곱하여 산정된다. 따라서 토지가격비준표는 개별공시지가의 적정성과 직결되며, 토지가격비준표 작성과 활용에 하자가 있을 경우 개별공시지가에 대한 취소소송이나 손해배상청구소송을 제기할 수 있는지가 문제된다.

2) 작성상의 하자

토지가격비준표는 그 작성 자체가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미친다고 보이지는 않으므로, 작성상 하자가 있더라도 쟁송의 제기는 불가능하다 할 것이다.

판례 역시 가격배율이나 토지특성 항목의 변경을 이유로 하는 행정쟁송의 제기를 부정하였다.

또한 비준표상의 토지의 특성 및 평가요소 등이 추가 또는 제외됨으로 인하여 가격상승 또는 가격하락이 있게 되었다는 것만으로는 개별토지가격결정이 부당하다고 하여 이를 다룰 수 없다고 하였다.

3) 활용상의 하자 (개별공시지가 산정 절차상 하자, 개별공시지가가 위법하게 됨)

- ① 판례는 토지가격비준표상의 가격배율은 비교표준지와 당해 토지의 특성을 비교하여 추출하고, 이를 개별토지의 가격을 산정할 때 모두 반영하여야 한다고 하고, 따라서 그 비교된 토지특성 중 임의로 일부 항목에 관한 가격배율만을 적용하여 산정한 지가를 기초로 하여 결정·공고된 개별토지가격결정은 위법하다고 하였다(대법원 1995. 3. 15. 94누12937판결).
- ② 또한 가격조정률은 토지가격비준표상의 것을 적용하여야 하며, 이와는 다른 조정률을 적용하여 개별토지가격을 결정하게 되면 그 처분은 위법한 것이 된다고 하였다
(대법원 1998. 7. 10. 선고 97누1051 판결).
- ③ 비준표를 활용함에 있어 여러 용도로 복합되어 사용되고 있는 토지의 경우에는 복합되어 있는 용도 중 그 점유 면적이 많거나 또는 이용가치면에서 높은 가치인 용도를 주용도로 보아 그에 따른 조정률을 적용한다
- ④ 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제11조, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 시행령 제17조 제2항의 취지와 문언에 비추어 보면, 시장 등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가업자의 검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여 당해 토지에 대하여 표준지공시지가와 균형을 유지한 개별공시지가를 결정할 수 있고, 그와 같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지가와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가 결정이 위법하다고 볼 수는 없다(대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두15364 판결).
- ⑤ 건설교통부장관이 작성하여 관계 행정기관에 제공하는 '지가형성요인에 관한 표준적인 비교표(토지가격비준표)'는 개별토지가격을 산정하기 위한 자료로 제공되는 것으로, 토지수용에 따른 보상액 산정의 기준이 되는 것은 아니고 단지 참작자료에 불과할 뿐이다
(대법원 2007. 7. 12. 선고 2006두11507 판결).

01 의의 및 근거

표준지, 개별공시지가 및 공동주택 공시에 관한 사항을 심의·의결하기 위한 위원회로 부동산가격공시법 제24, 25조 등에 근거를 둔다.

02 종류

국토교통부장관 소속의 중앙부동산가격공시위원회와 시장·군수 또는 구청장 소속의 시·군·구 부동산가격공시위원회가 있다.

03 심의사항

1) 중앙부동산가격공시위원회

표준지, 표준주택, 비주거용 표준부동산에 대한 선정 및 관리지침, 공동주택, 비주거용 집합부동산에 대한 조사 및 산정지침, 위 부동산들의 공시가격 및 이의신청에 관한 사항 등을 심의한다.

2) 시·군·구 부동산가격공시위원회

개별공시지가, 개별주택가격, 비주거용 개별부동산가격에 대한 결정, 이의신청에 관한 사항 및 시장, 군수 등이 심의에 부치는 사항을 심의한다.

04 위원회 구성 및 의결 방법

1) 중앙부동산가격공시위원회

위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.

위원장은 국토교통부 제1차관이 된다.

위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다.

2) 시·군·구 부동산가격공시위원회

위원장을 포함한 10명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하며 성별을 고려하여야 한다.

위원장은 부시장, 부군수, 부구청장이 된다.

01 타인토지출입

1) 의의

관계 공무원 또는 부동산가격공시업무를 의뢰받은 자(이하 “관계공무원등”이라 한다)는 표준지가격의 조사·평가 또는 개별토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다(부동산공시법 제13조 제1항).

2) 출입절차 및 제한 등

- ① 시장·군수 또는 구청장의 허가(부동산가격공시업무를 의뢰받은 자에 한정한다)를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.
다만, 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(부동산공시법 제13조 제2항).
- ② 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다(동조 제3항). 출입을 하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다(동조 제4항).

3) 토지보상법상 타인토지출입과의 비교

(1) 공통점

a. 법적성질

견해대립이 있으나, 그 성질상 일시적 공용사용에 해당하고, 행정조사로 볼 수 있다.
출입허가의 법적성질에 대하여 강학상 허가, 특허, 예외적 승인으로 보는 견해가 대립하나, 타인 토지에 출입할 권리를 설정한다는 점에서 강학상 특허로 봄이 타당하다.

b. 출입 제한 및 증표 등 제시

일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없고, 출입을 하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

(2) 차이점

a. 입법취지

토지보상법상 타인토지 출입은 공익 목적의 공익사업의 준비를 위함이며,
부동산공시법상 타인토지출입은 공시지가의 조사·평가를 위한 목적에 있다.

b. 보상규정

토지보상법상 타인토지출입으로 인한 손실에 대하여는 보상규정을 두고 있으나, 부동산공시법은 보상규정이 없어 논란이 있다. 특별한 희생이 발생했음에도 보상규정이 없다는 이유로 보상을 배제해야 하는가라는 문제가 제기되는 경우 논의가 필요하다.

c. 토지점유자의 인용의무

토지보상법은 인용의무를 규정하고, 위반시 벌칙규정을 두고 있다.

부동산공시법은 인용의무에 대한 규정이 없다.

부동산공시법상 타인토지출입은 토지보상법과 같은 장해물제거행위 등의 행위가 필요 없으므로, 토지점유자로서는 출입자의 행위를 방해할 이유가 없기 때문에 규정을 두지 않은 것으로 해석된다.

4) 부동산공시법상 타인토지 출입시 손실보상 가능여부

(1) 문제점

손실보상을 청구하려면 손실보상요건을 갖추어야 한다.

타인토지출입으로 특별한 희생이 발생한 경우, 손실보상을 해 주어야 하나, 침해의 유형요건과 보상규정 흠결시 보상청구 가능성의 문제가 생긴다.

(2) 침해의 유형 요건

침해의 유형에는 헌법 제23조 제3항에 따라 수용·사용·제한을 의미한다.

재산의 피해 역시 침해의 한 종류가 될 수 있고, 부동산공시법 제13조의 해석상 일시 사용으로 볼 수도, 출입기간이 단시간인 것을 고려할 때, 공용침해의 형태는 아니지만 재산상의 피해로 볼 수 있다.

(3) 보상규정 흠결시 보상청구 가능성

손실보상 파트 참조

02 주택가격공시제도

1) 서론

주택가격공시제도는 정부의 조세형평주의의 일환으로 종합부동산세를 부과하기 위한 기준을 마련하기 위하여 도입된 제도이다. 종전 지가공시법에는 표준지공시지가와 개별공시지가가 담겨 있었다. 이와 주택공시제도가 함께 포함되어 부동산공시법이 새로이 입법되었다. 「구 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」중 부동산 가격공시에 관한 내용이 「부동산 가격공시에 관한 법률」로 분리되면서 비주거용 부동산에 대한 가격공시제도가 입법적으로 마련됨으로써 주택가격 공시제도를 고찰하는 것은 의미있는 일이다.

2) 표준주택가격 공시제도

(1) 의의

표준주택가격이란 국토교통부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다 (부동산공시법 제16조 제1항).

(2) 법적성질

표준주택가격은 국가, 지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다. 그 법적성질은 표준지공시지가와 유사하게 국민의 권리의무에 직접 영향이 있다고 볼 수 있어 처분으로 봄이 타당하다.

(3) 공시절차

국토교통부장관은 일단의 단독주택 중에서 일단의 주택을 대표할 수 있는 표준주택을 선정하여야 하고, 한국부동산원에게 의뢰를 한다. 의뢰를 받은 한국부동산원은 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 표준주택가격을 공시한다. 표준주택가격을 공시할 때는 지번, 가격, 대지면적 및 형상, 용도, 연면적, 구조, 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 공시하여야 한다.

(4) 효력 및 불복

표준주택가격은 국가 등 기관이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우 기준이 된다(부동산공시법 제19조 제1항). 불복은 표준지공시지가 이의신청을 준용하도록 규정하고 있다(부동산공시법 제16조 제7항). 표준주택가격의 처분성을 인정하면 항고소송을 제기할 수 있다.

3) 개별주택가격 공시제도

(1) 의의

개별주택가격이란 시장·군수·구청장이 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결정·공시한 매년 공시기준일 현재의 가격을 말한다(부동산공시법 제17조 제1항).

(2) 법적성질

개별주택가격은 개별공시지가와 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 개별공시지가의 법적성질과 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 국민의 권리, 의무에 직접 영향을 미치는 처분에 해당한다.

(3) 공시절차

시장·군수·구청장은 주택가격비준표를 사용하여 가격을 산정하되, 표준주택가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 부동산원의 검증을 받고, 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택가격을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공한다.

(4) 개별주택가격을 공시하지 아니하는 단독주택

표준주택으로 선정된 단독주택, 국세 또는 지방세의 부과대상이 아닌 단독주택, 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 단독주택은 개별주택가격을 결정, 공시하지 아니할 수 있다.

(5) 효력 및 불복

개별주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등의 기관이 과세 등 업무와 관련하여 주택가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다(부동산공시법 제19조 제2항). 불복은 개별공시지가 이의신청을 준용(부동산공시법 제17조 제8항)하고, 개별주택가격의 처분성을 인정하는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

4) 공동주택가격 공시제도

(1) 의의

공동주택가격이란 국토교통부장관이 조사·산정하여 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한 공동주택에 대한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다(부동산공시법 제18조 제1항).

(2) 법적성질

개별공시지가 및 개별주택가격과 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 법적성질이 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 공동주택가격은 국민의 권리·의무에 직접 영향이 있다고 보여지므로 처분이라 봄이 타당하다.

(3) 공시절차

국토교통부장관은 공동주택에 대해 매년 공시기준일 현재 적정가격을 조사·산정한다.
이를 위해 한국부동산원에게 의뢰한다. 조사·산정시 공동주택소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한다.

(4) 효력 및 불복

공동주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등 기관이 과세 등 업무와 관련하여 주택가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다(부동산공시법 제19조 제2항). 불복은 표준지공시지가의 이의신청을 준용하고(부동산공시법 제18조 제8항), 처분으로 보는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

5) 비주거용 표준부동산 가격공시제도

(1) 의의

비주거용 표준부동산가격이란 국토교통부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 비주거용 일반부동산 중에서 선정한 비주거용 표준부동산에 대하여 조사·산정한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다(부동산공시법 제20조 제1항).

(2) 법적성질

비주거용 표준부동산가격은 국가, 지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다. 그 법적성질은 개별공시지가와 유사하게 국민의 권리·의무에 직접 영향이 있다고 볼 수 있어 처분으로 봄이 타당하다.

(3) 공시절차

국토교통부장관은 일단의 비주거용 부동산 중에서 대표할 수 있는 비주거용 표준부동산을 선정하여야 하고, 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자에게 의뢰한다. 의뢰받은 자는 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 비주거용 표준부동산가격을 공시한다. 비주거용 표준부동산가격을 공시할 때는 지번, 가격, 대지면적 및 형상, 용도, 연면적, 구조, 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 공시하여야 한다.

(4) 효력 및 불복

비주거용 표준부동산가격은 국가 등 기관이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우 기준이 된다(부동산공시법 제23조 제1항). 불복은 표준지공시지가 이의신청을 준용하도록 규정하고 있다(부동산공시법 제20조 제7항). 비주거용 표준부동산가격의 처분성을 인정하면 항고소송을 제기할 수 있다.

6) 비주거용 개별부동산 가격공시제도

(1) 의의

비주거용 개별부동산가격이란 시장·군수·구청장이 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결정·공시한 관할 구역 안의 비주거용 개별부동산에 대한 매년 공시기준일 현재의 가격을 말한다(부동산공시법 제21조 제1항).

(2) 법적성질

비주거용 개별부동산가격은 개별공시지가와 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 개별공시지가의 법적성질과 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 국민의 권리, 의무에 직접 영향을 미치는 처분에 해당한다.

(3) 공시절차

시장·군수·구청장은 비주거용 표준부동산가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정을 의뢰받은 자 등 대통령령으로 정하는 자의 검증을 받고, 비주거용 일반부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시기준일 현재 관할 구역 안의 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시한다.

(4) 효력 및 불복

비주거용 개별부동산가격은 비주거용 부동산시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등의 기관이 과세 등 업무와 관련하여 비주거용 부동산의 가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다(부동산공시법 제23조 제2항). 불복은 개별공시지가 이의신청을 준용(부동산공시법 제21조 제8항)하고, 비주거용 개별부동산가격의 처분성을 인정하는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

7) 비주거용 집합부동산 가격공시제도

(1) 의의

비주거용 집합부동산가격이란 국토교통부장관이 조사·산정하여 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한 비주거용 집합부동산가격에 대한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다(부동산공시법 제22조 제1항).

(2) 법적성질

개별공시지가 및 개별주택가격과 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 법적성질이 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 비주거용 집합부동산가격은 국민의 권리·의무에 직접 영향이 있다고 보여지므로 처분이라 봄이 타당하다.

(3) 공시절차

국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격에 대하여 매년 공시기준일 현재 적정가격을 조사·산정한다. 이를 위해 부동산원 또는 대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자에게 의뢰한다. 비주거용 집합부동산 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한다.

(4) 효력 및 불복

비주거용 집합부동산가격은 비주거용 부동산시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등 기관이 과세 등 업무와 관련하여 비주거용 부동산가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다(부동산공시법 제23조 제2항). 불복은 표준지공시지가의 이의신청을 준용하고(부동산공시법 제22조 제9항), 처분으로 보는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

8) 결론

토지와 주택에 대한 세 부담의 형평성 문제를 해결하고, 부동산가격의 평가체계를 일원화하기 위한 제도로써 주택가격공시제도는 의의가 있다. 이 취지를 살리기 위하여 지속적인 법제도의 정비가 이루어져야 할 것이다. 최근에는 비주거용 가격공시제도가 시행될 예정이어서 제도적 정비에 만전을 기해야 할 것이다.

03 공시제도의 적정성을 위한 노력

1) 공시보고서의 제출(제26조)과 회의록의 공개(제27조의2)

정부는 표준지공시지가, 표준주택가격 및 공동주택가격의 주요사항에 관한 보고서를 매년 정기국회의 개회 전까지 국회에 제출하여야 한다.

국토교통부장관은 표준지공시지가 등을 공시하는 때에는 부동산의 시세 반영률, 조사·평가 및 산정 근거 등의 자료를 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다. 또한, 중앙부동산가격공시위원회 및 시·군·구부동산가격공시위원회 심의의 일시·장소·안건·내용·결과 등이 기록된 회의록은 3개월의 범위에서 일정 기간이 지난 후에는 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다. 다만, 공익을 현저히 해할 우려가 있거나 심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름, 주민등록번호 등 개인 식별 정보에 관한 부분의 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 적정가격반영을 위한 계획 수립(제26조의2)

국토교통부장관은 부동산공시가격이 적정가격을 반영하고 부동산의 유형·지역 등에 따른 균형성을 확보하기 위하여 부동산의 시세 반영률의 목표치를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 계획을 수립하여야 한다. 계획을 수립하는 때에는 부동산 가격의 변동 상황, 지역 간의 형평성, 해당 부동산의 특수성 등 제반사항을 종합적으로 고려하여야 하고, 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 공청회를 실시하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다. 또한, 국토교통부장관, 시장·군수 또는 구청장은 부동산공시가격을 결정·공시하는 경우 위 계획에 부합하도록 하여야 한다.

3) 공시가격정보체계의 구축 및 관리(제27조)

국토교통부장관은 토지, 주택 및 비주거용 부동산의 공시가격과 관련된 정보를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 공시가격정보체계를 구축·운영할 수 있다. 이를 위해 필요한 경우 관계 기관에 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 정당한 사유가 없으면 그 요청을 따라야 한다.

04 공시지가와 시가의 관계

1) 개설

시가란 불특정 다수의 시장에서 자유로이 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립한다고 인정되는 가액이다.
시가와 현저히 차이가 나는 공시지가 결정은 위법한지와 관련하여 공시지가와 시가의 관계가 문제된다.

2) 학설

(1) <시가설>

공시지가는 각종 세금이나 부담금의 산정기준이 되는 토지가격으로 현실시장 가격을 반영한 가격이어야 한다고 한다.

(2) <정책가격설>

부동산공시법 제1조에서 나타나는 바와 같이 공시지가 공시를 통하여 부동산의 적절한 가격형성을 도모하는 기능이 있으므로, 이는 투기억제 또는 지가안정이라는 정책적 목적을 위하여 결정·공시되는 가격이라고 한다.

3) 판례

개별토지가격의 적정성 여부는 규정된 절차와 방법에 의하여 이루어진 것인지 여부에 따라 결정될 성질의 것이지, 당해 토지의 시가와 직접적 관련이 있는 것은 아니므로 단지 개별지가가 시가를 초과한다는 사유만으로는 그 가격 결정이 위법하다고 단정할 것은 아니라고 판시하여 공시지가를 정책적으로 결정한 가격으로 보고 있다.

4) 검토

(1) <정책가격설의 결론>

공시지가가 통상적 시장에서 형성되는 시가를 반영하는 것이 바람직하나,
공시지가 제도를 둔 취지상 공시지가와 시가가 현저한 차이가 난다는 사유만으로 그 위법을 인정할 수는 없다.
단지 공시지가의 산정절차나 비교표준지 선정 등에 위법이 있을 때 이러한 위법을 이유로 다룰 수 있을 것이다.

(2) <시가설의 결론>

공시지가의 산정절차 및 방법은 공시지가가 시가와 부합하여 시가를 담보하고 있는 것으로 보이고,
각종 세금 등의 산정기준으로서 정책적으로 결정되는 것이라면 조세형평의 원칙에 반할 위험이 있다.
또한 정책가격으로 볼 때 공시지가 수준에 대한 사법적 통제가 불가능하여 단지 절차·방식의 위반만을 다룰 수 있어 불복제도가 유명무실해질 것이다.

Chapter 01 감정평가사의 법적지위 및 자격등록

Chapter 02 감정평가법인 등

Chapter 03 감정평가법인등의 손해배상책임 (감정평가법 제28조)

Chapter 04 징계 및 징계위원회

Chapter 05 감정평가

Chapter 06 기타 (과징금, 과태료, 한국감정평가협회)

제1절

감정평가사의 법적 지위

01 개설

감정평가사는 감정평가법이 정한 요건에 의하여 자격을 취득한 자로서 타인의 의뢰에 의해 토지 등을 감정평가함을 그 직무로 한다. 감정평가사가 수행하는 업무는 국민의 재산권과 관련하여 사회성, 공공성, 윤리성이 강조된다. 이러한 견지에서 감정평가법은 감정평가사는 공공성을 지닌 가치평가 전문직으로서 공정하고 객관적으로 그 직무를 수행한다고 정하고(제4조 제2항), 감정평가사에 대한 권리와 의무 및 책임을 규정하고 있으며, 의무 위반에 대한 일정한 제재조치를 규정하고 있다.

02 권리 및 의무

1) 권리

감정평가사는 감정평가사 자격수첩을 교부받은 때로부터 감정평가상 권리능력을 취득한다.
감정평가사는 자격등록(감정평가법 제17조)을 하고 사무소 개설(제21조)을 하거나 감정평가법인설립인가를 받거나 그에 소속한 때로부터 감정평가상 행위능력을 취득하여 감정평가할 권리를 지닌다.
그 외 청문권(제45조), 행정쟁송 제기권 등의 권리를 가진다.

2) 의무

자격등록 및 갱신등록의 의무(감정평가법 제17조), 적정가격 평가의무(부동산공시법 제1조, 감정평가법 10조), 성실의무(감정평가법 제25조), 중복소속 금지의무(감정평가법 제25조 제5항), 감정평가서 서명날인 의무(제6조 제2항), 법정명칭 사용의무(제22조), 명의대여 등의 금지 의무(제27조) 등이 있다.

심화

감정평가법 제25조의 성실의무 [★★★]

1. 의의

감정평가법인등은 보상 평가, 담보 평가 등 국민 재산권과 국가경제에영향을 미치는 공공성이 높은 감정 평가 업무를 수행하고 있는바, 감정평가법은 이를 담보하기 위해 성실의무를 규정하고 있다.

2. 성실의무의 내용

(1) 품위유지의무

감정평가법인등은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니 된다.

(2) 불공정한 감정평가 금지

감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정한 감정평가를 할 우려가 있다고 인정되는 토지 등에 대해서는 이를 감정평가하여서는 아니 된다.

(3) 토지등의 매매업 금지

감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.

(4) 금품 등 제공금지

감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공 하기로 약속하여서는 아니 된다.

(5) 중복소속 금지

감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.

(6) 감정평가 유도 및 요구 금지

감정평가법인등이나 사무직원은 토지등에 대하여 특정가액으로 감정평가를 유도하거나 요구에 따라서는 아니된다.

3. 위반시 손해배상책임 등

위 규정 위반시 감정평가법인 등은 손해배상책임, 징계처분 등을 부담할 수 있다.

3) 책임

(1) 행정상 책임

① 자격의 취소 (감정평가법 제13조)

국토교통부장관은 감정평가사가 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우 및 제39조 제1항 제1호에 해당하는 징계를 받은 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

② 징계 (감정평가법 제39조)

국토교통부장관은 감정평가사가 감정평가법 제39조 제1항에서 정한 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 자격의 취소, 등록의 취소, 2년 이하의 업무정지, 견책의 징계를 할 수 있다.

(2) 형사상 책임

① 행정형벌 (감정평가법 제49조 내지 제51조, 벌칙, 몰수·추징 및 양벌규정)

감정평가법 제49조에서 정한 범죄를 저지른 자에 대해서는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금, 같은 법 제50조에서 정한 범죄를 저지른 자에 대해서는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

업무와 관련된 대가를 받거나 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속한 자(제49조 6호), 감정평가사의 자격증·등록증 또는 감정평가법인의 인가증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 자(제50조 제4호)가 받은 금품이나 그 밖의 이익은 몰수 한다(제50조의2). 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제49조 또는 제50조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

② **벌칙 적용에서 공무원 의제 (감정평가법 제48조)**

감정평가사는 부동산공시법에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무를 수행하거나 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상, 국유지·공유지의 취득 또는 처분, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지가격의 산정 업무와 감정평가법 제46조 제1항에 따른 위탁업무에 종사하는 협회의 임직원일 경우 벌칙적용에 있어 공무원으로 본다.

01 등록제도의 의의 및 취지

감정평가사의 등록이란 감정평가사 자격이 있는 자가 감정평가법 제10조의 업무를 하려는 경우 실무수습 또는 교육연수를 마치고 국토교통부장관에게 등록신청을 하여야 하는바, 이에 대해 국토교통부장관이 등록요건 구비사실을 유효한 것으로 받아들이는 것을 말한다.

등록제도는 감정평가사를 효율적으로 관리하고 자격취득 이후 감정평가사의 결격사유 해당여부를 판단함으로써 감정평가사 자격이 있는 자로 하여금 감정평가업무를 담당하게 하여 감정평가사 자격에 대한 신뢰성을 제고하는데 그 취지가 있다.

02 법적 성질 [★★]

1) 등록신청

등록신청은 사인인 감정평가사가 국토교통부장관에게 감정평가업무를 수행하겠다고 신청하는 사인의 공법행위이다.

2) 등록의 법적성질

(1) 강학상 수리여부

국토교통부장관의 등록에 대하여 강학상 수리로 보는 견해와 강학상 허가로 보는 견해, 등록은 장부에 기재하는 것이므로 강학상 수리와 구별된다는 견해가 있다. 생각건대, 국토교통부장관은 감정평가사 자격등록 신청에 대하여 감정평가법 제18조 제1항에서 정한 사유가 없는 이상 감정평가사 등록부에 등재하고 신청인에게 등록증을 발급하여야 하는바, 강학상 수리로 봄이 타당하다.

(2) 기속행위 여부

감정평가법 제17조에서는 “감정평가사 자격이 있는 사람이 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.”라고 되어 있어 법문언상 명확하지 않으나, 같은 법 시행령 제17조, 제18조에서는 “국토교통부장관은 등록거부 사유를 제외하고는 감정평가사 등록부에 등재하고, 신청인에게 등록증을 발급하여야 한다.”고 규정하고 있는 점, 여기에 입법의 취지, 행위의 성질, 기본권 관련성 등을 종합적으로 고려할 때, 기속행위에 해당한다. 따라서 감정평가법에서 정한 사유 외의 사유를 들어 등록을 거부하는 것은 감정평가법에 위반되는 위법한 거부처분이 된다.

03 등록의 요건 (감정평가법 제17조 제18조)

감정평가법 제12조에 따른 결격사유가 없어야 하고 실무수습을 받지 않은 경우는 등록거부사유에 해당한다. 징계규정에 따라 자격취소 또는 등록취소 된 후 3년이 지나지 않은 경우, 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지기간이 지나지 않은 경우 및 미성년자 또는 피성년후견인, 피한정후견인인 경우 역시 등록거부사유에 해당한다.

04 등록신청의 효과

적법한 등록신청만으로 등록의 효과는 발생하지 않고, 국토교통부장관이 등록신청을 유효하게 받아들이는 행정청의 수리행위가 있어야 한다. 위법한 등록신청의 경우 행정청이 수리를 하면 당해 수리는 하자있는 수리행위가 되고 하자의 정도가 취소사유에 해당하면 권한있는 기관에 의해 취소되기 전까지는 유효한 등록이 되며, 하자의 정도가 무효이면 등록의 효과는 발생하지 않는다.

05 등록거부에 대한 권리구제 [★★]

1) 국토교통부장관의 거부 등

국토교통부장관은 감정평가법에서 정한 사유가 있으며, 등록신청, 갱신등록신청에 대해 거부할 수 있으며, 등록을 취소할 수도 있다. 위 사유를 확인하기 위하여 관계 기관에 관련 자료를 요청할 수 있으며, 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다(제18조 제4항, 제19조 제4항).

2) 등록거부에 대한 권리구제

등록신청에 대한 거부가 행정소송법 제2조 제1항 제1호에서 정한 처분등에 해당하는지 여부는 거부처분의 처분성에 대한 논의와 연결된다. 적법한 등록신청을 하였으나 등록이 거부된 자는

- ① 공권력 행사의 거부일 것, ② 거부로 인해 권리·의무에 제한을 받을 것,
- ③ 법규상 또는 조리상 신청권이 존재할 것의 요건을 갖추면 항고소송의 대상이 될 수 있다.

감정평가법은 신고와 등록을 구분하여 규정하고 있는 점, 감정평가법 제18조 제1항 등에는 등록(갱신등록)거부의 사유를 규정하여 실질적 요건까지 요구하는 것으로 볼 수 있는 점, 취소소송으로 등록거부를 다룰 수 있게 하는 것이 권리구제측면에도 유리한 점 등을 고려할 때, 등록 거부는 처분으로 봄이 타당하다.

06 갱신등록과 관련한 논의

갱신등록은 등록에 기한이 있을 때, 종전 등록의 법적 효과를 유지시키는 행정청의 행위이다.

감정평가법상 갱신등록은 5년마다 행하는데, 주기적으로 검증된 감정평가사로 하여금 감정평가업무를 수행하게 하여 감정평가의 신뢰를 제고할 목적으로 도입되었다. 자격등록의 내용과 동일하다. 다만, 갱신등록을 거부할 때, 취소소송을 제기하면서 집행정지가 가능할 것인지, 사전통지를 해야 하는 것인지 등의 추가 논점이 있다.

제1절 사무소 개설 등

01 의미

감정평가사 자격 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 감정평가사사무소를 개설할 수 있다(감정평가법 제21조 제1항).

02 사무소 개설이 금지된 자

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1항에 따른 개설을 할 수 없다.

- ① 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
- ② 제32조제1항(제1호, 제7호 및 제15호는 제외한다)에 따라 설립인가가 취소되거나 업무가 정지된 감정평가법인의 설립인가가 취소된 후 1년이 지나지 아니하였거나 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우 그 감정평가법인의 사원 또는 이사였던 사람
- ③ 제32조제1항(제1호 및 제7호는 제외한다)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람

03 합동사무소의 개설

감정평가사는 그 업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 합동사무소를 설치할 수 있다.
이 경우 합동사무소는 대통령령으로 정하는 수(2명) 이상의 감정평가사를 두어야 한다(감정평가법 제21조 제3항).

04 사무소의 개수

감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다(감정평가법 제21조 제4항).

05 소속 감정평가사

감정평가사사무소에는 소속 감정평가사를 둘 수 있다.
이 경우 소속 감정평가사는 제18조 제1항 각 호(등록거부사유)의 어느 하나에 해당하는 사람이 아니어야 하며, 감정평가사사무소를 개설한 감정평가사는 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조(감정평가법인등의 업무)에 따른 업무를 하여서는 아니 된다.

01 감정평가법인등의 설립 (감정평가법 제29조)

감정평가법인등이란 감정평가법 제21조에 따라 사무소를 개설한 감정평가사와 동법 제29조에 따라 인가를 받은 감정평가법인을 말한다(제2조 제4호). 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 영위하려는 때에는 감정평가사사무소를 개설할 수 있고, 감정평가법 제10조의 업무를 조직적으로 수행하기 위하여 감정평가법인을 설립할 수 있다. 감정평가법인을 설립하고자 할 때에는 정관을 작성하여 국토교통부장관으로부터 인가를 받아야 한다(제29조 제5항).

02 감정평가법인등의 법적 지위

구분	내용	비고
권리	감정평가권	감정평가에 있어 권리능력 및 행위능력
	감정평가업권	
	타인토지 출입권	부동산공시법 제13조
	명칭사용권	감정평가법 제22조 제1항
	보수청구권	감정평가법 제23조
	청문권	감정평가법 제45조[자격취소, 인가취소, 다만, 제39조 제2항(징계)의 자격취소에 대해서는 청문 규정 없음]
	과징금에 대한 이의신청권	감정평가법 제42조
	행정쟁송 제기권	
의무	적정가격 평가의무	부동산공시법 제1조, 감정평가법 10조
	감정평가서 교부 및 보존의무	감정평가법 제6조
	고용인의 신고	감정평가법 제21조의2
	성실의무 등	감정평가법 제25조
	비밀엄수	감정평가법 제26조
	국토교통부장관의 지도·감독에 따를 의무	감정평가법 제47조
책임	민사상 손해배상책임	감정평가법 제28조
	행정상 인가취소, 업무정지	감정평가법 제32조
	행정상 과징금 관련 책임	감정평가법 제41조
	행정상 과태료 관련 책임	감정평가법 제52조
	형사상 행정형벌 관련 책임	감정평가법 제49조 내지 제50조의 2

01 기본행위(설립행위)에 하자가 있는 경우

인가는 신청에 따라 기본행위의 효력을 완성시켜 주는 보충행위이다.

따라서 기본행위가 성립하지 않거나 무효인 경우에 인가가 있어도 인가는 무효가 된다.

유효한 기본적 행위를 대상으로 인가가 행해진 후에 기본행위가 취소되거나 실효된 경우에는 인가도 실효된다.

기본행위에 취소원인이 있는 경우에는 기본행위가 취소되지 않는 이상, 인가의 효력에는 영향이 없다.

취소원인이 있는 기본행위는 인가가 있은 후에도 취소될 수 있고, 기본 행위가 취소되면 인가도 실효된다.

02 기본행위하자를 이유로 인가를 다룰 협의의 소익이 있는지 [★★]**1) 학설**

기본행위의 하자가 판결확정 전이라면, 기본행위 하자를 이유로 인가처분의 취소를 구할 협의의 소익이 없다는 견해가 다수의 입장이다. 반면, 분쟁해결의 일회성 취지를 강조하는 것을 근거로 협의의 소익을 인정해야 하는 소수의 견해도 있다.

2) 판례

판례는 인가처분에 하자가 없다면 기본행위의 무효를 내세워 행정청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다고 하여 소극적인 입장이다(대법원 1994. 10. 14. 선고 93누22753 판결).

3) 검토

취소소송을 담당하는 법원이 인가처분취소소송에서 민사소송 등의 사항인 기본행위 하자를 심리하기는 어렵다고 보아야 하므로, 부정하는 견해가 타당하다.

03 인가행위에 하자가 있는 경우

기본행위가 적법 유효하고 보충행위인 인가행위 자체에만 하자가 있다면 그 인가처분의 무효나 취소를 주장할 수 있다.

인가처분이 무효이거나 취소된 경우에는 그 기본행위는 무인가행위가 된다.

구분	내용
감정평가사 등록	감정평가사법 제17조 등록과 5년 단위 갱신등록
감정평가사무소 신고	감정평가사법 제21조(신고의무 삭제됨)
감정평가법인 인가	감정평가사법 제29 인가와 변경인가(경미한 사항은 신고)
고용인 신고	감정평가사법 제21조의 2 감정평가법인등은 고용인(감정평가사, 사무직원) 신고해야 함

01 신고의 의미, 종류 및 근거

사인의 공법행위로서 신고는 사인이 행정기관에 일정한 사항을 알려야 하는 의무가 있는 경우 그것을 알리는 행위를 말한다. 수리를 요하는 신고와 수리를 요하지 않은 신고로 구분할 수 있으며, 거부행위의 처분성을 구별 실익으로 볼 수 있다. 행정기본법 제34조 등에 근거를 둔다.

02 고용인 신고의 의미 및 근거

감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 제24조에 따른 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다(법 제21조의2).

03 고용인 신고의 법적성질

1) 관련 규정

행정기본법 제34조는 “법령등으로 정하는 바에 따라 행정청에 일정한 사항을 통지하여야 하는 신고로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우에는 행정청이 수리하여야 효력이 발생한다.”고 규정하고 있다.

2) 학설 및 판례

당해 법령의 목적과 문언에 대한 합리적이고 유기적인 해석을 통해서 판단하는 법령해석기준설과 신고요건의 내용을 구별기준으로 하여 신고요건이 형식적 요건만인 경우에는 자기완결적 신고, 실질적 요건도 포함하는 경우 수리를 요하는 신고로 구별하는 신고요건기준설이 있다.

판례는 신고대상인 행위와 그 시설에 대해 관계법이 이를 허용하여 실질적 적법요건을 두지 않고 형식적 심사요건만을 규정하면 자기완결적 신고로 보고, 근거법에서 그 대상행위를 원칙적으로 금지하여 실질적 적법요건을 두고 있는 때에는 수리를 거부할 수 있다고 보아 수리를 요하는 신고로 본다. 구체적으로 건축신고는 자기완결적 신고로 보나, 인허가의제 효과를 수반하는 건축신고에 대해서는 수리를 요하는 신고로 보았다.

3) 소결

일차적으로 법령의 목적을 기준으로 하되, 명확하지 않는 경우 신고요건의 내용에 실질적 요건이 포함되어 있는지를 판단기준으로 삼는 것이 타당하다. 자기완결적 신고의 대상이 되는 행위라 할지라도 타법상의 요건충족을 전제로 하는 경우나 그 신고가 인·허가의제의 효과를 갖는 경우에는 수리를 요하는 신고라고 봄이 타당하다.

4) 고용인 신고가 수리를 요하는 신고인지 여부

감정평가법 제21조의2에는 수리가 필요하다고 명시되어 있지 않으나, 같은 법 시행규칙 제18조의2 제2항에서 결격사유 여부를 확인해야 한다고 규정하고 있으므로, 수리를 요하는 신고로 봄이 타당하다.

04 고용인 신고 거부의 처분성 [★★]

고용인 신고는 수리를 요하는 신고에 해당하고, 소속감정평가사 변경신고가 거부된 상태에서 소속감정평가사로 하여금 감정평가법의 업무를 하게 되면, 같은 법 제32조 제1항 제9호에 따라 업무정지처분을 받을 수 있고 같은 법 제50조 제2호에 따라 형사처벌에 처해질 수 있다.

이러한 법적 불안을 해소하고 장차 업무정지처분 등을 받을 위험에서 벗어날 수 있도록 변경신고에 대한 수리거부는 처분성을 인정함이 옳다.

01 서론

손해배상이란 법률이 규정하는 일정한 경우 불법한 원인으로 발생한 손해를 피해자 이외의 자가 전보하는 것을 말한다.

감정평가법인등이 타인으로부터 감정평가를 의뢰받았을 때에는 감정평가법에서 정하는 성실의무 등에 따라 감정평가를 수행하여야 한다. 감정평가결과는 감정평가 의뢰인뿐만 아니라 이를 신뢰한 법원, 행정기관 및 다수의 이해관계인에게 미치는 영향이 지대하기 때문이다. 그럼에도 감정평가법인등이 이에 위반하여 평가의뢰인에게 손해를 가져오게 하였다면, 상대방에게 손해배상하는 것이 마땅하다.

감정평가법에서 손해배상책임을 규정하고 있는 것은 감정평가법인등의 성실한 감정평가를 유도하고, 감정평가법인등의 불법행위로 인해 선의의 평가 의뢰인 등이 입은 손해 구제에 그 취지가 있다.

감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가하거나 감정평가서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다(감정평가법 제28조 제1항).

02 감정평가의 법률관계

1) 문제점

의뢰인과 감정평가법인등과의 법률관계가 사법관계인지, 사법관계라면 도급계약 또는 위임계약인지 여부가 문제된다. 적용 법률의 결정 및 민법 제750조와 감정평가법 제28조의 관계를 검토함에 논의의 실익이 있다.

2) 사법관계인지 공법관계인지

의뢰인과 감정평가법인등과의 법률관계는 상호 대등한 관계라고 볼 수 있다.

사법관계로 볼 수도 있고 감정평가업무의 사회성·공공성에 따라 공법관계로도 볼 수 있다.

사인인 의뢰인이 감정평가를 의뢰한 경우는 일반적으로 상호 대등한 관계로서 사법관계의 성질을 가진다고 본다.

3) 도급·위임계약인지

감정평가라는 일의 완성을 목적으로 수수료의 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 도급계약을 보는 견해와 일정한 사무를 처리하기 위한 통일적 노무의 제공을 목적으로 하는 사법상 위임계약으로 보는 견해가 있다.

감정평가를 사법관계로 볼 경우 다수의 견해는 “사법상의 특수한 위임계약”으로 본다.

감정평가는 일정한 사무를 처리하기 위해 지식·경험 등의 통일적인 노무를 제공하므로, 위임계약으로 봄이 타당하다.

4) 소결

감정평가 법률관계를 사법관계로 볼 경우 감정평가법인등은 의뢰인에 대하여 계약의 취지에 따라 선량한 관리자의 주의의무(선관주의의무)를 부담한다. 따라서 감정평가결과가 부당하고 그 결과 의뢰인이 손해를 보는 경우, 의뢰인에 대하여는 채무불이행 중 불완전이행의 법리에 따라 감정평가법인등은 손해배상책임을 부담하고, 선의의 제3자가 손해를 입은 경우에는 민법 제750조에 따른 불법행위책임을 부담한다.

감정평가상 주의의무의 내용

타인의 의뢰에 의하여 일정한 보수를 받고 토지 등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 감정평가를 업으로 행하는 감정평가법인등이 토지를 개별적으로 감정평가하는 경우에는 실지조사에 의하여 대상 물건을 확인하고, 당해 토지와 용도, 지목, 주변환경 등이 동일 또는 유사한 인근지역에 소재하는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 공시 기준일로부터 가격시점까지의 지가변동율, 도매물가상승율 및 지가변동에 영향을 미치는 관계 법령에 의한 토지의 사용·처분 등의 제한 또는 그 해제, 토지의 형질변경이나 지목의 변경 등의 기타 사항을 종합적으로 참작하고 평가 대상 토지와 표준지의 지역요인 및 개별요인에 대한 분석 등 필요한 조정을 하는 방법으로 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 할 주의의무가 있다 (대판 98다56416).

03 감정평가법 제28조와 민법 제750조의 관계 (제28조의 적용범위)

1) 문제점

감정평가계약은 민법상 계약이므로, 감정평가법 제28조 제1항의 규정이 없더라도, 감정평가법인등은 의뢰인 및 선의의 제3자에게 민법상 손해배상책임을 부담한다. 따라서 감정평가법 제28조 제1항의 규정이 민법 제750조의 특칙인지 문제된다.

2) 견해의 대립

(1) 불법행위특칙설

이 규정은 감정평가법인등을 보호하기 위해 일반 채무불이행책임이나 불법행위책임을 저야 할 경우라도 특별한 경우에 한하여 불법행위책임만 지도록 특칙을 정한 것이라는 견해로서, 이에 의하면 규정의 반대해석상, 감정평가법인등에게 고의, 과실이 있어도 감정평가결과가 적정가격과 현저한 차이가 없는 한 손해배상책임을 지지 않는다고 본다.

감정평가법인등의 주관적 견해에 따라 평가액에 어느 정도 차이나는 것은 불가피하므로 현저한 차이가 있을 때만 위법성을 인정함이 상당한 점, 소액의 평가수수료를 받을 뿐인데 막대한 배상책임을 지거나 빈번한 배상책임을 추궁당하면 감정평가제도의 존속자체가 위태로울 수 있다는 점 등을 논거로 한다.

(2) 법정책임설

이 규정은 보험이나 공제와 관련하여 규정한 것으로서, 보험이나 공제로 처리되는 감정평가법인등의 손해배상책임을 한정하는 것일 뿐, 채무불이행책임이나 불법행위책임을 배제하는 규정은 아니라고 보는 견해이다. 이 견해는 이 규정은 감정평가업자에게 배상책임을 부과하면서 이를 담보하는 보험가입을 의무화 하도록 하는데 입법취지가 있고, 고의, 과실이 드러났는데도 다른 요건을 추가로 요구하여 감정평가법인등을 보호하는 것은 문제가 있다는 점을 논거로 한다.

3) 판례

판례는 감정평가법인등의 부실감정으로 인하여 손해를 입게 된 감정평가의뢰인이나 선의의 제3자는 감정평가법상 손해배상책임과 민법상의 불법행위로 인한 손해배상책임을 함께 물을 수 있다고 하여, 법정책임설을 취한 것으로 보여진다(대법원 97다36293).

4) 검토

감정평가법인등에 대한 손해배상책임을 널리 인정하는 것은 자칫 감정평가제도가 위태롭게 만들 우려가 있다. 감정평가법 제28조는 이러한 정책적 배려에서 마련 규정으로 볼 수 있는 점, 특칙이 아니라고 볼 경우 감정평가법 제28조 규정이 무의미한 규정이 된다는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 특칙으로 봄이 타당하다.

04 감정평가법인등의 손해배상책임 요건 [★★★]

1) 타인의 의뢰에 의해 감정평가를 하는 경우일 것

타인의 의뢰에 의한 감정평가로 발생한 손해에 해당하여야 하고, 가치판단 작용이 아닌 순수 사실조사 잘못으로 인한 손해에 대해서는 적용이 없다. 그러나 판례는 임대차관계에 대한 사실조사에 잘못이 있는 경우 사실조사는 감정평가의 내용은 아니라면서도 감정평가법 제28조에 의한 감정평가법인등의 손해배상책임을 인정하였다.

이에 대하여 임대차조사는 감정평가의 내용이 아님에도 불구하고 감정평가를 함에 있어서 발생한 손해배상책임을 규정하고 있는 감정평가법 제28조의 배상책임을 인정한 것은 타당하지 못하다는 견해가 있다. 이 경우에는 민법 제750조의 불법행위책임을 지면 될 것인데, 감정평가법 제28조의 손해배상책임을 인정하면, 손해의 배상과 함께 업무정지처분도 함께 받게 되므로, 감정평가법 제28조의 손해배상책임을 엄격하게 인정해야 한다고 본다.

2) 고의 또는 과실이 있을 것

고의란 자기 행위가 일정한 결과를 낳을 것을 인식하고 그 결과를 용인하는 것을 말한다. 판례는 감정평가법과 감정평가에 관한 규칙을 무시하고 자의적인 방법에 의해 토지를 감정평가한 것은 고의·중과실에 의한 부당한 감정평가로 볼 수 있다고 보았다.

과실이란 일정한 사실을 인식할 수 있음에도 부주의로 인식하지 못한 것을 말한다.

사전자료준비, 평가절차, 윤리규정, 평가방식 적용 등에 대한 부주의를 그 예로 들 수 있다.

3) 부당한 감정평가를 하였을 것

(1) 적정가격과 현저한 차이가 있는 감정평가

현저한 차이는 일반적으로 달라질 수 있다고 인정할 수 있는 범위를 초과하여 발생한 차이를 말한다.

판례는 1.3배가 유일한 판단기준이 될 수 없고, 고의에 의한 부당 감정의 경우와 과실에 의한 부당 감정의 경우를 가리지 아니하고 획일적으로 감정평가액과 적정 가격 사이에 일정한 비율 이상의 격차가 날 때에만 '현저한 차이'가 있다고 보아 감정평가법인등의 손해배상책임을 인정한다면 오히려 정의의 관념에 반할 수도 있으므로, 결국 감정평가액과 적정 가격 사이에 '현저한 차이'가 있는지 여부는 부당 감정에 이르게 된 감정평가법인등의 귀책사유가 무엇인가 하는 점을 고려하여 사회통념에 따라 탄력적으로 판단하여야 한다 (대법원 96다52427).

(2) 감정평가서류에 거짓을 기록한 경우

감정평가서상 기재사항에 대해 물건의 내용, 산출근거, 평가액에 거짓을 기록함으로써 가격에 변화를 일으키는 요인을 고의, 과실로 거짓으로 기재하는 것을 말한다.

4) 의뢰인 또는 선의의 제3자에게 손해가 발생하였을 것

선의의 제3자인 감정내용이 허위 또는 적정가격과 현저한 차이가 있음을 인식하지 못한 것뿐만 아니라, 타인이 사용할 수 없음이 명시되어 있는 경우 그 사용사실까지 인식하지 못한 제3자를 의미한다(대법원 99다28661). 여기에서 손해는 일반적으로 법익(주로 재산권)에 대해 받은 불이익을 말한다.

5) 상당 인과관계가 있을 것

적정가격과 현저한 차이가 있게 한 감정평가와 손해발생 사이에 인과관계가 있어야 한다.

인과관계란 선·후행 사실 사이 전자가 없었더라면 후자도 없었으리라는 관계가 있는 경우에 성립되는 관계를 말한다.

6) 위법성 요건에 대한 논의

위법성 요건이 별도 필요하다는 견해, 위법성 요건은 고의 또는 과실 요건에 포함되는 것으로 보는 견해, 위법성 요건은 부당한 감정평가 요건에 포함되는 것으로 보는 견해가 있다. 생각건대, 감정평가법 제28조는 민법 제750조에 대한 특칙으로 볼 수 있으므로, 부당한 감정평가의 개념 속에 위법성 요건이 포함되는 것으로 봄이 타당하다.

05 손해배상책임의 내용

1) 손해배상의 범위

손해의 범위는 부당한 감정평가가 없었다고 한다면 있어야 할 법익상태와 부당한 감정평가가 이미 발생하고 있는 현재의 법익상태의 차이를 말한다.

심화

대법원 97다36293

불법행위로 인한 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태와의 차이이므로, 낙찰자가 감정평가업자의 불법행위로 인하여 입은 손해도 감정평가업자의 위법한 감정이 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 위법한 감정으로 인한 재산 상태와의 차이가 된다.

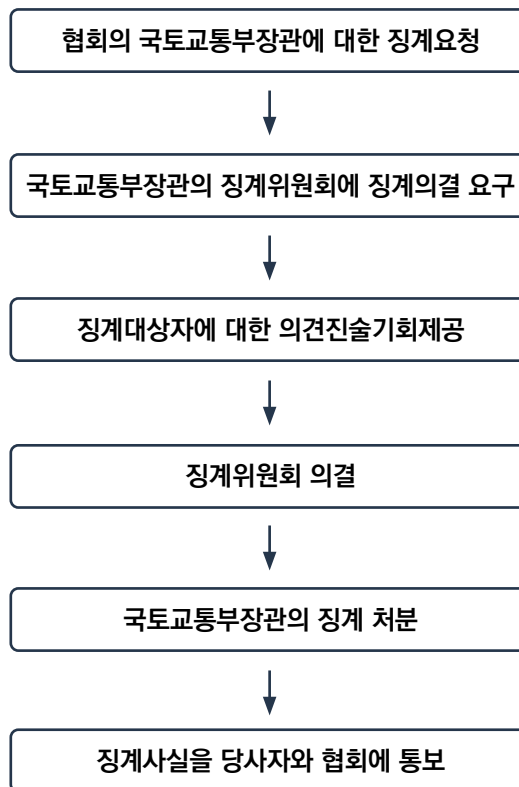
2) 보증보험과 공제사업에의 가입

감정평가법인등은 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험에 가입하거나 감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하거나 그 밖의 필요한 조치를 하여야 한다(감정평가법 제28조 제2항). 감정평가법인등이 보증보험에 가입하는 경우 당해 보험의 보험가입금액은 감정평가사 1인당 1억 원 이상으로 해야 한다(감정평가법 시행령 제23조 제3항).

01 징계사유 및 징계종류

감정평가법 제39조 제1항 각 호의 사유가 발생한 경우 국토교통부장관은 감정평가사에게 감정평가사관리·징계위원회의 의결에 따라 자격의 취소, 등록의 취소, 2년 이하의 업무정지, 견책의 징계를 할 수 있다. 징계권자는 국토교통부장관이 된다.

02 절차



감정평가사협회는 감정평가사에게 징계 사유가 있다고 인정하는 경우, 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다(감정평가법 제39조 제3항). 국토교통부장관은 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정되면, 그 증명서류를 갖추어 감정평가관리·징계위원회에 징계의결을 요구한다(동법 시행령 제34조 제1항). 징계위원회는 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 그 징계요구 내용과 징계심의기일을 해당 감정평가사에게 통지하여야 한다(동법 시행령 제34조 제2항). 징계위원회는 징계의결의 요구를 받은 날부터 60일 이내 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 때에는 위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다(동법 시행령 제35조). 당사자는 징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다(동법 시행령 제41조). 국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 징계사실을 당사자와 감정평가사협회에 각각 서면으로 통보하여야 한다. 이 경우 통보 서면은 징계사유를 명시하여야 한다(감정평가법 제39조의2).

03 감정평가관리·징계위원회

1) 감정평가관리·징계위원회 도입배경 및 취지

감정평가관리·징계위원회는 기존에 감정평가사협회에서 운영하였으나, 감정평가사에 대한 징계의 공정성을 확보하고 감정평가사 적격성 기준이 강화됨에 따라 엄정한 절차에 따라 징계가 이루어지도록 하기 위해 징계위원회를 감정평가법에 직접 규정하기에 이르렀고 징계의 내용도 한층 강화되었다.

2) 감정평가관리·징계위원회의 법적 지위

감정평가관리·징계위원회는 다수의 위원으로 구성되어서 감정평가사의 징계에 관한 사항을 의결하는 합의제 행정기관이다. 징계위원회는 감정평가사를 징계하기 위해 반드시 설치해야 하는 필수기관이다. 징계권자는 국토교통부장관이지만 징계내용에 관한 의결은 위원회에 맡겨져 있다. 따라서 위원회는 의결권을 가진 의결기관에 해당한다.

3) 감정평가관리·징계위원회 의결과 달리 징계처분을 한 경우 그 징계처분의 효력

(1) 위원회 결정의 구속력

감정평가법 제39조 제1항에서는 징계 시 징계위원회의 의결에 따라야 한다고 규정하는바, 위 규정이 동의 규정인지 자문규정인지 문제되나, 문언상 동의 규정으로 봄이 타당하다. 따라서 징계위원회의 결정은 구속력이 인정된다.

(2) 검토

징계위원회는 단순 자문기관이 아니라 의결기관이므로, 국토교통부장관이 위원회의 의결내용과 달리 징계처분을 하였다면 징계처분의 효력은 위법하고 이는 무권한의 하자에 해당하며, 그 하자가 중대하고 명백하여 무효에 해당한다.

04 징계의 공고 (제39조의2)

1) 의의, 취지 및 근거

국토교통부장관은 감정평가사에 대한 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다. 감정평가제도의 신뢰성, 공정성 제고 등에 취지가 있으며 감정평가법 제39조의2에 근거를 둔다.

2) 공고의 방법

국토교통부장관은 징계처분이 확정된 경우 징계처분의 내용 등을 관보에 고시하고 징계처분의 확정일부터 2주일 이내 감정평가 정보체계에 게시하여야 한다. 또한, 협회는 국토교통부장관으로부터 통보받은 내용을 협회가 운영하는 인터넷 홈페이지에 3개월 이상 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.

3) 공고의 내용 및 기간

공고의 내용에는 징계처분을 받은 감정평가사의 이름, 징계처분의 내용, 징계사유 및 징계처분의 효력발생일 등이 포함된다.

협회가 징계정보를 인터넷 홈페이지에 게재하는 기간은, 자격의 취소, 등록의 취소는 3년, 업무정지는 해당 업무정지기간(3개월 미만은 3개월), 견책은 3개월이며, 징계 정보의 범위는 신청일을 기준으로 자격의 취소, 등록의 취소는 과거 10년, 업무정지는 5년, 견책은 1년이다.

심화

징계 공고(감정평가법 제39조의2)의 처분성

1. 징계 공고의 개념

행정상 공표란, 행정청이 스스로 확보한 정보를 직접 또는 인터넷, 신문, 방송 등 매체를 통하거나 불특정 다수인이 알 수 있도록 외부적으로 표시하는 행위를 말한다. 징계 사실을 관보 또는 홈페이지 등에 게시 또는 공고하는 것은 행정상 공표에 해당한다.

2. 처분성 여부

1) 학설 및 판례

행정상 공표는 행정상 '사실행위'에 속한다. 이는 행정행위와는 달리 종국적으로는 특정한 법적 효과를 지향하지 않고 직접적으로 단지 사실상의 결과만을 가져오는 행정청의 행위형식이기 때문이다. 공표가 권력적 사실행위인지, 비권력적 사실행위인지에 관하여는 학설이 대립한다.

대법원은 여호와의 증인 신도를 병역의무 기피자로 판단하여 인적사항을 홈페이지에 게시한 사건에서
 ① 대상자의 명예를 훼손하여 병역의무 이행을 간접 강제하는 조치로 병역법에 근거한 공권력 행사인 점,
 ② 공개라는 사실행위는 특정인을 병역의무 기피자로 판단하여 그에게 불이익을 가하는 행정결정의 집행행위인 점 등을 이유로 위 공개를 항고소송의 대상이 된다고 판단하였다
 (대법원 2019. 6. 27. 선고 2018두49130 판결).

2) 검토

생각건대, 행정소송법의 목적인 국민 권리 구제의 취지상 공표의 내용이 처분의 실질을 가지고 있는 경우에는 항고소송의 대상이 된다고 보는 것이 타당하다(서울행정법원 2011. 10. 21. 선고 2011구합16933 판결도 고액·상습체납자 명단공개의 처분성을 인정함), 징계 공고는 감정평가사의 권리의무에 직접 영향을 미치고 권리구제의 필요성이 있는 점에서 처분의 실질을 가진다고 봄이 타당하다.

05 징계정보 열람 (시행령 제36조의2)

1) 의의 및 근거

감정평가를 의뢰하려는 자는 협회에 징계정보의 열람을 신청할 수 있다. 시행령 제36조의 2에 근거를 둔다.

2) 열람 신청의 방법

이 경우 신청서에 신분을 확인할 수 있는 서류, 감정평가를 의뢰하려는 의사 및 징계정보가 필요한 사유를 적은 확인서를 첨부하여야 한다. 신청 방법은 직접 제출, 우편, 팩스 또는 전자우편 등으로 가능하며, 이에 소요되는 비용은 신청인이 부담한다.

3) 협회의 징계 정보의 제공

협회는 신청을 받으면, 신청일부터 10일 이내 신청인에게 징계정보를 제공하여야 한다.

이 경우 해당 감정평가사에게 그 사실을 알려야 한다.

또한, 협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

06 감정평가사 자격취소와 청문 [★★]

국토교통부장관은 제13조 제1항 등에 근거하여 감정평가사 자격취소처분을 할 수 있다.

그런데 감정평가법 제45조에서는 징계로서 자격취소처분을 받는 경우를 청문 사유로 규정하고 있지 않으므로, 이 경우 청문을 생략할 수 있는지 문제된다.

그러나 행정절차법 제22조 제1항 제3호는, 자격을 박탈하는 처분은 청문을 실시한다고 규정하고 있으며, 이러한 청문제도는 행정처분의 사유에 대하여 당사자에게 변명과 유리한 자료를 제출할 기회를 부여함으로써 위법사유의 시정가능성을 고려하고, 처분의 신중과 적정을 기하려는 데 그 취지가 있는 점을 감안할 때, 행정절차법 등 관련 법령상 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당하지 않는 한, 반드시 청문을 실시하여야 하며, 그러한 절차를 결여한 처분은 위법한 처분으로서 취소사유에 해당한다고 봄이 타당하다.

[감정평가법]

제13조 (자격의 취소)

① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우

제27조 (명의대여 등의 금지)

① 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

제39조 (징계)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

(생략)

11. 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우
12. 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

제45조 (청문)

국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

[행정절차법]

제22조 (의견청취)

- ① 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 한다.

1. 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우
2. 행정청이 필요하다고 인정하는 경우
3. 다음 각 목의 처분을 하는 경우
 - 가. 인허가 등의 취소
 - 나. 신분·자격의 박탈
 - 다. 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소

01 감정평가

1) 의의와 기준

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(이하 '감정평가법')에서는 감정평가를 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액(價額)으로 표시하는 것으로 정의한다. 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 부동산 가격공시법에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 하되, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다. 다만, 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다(제3조 제2항).

2) 감정평가 실무기준 (제3조 제4항 등)

국토교통부장관은 감정평가법인등이 감정평가를 할 때 필요한 세부적인 기준(감정평가 실무기준)의 제정 등에 관한 업무를 수행하기 위하여 전문성을 갖춘 민간법인 또는 단체(기준제정기관)를 지정할 수 있고, 필요하다고 인정되는 경우 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐 기준제정기관에 실무기준의 내용을 변경하도록 요구할 수 있다. 이 경우 기준제정기관은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 국가는 기준제정기관의 설립 및 운영에 필요한 비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

02 감정평가서의 심사와 검토제도 [★★]

1) 개설 (감정평가서)

감정평가법인등은 감정평가를 의뢰받은 때에는 지체 없이 감정평가를 실시한 후 감정평가 의뢰인에게 감정평가서 (전자문서로 된 감정평가서를 포함)를 발급하여야 하고, 감정평가서 원본은 발급일부터 5년, 감정평가서 관련 서류는 발급일부터 2년 이상 보존하여야 한다. 감정평가법은 감정평가서의 신뢰확보 등을 위해, 심사제도, 검토제도 및 타당성조사 제도 등을 두고 있다.

2) 감정평가서 심사

(1) 의의 및 취지

감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 **감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.** 감정평가산업의 경쟁력 강화, 감정평가에 대한 신뢰 확보 및 감정평가 품질 향상 등에 취지가 있다.

(2) 근거

감정평가법 제7조 제1항 등에 근거를 둔다.

(3) 감정평가서 심사의 기준과 의무 (시행령 제7조)

감정평가서의 적정성을 심사하는 감정평가사는 감정평가서가 감정평가법 제3조에 따른 원칙과 기준을 준수하여 작성되었는지 여부를 신의와 성실로써 공정하게 심사하여야 한다. 작성된 감정평가서의 수정·보완이 필요하다고 판단하는 경우 감정평가서를 심사하는 감정평가사는 해당 감정평가서를 작성한 감정평가사에게 수정·보완 의견을 제시하고, 수정·보완을 확인한 후 감정평가서에 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하여야 한다.

03 감정평가서 검토제도 (적정성검토 의뢰)

1) 의의 및 취지

감정평가 의뢰인 등이 해당 감정평가서를 발급하지 아니한 다른 감정평가법인등에게 감정평가서 검토를 의뢰하면 해당 감정평가법인등은 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정하여 발급된 감정평가서의 적정성을 검토결과서로 작성하여 발급하는 일련의 과정을 의미한다. 감정평가산업의 경쟁력 강화, 감정평가에 대한 신뢰 확보 및 감정평가 품질 향상 등에 취지가 있다.

2) 근거

감정평가법 제7조 제3항 등에 근거를 둔다.

3) 법적성격 및 효력

감정평가서 검토는 발급된 감정평가서에 대한 적정성을 검토하여 의견을 제시하는 것으로 감정평가 재평가로 보기 어렵고 감정평가와 관련된 상담 및 자문 등의 성격을 지닌다고 볼 수 있다. 검토결과서는 적정성에 대한 의견 제시일 뿐, 원칙적으로 법적 효력이 발생하지 않고 국가기관 등을 법적으로 구속하지는 못하지만, 행정기관이 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하는 데 활용한다는 간접적인 효과는 있다.

4) 적정성검토 의뢰인 (시행령 제7조의2 제1항)

감정평가 의뢰인, 감정평가 의뢰인이 발급받은 감정평가서를 활용하는 거래나 계약 등의 상대방, 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하거나 그 밖의 업무를 수행하려는 행정기관이 의뢰를 할 수 있다.

5) 적정성검토를 할 수 있는 자 (시행령 제7조의2 제2항)

소속된 감정평가사가 둘 이상인 감정평가법인등은 적정성검토를 할 수 있다.

6) 검토절차 (시행령 제7조의3)

적정성 검토를 의뢰하려는 자는 감정평가서의 사본을 첨부하여 검토를 의뢰하여야 하고, 의뢰를 받은 감정평가법인등은 지체 없이 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정해야 한다. 검토업무를 수행할 감정평가사는 5년 이상 감정평가 업무를 수행한 사람으로서 감정평가실적이 100건 이상이어야 한다.

7) 적정성 검토결과와 통보 (시행령 제7조의4)

검토 의뢰를 받은 감정평가법인등은 의뢰받은 감정평가서의 적정성 검토가 완료된 경우에 의뢰인에게 검토결과서를 발급해야 한다. 검토결과서에는 감정평가법인등의 사무소 또는 법인의 명칭을 적고, 적정성 검토를 한 감정평가사가 그 자격을 표시한 후 서명과 날인을 해야 한다. 이 경우 감정평가사가 소속된 곳이 감정평가법인인 경우에는 그 대표사원 또는 대표이사도 서명이나 날인을 해야 한다.

04 타당성 조사

1) 의의 및 취지

국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 감정평가법 등의 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사할 수 있다.
이를 타당성 조사를 한다. 평가보고서의 합리성 검증 및 제고 등에 취지가 있다. 감정평가법 제8조에 근거가 있다.

2) 실시 및 중지사유 (시행령 제8조 제1, 2항)

- ① 제47조에 따른 지도·감독을 위한 감정평가법인등의 사무소 출입·검사 결과나 그 밖의 사유에 따라 조사가 필요하다고 인정하는 경우
- ② 관계 기관 또는 제3항에 따른 이해관계인이 조사를 요청하는 경우에 실시할 수 있으며,
- ③ 법원의 판결에 따라 확정된 경우, 재판이 계속 중이거나 수사기관에서 수사 중인 경우, 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 경우, 징계처분, 제재처분, 형사처벌 등을 할 수 없어 타당성조사의 실익이 없는 경우 등에는 타당성조사를 하지 않거나 중지할 수 있다.

3) 절차 등 (시행령 제8조 제4항 내지 6항)

국토교통부장관은 타당성조사에 착수한 경우 10일 내 감정평가법인등과 감정평가 의뢰인에게 타당성조사의 사유 등을 알려야 하며, 감정평가법인등과 이해관계인은 통지받고 10일 내 의견을 제출할 수 있으며, 국토교통부장관은 타당성조사를 완료한 경우 지체없이 그 결과를 통지해야 한다.

05 감정평가 제도개선을 위한 표본조사와 정보체계의 구축

1) 의의, 근거 및 취지

국토교통부장관은 감정평가의 방법·절차 등과 실제 감정평가서의 작성 간에 차이가 있는지 여부를 확인하여 감정평가제도를 개선하기 위해 표본조사를 할 수 있다. 감정평가법 제8조 제4항에 근거를 둔다.

2) 표본조사의 방법과 결과 활용

국토교통부장관은 무작위추출방식의 표본조사, 우선추출방식의 표본조사를 할 수 있고, 표본조사 결과 감정평가 제도의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 기준제정기관에 감정평가의 방법과 절차 등에 관한 개선 의견을 요청할 수 있다.

3) 감정평가 정보체계의 구축·운용 (제9조)

국토교통부장관은 국가등이 의뢰하는 감정평가와 관련된 정보 및 자료를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 감정평가 정보체계를 운용할 수 있다. 감정평가법인등은 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하여야 하되, 개인정보 보호 등 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 감정평가법인등은 감정평가 정보체계 등록 대상인 감정평가에 대해서는 감정평가서를 발급할 때 해당 의뢰인에게 그 등록에 대한 사실을 알려야 한다. 그리고 국토교통부장관은 감정평가 정보체계의 운용을 위하여 필요한 경우 관계 기관에 자료제공을 요청할 수 있으며, 이 경우 해당 기관은 정당한 사유가 없는 이상 그 요청을 따라야 한다.

01 과징금

1) 제도의 도입 취지 및 근거

감정평가법인등의 업무영역이 확대되고 공공성이 강화됨에 따라 감정평가법인등이 업무정지처분을 받는 경우에 그 감정평가법인등의 감정평가를 필요로 하는 공공목적의 감정평가의 영역의 원활한 추진에 어려움을 겪게 될 수 있다. 과징금 제도는 이러한 사정을 감안하여 감정평가법 제41조 내지 제44조에 도입되게 되었다.

2) 과징금 제도

(1) 의의

과징금이란 행정법규의 위반이나 행정법상의 의무 위반으로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우엔 당해 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위하여 그 이익액에 따라 행정기관이 과하는 행정상 제재금이다. 과징금은 행정법규 위반으로 발생하는 경제적 이익을 박탈함으로써 행정법규 위반행위를 막는 효과가 있다.

(2) 변형된 과징금

영업정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있는 경우 영업정지에 갈음하여 부과되는 과징금을 변형된 과징금이라 한다. 변형된 과징금의 취지는 영업을 정지함으로써 시민 등이 큰 불편을 겪거나 국민경제에 적지 않은 피해를 주는 등 공익을 해할 우려가 있는 경우 그 영업정지로 인해 초래될 공익에 대한 침해 등 문제를 고려하여, 영업정지처분을 대신하여 영업으로 인한 이익을 박탈하는 과징금을 부과할 수 있도록 한 것이다.

(3) 법적성질

과징금 부과행위는 강학상 하명으로 침익적 행정행위이므로, 행정소송법 제2조에서 정하는 처분에 해당한다.

3) 과징금의 성질 및 이중부과 가능성 [★]

과징금은 행정상 제재금이고, 범죄에 대한 국가의 형벌권 실행으로서의 과벌이 아니므로, 행정법규 위반에 대하여 벌금이나 범칙금 이외 과징금을 부과하는 것은 이중처벌금지의 원칙에 반하지 않는다. 헌법재판소도 같은 입장이다(헌법재판소 1994. 6. 30. 92헌바38결정).

헌법재판소 199(4) (6) 30. 선고 92헌바38 전원재판부 [합헌]

헌법 제13조 제1항이 정한 “이중처벌금지의 원칙”은 동일한 범죄행위에 대하여 국가가 형벌권을 거듭 행사할 수 없도록 함으로써 국민의 기본권 특히 신체의 자유를 보장하기 위한 것이므로, 그 “처벌”은 원칙으로 범죄에 대한 국가의 형벌권 실행으로서의 과벌을 의미하는 것이고, 국가가 행하는 일체의 제재나 불이익처분을 모두 그에 포함된다고 할 수는 없다.

무허가건축행위로 구(舊) 건축법 제54조 제1항에 의하여 형벌(刑罰)을 받은 자가 그 위법건축물에 대한 시정명령에 위반한 경우 그에 대하여 과태료를 부과할 수 있도록 한 동법 제56조의2 제1항의 규정이 이중처벌금지원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

4) 감정평가법상 과징금의 부과 및 징수

(1) 과징금의 부과 (감정평가법 제41조 제1항 및 제2항)

국토교통부장관은 감정평가법인등이 업무정지사유에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 표준지공시지가의 조사·평가 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분에 갈음하여 5,000만 원(감정평가법인의 경우는 5억 원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 국토교통부장관은 과징금을 부과하는 경우 위반행위의 내용과 정도, 위반행위의 기간과 위반횟수, 위반행위로 취득한 이익의 규모를 고려하여야 한다.

(2) 과징금의 승계 (감정평가법 제41조 제3항)

국토교통부장관은 이 법을 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병에 의해 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.

(3) 과징금의 징수 및 체납처분 (감정평가법 제44조)

국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 납부한 날의 전일까지의 기간에 대하여 대통령령이 정하는 가산금을 징수할 수 있다. 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

(4) 권리구제 [★]

① 이의신청 (감정평가법 제42조)

과징금 부과에 이의가 있는 자는 통보받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다. 국토교통부장관은 이의신청에 대하여 30일 이내 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. 위 이의신청은 강학상 이의신청에 해당한다(행정심판이 아니다).

② 행정심판 (감정평가법 제42조 제3항)

이의신청에 따른 결정에 이의가 있는 자는 행정심판을 청구할 수 있다.

③ 행정소송 및 부당이득반환청구소송

과징금은 급부하명으로서 행정소송법상 처분에 해당하므로, 행정소송을 제기할 수 있다. 또한, 법률상 원인 없이 부과된 경우 민사상 부당이득반환청구소송을 제기할 수도 있다.

02 과태료

1) 과태료 의의

행정법에서 일정한 의무를 이행하지 않거나 가벼운 벌칙을 위반한 사람에게 부담해서 국가에 납부하게 하는 돈으로, 판례는 행정상의 질서유지를 위한 행정질서벌에 해당할 뿐 형벌이라고 할 수 없어 죄형법정주의의 규율대상이 아니라고 본다. 따라서 과태료부과는 행정소송의 대상이 되는 처분으로 보기 어렵다.

2) 근거

감정평가사법 제52조

3) 불복절차

과태료에 대한 불복절차는 “이의제기 - 법원의 재판 - 항고(법원 결정에 대한 불복을 항고, 단 약식재판으로 할 경우 이의신청 가능) - 재항고”로 진행된다.

4) 과태료, 과징금, 벌금 비교

	과태료	과징금	벌금
개념	경미한 위반행위에 대한 금전적 제재	불법이익 환수 또는 영업정지 대체의 금전적 제재	범죄인에 대한 금전지불의무 부과 형벌
부과주체	행정청/법원(이의제기시)	행정청	법원
불복절차	질서위반행위규제법/ 비송사건절차법(이의제기시)	행정소송	형사소송

03 한국감정평가사협회

1) 목적 및 설립(33조)

협회의 목적은 감정평가사의 품위 유지와 직무의 개선·발전을 도모하고, 회원의 관리 및 지도에 관한 사무를 하도록 하기 위함이며, 법인의 형태를 가진다.

2) 회칙(34조)과 윤리규정(36조)

협회는 회칙을 정하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 하는데, 명칭과 사무소 소재지, 회원가입 및 탈퇴에 관한 사항, 임원 구성에 관한 사항 등이 회칙에 포함되어야 한다. 협회는 회원이 직무를 수행할 때 지켜야 할 직업윤리에 관한 규정을 제정하여야 하고, 감정평가법인등의 손해배상책임을 보장하기 위해 공제사업을 운영한다. 회원은 위 윤리규정을 준수할 의무가 있다.

3) 회원가입 의무(35조)

감정평가법인등과 그 소속 감정평가사는 협회에 회원으로 가입하여야 하며, 그 밖의 감정평가사는 협회의 회원으로 가입할 수 있다. 회원은 회칙을 준수하여야 한다.

4) 자문(37조)과 회원에 대한 교육·연수(38조)

국가 등은 제감정평가사의 직무에 관한 사항에 대하여 협회에 업무의 자문을 요청하거나 협회의 임원·회원 또는 직원을 전문분야에 위촉하기 위하여 추천을 요청할 수 있으며, 협회는 해당 회원으로 하여금 업무를 수행하게 할 수 있고, 국가등에 대하여 필요한 경우 감정평가의 관리·감독·의뢰 등과 관련한 업무의 개선을 건의할 수 있다. 또한, 협회는 회원에 대해서 교육·연수를 실시하고 회원의 자체적인 교육·연수활동을 지도·관리한다.

5) 국토교통부장관의 업무의 위탁(46조)

협회 한국부동산원, 한국산업인력공단과 함께 국토교통부장관의 업무를 위탁받아 수행할 수 있는데, 감정평가사 등록 및 등록 갱신, 소속 감정평가사 또는 사무직원의 신고 업무는 협회만이 위탁받을 수 있다.